BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
65 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
NGUYỄN MINH THU
VÕ THỊ MỸ HƯƠNG
NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

GIÁO TRÌNH

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG



NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Chủ biên:

PGS.TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI, TS. NGUYỄN MINH THU,
ThS. VÕ THỊ MỸ HƯƠNG, ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

Giáo trình

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2023

LỜI MỞ ĐẦU

Giáo trình Pháp luật đại cương đã được nhiều trường đại học xây dựng và triển khai cho phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo cũng như sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường trong tiến trình phát triển. Theo xu hướng chung này, Giáo trình Pháp luật đại cương do tập thể tác giả Bộ môn Luật trực thuộc Khoa Chính trị và Luật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn đáp ứng yêu cầu:

- Phản ánh được sự đa dạng của pháp luật trong xu hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

- Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các học thuyết nhà nước, pháp luật và một số lĩnh vực pháp luật gắn liền với đời sống của mỗi cá nhân, doanh nghiệp nhằm giúp người học có cái nhìn tổng thể, mang tính hệ thống về nhà nước và pháp luật cũng như từng lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.

- Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể tự tìm hiểu và nâng cao kiến thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn công việc.

- Hiện thực hóa mục tiêu học tập suốt đời và biết cách vận dụng các quy định pháp luật như một công cụ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong những điều kiện, hoàn cảnh tình huống cụ thể.

- Kiến tạo và bảo vệ công lý một cách chủ động bằng các hành vi pháp lý tích cực, biết lên án và tránh các vi phạm pháp luật cũng như các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong đời sống thường ngày.

Về nội dung, các bài học được các tác giả trình bày một cách cơ bản và có hệ thống từ lý luận đến nội dung pháp luật.

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hiện tượng nhà nước và pháp luật theo đó cũng có những giao thoa, biến đổi cho phù hợp với xu hướng của thời đại. Theo lẽ thông thường đó, dù đã cố gắng hết sức, song những thiếu sót trong quá trình biên soạn là điều không thể tránh khỏi, các tác giả mong nhận được sự thông cảm, phản hồi từ phía người học và các bạn đọc để sửa chữa, khắc phục kịp thời. Những ý kiến đóng góp, phản hồi kịp thời từ phía người học sẽ là đóng góp vô giá trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học phục vụ đào tạo cũng như đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hiện nay.

Tập thể tác giả

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 11
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước 11
1.1.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước 11
1.1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước 11
1.1.1.2. Các đặc trưng của nhà nước 14
1.1.2. Chức năng và hình thức của nhà nước 17
1.1.2.1. Chức năng của nhà nước 17
1.1.2.2. Hình thức nhà nước 17
1.1.3. Bộ máy nhà nước 20
1.2. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20
1.2.1. Sự ra đời và bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20
1.2.1.1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20
1.2.1.2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 22
1.2.2. Các chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 25
1.2.2.1. Chức năng đối nội 25
1.2.2.2. Chức năng đối ngoại 28
1.2.3. Hình thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29
1.2.3.1. Về hình thức chính thể nhà nước 29
1.2.3.2. Về hình thức cấu trúc nhà nước 30
1.2.3.3. Chế độ chính trị 30
1.2.4. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 31
1.2.5. Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 33
1.2.5.1. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 33
1.2.5.2. Quan điểm và định hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 34
1.2.5.3. Những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể 35

CHƯƠNG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 40
2.1. Khái niệm, bản chất, thuộc tính, hình thức của pháp luật 40
2.1.1. Khái niệm pháp luật 40
2.1.2. Bản chất của pháp luật 44
2.1.3. Các thuộc tính của pháp luật 47
2.1.4. Hình thức pháp luật 49
2.2. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật 56
2.2.1. Quy phạm pháp luật 56
2.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật 60
2.3. Quan hệ pháp luật và thực hiện pháp luật 61
2.3.1. Quan hệ pháp luật 61
2.3.1.1. Khái niệm quan hệ pháp luật 61
2.3.1.2. Chủ thể quan hệ pháp luật 63
2.3.1.3. Nội dung quan hệ pháp luật 67
2.3.1.4. Khách thể quan hệ pháp luật 68
2.3.1.5. Sự kiện pháp lý 68
2.3.2. Thực hiện pháp luật 69
2.4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 70
2.4.1. Vi phạm pháp luật 70
2.4.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật 70
2.4.1.2. Cấu thành của vi phạm pháp luật 73
2.4.1.3. Phân loại vi phạm pháp luật 74
2.4.2. Trách nhiệm pháp lý 76
2.4.2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý 76
2.4.2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý 77

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT HÌNH SỰ 81
3.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh 81
3.1.1. Khái niệm 81
3.1.2. Đối tượng điều chỉnh 81
3.1.3. Phương pháp điều chỉnh 82
3.2. Tội phạm 82
3.2.1. Khái niệm tội phạm 82
3.2.2. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm 83
3.2.3. Phân loại tội phạm 88
3.2.4. Cấu thành tội phạm 89
3.2.5. Các giai đoạn thực hiện tội phạm 102

3.2.6. Đồng phạm 108
3.2.6.1. Khái niệm và những dấu hiệu pháp lý của đồng phạm 108
3.2.6.2. Các loại người đồng phạm 111
3.2.6.3. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm 116
3.2.7. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự 116
3.2.7.1. Phòng vệ chính đáng 116
3.2.7.2. Tình thế cấp thiết 120
3.2.7.3. Sự kiện bất ngờ 121
3.2.7.4. Gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội 122
3.2.7.5. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ 123
3.2.7.6. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên 124
3.2.7.7. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự 125
3.3. Hình phạt 126
3.3.1. Khái niệm hình phạt 126
3.3.2. Đặc điểm 126
3.3.3. Hệ thống hình phạt 128

CHƯƠNG 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT DÂN SỰ 143
4.1 Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể của Luật Dân sự 143
4.1.1. Khái niệm 143
4.1.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự 143
4.1.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự 145
4.1.4. Chủ thể của Luật Dân sự 146
4.1.4.1. Cá nhân 146
4.1.4.2. Pháp nhân 148
4.1.4.3. Các chủ thể khác 150
4.2. Quyền nhân thân 151
4.2.1. Khái niệm, đặc điểm quyền nhân thân 151
4.2.2. Các quyền nhân thân trong Luật Dân sự 151
4.3. Tài sản và quyền sở hữu 159
4.3.1. Tài sản 159
4.3.2. Quyền sở hữu tài sản 161
4.3.2.1. Nội dung quyền sở hữu 161
4.3.2.2. Xác lập quyền sở hữu 162
4.3.2.3. Chấm dứt quyền sở hữu 167
4.3.3. Chiếm hữu tài sản 167

4.4. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 169
4.4.1. Nghĩa vụ dân sự 169
4.4.1.1. Khái niệm 169
4.4.1.2. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự 169
4.4.1.3. Thực hiện nghĩa vụ dân sự 171
4.4.1.4. Các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự 172
4.4.2. Hợp đồng dân sự 175
4.4.2.1. Khái niệm và phân loại 175
4.4.2.2. Hình thức và nội dung hợp đồng 176
4.4.2.3 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu 177
4.5. Thừa kế 178
4.5.1. Khái quát về thừa kế 178
4.5.2. Thừa kế theo di chúc 180
4.5.3. Thừa kế theo pháp luật 183
4.5.4. Thanh toán và phân chia di sản 184

CHƯƠNG 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT LAO ĐỘNG 188
5.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của Luật Lao động 188
5.1.1. Khái niệm Luật Lao động 188
5.1.2. Đối tượng điều chỉnh 191
5.1.3. Phương pháp điều chỉnh 193
5.2. Hợp đồng lao động 194
5.2.1. Khái niệm, phân loại hợp đồng lao động 194
5.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng lao động 194
5.1.1.2. Các loại hợp đồng lao động 197
5.2.2. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động 199
5.2.3. Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động 200
5.2.4. Thử việc 203
5.2.5. Thực hiện hợp đồng lao động 205
5.2.6. Chấm dứt hợp đồng lao động 207
5.3. Tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 215
5.3.1. Tiền lương 215
5.3.2. Thời gian làm việc 221
5.3.3. Thời giờ nghỉ ngơi 223
5.4. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 226

5.4.1. Kỷ luật lao động 226
5.4.2. Trách nhiệm vật chất 229

CHƯƠNG 6 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 231
6.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình 231
6.1.1. Khái niệm 231
6.1.2. Đối tượng điều chỉnh 231
6.1.3. Phương pháp điều chỉnh 232
6.1.4. Các nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình 232
6.2. Kết hôn 235
6.2.1. Khái niệm kết hôn 235
6.2.2. Điều kiện kết hôn 236
6.2.3. Đăng ký kết hôn 240
6.2.4. Kết hôn trái pháp luật 241
6.2.4.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật 241
6.2.4.2. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật 241
6.2.4.3. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật 241
6.2.4.4. Hậu quả của việc hủy kết hôn trái pháp luật 243
6.3. Quan hệ giữa vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 243
6.3.1. Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng 243
6.3.2. Đại diện giữa vợ và chồng 244
6.3.3. Quan hệ tài sản của vợ và chồng 245
6.3.3.1. Chế độ tài sản theo thỏa thuận 245
6.3.3.2. Chế độ tài sản theo luật định 246
6.4. Quan hệ giữa cha mẹ và con 250
6.4.1. Căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con đẻ 250
6.4.2. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi 252
6.4.3. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, con 252
6.4.3.1. Quan hệ nhân thân 252
6.4.3.2. Quan hệ tài sản 253
6.5. Ly hôn 254
6.5.1. Khái niệm 254
6.5.2. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 255

6.5.3. Các trường hợp ly hôn 255
6.5.3.1. Thuận tình ly hôn 255
6.5.3.2. Ly hôn theo yêu cầu của một bên 256
6.5.4. Hậu quả pháp lý của việc ly hôn 258

CHƯƠNG 7 PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 263
7.1. Khái quát về tham nhũng 263
7.1.1. Định nghĩa, đặc điểm của tham nhũng 263
7.1.2. Phân loại hành vi tham nhũng 265
7.1.3 Các hành vi tham nhũng và tội phạm tham nhũng 266
7.1.4. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng 272
7.1.4.1. Nguyên nhân tham nhũng 272
7.1.4.2. Tác hại của tham nhũng 275
7.2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng 277
7.2.1. Cơ sở pháp lý của việc phòng, chống tham nhũng 277
7.2.1.1. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng 277
7.2.1.2. Luật phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam 278
7.2.2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng 281
7.2.2.1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng 281
7.2.2.2. Các giải pháp phát hiện tham nhũng 289
7.2.2.3. Xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng 292
7.3. Trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng 293

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước

1.1.1. Nguồn gốc, bản chất và các đặc trưng của nhà nước

1.1.1.1. Nguồn gốc của nhà nước

Khi nghiên cứu về nhà nước trong khoa học pháp lý, một trong những vấn đề lý luận quan trọng là vấn đề nguồn gốc nhà nước. Trong lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý, có nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc nhà nước. Mỗi quan điểm được các nhà tư tưởng đưa ra dựa trên những cơ sở nhất định và mặc dù đều giải thích nguồn gốc ra đời nhà nước, đều tập trung trả lời các câu hỏi như nhà nước do ai thành lập nên?, dựa trên những điều kiện nào?, quyền lực nhà nước tồn tại như thế nào?, mối quan hệ giữa nhà nước với người dân trong xã hội là như thế nào?... song, mỗi quan điểm lại đưa ra những câu trả lời khác nhau và hướng đến những mục đích khác nhau.

Có thể khái quát một số quan điểm sau đây để minh chứng cho nhận định về sự đa dạng của quan điểm nguồn gốc nhà nước[1].

Các nhà tư tưởng theo *Thuyết thần học* cho rằng nhà nước là lực lượng siêu nhiên, nhà nước do Thượng đế (hay Đấng sáng tạo) tạo ra để cai trị thần dân. Xuất phát từ nguồn gốc đó, nhà nước mang quyền lực, quyền lực nhà nước tồn tại vĩnh cửu và mọi người đều phải phục tùng. Khác với các nhà tư tưởng theo Thuyết thần học, các nhà tư tưởng theo *Thuyết gia trưởng* lại quan niệm rằng nhà nước là kết quả phát triển của gia đình, tức là có nguồn gốc tự nhiên. Với nguồn gốc tự nhiên đó, quyền lực nhà nước tồn tại và có sức mạnh tương tự như quyền lực của người đứng đầu gia đình. Trong xã hội, mọi người phục tùng quyền lực nhà nước giống như việc phục tùng quyền của người chủ gia đình. Bên cạnh quan niệm về nguồn gốc nhà nước theo các tư tưởng như trên, còn có nhiều nhà tư tưởng khác, với những quan điểm khác, có thể kể đến như: Quan điểm của các nhà tư tưởng theo *Thuyết bạo lực* cho rằng, khi một thị tộc chiến

[1] Xem thêm: Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật: *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2005.

thắng thị tộc khác, đã tạo ra một hệ thống cơ quan đặc biệt để thực hiện sự thống trị của thị tộc mình đối với thị tộc thất bại, đó chính là nhà nước; Quan điểm của các nhà tư tưởng theo *Thuyết "Khế ước xã hội"* cho rằng nhà nước được hình thành dựa trên sự thỏa thuận, thể hiện bằng một khế ước (hợp đồng). Hợp đồng/khế ước được ký kết giữa những con người sống trong trạng thái tự nhiên không có nhà nước và mục đích thành lập nhà nước của những người ký khế ước là nhằm bảo vệ lợi ích cho các thành viên trong xã hội. Khế ước do vậy được gọi là khế ước xã hội (hợp đồng xã hội). Nếu mục đích ký kết khế ước xã hội không đạt, tức là nhà nước ra đời từ khế ước không đáp ứng được mong muốn của những người ký khế ước, thì nhà nước có thể bị các thành viên đã ký khế ước lật đổ, để thỏa thuận và ký kết khế ước xã hội mới, thành lập nhà nước mới. Một số nhà tư tưởng tiêu biểu của thuyết "Khế ước xã hội" có thể kể đến như: J. Locke (1632 - 1704), J.J. Rousseau (1712 - 1778)…[2]. Trong tác phẩm "Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social)", J.J. Rousseau viết: "Có thể Công ước không hề được công bố một cách hợp thức, nhưng đâu đâu nó cũng được mặc nhiên chấp nhận cho đến mức, ví phỏng Công ước xã hội (Pacte social) có bị vi phạm đi chăng nữa, thì mỗi thành viên sẽ sử dụng quyền nguyên thủy của mình; bởi vì một khi công ước không bảo đảm quyền tự do dân sự thì người ta từ bỏ công ước để giữ lại quyền tự do thiên nhiên vốn có"[3].

Khác với các quan điểm trên, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin với những luận điểm khoa học khi lý giải về nguồn gốc của nhà nước cho rằng: Nhà nước là sản phẩm của xã hội loài người khi xã hội đó đã phát triển đến một giai đoạn nhất định[4]. Chủ nghĩa Mác-Lênin không cho rằng nhà nước là hiện tượng tự nhiên, vĩnh cửu, mà cho rằng nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử. Sự ra đời của nhà nước là do những nguyên nhân nhất định, và sự tồn tại, phát triển của nhà nước cũng dựa trên những cơ sở kinh tế, xã hội nhất định. Nguyên nhân ra đời, tồn tại của nhà nước gắn liền với các đặc điểm của xã hội loài người trong từng giai đoạn phát triển.

---

[2] Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật: *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2005.

[3] Jean Jacques Rousseau, *Bàn về khế ước xã hội (Du Contrat Social),* (Hoàng Thanh Đạm dịch, chú thích và bình giải), Nxb Lý luận Chính trị, H.2004, tr.67.

[4] C. Mác và Ph. Ăngghen, *Tuyển tập,* Tập VI (Phri-đrích Ăng-ghen, *Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước),* Nxb Sự thật, H.1984, tr.260.

Để hiểu rõ nguồn gốc của nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, cần phải nghiên cứu về thời kỳ chưa có nhà nước, cùng với những biến đổi xã hội thời kỳ đó để dẫn đến sự ra đời nhà nước. Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định, thời kỳ xã hội *cộng sản nguyên thủy* không có nhà nước, nhưng trong thời kỳ đó, dần xuất hiện các nguyên nhân dẫn đến sự ra đời nhà nước.

Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, đời sống xã hội loài người được tổ chức, quản lý thông qua các thiết chế: Hội đồng thị tộc, Hội đồng bào tộc, Hội đồng bộ lạc[5]. Tức là trong xã hội có tổ chức và thực thi quyền lực công cộng, gọi là quyền lực xã hội, song, quyền lực xã hội lúc này hòa nhập với dân cư, do toàn xã hội tổ chức, để phục vụ cả cộng đồng. Không có một cá nhân hay một thiết chế nào trong xã hội đó có đặc quyền, đặc lợi.

Trong tiến trình phát triển của xã hội, con người trong xã hội cộng sản nguyên thủy ngày càng hoàn thiện hơn. Do sự phát triển đó, xã hội cộng sản nguyên thủy từ chỗ phân công lao động mang tính tự nhiên (theo giới tính, nam giới làm công việc săn bắn, nữ giới làm công việc hái lượm) đã xuất hiện ba lần phân công lao động xã hội là *chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp; thương mại ra đời.* Theo tiến trình đó, xã hội cộng sản nguyên thủy trải qua những biến đổi sâu sắc. Về phương diện kinh tế, của cải vật chất trong xã hội ngày càng nhiều lên và gia tăng tích lũy, chế độ tư hữu dần xuất hiện. Về phương diện xã hội, với các mức độ sở hữu của cải vật chất trong xã hội khác nhau của từng tập đoàn người, xã hội hình thành các giai cấp, giữa các giai cấp ngày càng gia tăng mâu thuẫn với nhau về mặt lợi ích. Những biến đổi về kinh tế và xã hội như vậy đã làm cho tổ chức thị tộc, bộ lạc không còn phù hợp để bảo đảm cho xã hội được trật tự và ổn định, phát triển. Nhu cầu về một tổ chức mới để quản lý xã hội xuất hiện và ngày càng gay gắt. Trong số các giai cấp cùng tồn tại trong xã hội thì giai cấp thống trị về kinh tế có khả năng thành lập tổ chức đó, và đó chính là nhà nước. Như vậy, nhà nước là tổ chức thay thế cho thị tộc, bộ lạc. Nhà nước được giai cấp thống trị lập ra để duy trì sự thống trị của giai cấp mình.

---

[5] C. Mác và Ph. Ăngghen, *Tuyển tập,* Tập VI (Phri-đrích Ăng-ghen, *Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước),* Nxb Sự thật, H.1984, tr.56-203.

Ph. Ăngghen, đã nêu khái quát ba hình thức ra đời nhà nước[6]:

- *Nhà nước Aten*: nhà nước ra đời do những nguyên nhân rất thuần túy, xuất phát từ sự phân chia giai cấp trong nội bộ xã hội thị tộc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không điều hòa được, trong bối cảnh xã hội như vậy, giai cấp thống trị đã thành lập nên nhà nước.

- *Nhà nước Rôma:* nhà nước ra đời sau thắng lợi của giới bình dân chống lại giới quý tộc thị tộc Rôma. Xã hội Rôma khi đã có nhà nước thì giới bình dân và giới quý tộc được cho là hòa tan vào nhau.

- *Nhà nước Giécmanh*: nhà nước được thiết lập do người Giécmanh chiến thắng đế chế Rôma và cần quản lý lãnh thổ xâm chiếm được. Lúc này, tại đó, nhà nước ra đời không phải từ kết quả đấu tranh giai cấp trong nội bộ xã hội của người Giécmanh.

Ở nhiều quốc gia phương Đông, nhà nước được cho là xuất hiện sớm, khi chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp đã xuất hiện trong xã hội nhưng chưa ở mức *mâu thuẫn giai cấp gay gắt không thể điều hòa được*. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời nhà nước sớm hơn điều kiện chín muồi tại các quốc gia ở phương Đông được cho là cơ bản do nhu cầu bảo vệ lợi ích công cộng và chống ngoại xâm[7].

1.1.1.2. Bản chất của nhà nước

Cũng như quan niệm về nguồn gốc nhà nước, có nhiều quan niệm về bản chất của nhà nước, các quan niệm này có mối liên hệ chặt chẽ với quan niệm về nguồn gốc nhà nước. Cụ thể hơn, sự khác nhau về quan niệm nguồn gốc nhà nước đã dẫn đến những quan niệm khác nhau về bản chất nhà nước. Trong tài liệu này, chỉ trình bày bản chất của nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Để xác định bản chất của nhà nước, trước hết cần xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về khái niệm "bản chất". Theo đó, "bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật đó"[8].

---

[6] C. Mác và Ph. Ăngghen, *Tuyển tập,* Tập VI (Phri-đrích Ăng-ghen, *Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước),* Nxb Sự thật, H.1984, tr.259-260.

[7] Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật: *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2005, tr.76-77.

[8] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: *Giáo trình Triết học Mác-Lênin,* Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.275.

Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, về bản chất, nhà nước gồm các mặt: tính giai cấp và tính xã hội[9]. Về *tính giai cấp*, thể hiện ở các phương diện: nhà nước do giai cấp thống trị thành lập nên, là công cụ của giai cấp thống trị để duy trì địa vị thống trị, bảo vệ lợi ích của giai cấp mình. Về *tính xã hội,* khi đã được ra đời, nhà nước đồng thời phải bảo vệ lợi ích cho các giai cấp, tầng lớp khác ở mức độ nhất định, và duy trì trật tự xã hội, thực hiện những nhiệm vụ phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân mà xã hội có nhu cầu song không có tổ chức, cá nhân nào có khả năng thực hiện hoặc không muốn thực hiện... Một nhà nước không thể không có tính giai cấp. Tương tự như vậy, một nhà nước không thể không có tính xã hội.

1.1.1.3. Các đặc trưng của nhà nước

Trước khi có nhà nước và kể từ khi nhà nước ra đời thì trong xã hội loài người đã và vẫn tồn tại các tổ chức khác. Vì vậy, để phân biệt nhà nước với những tổ chức không phải là nhà nước, có thể dựa trên các đặc trưng của nhà nước. Nói cách khác, nghiên cứu đặc trưng của nhà nước là nghiên cứu những điểm riêng có của nhà nước, nhằm phân biệt nhà nước với những tổ chức khác của xã hội loài người. Theo đó, nhà nước có các đặc trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, nhà nước thiết lập, duy trì quyền lực công cộng đặc biệt.

Giai cấp thống trị thành lập nhà nước chính là thành lập tổ chức để quản lý xã hội, duy trì trật tự xã hội, duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, tức là thiết lập quyền lực. Quyền lực đó được gọi là quyền lực công cộng, nhưng quyền lực công cộng của nhà nước có tính chất đặc biệt – dường như không hòa nhập với dân cư nữa, khác với quyền lực công cộng của xã hội cộng sản nguyên thủy là quyền lực công cộng hòa nhập với dân cư. Có nghĩa là, có thể có tổ chức khác trong xã hội loài người cũng thiết lập, duy trì quyền lực công cộng, song, quyền lực công cộng mà nhà nước thiết lập và duy trì là quyền lực công cộng đặc biệt. Quyền lực nhà nước được thiết lập, duy trì, đảm bảo thực hiện thông qua các cơ quan cấu thành nên nhà nước, còn gọi là bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước có những con người, công cụ, biện pháp, quy định, quy trình để bảo vệ quyền lực nhà nước.

[9] C. Mác và Ph. Ăngghen: *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1995, t.21, tr.255; t.22, tr.290-291.

Thứ hai, nhà nước phân chia và quản lý dân cư theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ.

Trong xã hội trước khi có nhà nước đã tồn tại tổ chức thị tộc, bộ lạc. Từ khi nhà nước xuất hiện, trong xã hội còn có những tổ chức khác. Mỗi tổ chức trong xã hội đều có những tiêu chí để tập hợp thành viên, quản lý thành viên. Có thể có tổ chức phân chia và quản lý thành viên theo tiêu chí huyết thống (như là thị tộc), hoặc theo tiêu chí độ tuổi (ví dụ như Đoàn Thanh niên), nghề nghiệp (ví dụ như Hội Nông dân), giới tính (ví dụ như Hội Phụ nữ), khuynh hướng chính trị v.v... Nhà nước không dựa vào các tiêu chí đó để phân chia và quản lý dân cư mà dựa vào các đơn vị hành chính – lãnh thổ.

Thứ ba, nhà nước có chủ quyền quốc gia.

Chủ quyền là "quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt"[10]. Chỉ có nhà nước mới có chủ quyền quốc gia, điều này không phụ thuộc vào quy mô lãnh thổ mà nhà nước xác lập được chủ quyền. Có thể trong xã hội loài người, cùng với nhà nước còn có nhiều tổ chức cũng có phạm vi tác động rộng lớn và số lượng thành viên đông đảo – xuyên quốc gia, liên quốc gia - song, nếu một tổ chức không phải là nhà nước thì tổ chức đó không có chủ quyền quốc gia.

Thứ tư, nhà nước ban hành pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện.

Mỗi cộng đồng, mỗi tổ chức của xã hội loài người, để duy trì trật tự, quản lý thành viên đều cần có những , nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực hiện bằng nhiều biện pháp như giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

Thứ năm, nhà nước quy định về việc thu các loại thuế và đảm bảo thực hiện các quy định đó.

Đây cũng là một trong những đặc trưng quan trọng, riêng có của nhà nước. Đặc trưng này xuất phát từ vị trí, chức năng, vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội và yêu cầu phải bảo đảm vị trí, chức năng, vai trò đó bằng nguồn lực tài chính. Theo đó, nhà nước quy định về các loại thuế mà nhà nước sẽ thu trong từng thời kỳ phát triển của xã hội, nhà nước tiến hành thu các loại thuế đã quy định nhằm bảo đảm duy trì tổ chức, hoạt động của mình, thực hiện các mục tiêu đề ra trong quản lý xã hội. Nhà

[10] Nguyễn Như Ý (chủ biên), *Đại từ điển tiếng Việt,* Nxb Văn hóa – Thông tin, H.1998, tr.394.

nước cũng hình thành các thiết chế và các biện pháp để bảo đảm cho việc thu các loại thuế.

1.1.2. Chức năng và hình thức của nhà nước

1.1.2.1. Chức năng của nhà nước

Chức năng của nhà nước thường được quan niệm là những phương diện (mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước[11]. Có nhiều cách tiếp cận để xác định chức năng, từ đó, xác định cụ thể từng chức năng của nhà nước:

- Tiếp cận theo các lĩnh vực của đời sống mà nhà nước quản lý, nhà nước có các chức năng: chức năng kinh tế, chức năng xã hội, chức năng văn hóa,…

- Tiếp cận theo phạm vi hoạt động của nhà nước, nhà nước có các chức năng đối nội và đối ngoại. Thông thường, nếu chỉ nghiên cứu nhà nước ở góc độ chung nhất, chức năng của nhà nước sẽ tiếp cận theo phạm vi hoạt động. Trường hợp nghiên cứu sâu hơn từng mặt, từng phương diện trong các phạm vi hoạt động đối nội và đối ngoại, thì thường đề cập đến các lĩnh vực nhà nước tác động đến (kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ Tổ quốc, thiết lập quan hệ ngoại giao…).

- Tiếp cận chức năng theo ba quyền cấu thành nên quyền lực nhà nước, nhà nước có ba chức năng là chức năng lập pháp, chức năng hành pháp, chức năng tư pháp.

Chức năng của nhà nước được triển khai, tổ chức thực hiện thông qua chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Do đó, mỗi cơ quan nhà nước được thành lập ra đều có chức năng cụ thể để nhằm thực hiện chức năng của nhà nước nói chung.

1.1.2.2. Hình thức nhà nước

Cũng là một trong những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước, hình thức nhà nước trong khoa học pháp lý được hiểu là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Từ quan niệm này, ở Việt Nam có hai cách xác định hình thức nhà nước. Có quan niệm

[11] Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật: *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2005, tr.106.

cho rằng hình thức nhà nước gồm hình thức chính thể và hình thức cấu trúc[12], có quan niệm lại xác định hình thức nhà nước gồm ba dạng hình thức cụ thể: hình thức chính thể nhà nước (hay còn gọi là hình thức cầm quyền), hình thức cấu trúc và chế độ chính trị[13]. Trong tài liệu này, hình thức nhà nước được xác định theo cách thứ hai, tức là hình thức nhà nước thể hiện qua ba dạng sau[14]:

* Hình thức chính thể: Hình thức chính thể được biểu hiện thông qua cách thức hình thành cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mức độ tập trung quyền lực, cách tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước tại các cơ quan nhà nước ở trung ương và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước đó với nhau. Theo đó, có hai dạng hình thức chính thể phổ biến là chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà.

Chính thể quân chủ là hình thức chính thể mà quyền lực nhà nước cao nhất thuộc về một cá nhân thông qua trao truyền (thế tập truyền ngôi), mức độ tập trung quyền lực có thể là tập trung toàn bộ hoặc tập trung một phần. Mức độ tập trung quyền lực vào cá nhân (vua, quốc vương, nữ hoàng…) là toàn bộ hay một phần sẽ phản ánh hình thức chính thể quân chủ đó là *chính thể quân chủ tuyệt đối* hay *chính thể quân chủ hạn chế*.

Chính thể cộng hoà là hình thức chính thể mà quyền lực nhà nước cao nhất thuộc về một cơ quan nhà nước, cơ quan đó được bầu ra trong một thời hạn nhất định. Việc bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước được thực hiện bởi nhân dân theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu hay chỉ được thực hiện bởi tầng lớp quý tộc sẽ xác định hình thức chính thể cộng hòa đó là *cộng hoà dân chủ* hay *cộng hòa quý tộc*. Trong xã hội hiện nay, hình thức chính thể cộng hòa dân chủ còn được nhận diện là có nhiều dạng tồn tại, với các tên gọi cụ thể như: cộng hòa dân chủ tư sản (với các mô hình cụ thể hơn nữa là cộng hòa tổng thống, cộng hòa đại nghị, cộng hòa lưỡng tính); cộng hòa xã hội chủ nghĩa, cộng hòa dân chủ nhân dân.

---

[12] Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật: *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2005, tr.101.

[13] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: *Giáo trình Triết học Mác-Lênin dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị,* PGS. TS. Đặng Quang Định (chủ biên), Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.242

[14] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: *Giáo trình Triết học Mác-Lênin dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị,* PGS. TS. Đặng Quang Định (chủ biên), Nxb Lý luận Chính trị, H.2021, tr.242-245.

* Hình thức cấu trúc: hình thức cấu trúc nhà nước là cách phân chia nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ, đồng thời xác định mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở các đơn vị hành chính lãnh thổ đó với nhau, giữa trung ương với địa phương.

Theo đó, có hai hình thức cấu trúc nhà nước thường được đề cập đến bởi mức độ phổ biến cao, đó là nhà nước có cấu trúc đơn nhất và nhà nước có cấu trúc liên bang, còn gọi là nhà nước đơn nhất và nhà nước liên bang.

Nhà nước đơn nhất là nhà nước mà trên lãnh thổ quốc gia tồn tại một nhà nước duy nhất, từ đó, lãnh thổ quốc gia được cấu trúc thành các đơn vị hành chính lãnh thổ trực thuộc để nhà nước quản lý mà những đơn vị này không có các đặc trưng của nhà nước. Trong nhà nước đơn nhất tồn tại một hệ thống cơ quan quyền lực, cơ quan quản lý thống nhất và một hệ thống pháp luật thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Nhà nước liên bang là nhà nước mà trong cấu trúc của nó gồm có nhiều nhà nước thành viên, còn gọi là các bang (state). Tổ chức bộ máy nhà nước liên bang gồm chính quyền liên bang và chính quyền của các bang thành viên. Theo đó, trong nhà nước liên bang tồn tại hai hệ thống cơ quan quyền lực, quản lý và có hai hệ thống pháp luật, đó là hệ thống của liên bang và hệ thống của các bang thành viên.

Ngoài ra, còn có quan niệm cho rằng, trong thực tế tồn tại những hình thức cấu trúc nhà nước ít phổ biến hơn. Ví dụ như Liên minh nhà nước Hoa Kỳ trước đây (vào thời kỳ 13 bang thuộc địa mới tuyên bố độc lập với nước Anh năm 1776 và ký kết *Điều lệ Liên bang và Liên minh vĩnh cửu* vào năm 1777)[15], Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Liên minh Châu Âu (EU)…

* Chế độ chính trị: là dạng hình thức nhà nước thể hiện việc nhà nước sử dụng các phương pháp, cách thức nào nhằm thực hiện quyền lực nhà nước và mức độ tham gia của người dân khi thực hiện quyền lực nhà nước. Trong lịch sử có hai hình thức chế độ chính trị của nhà nước là chế độ dân chủ và chế độ phản dân chủ.

Chế độ dân chủ: nhân dân có quyền và được tham gia vào việc hình thành cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, có quyền và được tham gia vào hoạt động của nhà nước. Tất nhiên, mức độ có thể rộng, hẹp khác nhau.

---

[15] Xem thêm: PGS. TS. Nguyễn Đăng Dung: *Hình thức của các nhà nước đương đại,* Nxb Thế giới, H.2004, tr.52.

Chế độ phản dân chủ: nhân dân bị cản trở hoặc không có quyền tham gia quá trình làm hình thành nên các cơ quan nhà nước, tham gia hoạt động của nhà nước.

1.1.3. Bộ máy nhà nước

Trong khoa học pháp lý, nói đến bộ máy nhà nước tức là đề cập đến hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương. Khi nghiên cứu khái quát về bộ máy của một nhà nước, thường xem xét hai khía cạnh: Thứ nhất, những cơ quan nhà nước cấu thành bộ máy nhà nước; Thứ hai, những nguyên tắc tổ chức, hoạt động chung và riêng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Về các cơ quan nhà nước: đây là các bộ phận cấu thành nên bộ máy nhà nước. Các cơ quan nhà nước được thành lập từ trung ương đến địa phương với những chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể, cùng hợp thành hệ thống thống nhất, nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử từng quốc gia, các cơ quan nhà nước có thể được tổ chức khác nhau, có tên gọi khác nhau.

Về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước: các cơ quan trong bộ máy nhà nước sở dĩ được khẳng định là có tính hệ thống, thống nhất là bởi chúng được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, dù cho chúng thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, mỗi cơ quan tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình có thể được quy định những nguyên tắc tổ chức và hoạt động đặc thù. Cũng giống như các cơ quan nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của những cơ quan nhà nước trong bộ máy có thể được thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của xã hội.

1.2. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1. Sự ra đời và bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.1.1. Sự ra đời của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng của Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật là cơ sở lý luận rất quan trọng, là nền tảng tư tưởng để thiết kế nên bộ máy nhà nước ta từ khi Cách mạng tháng Tám thành công.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Lãnh tụ Hồ Chí Minh soạn thảo được Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 thông qua, đã xác

định "dựng ra chính phủ công nông binh"[16]. Với cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi và tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh chống thực dân, phong kiến đòi quyền sống, quyền độc lập dân tộc, mà đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Khi đó ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã ra đời các Xô viết cấp xã[17]. Tiếp đó, trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 diễn ra ở 20/21 tỉnh, thành phố, có nơi đã thành lập chính quyền cách mạng ở cấp huyện (Vũng Liêm). Ở Mỹ Tho, nhân dân lập tòa án cách mạng xét xử bọn phản động, xóa bỏ các thứ thuế vô lý, xóa các khoản nợ, tịch thu thóc gạo của địch chia cho dân nghèo. Mùa Xuân năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 do Người chủ trì đã quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thành lập Mặt trận Việt Minh, xúc tiến chuẩn bị tổng khởi nghĩa khi có thời cơ, chủ trương **"**lập chính phủ dân chủ cộng hoà". Chương trình Việt Minh nêu rõ: "Sau khi đánh đuổi được bọn đế quốc Pháp, Nhật sẽ thành lập một chính phủ nhân dân của Việt Nam dân chủ cộng hoà... Chính phủ ấy do Quốc dân Đại hội cử lên". Như vậy, từ mô hình nhà nước công nông chuyển sang mô hình nhà nước dân chủ cộng hoà, đại biểu cho khối đại đoàn kết của toàn thể quốc dân là một bước chuyển sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, phản ánh được thực tiễn của dân tộc, phù hợp với sự chuyển hướng chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam.

Giữa năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Phát xít Đức đã bị đánh bại, phát xít Nhật đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước tình hình đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã chỉ thị thành lập khu giải phóng, cử ra *Ủy ban lâm thời*, thực hiện chức năng chính quyền cách mạng. Ở các địa phương trong khu giải phóng, các uỷ ban nhân dân cũng được nhân dân cử ra để thực hiện 10 chính sách của Việt Minh. Các uỷ ban này vừa lãnh đạo nhân dân chuẩn bị tổng khởi nghĩa, vừa tập cho nhân dân nắm chính quyền. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định

---

[16] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị,* PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên (chủ biên), NXB Lý luận Chính trị, H.2021, tr.19, 20.

[17] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị,* PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên (chủ biên), NXB Lý luận Chính trị, H.2021, tr.23.

điều kiện tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Cũng tại Tân Trào, ngày 16 tháng 8 năm 1945 đã khai mạc *Đại hội đại biểu quốc dân*, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa. Quốc dân Đại hội đã quyết định thành lập *Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam,* do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ủy ban có chức năng chủ trì mọi công việc đối nội và đối ngoại. Các *Ủy ban giải phóng* ra đời trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các huyện, các làng... là hình thức chính quyền của nhân dân các địa phương khi chưa giành được chính quyền trong cả nước. Đại hội cũng quyết định quốc kỳ và quốc ca của nước Việt Nam mới. Từ ngày 14 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa lần lượt nổ ra trong cả nước. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, địa phương cuối cùng đã giành được chính quyền. Vua Bảo Đại thoái vị, chính quyền phong kiến thực dân bị xoá bỏ. Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời. Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngày 2 tháng 9 năm 19545, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam)[18].

Sau đó, nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hiệp định Giơnevơ được ký kết. Nước ta tạm thời chia cắt làm hai miền, chờ ngày hiệp thương thống nhất. Miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất đất nước. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài đến năm 1975. Đất nước thống nhất, Quốc hội khóa VI được cử tri cả nước bầu ra trong cuộc Tổng tuyển cử năm 1976 đã quyết định đổi tên nước thành Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

1.2.1.2. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước có thể khẳng định, bản chất của một nhà nước được quy định bởi các cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội ở giai đoạn nhà nước đó tồn tại. Trong tiến trình phát triển của xã hội loài người kể từ khi có nhà nước, có nhiều kiểu nhà nước với bản chất khác nhau do chúng tồn tại trên những cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội khác nhau. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

[18] Xem thêm: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị,* PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên (chủ biên), NXB Lý luận Chính trị, H.2021, tr.32-37.

thuộc kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là nhà nước kiểu mới. Kiểu mới ở đây có nghĩa là xét về bản chất, nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước mới.

Yếu tố quy định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định bản chất kiểu mới của nước ta là các yếu tố sau:

Thứ nhất, về cơ sở kinh tế, Điều 51 và Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 quy định: "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" (Điều 51). Trong nhiều hình thức sở hữu đó, "đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" (Điều 53). Như vậy, toàn dân là chủ sở hữu của các loại tài nguyên, nguồn lợi, tài sản hết sức quan trọng, mang tính chất cơ bản, được Hiến pháp quy định.

Thứ hai, về cơ sở xã hội, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức". Như vậy, Nhà nước ta chính là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Trên cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội đó, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét về bản chất là một nhà nước vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội.

Trước hết, về tính giai cấp, Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân. Đồng thời, Nhà nước cũng mang tính xã hội sâu sắc. Bản chất giai cấp công nhân và tính xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện cụ thể như:

1, Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân - lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp 2013 là "Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Trong điều kiện một Đảng cầm quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu

trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được khẳng định là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước[19].

2, Nhà nước phục vụ và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước được tổ chức, hoạt động và hoàn thiện trên cơ sở nền tảng tư tưởng lý luận là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn xã hội Việt Nam[20]. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua tất cả các cơ quan nhà nước gồm: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước theo như sự khẳng định của Hiến pháp năm 2013 tại Điều 6. Để giữ vững bản chất, Nhà nước xây dựng hệ thống chính sách và thiết lập các biện pháp bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện[21].

Bên cạnh đó, bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam còn mang tính dân tộc và tính thời đại. Tính dân tộc thể hiện qua việc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thể hiện qua các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Đồng thời, tính dân tộc thể hiện rõ nét qua việc xác định mục tiêu phục vụ nhân dân của tất cả các dân tộc trong cả nước, mục tiêu quản lý phát triển xã hội. Nhà nước luôn chú ý kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc; có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Điều 5 Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ yếu tố này: "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. (…) Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ

[19] Điều 9 Hiến pháp 2013.

[20] Xem thêm: PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (Chủ biên): *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2005, tr.149-150.

[21] Điều 3, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước".

Tính thời đại của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện sâu sắc ở quan điểm và hành động chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế, thể hiện ở việc khẳng định và thực hiện đường lối đối ngoại. Điều 12 của Hiến pháp 2013 nêu rõ: "Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi". Với chủ trương xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Việt Nam tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đồng thời, Việt Nam khẳng định vai trò là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

1.2.2. Các chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Có nhiều tiêu chí để phân loại chức năng của nhà nước. Thông thường, khi tiếp cận nghiên cứu chức năng của nhà nước ở phương diện lý luận chung, thường căn cứ vào phạm vi hoạt động của nhà nước. Theo đó, chức năng của nhà nước gồm chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. Từ góc độ tiếp cận này, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

1.2.2.1. Chức năng đối nội

Với ý nghĩa là những phương diện hoạt động chủ yếu, cơ bản trong phạm vi nội bộ lãnh thổ, phản ánh bản chất của Nhà nước, chức năng đối nội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét theo các lĩnh vực nhà nước quản lý như sau:

i) Chức năng kinh tế

Những phương diện, những mặt hoạt động thể hiện chức năng kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều hướng đến các mục tiêu của Nhà nước trong quản lý kinh tế và luôn thể hiện bản chất của nhà nước là tính giai cấp và tính xã hội. Cụ thể, theo Điều 50 Hiến pháp

2013, Nhà nước thực hiện chức năng kinh tế nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện chức năng này, Nhà nước tiến hành nhiều biện pháp, luôn chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, thực hiện việc điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường; đồng thời, chú trọng và thực hiện ngày càng khoa học, hiệu quả việc phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Nhà nước cũng là chủ thể đóng vai trò thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, quyết định, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân, nỗ lực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng đắn, đầy đủ những quy định của Hiến pháp, pháp luật[22].

Với việc chú trọng thực hiện tốt chức năng kinh tế, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội ngày càng đạt nhiều thành tựu to lớn. Về phát triển kinh tế, có thể khái quát, *nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện*[23].

ii) Chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Để có được độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cả dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều đau thương, mất mát, hy sinh. Nay mặc dù Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, song, chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là hết sức quan trọng, có thể nói là mang tính sống còn của Nhà nước, của chế độ. Về chức năng này, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng yêu cầu: "Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa (…) bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân"[24].

---

[22] Xem thêm các quy định tại Điều 50, Điều 52 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

[23] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, t.1, H.2021, tr.59.

[24] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, t.2, H.2021, tr.334.

iii) Chức năng bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân

Bằng việc hiến định Nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước, hiến định quyền con người, quyền công dân và khẳng định trách nhiệm của Nhà nước để bảo đảm những quy định đó, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một chức năng rất quan trọng là bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Thực hiện chức năng này, Nhà nước không ngừng hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, củng cố các nguồn lực, chủ động, tích cực trong việc thực hiện các điều ước quốc tế và tham gia vào các thiết chế quốc tế bảo vệ quyền con người. Từ những nỗ lực đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa qua hơn 35 năm đổi mới được tăng cường trên cả phương diện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Hiến pháp 2013 mở rộng hơn cơ chế thực hiện dân chủ đại diện của nhân dân, đó là thông qua tất cả các cơ quan nhà nước. Quyền con người, quyền công dân được thực hiện tốt hơn trên thực tế[25].

iv) Chức năng quản lý các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội

Văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ là những lĩnh vực cơ bản, rất quan trọng của đời sống xã hội mà nhà nước quản lý, đã được khẳng định rõ trong Hiến pháp 2013. Theo quy định tại Điều 60, Điều 61, Điều 62 Hiến pháp 2013, Nhà nước chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân. Để có thể giữ gìn, xây dựng được nền văn hóa và con người văn hóa, vấn đề giáo dục cũng được hết sức đề cao. Thực hiện chức năng nhà nước về văn hóa, Nhà nước thực hiện việc đầu tư và thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tạo cơ hội thuận lợi, công bằng, bình đẳng cho mọi người dân thực hiện quyền học tập của mình. Nhà nước cũng ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học.

---

[25] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIII ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới*. (I- Tình hình).

Vấn đề an sinh xã hội cũng được Nhà nước hết sức chăm lo. Với hệ thống chính sách an sinh xã hội không ngừng cải cách, ngày càng hoàn thiện, toàn diện và có tính thực tiễn, tính khả thi cao, đời sống của nhân dân theo đó được được nâng lên rõ rệt. Trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, Nhà nước tiếp tục thực hiện chức năng bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người… Xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững, hài hoà"[26].

1.2.2.2. Chức năng đối ngoại

Chức năng đối ngoại thể hiện các mặt, phạm vi hoạt động của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong mối quan hệ với các quốc gia, dân tộc, vùng lãnh thổ khác. Theo đó, chức năng đối ngoại được thể hiện qua các mặt hoạt động:

i) Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Giành được chính quyền đã khó, giữ được chính quyền, bảo vệ Tổ quốc lại càng khó gấp bội. Nhận thức rõ điều này, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiến định nguyên tắc: "Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân"[27]. Trong điều kiện hiện nay, để thực hiện được chức năng này, Nhà nước cần phải phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, đồng thời, cũng phải chú trọng kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc[28].

ii) *Chức năng mở rộng quan hệ đối ngoại*

Thiết lập, duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại theo nguyên tắc đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế là phương châm của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được khẳng định trong Hiến pháp 2013. Đây cũng là mặt hoạt động nhằm khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần giúp cho Việt Nam thành công hơn trong thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại khác.

---

[26] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, t.1, H.2021, tr.147, 148.

[27] Điều 64 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

[28] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, t.1, H.2021, tr.155, 156.

iii) Chức năng ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội

Ngay trong lời mở đầu, Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã khẳng định, bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân Việt Nam đã giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như vậy, trên đà thắng lợi đó, và để củng cố thêm sức mạnh của dân tộc, đồng thời góp phần xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, Việt Nam thực hiện chức năng đối ngoại với một trong những mặt hoạt động quan trọng là ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội.

1.2.3. Hình thức của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hình thức nhà nước thể hiện trên ba yếu tố: hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ chính trị.

1.2.3.1. Hình thức chính thể

Theo Hiến pháp năm 2013, hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cộng hòa xã hội chủ nghĩa (theo mô hình dân chủ nhân dân), cụ thể:

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức (Khoản 2 Điều 2 Hiến pháp 2013).

+ Quyền lực nhà nước của Nhân dân được Nhân dân thực hiện bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước (Điều 6 Hiến pháp năm 2013); Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri bãi nhiệm hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân (Điều 7, Hiến pháp năm 2013). Quốc hội có vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69, Hiến pháp năm 2013). Hội đồng nhân dân có vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân,

do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; có thẩm quyền quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Điều 113, Hiến pháp năm 2013).

1.2.3.2. Hình thức cấu trúc nhà nước

Xét về hình thức cấu trúc, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước có cấu trúc đơn nhất.

Hình thức cấu trúc đơn nhất thể hiện trên ba phương diện sau đây:

+ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau: Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương (thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương). Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

+ Cơ quan nhà nước được thành lập ở các đơn vị hành chính theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, tạo thành một hệ thống thống nhất từ trung ương đến địa phương. Các đơn vị hành chính không phải là những nhà nước độc lập, có chủ quyền riêng.

+ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có một hệ thống pháp luật thống nhất trên phạm vi toàn quốc, trong đó, tại Điều 119 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất.

1.2.3.3. Chế độ chính trị

Với cách hiểu chế độ chính trị là phương pháp thực hiện quyền lực chính trị của nhà nước, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chế độ chính trị dân chủ. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị của Đảng với vai trò là Đảng cầm quyền[29]: Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ

[29] Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam, *Cương lĩnh 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011).*

chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đồng thời, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân" (Điều 28), "Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện" (Điều 3).

1.2.4. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Do bộ máy nhà nước được hợp thành từ các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức, hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất và những nguyên tắc riêng cho từng cơ quan, nên trong mỗi giai đoạn phát triển của xã hội, bộ máy nhà nước có thể có sự điều chỉnh theo hướng có tổ chức hay không tổ chức một số cơ quan nhà nước nhất định, có thể ghi nhận hay không ghi nhận những nguyên tắc nhất định. Xác định các cơ quan trong bộ máy nhà nước cần căn cứ vào Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác (các luật về tổ chức các cơ quan nhà nước, các Nghị định).

Trong giai đoạn hiện nay, bộ máy nhà nước của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Hiến pháp 2013 gồm các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, cụ thể:

Quốc hội: Theo quy định tại Điều 69 Hiến pháp 2013, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Chủ tịch nước: Theo quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội; là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Chính phủ: Điều 94 và Điều 95 Hiến pháp năm 2013 quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Tòa án nhân dân: Điều 102 Hiến pháp 2013 quy định về Tòa án nhân dân như sau: Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án khác do luật định, là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân: Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 107 Hiến pháp 2013, gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định. Nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Chính quyền địa phương: Tại các Điều 110, Điều 111, Điều 113 và Điều 114 Hiến pháp 2013 quy định:

+ Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Uỷ ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức theo những nguyên tắc chung cho cả bộ máy và những nguyên tắc riêng, đặc thù. Các nguyên tắc chung mang tính hiến định về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước gồm[30]: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước; Quyền lực nhà

[30] Điều 2, Điều 4, Điều 6, Điều 8 Hiến pháp 2013.

nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; Nguyên tắc tập trung dân chủ…

1.2.5. Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

1.2.5.1. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ trương xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là chủ trương nhất quán, xuyên suốt kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong Văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994) đến nay. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: "Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị"[31]. Trong đó, xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền[32]. Từ đó đặt ra yêu cầu, *"*Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có Chiến lược pháp luật và cải cách tư pháp"[33]. Nhất quán chủ trương, yêu cầu từ Đại hội XIII, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã ban ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trải qua quá trình phát triển nhận thức lý luận trên cơ sở nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu những yếu tố hợp lý trong học thuyết về nhà nước pháp quyền do các nhà tư tưởng tiến bộ trong lịch sử tư tưởng nhân loại xây dựng nên và triển khai xây

---

[31] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.174.

[32] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.174-175.

[33] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, *Sđd*, t.1, tr.177.

dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền trong thực tiễn, đến nay, Nghị quyết số 27-NQ/TW khẳng định thống nhất nhận thức về những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:

1, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;

2, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;

3, Quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật;

4, Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật;

5, Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp;

6, Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán;

7, Độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

8, Tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế[34].

1.2.5.2. Quan điểm và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu định định hướng xây dựng Nhà nước trong 10 năm tới: "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước và

[34] Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09-11-2022 của BCHTW *về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.*

của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội"[35].

Trên cơ sở định hướng đó, Văn kiện Đại hội XIII đồng thời xác định giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu trong 5 năm (2021-2025) là: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thốngchính trị. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước. Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, hiện đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững[36].

1.2.5.3. Những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể

Các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII và được phát triển, cụ thể hóa thêm trong Nghị quyết 27-NQ/TW có thể khái quát gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, tuyên truyền, phổ biến nhằm thống nhất nhận thức về các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao nhận thức về quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để đạt mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ hai, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Nhiệm vụ, giải pháp này bao gồm các nhiệm vụ, giải pháp về

---

[35] Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, *Sđd*, t.1, tr.118.

[36] PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, *Một số điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng,* http://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/mot-so-diem-moi-noi-bat-trong-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-132091, Thứ Hai, 22/2/2021 6:0'(GMT+7).

xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nội luật hóa điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia, tổ chức thực hiện pháp luật tốt hơn để nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với các tiêu chí để xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng rõ nét, nhiệm vụ và giải pháp này yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục sự thiếu hụt quy phạm pháp luật bằng đa dạng hóa nguồn của pháp luật, khắc phục những hạn chế trong xây dựng pháp luật. Đặc biệt, cần gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật.

Thứ tư, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cụ thể, tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội; Tiếp tục thực hiện tốt thiết chế Chủ tịch nước theo Hiến pháp; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước, điều quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế để thực hiện các phạm vi kiểm soát (trong và ngoài), triển khai đa dạng các hình thức kiểm soát trên cơ sở những hình thức phổ biến và tăng cường hình thức mới, đồng thời đảm bảo tính hiệu lực của kiểm soát. Đây cũng chính là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa và chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ sáu, tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng thành công một trong số các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thống nhất tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Thứ bảy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiệm vụ, giải pháp này nhằm thực hiện tốt quan điểm của Đảng về xây dựng, hoàn thiện nhà nước

pháp quyền ở Việt Nam, đồng thời, để bảo đảm thực hiện nguyên tắc hiến định về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước cũng như vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò chủ thể quyền lực nhà nước của Nhân dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. C. Mác và Ph. Ăngghen (2002), *Toàn tập,* NXB Chính trị Quốc gia, H., t.1.
2. C. Mác và Ph. Ăngghen (1984), *Tuyển tập*, Tập VI (Phri-đrích Ăng-ghen, *Nguồn gốc của gia đình, của sở hữu tư nhân và của nhà nước)*, NXB Sự thật, H.
3. C. Mác và Ph. Ăngghen (1995), *Toàn tập,* NXB Chính trị Quốc gia, H., t.21, t22.
4. Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Luật (2005), *Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* PGS. TS. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.76-77.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,* NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội.
7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1*, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 2*, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội,.
9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X)*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), *Văn kiện Đảng toàn tập*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 37.
11. Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), *Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa VII*, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
12. GS. TSKH Đào Trí Úc (chủ biên) (2007), *Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam,* NXB Tư pháp, Hà Nội.
13. GS. TS. Lê Minh Tâm. ThS Vũ Thị Nga (2017), *Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam*, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

14. GS. VS. Nguyễn Duy Quý, PGS.TS Nguyễn Tất Viễn (Đồng chủ biên) (2010), *Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.* NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị khu vực II (2022), *Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật*, TS Nguyễn Thị Tuyết Mai (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), *Giáo trình cao cấp lý luận chính trị: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam,* NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), *Giáo trình cao cấp lý luận chính trị: Nhà nước và Pháp luật Việt Nam,* NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.
18. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khoa Nhà nước và Pháp luật (2004), *Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật,* Tập 1, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội.
19. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học (chủ trì), PGS. TS Lê Minh Quân (chủ nhiệm), Tổng quan đề tài khoa học cấp Bộ, *Một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay và tác động của chúng đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam,* Hà Nội, 2005.
20. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), *Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị*, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà và PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên (chủ biên), NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
21. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), *Giáo trình Triết học Mác-Lênin dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị*, PGS. TS. Đặng Quang Định (chủ biên), NXB Lý luận chính trị, Hà Nội.
22. Hồ Chí Minh (2000), *Toàn tập*, NXB Chính trị Quốc gia, H., t.4.
23. Hồ Chí Minh (2002), *Toàn tập,* NXB Chính trị Quốc gia, H., t.1.
24. Hồ Chí Minh (2002), *Toàn tập,* NXB Chính trị Quốc gia, H., t.2.
25. Hội đồng lý luận Trung ương (2020), *30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội*, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, H.
26. Hội đồng lý luận Trung ương (2021), *Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng,* NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội .

27. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (1999), *Giáo trình triết học Mác-Lênin*, Nxb Chính trị Quốc gia, H.

28. Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XIII, *Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.*

29. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

30. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

31. Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), *Đại từ điển tiếng Việt,* NXB Văn hóa – Thông tin, H.

32. PGS. TS Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) (2009), *Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị,* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

33. PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, *Một số điểm mới nổi bật trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng,* http://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao- cuoc-song/mot-so-diem-moi-noi-bat-trong-cac-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang- 132091, Thứ Hai, 22/2/2021 6:0'(GMT+7).

34. Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật,* NXB Công an Nhân dân, Hà Nội.

35. V.I. Lênin (1978), *Toàn tập,* NXB Tiến bộ, M., t.45.

36. V.I. Lênin (1981), *Toàn tập,* NXB Tiến bộ, M., t.31.

37. V.I. Lênin (1977), *Toàn tập,* NXB Tiến bộ, H.

CHƯƠNG 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT

2.1. Khái niệm, bản chất, thuộc tính, hình thức của pháp luật

2.1.1. Khái niệm pháp luật

Khái niệm pháp luật cho đến nay vẫn tồn tại nhiều cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào từng trường phái hay quan điểm nhận thức về pháp luật. Nhìn từ góc độ nguồn gốc pháp luật, chúng ta có pháp luật tự nhiên (natural law)[37] và pháp luật thực định (positive law). Nhìn từ góc độ chủ thể ban hành, chúng ta có pháp luật do nhà nước ban hành (legal centralism) và pháp luật bao gồm cả luật của nhà nước ban hành và luật không do nhà nước ban hành (legal pluralism). Cho đến nay, vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của pháp luật. Có quan điểm coi vai trò và giá trị cao nhất của pháp luật là chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của nó, nhưng có quan điểm xem xét vai trò của pháp luật trong mối liên hệ, tác động với các lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, đạo đức, tư tưởng)[38] và khẳng định pháp luật là công cụ không thể thiếu trong quản lý xã hội. Về vấn đề này, tác giả Nguyễn Minh Đoan nhận xét: "Cùng với việc xây dựng một nhà nước kiểu mới, hệ thống pháp luật mới cũng nhanh chóng được xây dựng để ghi nhận, củng cố, bảo vệ và phát triển những thay đổi cơ bản của xã hội về kinh tế, chính trị - xã hội từ phương diện pháp lý"[39] và khẳng định pháp luật "là công cụ quản lý không thể thiếu, một công cụ quản lý xã hội quan trọng và hiệu quả"[40]. Có tác giả tiếp cận vai trò của pháp luật thông qua các giá trị xã hội của nó[41]. Nguyễn Đình Đặng Lục khẳng định: "Với tư cách là những chuẩn mực, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách"[42], trong đó pháp luật hình thành tính hướng thiện trong hành vi của

---

[37] Xem thêm: Nguyễn Xuân Tùng, "Luật tự nhiên trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam", *Tạp chí Luật học* số 3/2010, tr.58-63.

[38] Viện Nghiên cứu nhà nước và pháp luật, *Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.196-201.

[39] Nguyễn Minh Đoan, *Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội*, sách chuyên khảo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.107.

[40] Nguyễn Minh Đoan, *Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội*, sách chuyên khảo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.7-21.

[41] Đào Trí Úc, *Những vấn đề cơ bản về pháp luật*, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1999, tr.31-37.

[42] Nguyễn Đình Đặng Lục, *Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách*, sách chuyên khảo, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr.83.

chủ thể. Theo tác giả, pháp luật là những quy tắc xử sự do nhà nước xác lập nhằm điều chỉnh hành vi của mọi thành viên trong xã hội. Do đó, sự điều chỉnh của pháp luật ở đây có vai trò "nhằm chống lại cái ác bảo vệ cái thiện, hướng con người hành động trong mối quan hệ vươn tới cái thiện"[43].

Theo cách hiểu truyền thống trong các giáo trình, tài liệu, bài viết ở nước ta hiện nay, pháp luật được hiểu là hệ thống các quy phạm (quy tắc hành vi hay quy tắc xử sự) có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và được nhà nước đảm bảo thực hiện điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật được ban hành nhằm mục đích duy trì trật tự xã hội theo ý chí, mong muốn của nhà nước. Với cách thức quan niệm này, pháp luật có những đặc trưng riêng mà các loại quy phạm xã hội khác không có. So với các hiện tượng xã hội khác, pháp luật mang ba đặc điểm sau: tính quy phạm phổ biến; tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức; tính bảo đảm thực hiện bằng nhà nước. Về cơ bản, quan niệm trên phản ánh đầy đủ bản chất giai cấp và tính xã hội của pháp luật. Tuy nhiên, trong một thế giới không ngừng vận động và phát triển như hiện nay, khái niệm và đặc điểm của pháp luật cần tiếp cận ở nhiều khía cạnh khác nhau, mang tính mềm dẻo hơn. Do vậy, quan điểm pháp lý Việt Nam nhìn chung theo thuyết nhất nguyên và pháp luật thực định. Hầu hết các khái niệm pháp luật trong giáo trình hay tài liệu nghiên cứu mang tính pháp lý đều cho rằng pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội. Như vậy, những quy tắc xử sự (mang tính quy phạm) không phải do nhà nước ban hành hay thừa nhận đều không được xem là pháp luật mà chúng là những quy phạm xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Việt Nam cũng không theo quan điểm nhất nguyên một cách tuyệt đối. Việc thừa nhận và áp dụng luật tập quán hay các quy phạm đạo đức và hiện nay là án lệ đã phần nào phản ánh tính đa nguyên trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Thực tiễn pháp lý Việt Nam cho thấy luật tập quán đã được áp dụng từ thời kỳ phong kiến. Việc thừa nhận luật tập quán vẫn thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như trong luật dân sự, luật hôn nhân gia đình cũng như các văn bản quy phạm khác là minh chứng cho quan điểm mở hoặc không theo đuổi đến cùng tính nhất nguyên của pháp luật.

---

[43] Nguyễn Đình Đặng Lục, *Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách*, sách chuyên khảo, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr.85.

Theo Phan Nhật Thanh, thuyết nhất nguyên hay mô hình pháp luật tập trung thì pháp luật là hệ thống các quy phạm do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận từ luật tập quán hay tín điều tôn giáo, đạo đức). Pháp luật, theo học thuyết này, phải đáp ứng ba tiêu chí: thứ nhất, pháp luật chỉ là luật của nhà nước; thứ hai, pháp luật nhà nước là cách thức tốt nhất trong việc quản lý xã hội và điều chỉnh hành vi của các chủ thể và; thứ ba, trong xã hội có nhiều hệ thống quy phạm nhưng pháp luật nhà nước chiếm vị trí tối cao trong hệ thống các quy phạm đó. Các hệ thống quy phạm khác như đạo đức, tập quán, tín điều tôn giáo có thể được nhà nước thừa nhận như pháp luật hoặc trở thành nguồn hỗ trợ cho pháp luật nhà nước. Với những thuộc tính cơ bản như tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính được đảm bảo bằng nhà nước, do nhà nước ban hành có cấu trúc chặt chẽ, dễ hiểu, áp dụng chung cho nhiều đối tượng và được ban hành theo thủ tục nhất định, pháp luật được đánh giá là công cụ hữu hiệu nhất trong việc quản lý xã hội. Và lý lẽ đó, so với các quy phạm khác, pháp luật có tính vượt trội rõ nét. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà nghiên cứu ủng hộ mô hình pháp luật tập trung cho rằng bản chất của pháp luật là mang ý chí tập thể, mang quyền lực nhà nước trong đó chứa đựng quy tắc xử sự của hành vi và được đảm bảo thực hiện bởi quyền lực nhà nước. Bởi lẽ, pháp luật mang tính mệnh lệnh của nhà cầm quyền. Pháp luật phải là một hệ thống quy phạm hoàn thiện với sự xác định rõ thứ bậc của các văn bản quy phạm, và nó phải xuất phát từ nhà nước và mang quyền lực nhà nước. Nhà nước, bằng các biện pháp tư tưởng, kinh tế và tổ chức đã đảm bảo được tính khả thi và tính hiệu quả của pháp luật. Việc nhà nước xác định rõ các quy phạm mang tính bắt buộc chung do mình ban hành là pháp luật không có nghĩa là nhà nước hoàn toàn phủ nhận các quy phạm khác. Ở một mức độ tương đối nhất định, vẫn có sự tồn tại đa dạng của các quy phạm trong đời sống xã hội và các quy phạm này được kiểm soát bởi nhà nước. Các quy phạm khác được xem là các quy phạm xã hội như quy phạm tôn giáo, quy phạm đạo đức hay luật tập quán. Các quy phạm này có thể được nhà nước thừa nhận và sử dụng như một nguồn bổ trợ cho pháp luật nhà nước và chắc chắn, nó không được trái với pháp luật nhà nước[44].

Thực tiễn đã chứng minh, pháp luật không chỉ thể hiện ý chí giai cấp thống trị mà pháp luật phải đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân

[44] Phan Nhật Thanh, "Bàn về nguồn gốc của pháp luật", *Tạp chí Khoa học Pháp lý* số 03(97)/2016, tr.43-49.

dân. Chính vì thế, trong quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, một trong những yêu cầu, quy định đó là hỏi ý kiến đối tượng chịu sự tác động. Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật chứa đựng những triết lý sâu sắc về bản chất, vai trò và mối quan hệ tương đồng giữa pháp luật với các quy tắc xử sự xã hội khác. Người cho rằng, pháp luật phải gắn liền với đạo đức, việc tuân thủ pháp luật cũng có nghĩa là thuận theo đạo đức, thuần phong mỹ tục của xã hội[45]. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ sở tư tưởng để định ra pháp luật là phải dựa hẳn vào lực lượng nhân dân, lực lượng lao động làm nền tảng và quy định nội dung của luật pháp. Người nhấn mạnh việc định ra luật pháp là rất quan trọng, song vấn đề quan trọng hơn là luật pháp ấy phải được toàn xã hội thi hành một cách nghiêm túc[46]. Mặt khác, trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền, hướng tới một xã hội dân chủ, người dân có quyền thể hiện quan điểm, khuynh hướng của mình không chỉ đối với những nội dung liên quan đến cá nhân mà còn với các vấn đề chung của đất nước. Điều 28 Hiến pháp 2013 quy định: "công dân có quyền tham gia thảo luận... và kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước". Pháp luật là một trong những công cụ do Nhà nước ban hành để quản lý xã hội. Cùng với pháp luật, Nhà nước sử dụng công cụ như chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách để đạt hiệu lực, hiệu quả quản lý. Đồng thời, pháp luật do Nhà nước ban hành song pháp luật cũng là phương tiện kiểm soát quyền lực nhà nước. Chính vì thế có nguyên tắc chung nhất là: cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Mặt khác, mục đích điều chỉnh của pháp luật không chỉ dừng việc ổn định, duy trì trật tự các quan hệ xã hội mà pháp luật phải định hướng các quan hệ xã hội vận động và phát triển hướng tới mục tiêu bền vững. Để đáp ứng yêu cầu định hướng các quan hệ xã hội phát triển bền vững, pháp luật phải tạo ra những không gian pháp lý mà trong đó các quyền con người, quyền công dân được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm và thực thi; các quy luật vận động khách quan được tôn trọng để bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà nước, xã hội và công dân. Theo Từ điển luật học, pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận

[45] Hồ Chí Minh, *Về vấn đề nhà nước và pháp luật*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.5.

[46] Đức Vượng, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật thể hiện trong bộ "Hồ Chí Minh toàn tập"*, in trong "Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật", Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Hà Nội, 1993, tr.154.

nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, phục vụ và bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư trong xã hội (của giai cấp thống trị trong các nhà nước bóc lột). Quan niệm này nhấn mạnh đến việc pháp luật phản ánh ý chí nhà nước, được ban hành bởi các cơ quan nhà nước dưới những hình thức nhất định và được nhà nước dùng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thực hiện[47]. Từ những phân tích trên cho thấy, *pháp luật là hệ thống các quy phạm (quy tắc hành vi hay quy tắc xử sự) có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận; được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các phương pháp, hình thức quản lý khác nhau nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội hướng tới mục đích bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của con người.* Tiếp cận khái niệm pháp luật như một nhân tố chứa đựng yêu cầu phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người là bước tiến mới về nhận thức pháp luật ở Việt Nam.

2.1.2. Bản chất của pháp luật

Có nhiều tranh luận liên quan đến bản chất của pháp luật do việc xác định hoặc miêu tả bản thể hay bản chất của pháp luật là một công việc rất khó khăn[48] và thường xuyên khơi dậy những tranh cãi, song mọi người đều thừa nhận pháp luật là phương tiện thay đổi xã hội, là trung tâm trong đời sống xã hội, chính trị, đạo đức và kinh tế[49]. Pháp luật có vai trò tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm thiết lập trật tự xã hội. Sự tác động và ảnh hưởng của pháp luật thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng loại đối tượng và từng loại quan hệ, nhưng sự biểu hiện cụ thể của sự tác động đó bao giờ cũng phản ánh trong khuôn mẫu của các hành vi xử sự được xác định, mà các chủ thể pháp luật phải tuân theo, chấp hành hoặc lấy làm cơ sở để sử dụng và áp dụng chúng phù hợp với những điều kiện thực tiễn. Bản chất của pháp luật hiện nay được tiếp cận và phân tích trên hai khía cạnh:

Thứ nhất, bản chất giai cấp của pháp luật.

Pháp luật do Nhà nước đặt ra thể hiện ý chí của giai cấp thống trị. Giai cấp thống trị cụ thể hóa ý chí của mình thông qua Nhà nước thành các

---

[47] Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp, *Từ điển luật học,* Nxb Tư pháp và Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2006, tr.606.

[48] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.7.

[49] Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A very short Introduction, Oxford University Press,* 2006, p.xii.

quy tắc xử sự áp đặt lên xã hội buộc mọi người phải tuân theo. Trong sự hình thành pháp luật, nhà nước như người "bà đỡ", làm cho pháp luật "hiện diện" trong đời sống với những hình thức xác định[50]. Theo Mác và Ăng ghen, pháp luật là sự phản ánh của một thực tại cao hơn và hiện hữu hơn, thể hiện mối tương quan lực lượng đặc trưng cho một phương thức sản xuất nhất định. Pháp luật không tồn tại như một thực thể riêng rẽ mà chỉ là cái tạo nên từ mối tương quan lực lượng giữa các giai cấp trong xã hội. Khi đấu tranh giai cấp không còn nữa thì pháp luật cũng sẽ biến mất trong xã hội cộng sản, một xã hội không có giai cấp và không có nhà nước[51]. Tư tưởng trung tâm của chủ nghĩa Mác coi pháp luật chỉ là một kiến trúc thượng tầng xã hội, là sự phản ánh của hiện thực các cơ sở hạ tầng xã hội, do đó cần phải xác định rõ những yếu tố của hiện thực này. Trong bối cảnh xã hội tư sản có hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản thì nhà nước là công cụ bảo vệ giai cấp tư sản nên pháp luật phục vụ cho việc áp bức của nhà nước mà thực chất là của giai cấp tư sản đối với giai cấp vô sản. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, pháp luật cũng có chức năng che đậy tính trấn áp của nhà nước, nhưng điểm khác biệt với nhà nước tư sản là được chấp nhận về mặt đạo đức vì nó là chuyên chính của đa số đối với một nhóm nhỏ những cá nhân có đặc quyền[52]. Đây cũng là luận điểm mà các nhà khoa học phương Tây phê phán học thuyết Mác vì đã quá nặng về việc lý giải yếu tố giai cấp[53].

Dựa trên tư tưởng về Nhà nước và pháp luật của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh đến tính ý chí của pháp luật, theo Người pháp luật là ý chí của giai cấp công nhân, nó bảo vệ quyền lợi của hàng triệu người lao động. Về tính chất, pháp luật của nhà nước ta (Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa) là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động[54]. Trong khi

---

[50] Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, tái bản lần thứ hai, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2018, tr.214-215.

[51] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.13.

[52] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.28-29.

[53] Nguyễn Minh Tuấn, "Một góc nhìn khác về nguồn gốc và xu hướng vận động của nhà nước", *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật* số 8 (304) năm 2013, tr.3-9.

[54] Đức Vượng, *Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật thể hiện trong bộ "Hồ Chí Minh toàn tập"*, in trong "Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật", Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Hà Nội, 1993, tr.162.

xây dựng chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa đức trị với pháp trị, tùy theo hoàn cảnh đất nước. Trong đó Người nhấn mạnh, cái khó trong việc thi hành pháp luật là phải bảo đảm được tính vô tư, khách quan, công bằng, bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật trên tinh thần vua tôi, trên dưới, sang hèn đều phải theo pháp luật như thế thịnh trị[55]. Trong chừng mực nhất định, luật pháp thường là các quy tắc xử sự được khái quát hóa từ tập tụ, thói quen của cộng đồng người, được hình thành, tuân thủ qua nhiều thế hệ, khi được quyền lực nhà nước thừa nhận và cưỡng chế thi hành thì những tập tục đó trở thành luật tục và do đó, sự phát triển của luật pháp không thể tách khỏi cung cách sống và truyền thống của dân tộc và càng không nên đơn giản hóa nó chỉ là biểu hiện cho ý chí của một giai cấp thống trị nhất định nào[56].

Thứ hai, bản chất xã hội của pháp luật.

Nhà nước với tư cách là tổ chức quản lý xã hội ghi nhận những cách xử sự hợp lý khách quan, được số đông trong xã hội chấp nhận phù hợp với lợi ích xã hội và quy định thành những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc đối với mọi người. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở chỗ: Pháp luật là sự thể hiện ý chí chung của cả xã hội, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội, nhằm thiết lập và giữ gìn trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích chung của cả cộng đồng, vì sự phát triển chung của xã hội. Trong đời sống xã hội, do đòi hỏi của các quan hệ giao tiếp giữa mọi người nên đã hình thành các thói quen, các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử có tính chất chân lý, thể hiện ý chí chung của cả cộng đồng, được cả cộng đồng chấp thuận và tuân thủ. Ví dụ: cách ứng xử giữa cha mẹ và các con, ông bà và các cháu, giữa người mua và người bán… Khi nhà nước thừa nhận các quy tắc này thì tạo nên tính xã hội của pháp luật.

Bên cạnh đó, pháp luật là phương tiện để giải quyết khía cạnh "xã hội" của đời sống như phòng, chống và khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người lang thang, cơ nhỡ… Như thế, pháp luật luôn hàm chứa các giá trị xã hội phổ biến, thuộc về con người. Pháp luật luôn phản ánh điều kiện kinh tế - xã hội, những quan niệm

---

[55] Song Thành, *Tư tưởng pháp quyền Hồ Chí Minh sự thống nhất giữa "đức trị" với "pháp trị"*, in trong "Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật", Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Pháp lý, Hà Nội, 1993, tr.213.

[56] Phạm Duy Nghĩa, *Chuyên khảo luật kinh tế*, chương trình sau đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004, tr.7, 8.

đạo đức truyền thống tốt đẹp, thuần phong, mỹ tục… của dân tộc. Vì thế, trong pháp luật có nhiều quy định thể hiện tính xã hội của nó: Quy định về chế độ phổ cập giáo dục bắt buộc cho công dân, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn giao thông, bảo đảm thông tin, liên lạc, bảo vệ môi trường sống…

Trong giai đoạn hiện nay, pháp luật là biểu tượng của nền công lý, công bằng xã hội, nó bảo đảm cho các chủ thể ngang quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau trong những mối quan hệ xã hội nhất định. Pháp luật là một trong những công cụ để bảo vệ những công trình và những giá trị văn hoá, tinh thần chung của xã hội, những giá trị đạo đức, truyền thống và một số phong tục, tập quán của dân tộc.

Thực tiễn cho thấy, mặc dù tính xã hội là thuộc tính chung của tất cả các kiểu pháp luật, song sự thể hiện tính xã hội có sự khác nhau giữa các kiểu pháp luật. Cùng với sự phát triển của xã hội, tính xã hội của pháp luật ngày càng trở nên sâu sắc và rộng rãi hơn. Chẳng hạn, bản chất xã hội của pháp luật chủ nô, phong kiến còn mờ nhạt và hạn chế, chủ yếu thể hiện qua vai trò là công cụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trừng trị tội phạm, bảo vệ các công trình công cộng… Sang đến pháp luật tư sản, bản chất xã hội có sự thay đổi rất lớn qua các giai đoạn phát triển của nhà nước tư sản. Pháp luật tư sản ra đời đã thể hiện sự tiến bộ hơn so với pháp luật phong kiến. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật được mở rộng dần, tới hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ các quan hệ trong gia đình đến các quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội trong đời sống cộng đồng. Pháp luật trở thành công cụ quan trọng để thiết lập địa vị pháp lý bình đẳng giữa các cá nhân trong xã hội, hướng tới bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

2.1.3. Các thuộc tính của pháp luật

Thuộc tính là tính chất vốn có, gắn liền, không thể tách rời của sự vật, hiện tượng, qua đó có thể phân biệt sự vật, hiện tượng này với sự vật, hiện tượng kia. Thuộc tính của pháp luật là những dấu hiệu đặc trưng của pháp luật, nhằm phân biệt chúng với các quy phạm xã hội khác. Các thuộc tính của pháp luật bao gồm:

Một là, tính quy phạm phổ biến.

Pháp luật được tạo bởi hệ thống các quy phạm pháp luật, quy phạm là tế bào của pháp luật, là khuôn mẫu, là mô hình xử sự chung. Trong xã hội, các hành vi xử sự của con người rất khác nhau, tuy nhiên trong những hoàn cảnh điều kiện nhất định vẫn đưa ra được cách xử sự chung phù hợp với đa số. Cũng như quy phạm pháp luật, các quy phạm xã hội khác đều

có những quy tắc xử sự chung. Nhưng khác với các quy phạm xã hội, pháp luật có tính quy phạm phổ biến. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật dựa trên ý chí của nhà nước "được đề lên thành luật". Pháp luật đã hợp pháp hóa ý chí này làm cho nó có tính chất chủ quyền duy nhất trong một quốc gia. Chính quyền lực chính trị đem lại cho pháp luật tính quy phạm đặc biệt – tính quy phạm phổ biến. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được biểu hiện ở chỗ:

- Các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trên lãnh thổ, việc áp dụng các quy phạm này chỉ bị đình chỉ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi hoặc thời hiệu các quy phạm đã hết.

- Pháp luật được ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội mà nhà nước cho là cần thiết để thiết lập trật tự xã hội theo mong muốn của mình. Trong không gian lãnh thổ đó, mỗi chủ thể pháp luật đều phải "làm theo" các quy tắc xử sự đã được ấn định trong các quy phạm pháp luật. Việc áp dụng nhiều lần trong đời sống làm cho pháp luật có tính phổ biến, nghĩa là trở thành chuẩn mực chung cho các quan hệ xã hội.

Hai là, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Thuộc tính thứ hai của pháp luật là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, nó là sự thể hiện nội dung pháp luật dưới những hình thức nhất định. Thuộc tính này thể hiện ở chỗ nội dung của pháp luật được xác định rõ ràng, chặt chẽ khái quát trong các điều, khoản của các điều luật trong một văn bản quy phạm pháp luật cũng như toàn bộ hệ thống pháp luật do nhà nước ban hành. Ngôn ngữ sử dụng trong pháp luật là ngôn ngữ pháp luật, lời văn trong sáng, đơn nghĩa. Trong pháp luật không sử dụng những từ " vân vân" và các dấu (…), một quy phạm pháp luật không cho phép hiểu thế này cũng được mà hiểu thế khác cũng được. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật được xác định dựa trên các tiêu chí:

- Tất cả các văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp dưới phải phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và không trái với Hiến pháp.

- Xác định được mối tương quan giữa nội dung và hình thức của pháp luật.

- Chuyển tải một cách chính xác những chủ trương, chính sách của Đảng sang các phạm trù, cấu trúc pháp lý thích hợp.

- Bảo đảm nguyên tắc pháp chế trong hoạt động xây dựng pháp luật.

- Mỗi văn bản pháp luật phải xác định rõ phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, cơ quan có thẩm quyền ra văn bản.

- Phân định phạm vi, mức độ của hoạt động lập pháp, lập quy.

- Pháp luật khi ban hành phải có giá trị trong một thời gian tương đối dài và phải phù hợp với các quy luật khách quan và chỉ được sửa đổi, bổ sung khi điều kiện kinh tế, xã hội thay đổi.

Ba là, pháp luật được bảo đảm thi hành bằng nhà nước.

Khác với các quy phạm xã hội khác pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm thực hiện. Sự bảo đảm bằng nhà nước là thuộc tính của pháp luật. Pháp luật không chỉ do nhà nước ban hành mà nhà nước còn bảo đảm cho pháp luật được thực hiện, có nghĩa là nhà nước trao cho các quy phạm pháp luật có tính quyền lực bắt buộc đối với mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân. Như vậy pháp luật trở thành quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung nhờ vào sức mạnh quyền lực của nhà nước.

Tuỳ theo mức độ khác nhau mà nhà nước áp dụng các biện pháp về tư tưởng, tổ chức, khuyến khích… kể cả biện pháp cưỡng chế cần thiết để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện. Do đó, tính được bảo đảm bằng nhà nước của pháp luật được hiểu dưới hai khía cạnh. Một mặt, nhà nước tổ chức thực hiện pháp luật bằng cả hai phương pháp thuyết phục và cưỡng chế. Mặt khác, nhà nước là người bảo đảm tính hợp lý và uy tín của pháp luật, nhờ đó pháp luật được thực hiện thuận lợi trong đời sống xã hội.

2.1.4. Hình thức pháp luật

Trong khoa học pháp lý, hình thức của pháp luật là "cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật"[57], theo đó, pháp luật được xác định ở ba hình thức: *tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật*. Quan điểm này nhận được sự đồng thuận của khá nhiều nhà nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam bởi nó phù hợp với đời sống pháp lý và tập quán của người Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có một số công trình nghiên cứu giới thiệu thêm hình thức pháp luật khác như: các hợp đồng mẫu chứa các quy phạm pháp luật, các học thuyết pháp lý[58] hay những quy định của luật tôn giáo[59]. Từ các quan điểm tiếp cận phân tích bản chất

---

[57] Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật,* Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007, tr.81.

[58] Phạm Hồng Thái, *Lý luận nhà nước và pháp luật,* Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2009, tr.310.

[59] Nguyễn Cửu Việt (chủ biên), *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật,* Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004, tr.219.

của khái niệm hình thức pháp luật cho thấy, khái niệm hình thức pháp luật không chỉ bó gọn trong văn bản quy phạm pháp luật mà nhà nước ban hành và tập quán pháp mà nhà nước công nhận áp dụng mà còn bao gồm những hình thức khác của pháp luật được nhà nước của một quốc gia công nhận là: tiền lệ pháp, tôn giáo pháp. Những dạng tồn tại này, trong một số trường hợp, có mặt trong đời sống xã hội trước khi văn bản quy phạm pháp luật ban hành. Về phân loại hình thức pháp luật cho thấy, nhiều nhà nghiên cứu đồng nhất hai khái niệm "nguồn của luật" và "hình thức (bên ngoài) của pháp luật"; tuy nhiên, một số nghiên cứu khác phân chia theo hai dạng: nguồn hình thức và nguồn nội dung. Dù các quan niệm có khác nhau về cách diễn đạt thì hình thức pháp luật được hiểu là sự biểu hiện của pháp luật ra ngoài xã hội. Trong lịch sử, có ba hình thức pháp luật phổ biến là tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

a) Tập quán pháp

Tập quán[60] là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự. Tập quán pháp là một loại nguồn pháp luật được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, một đất nước có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống trong sự đa dạng văn hóa, tập quán pháp hay luật tục của mỗi dân tộc có sự khác biệt và có vai trò không hoàn toàn giống nhau trong mỗi cộng đồng dân tộc. Đối với các dân tộc ít người ở vùng cao và Tây Nguyên, luật tục được biểu hiện như nét đẹp văn hóa riêng của mỗi dân tộc, và dường như đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành tiêu chuẩn cho hành vi ứng xử của mỗi thành viên trong các cộng đồng dân tộc đó.

Từ phân tích quá trình tiếp nhận truyền thống Civil Law, Nguyễn Mạnh Thắng bình luận "tập quán pháp hay còn gọi là tục lệ được xem là một loại nguồn bổ sung của pháp luật để bù đắp cho những thiếu hụt trong pháp luật. Tại đây, việc áp dụng tập quán pháp hay tục lệ được khái quát thành lý luận pháp luật góp phần quan trọng cho việc điều tiết các quan hệ thương mại (dù còn nhỏ bé). Tục lệ chỉ được áp dụng khi không có điều khoản nào của pháp luật liên quan và không thể trái với các điều khoản của pháp luật. Tục lệ được nhận biết qua hai yếu tố: (1) yếu tố thực thể hay

[60] Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Dân sự năm 2015.

yếu tố tập quán, có nghĩa là biện pháp ứng xử được nhiều người làm theo trong một khoảng thời gian nhất định, miễn là không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác; và (2) yếu tố tinh thần hay ý thức về sự cần thiết của tập quán đó" và đưa ra nhận định các vấn đề lịch sử này cho thấy sự nhận thức và tình cảm sâu xa của người Việt Nam đối với tập quán và áp dụng tập quán trong sinh hoạt xã hội. Đây là nền tảng tư tưởng thuận lợi cho việc nghiên cứu tập quán và áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp trong đời sống dân sinh nói chung và trong kinh doanh, thương mại nói riêng[61].

Tập quán pháp là hình thức Nhà nước do phê chuẩn hoặc thừa nhận một số tập quán đã lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, lợi ích xã hội và nâng lên thành những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Hình thức này phổ biến trong pháp luật chủ nô, phong kiến là do pháp luật thành văn chưa phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các quan hệ thương mại trong nước cũng như tập quán thương mại quốc tế càng làm cho vai trò của tập quán pháp trở nên quan trọng vì nó bổ khuyết khoảng trống của luật thành văn cũng như là bước tiếp nối truyền thống dân tộc trong pháp luật của mỗi quốc gia[62].

b) Tiền lệ pháp

Tiền lệ pháp hay phép xét xử theo tiền lệ là một hình thức của pháp luật, theo đó Nhà nước thừa nhận những bản án, quyết định giải quyết vụ việc của tòa án (trong các tập san án lệ) làm khuôn mẫu và cơ sở để đưa ra phán quyết cho những vụ việc hoặc trường hợp có tình tiết hay vấn đề tương tự sau đó. Tiền lệ pháp còn là quá trình làm luật của toà án trong việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc mới trong quá trình xét xử.

Về con đường hình thành, tiền lệ pháp hình thành không phải do hoạt động của cơ quan lập pháp mà xuất hiện từ hoạt động của cơ quan hành pháp và tư pháp. Vì vậy, hình thức này dễ tạo ra sự tùy tiện, không phù hợp với nguyên tắc pháp chế đòi hỏi phải tôn trọng nguyên tắc tối cao của luật và phải phân định rõ chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật. Tuy nhiên, trên

[61] Nguyễn Mạnh Thắng, "Môi trường pháp lý liên quan đến áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam", *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 2+3 (234+235), tháng 2/2013, tr.111-116.
[62] Xem thêm: Luke McNamara, Phan Nhật Thanh, "Tập quán pháp với các góc nhìn khau trên thế giới", *Tạp chí Khoa học Pháp lý* số 5(66)/2011, tr.9-14.

thực tế, bởi xuất phát điểm của tiền lệ pháp là hình thành từ con đường thông qua quá trình xét xử; phù hợp với chức năng của cơ quan tư pháp và nếu như các cơ quan hành chính cũng ban hành tiền lệ thì không phù hợp với thẩm quyền và chức năng là cơ quan quản lý – không phải là cơ quan xét xử, tạo nên một sự chồng chéo trong việc hình thành và áp dụng tiền lệ giữa hai cơ quan hành pháp và tư pháp. Cho nên, tiền lệ pháp chỉ có thể được hình thành từ hoạt động xét xử của cơ quan tư pháp, hình thành từ cơ quan tư pháp chứ không phải từ cơ quan lập pháp hay hành pháp. Tiền lệ pháp hình thành từ các cơ quan tư pháp được gọi là án lệ, đây là một hình thức pháp luật chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Anh - Mỹ (Anglo - Sacxon). Hình thức này được sử dụng rộng rãi trên thế giới, là nguồn chủ yếu và quan trọng trong hệ thống pháp luật của các quốc gia trong Khối Thịnh vượng chung Anh, bao gồm Anh, hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ (ngoại trừ tiểu bang Louisiana), Canada (ngoại trừ tỉnh bang Québec) và các thuộc địa trước kia của Anh cũng như các lãnh thổ được ủy trị của Hoa Kỳ. Nghiên cứu tiền lệ pháp cho thấy, có một khái niệm tương đối gần gũi với nó là án lệ[63].

Án lệ được hiểu là đường lối giải thích và áp dụng luật pháp của các Tòa án về một điểm pháp lý, đường lối này đã được coi như một tiền lệ, khiến các thẩm phán sau đó có thể noi theo trong các trường hợp tương tự. Nói nôm na, xử theo án lệ là việc Tòa án cấp dưới vận dụng các phán quyết có từ trước của Tòa án cấp trên để đưa ra một phán quyết tương tự trong một vụ việc tương tự. Theo Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao, án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử[64]. Án lệ được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây[65]:

- Có giá trị làm rõ quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể

---

[63] Xem thêm: Nguyễn Bá Bình (Chủ biên), *Án lệ và sử dụng án lệ trong đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay*, Sách chuyên khảo, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2019.

[64] Điều 1 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/06/2019 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

[65] Điều 2 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/06/2019 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

hoặc thể hiện lẽ công bằng đối với những vấn đề chưa có điều luật quy định cụ thể.

- Có tính chuẩn mực.

- Có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Từ tiêu chí lựa chọn án lệ cho thấy, cơ sở để hình thành nên án lệ chính là những khuyết điểm của hệ thống pháp luật cũng như hoạt động xét xử của toà án. Khi có những khuyết điểm của hệ thống luật, Tòa án sẽ viện dẫn những căn cứ pháp luật được coi là hợp lý để đưa ra những phán quyết có tính đột phá và bản án này sẽ được Tòa tối cao công bố là án lệ để áp dụng chung cho các trường hợp tương tự do khiếm khuyết quy phạm hoặc chưa có dẫn chiếu quy phạm rõ ràng. Trong khi đó, tiền lệ pháp được hiểu là việc làm luật của Tòa án trong việc công nhận và áp dụng nguyên tắc mới trong quá trình xét xử dựa trên những cơ sở vụ việc đã được quyết định trước đây cho những trường hợp và vấn đề tương tự. Từ những phân tích trên cho thấy, thuật ngữ án lệ hàm chứa những nội dung cơ bản của thuật ngữ tiền lệ pháp và giữa chúng có sự khác nhau về mặt thuật ngữ nhưng lại cùng chỉ một khái niệm. Về bản chất, án lệ cũng chính là tiền lệ pháp, do cả hai đều xuất phát từ tòa án và hình thành từ quá trình xét xử. Tiền lệ pháp là thuật ngữ dùng để chỉ về một hình thành pháp luật, còn án lệ dùng để chỉ về nguồn của pháp luật, mà nguồn của pháp luật cũng chính là hình thức của pháp luật. Nói cách khác, tiền lệ pháp là một hình thức pháp luật hay quá trình làm luật của Tòa án, còn án lệ là những bản án, quyết định mà Tòa án làm căn cứ để áp dụng sau này cho những vụ việc có tình tiết tương tự. Dù không phải là hai từ đồng nghĩa nhưng thông thường, người ta gọi các bản án sau có giá trị áp dụng tương tự và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc công bố và cho xuất bản phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và tham khảo gọi là những án lệ.

Việc áp dụng án lệ ngoài ý nghĩa giải quyết một vụ án cụ thể còn thiết lập ra một tiền lệ để xử những vụ án tương tự sau này, do đó, sẽ tạo bình đẳng trong việc xét xử các vụ án giống nhau, giúp tiên lượng được kết quả của các vụ tranh chấp, tiết kiệm công sức của các Thẩm phán, Người tham gia tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng, tạo ra sự công bằng trong xã hội. Án lệ là khuôn thước mẫu mực để các thẩm phán tuân theo vì được đúc kết, chọn lọc kỹ và mang tính chuyên nghiệp. Khi ấy thẩm phán chỉ cần đối chiếu để đưa ra phán quyết, tránh chuyện mỗi người nhìn nhận, đánh giá vấn đề một kiểu. Từ đó tránh được chuyện dư luận xã hội cho rằng việc xét xử của tòa án là không bình đẳng. Đồng thời, áp dụng án lệ còn giúp các đơn vị khi đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng giao

dịch dân sự, thương mại biết phòng tránh rủi ro... Có thể khẳng định tiền lệ pháp hay án lệ có vai trò bổ khuyết quan trọng cho pháp luật thành văn của nhà nước. Cụ thể là[66]:

Thứ nhất, án lệ chứa đựng quy tắc pháp lý mới, giải pháp pháp lý mới, giải thích những điểm chưa rõ trong các quy phạm pháp luật giúp khắc phục những nhược điểm trong quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thực tế cho thấy, luật thành văn dù được xây dựng cẩn thận và kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể dự đoán được hết những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai và luôn có những khoảng trống, lỗ hổng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự. Vì vậy, án lệ góp phần bổ sung giúp cho luật thành văn gắn liền với thực tiễn.

Thứ hai, vai trò của án lệ trong hoạt động phát triển pháp luật. Án lệ là sản phẩm của hoạt động xét xử, do toà án tạo lập trong quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể, được Nhà nước thừa nhận như khuôn mẫu để giải quyết những vụ việc tương tự về sau. Việc thừa nhận và áp dụng án lệ góp phần lấp "những lỗ hổng" của pháp luật và qua đó có sự phát triển của pháp luật.

Thứ ba, án lệ góp phần bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Qua hoạt động lấp "những lỗ hổng" của pháp luật, việc áp dụng án lệ trên thực tế góp phần bảo đảm thực hiện, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Công dân sẽ không phải gánh chịu bất lợi hay lo sợ vì không có quy phạm pháp luật điều chỉnh khi tham gia vào quan hệ dân sự hợp pháp. Xây dựng án lệ còn là hoạt động nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, mà hoàn thiện hệ thống pháp luật đang là một trong những tiêu chí quan trọng cho việc hướng tới xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam. Đây là đóng góp to lớn trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền với quan điểm tất cả vì con người và hướng tới con người.

c) Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức pháp luật phổ biến của Nhà nước và do đó, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa không chỉ về mặt lý luận nhận thức mà còn phục vụ rất thiết thực cho các hoạt

---

[66] Nguyễn Minh Tuấn, "Bàn về án lệ và việc áp dụng án lệ ở Việt Nam", *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 01 (449), tháng 01/2022, http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210998, truy cập ngày 02/03/2022.

động thực tiễn pháp lý như hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động thực hiện và áp dụng pháp luật được chính xác và khoa học mà còn phục vụ việc nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, tạo kỹ năng sống và làm việc theo pháp luật của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, khi xem xét các tài liệu giảng dạy của các cơ sở đào tạo luật và trong các văn bản luật đã ban hành lại có sự không thống nhất trong việc xác định thế nào là văn bản quy phạm pháp luật[67], tác giả Nguyễn Minh Đoan đề nghị văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành và bảo đảm thực hiện theo trình tự, thủ tục nhất định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hình thức, nội dung phù hợp với thẩm quyền của cơ quan ban hành, được thực hiện nhiều lần để điều chỉnh các quan hệ xã hội vì lợi ích cộng đồng. Cách xác định văn bản quy phạm pháp luật như trên sẽ cho phép giải quyết được[68]:

- Tất cả các văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành và bảo đảm thực hiện mà trong đó có quy tắc xử sự chung, được thực hiện nhiều lần thì đều là văn bản quy phạm pháp luật, không phụ thuộc vào việc có được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật liệt kê hay không.

- Trình tự, thủ tục ban hành và bảo đảm thực hiện của một số văn bản quy phạm pháp luật có thể được luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ, chính xác, một số khác thì không. Chẳng hạn, trình tự, thủ tục ban hành Hiến pháp được quy định trong Hiến pháp; trình tự, thủ tục ban hành các văn bản có tính chất nội bộ trong một cơ quan như quy chế, quy định… do chính cơ quan đó quy định.

---

[67] Chẳng hạn:
- Theo Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Công an Nhân dân 2013, tr.116 của Trường Đại học Luật Hà Nội thì: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa đựng các quy tắc xử sự chung, do các chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức luật định, được Nhà nước bảo đảm thực hiện và được sử dụng nhiều lần trong cuộc sống".
- Theo Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr.309-310 của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội thì: "Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện các quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hoặc các cá nhân, tổ chức xã hội được Nhà nước trao quyền) ban hành theo những trình tự, thủ tục pháp lý nhất định, trong đó quy định những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung đối với tất cả các chủ thể pháp luật, được áp dụng nhiều lần trong đời sống.

[68] Nguyễn Minh Đoan, "Bàn về khái niệm "văn bản quy phạm pháp luật" trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật", *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 15(271), tháng 8/2014, tr.33-37.

- Hình thức và nội dung của văn bản quy phạm pháp luật không thể chỉ do Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mà phải phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan hoặc các cơ quan ban hành (trong trường hợp có sự phối hợp ban hành). Thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Hiến pháp, Luật về tổ chức cơ quan quy định (Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ...).

- Mục đích ban hành văn bản quy phạm pháp luật không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh quan hệ xã hội mà phải xét đến cùng là vì lợi ích cộng đồng, đó có thể là một cộng đồng xã hội nhỏ và cũng có thể là toàn xã hội.

2.2. Quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật

2.2.1. Quy phạm pháp luật

Khái niệm quy phạm pháp luật lần đầu tiên được định nghĩa chính thức tại Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 như sau: *Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong luật này ban hành và được Nhà nước đảm bảo thực hiện*[69]. Được xem là tế bào của pháp luật, khái niệm quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến việc xây dựng và sử dụng các thuật ngữ pháp lý khác như hệ thống pháp luật, ngành luật, văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng pháp luật và giải thích pháp luật… Đặc điểm nổi bật của quy phạm pháp luật *là quy tắc xử sự chung do cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành*. Bên cạnh đó, theo Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật của Trường Đại học Luật Hà Nội thì quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được mục đích nhất định. Theo Phạm Hồng Thái và Đinh Văn Mậu thì quy phạm pháp luật là quy tắc hành vi, có tính bắt buộc chung, được biểu thị bằng hình thức nhất định, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội[70]. Dù có một số điểm khác biệt nhưng các định nghĩa đều nêu bật được đặc điểm quan trọng của quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự, là chuẩn mực cư xử, là thước đo cho hành vi của con người. Tuy nhiên, khi xây dựng các thuật ngữ pháp lý

[69] Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
[70] Phạm Hồng Thái và Đinh Văn Mậu, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội, 2009, tr.355.

có liên quan đến quy phạm pháp luật, thuộc tính *quy tắc xử sự chung* của quy phạm pháp luật dường như bị bỏ quên. Do đó, nếu hiểu quy phạm pháp luật dưới góc độ là quy tắc xử sự như trên thì các bộ phận cấu thành của nó không phải chỉ được tìm thấy trong một điều, khoản của cùng một văn bản quy phạm pháp luật mà chúng có thể nằm trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành luật khác nhau. Điều đó có nghĩa là các quy phạm pháp luật một khi được hiểu dưới góc độ là quy tắc xử sự chung thì chúng có tính chất "xuyên ngành luật". Quy phạm pháp luật nêu lên cách cư xử mẫu (phải làm gì, không làm gì, được làm gì, làm như thế nào) cho chủ thể khi rơi vào hoàn cảnh, tình huống được dự liệu và nếu chủ thể không làm đúng theo cách cư xử mẫu đó sẽ bị xử lý như thế nào, hoặc nếu làm tốt theo cách cư xử đó được khen thưởng gì.

Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có vai trò quan trọng nhất trong điều chỉnh quan hệ xã hội, được nhà nước ban hành và áp dụng đối với mọi chủ thể xã hội. Quy phạm pháp luật là kết quả của hoạt động có tính mục đích của nhà làm luật (tính ý chí của quy phạm pháp luật). Ý chí này phản ánh nhu cầu quản lý, thiết lập trật tự xã hội hay loại hành vi cần được mô hình hóa bằng những khuôn mẫu và luôn chịu sự chi phối của đời sống xã hội. Hướng tiếp cận này nhấn mạnh đến trạng thái động của quy tắc xử sự được ghi nhận trong quy phạm pháp luật. Bởi lẽ, các hành vi pháp lý trong xã hội không ngừng vận động và phát triển nên nội dung quy tắc xử sự theo đó cũng phải thay đổi theo cho phù hợp. Theo quan điểm được chấp nhận khá phổ biến thì quy phạm pháp luật có cấu thành từ ba bộ phận: giả định, quy định và bảo đảm (trong biện pháp bảo đảm có khen thưởng hoặc (và) chế tài).

Giả định là phần xác định chủ thể tham gia quan hệ pháp luật và những hoàn cảnh, điều diện mà chủ thể phải làm gì khi gặp phải hoàn cảnh, điều kiện đã nêu trong phần giả định (được một quyền, phải làm một nghĩa vụ, phải tránh các xử sự bị cấm). Những tình huống, điều kiện vô cùng phong phú, đa dạng. Về hoàn cảnh có thể là sự kiện liên quan đến hành vi của con người, sự kiện trong xã hội như thiên tai, sự sinh, tử… được đặt trong không gian và thời gian xác định. Điều kiện được dự liệu trong giả định cũng rất đa dạng như độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn… Do tính đa dạng của giả định nên khi xây dựng pháp luật cần dự liệu đầy đủ nhất có thể, đồng thời tạo ra các tiêu chí mang tính định hướng, dự liệu cho những diễn tiến mới có thể xảy ra trong đời sống xã hội để tránh tạo ra những lỗ hổng pháp luật.

Quy định là một bộ phận cấu thành của quy phạm pháp luật nêu lên những cách xử sự mà các chủ thể được, không được hoặc buộc phải thực hiện khi gặp những hoàn cảnh đã nêu ở bộ phận giả định của quy phạm pháp luật. Đây là bộ phận cốt lõi của quy phạm pháp luật, phản ánh đậm nét ý chí, kỳ vọng của người ban hành pháp luật đối với cách xử sự của các chủ thể pháp luật; trật tự xã hội kỳ vọng; những biện pháp ứng phó, xử lý khi xảy ra vi phạm pháp luật… Nội dung quy định thường là cho phép thực hiện (như quy định mọi người có quyền kết hôn, quyền lao động, quyền tự do cư trú…), không được phép thực hiện (thể hiện rõ trong quy định về xử lý vi phạm hành chính và tội phạm) và hướng dẫn chủ thể thực hiện (liên quan nhiều đến cách thức, trình tự, thủ tục, chỉ dẫn để chủ thể dựa vào đó mà thực hiện cho đúng).

Chế tài là bộ phận thứ ba cấu thành nên quy phạm pháp luật, trong đó chứa đựng thái độ của nhà nước đối với các hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ mà nhà nước yêu cầu phải thực hiện hoặc có hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Về bản chất, chế tài là biện pháp cưỡng chế mang tính trừng phạt mà nhà nước áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật, thực hiện không đúng, không đầy đủ những mệnh lệnh đã được nêu trong bộ phận quy định của quy phạm pháp luật.

Việc xác định các bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật có nhiều ý nghĩa trong hoạt động nghiên cứu, học lập, xây dựng pháp luật. Khi nói tới khái niệm quy phạm pháp luật là nói tới đầy đủ các bộ phận cấu thành là giả định, quy định, chế tài. Trong thực tiễn, áp dụng đúng không phải lúc nào cũng có thể xác định ngay được các bộ phận của quy phạm pháp luật. Đồng thời, quy phạm pháp luật không đồng nhất với một điều luật. Các điều khoản trong văn bản quy phạm pháp luật chỉ thể hiện một hoặc một số bộ phận của quy phạm pháp luật. Chính vì vậy, chúng ta có thể tìm kiếm, nhận diện các bộ phận của quy phạm pháp luật tại các điều khoản cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ nhất, quy phạm pháp luật hiến pháp thường có cấu thành bởi hai bộ phận, *giả định* và *quy định* mà không nhất thiết phải có bộ phận *bảo đảm.* Do đó, khó có thể phân loại thành quy phạm pháp luật hiến pháp vì nếu xem quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung thì một quy phạm pháp luật có bộ phận giả định và quy định trong Hiến pháp nhưng lại có bộ phận đảm bảo được đặt trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành luật khác, có thể hành chính hoặc hình sự. Chẳng hạn, Hiến pháp năm 2013 tại khoản 2 Điều 45 quy định: "Công dân phải thực hiện

nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân". Nếu tìm bộ phận *bảo đảm* thì rõ ràng trong phạm vi Điều 45 của Hiến pháp 2013 không có, còn quy tắc xử sự đã là công dân thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự thì không thể thiếu bộ phận *bảo đảm*, nghĩa là nếu bị xử lý hành chính về một trong các hành vi trên mà còn vi phạm thì có thể bị khởi tố hình sự về tội trốn nghĩa vụ quân sự. Hiến pháp được xem là đạo luật gốc, có giá trị pháp lý cao nhất, nội dung của Hiến pháp dùng để điều chỉnh những vấn đề mang tính nguyên tắc, cơ bản. Vì vậy, để giữ tính ổn định của Hiến pháp, Hiến pháp không thể chứa bộ phận bảo đảm cụ thể.

Thứ hai, việc phân chia thành loại quy phạm pháp luật hành chính cũng không hợp lý vì các văn bản luật trong các lĩnh vực quản lý cụ thể như Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hoặc Luật Giao thông đường bộ thường chỉ chứa giả định và quy định, không bao gồm các biện pháp bảo đảm cho bộ phận quy định được thực hiện. Các biện pháp bảo đảm bao gồm khen thưởng nhằm động viên, hoặc chế tài nhằm để trừng trị, xử lý chủ thể thường được dẫn chiếu sang các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các ngành luật khác. Cụ thể, Chương VII Luật Tố cáo năm 2011 quy định: "Cá nhân, tổ chức nào có thành tích trong việc giải quyết tố cáo… thì được khen thưởng về vật chất hoặc tinh thần, cá nhân, tổ chức vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật". Như vậy, bộ phận bảo đảm cho việc thực hiện các cách cư xử trong các văn bản luật thuộc ngành luật hành chính được dẫn chiếu đến các nghị định xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí Bộ luật Hình sự (khi áp dụng chế tài hình sự), Bộ luật Dân sự (khi áp dụng chế tài dân sự - bồi thường thiệt hại).

Thứ ba, các điều luật ở phần chung Bộ luật Hình sự như định nghĩa tội phạm, phân loại tội phạm… không đưa ra quy tắc xử sự, không chứa đựng bất cứ bộ phận nào từ giả định, quy định và chế tài. Còn các điều luật chỉ ra hành vi nào là tội phạm cùng với hình phạt đi kèm chính là các quy tắc xử phạt, không phải quy tắc xử sự. Có quan điểm cho rằng, quy phạm pháp luật hình sự được cấu thành bởi giả định và chế tài mà không có bộ phận quy định vì nếu thể hiện bộ phận quy định sẽ dài dòng và chúng có thể được hiểu ngầm theo cách là "không được thực hiện hành vi mà Nhà nước cho là phải gánh chịu hình phạt". Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ ta thấy, giả định trong các điều luật này không phải là giả định của quy phạm pháp luật mà là giả định riêng cho bộ phận bảo đảm. Khác với giả định của quy

phạm pháp luật nêu lên *chủ thể, hoàn cảnh, tình huống* có thể xảy ra trong cuộc sống, giả định của bảo đảm nêu lên *chủ thể và hành vi mà chủ thể đã thực hiện* để trên cơ sở đó, Nhà nước khen thưởng hoặc xử lý chủ thể. Bộ phận quy định không cần phải hiểu ngầm mà quy định cùng với giả định của nó được thể hiện khá rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. Có thể cho rằng, hành vi của chúng ta không chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Hình sự mà đang chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật khác như Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình… nếu vi phạm quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đó ở mức độ đáng kể thì phải chịu chế tài trong Bộ luật Hình sự. Đó là lý do để cho rằng, tội phạm không phải là hành vi trái pháp luật hình sự mà phải hợp với pháp luật hình sự nhưng lại trái với quy định của ngành luật khác. Như vậy, đa số các điều luật trong Bộ luật Hình sự thường không phải là quy phạm pháp luật vì không nêu lên được quy tắc xử sự.

Thứ tư, nhiều quy phạm định nghĩa, các nguyên tắc pháp lý, các quy định về quốc kỳ, quốc ca trong các văn bản quy phạm pháp luật chỉ nêu nội hàm ý nghĩa các thuật ngữ pháp lý, không chứa đựng giả định, quy định hay chế tài.

2.2.2. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật theo pháp luật hiện hành là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật Văn bản quy phạm pháp luật[71]. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm[72]:

- Hiến pháp.

- Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

- Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

- Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

---

[71] Điều 2 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi 2020.
[72] Điều 4 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi 2020.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

- Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.3. Quan hệ pháp luật và thực hiện pháp luật

2.3.1. Quan hệ pháp luật

2.3.1.1. Khái niệm quan hệ pháp luật

Theo cách hiểu phổ biến, quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh, phản ánh mối liên hệ giữa con người với con người trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Quan hệ pháp luật được coi là một dạng của quan hệ xã hội nên nó mang những đặc điểm của quan hệ xã hội, là quan hệ giữa người với người được hình thành và tồn tại phụ thuộc vào những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định và có những đặc điểm sau:

Một là, quan hệ pháp luật là quan hệ có tính ý chí.

Tính ý chí trong quan hệ pháp luật là ý chí của Nhà nước được thể hiện trong các quy phạm pháp luật. Các chủ thể khi tham gia vào quan hệ

xã hội được pháp luật điều chỉnh phải xử sự theo cách thức được Nhà nước đặt ra. Có thể là ý chí đơn phương của Nhà nước trong quan hệ pháp luật hình sự, hoặc ý chí của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật trong khuôn khổ ý chí của Nhà nước thể hiện trong quy phạm pháp luật (quan hệ hợp đồng, quan hệ hôn nhân). Trong quan hệ hôn nhân, hai bên nam nữ tự do lựa chọn, tìm hiểu người bạn đời theo ý chí, theo mong muốn của mình. Nhưng khi họ muốn trở thành vợ chồng thì phải được sự đồng ý của bên kia và phù hợp với những quy định của pháp luật (thể hiện ý chí của Nhà nước) như: về giới tính, về quan hệ huyết thống, về độ tuổi, và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn theo luật định. Trong loại quan hệ này, nhà nước không trực tiếp tham gia, không phải là một bên tham gia quan hệ pháp luật, mà chỉ đặt ra những điều kiện, khi chủ thể đáp ứng những điều kiện đó thì họ chủ động tham gia và thể hiện ý chí của mình.

Hai là, quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định.

Thông thường, các quan hệ xã hội không có cơ cấu chủ thể cụ thể. chẳng hạn, không có điều kiện nào ràng buộc về độ tuổi, về giới tính, về tài sản... để kết bạn. Các chủ thể hoàn toàn tự do trong việc xác lập các quan hệ xã hội theo ý chí của họ. Nhưng trong quan hệ pháp luật, dưới sự tác động của quy phạm pháp luật, mỗi loại quan hệ pháp luật có cơ cấu chủ thể nhất định. Mỗi chủ thể trong quan hệ pháp luật khác nhau lại cần phải đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định cho loại quan hệ pháp luật đó. Quan hệ pháp luật chứa đựng nội dung là quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể. Trong quan hệ xã hội, giữa các chủ thể tham gia cũng hình thành quyền và nghĩa vụ, mặc dù không cụ thể, không rõ ràng. Các chủ thể trong quan hệ xã hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ đó như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức, điều kiện và môi trường sống của họ.

Ba là, quan hệ pháp luật được nhà nước bảo đảm thực hiện.

Đối với các quan hệ xã hội, sự hình thành, vận động của chúng chịu sự giám sát bởi dư luận xã hội dựa trên những quan niệm đạo đức, phong tục, tập quán. Chúng ta không phủ nhận "bia miệng" cũng có những giá trị nhất định trong việc kiểm soát hành vi của con người nhưng chứa đựng trong nó là sự thiếu khách quan, công bằng, thậm chí rất nghiệt ngã.

Đối với quan hệ pháp luật, do được hình thành, vận động theo quy định của pháp luật thể hiện ý chí của Nhà nước, nên các quan hệ pháp luật ngoài việc chịu sự kiểm soát của dư luận xã hội còn chịu sự kiểm soát của Nhà nước và được nhà nước bảo đảm thực hiện. Tuy nhiên, do tính chất

của các quan hệ pháp luật khác nhau, nên sự bảo đảm của Nhà nước cũng có những hình thức, biện pháp khác nhau. Có thể là sự bảo đảm về pháp lý, vật chất, tổ chức, kỹ thuật... các biện pháp tuyên truyền, giáo dục hoặc cưỡng chế khi cần thiết.

2.3.1.2. Chủ thể quan hệ pháp luật

Chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân, tổ chức đáp ứng yêu cầu, điều kiện luật định và tham gia vào các quan hệ pháp luật, trong đó, Nhà nước vừa tham gia trực tiếp là một chủ thể của quan hệ pháp luật, vừa là chủ thể gián tiếp hỗ trợ các chủ thể trong các quan hệ pháp luật về thủ tục, về biện pháp thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung thêm quy định pháp luật cho phù hợp với diễn tiến của đời sống xã hội. Để tham gia vào quan hệ pháp luật, chủ thể phải có năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

a) Năng lực pháp luật của chủ thể pháp luật: Năng lực pháp luật là khả năng mà pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức có thể được tham gia vào từng quan hệ pháp luật cụ thể, tức là khả năng đảm nhận được một vai trò nào đó trong đời sống pháp luật. Nói một người có năng lực pháp luật không hẳn có nghĩa người đó thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ năng lực pháp luật. Năng lực pháp luật giống như chiếc "mặt nạ" thời cổ, là một thứ biểu tượng mà xã hội cho phép con người tự tạo cho mình như một trạng thái vay mượn, một trạng thái hoàn toàn mang tính quy ước. Dưới cái vỏ bọc này con người được giao những quyền và nghĩa vụ, những thứ làm cho người trở thành một chủ thể pháp luật[73].

Trong lĩnh vực dân sự, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Về tính chất, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là như nhau, có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bao gồm: i) quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; ii) quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản; iii) quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó[74].

---

[73] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn Luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.87-88.

[74] Điều 16, Điều 17 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của các kỹ thuật y học đã làm nảy sinh các trường hợp sống nhân tạo: hôn mê kéo dài, cơ thể sống được ướp lạnh. Có nhiều trường hợp rất khó xác định khi mà chết lâm sàng (mọi chức năng sống ngừng hoạt động) không tương đối với chết bộ não (được xác nhận thông qua điện não đồ "phẳng")[75] và do đó cũng gây khó khăn cho việc xác định thời điểm chấm dứt năng lực pháp luật. Ngoài ra cũng còn có một số ngoại lệ khác như vắng mặt – chỉ tình trạng một cá nhân không xuất hiện trong một khoảng thời gian rất lâu mà không trở về nên không thể xác định được xem hiện tại năng lực pháp luật của người đó có còn hay không nên gây khó khăn cho việc thực hiện quyền của các chủ nợ cũng như quyền của các chủ thể có liên quan. Một trường hợp nữa là tình trạng mất tích trong trường hợp xác định chắc chắn một người là đã chết nhưng không tìm thấy xác như đắm tàu, hỏa hoạn, động đất nên không thể làm thủ tục khai tử, nên buộc tuyên bố một người là đã chết[76]. Những trường hợp này Bộ luật Dân sự Việt Nam cũng đã giải quyết khá cụ thể, chi tiết[77]. Nội dung năng lực pháp luật có những yếu tố cho phép cá thể hóa mỗi người về mặt pháp lý và trao cho người đó năng lực riêng dựa trên ba yếu tố: họ tên, nơi cư trú, hộ tịch[78].

Đối với pháp nhân, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan quy định khác. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký và chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân[79].

b) Năng lực hành vi của chủ thể pháp luật: Năng lực hành vi của chủ thể pháp luật là khả năng làm nhà nước thừa nhận cho các cá nhân, tổ chức bằng hành vi của mình xác lập (tham gia) và thực hiện các quyền và nghĩa

---

[75] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn Luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.90.
[76] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn Luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.91.
[77] Xem cụ thể từ Điều 64 đến Điều 73 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[78] Jean-Claude Ricci, *Nhập môn Luật học*, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.92-100.
[79] Điều 86 Bộ luật Dân sự năm 2015.

vụ pháp lý. Năng lực hành vi của cá nhân được xác định dựa trên độ tuổi theo quy định của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành[80] và khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Khả năng nhận thức và điều khiển hành vi đề cập đến trường hợp chủ thể pháp luật là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự[81], hạn chế năng lực hành vi dân sự[82]. Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành, giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện[83]. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện

---

[80] Chẳng hạn:
- Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân (Điều 27 Hiến pháp 2013).
- Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29 Hiến pháp 2013).
- Theo quy định của Bộ luật Lao động người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động thì được tham gia vào quan hệ pháp luật lao động.
- Tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 là: 1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác; 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

[81] Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự "*Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân phải đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đủ 18 tuổi*" (Điều 12).
Độ tuổi gọi nhập ngũ Luật Nghĩa vụ quân sự quy định như sau: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (Điều 30).

[82] Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện.

[83] Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015.

theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác[84]. Đối với trường hợp người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tức là Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ[85].

Đối với người chưa thành niên, tức là người chưa đủ mười tám tuổi thì tùy trường hợp mà người chưa thành niên có thể tự mình thực hiện hoặc buộc phải thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật. Cụ thể là: i) Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện; ii) Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi; iii) Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý[86]. Người thành niên (người từ đủ mười tám tuổi trở lên) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quyết định của Tòa án được tự mình xác lập và thực hiện quan hệ pháp luật dân sự.

c) Các loại chủ thể pháp luật: Chủ thể pháp luật bao gồm cá nhân, pháp nhân và nhà nước. Cá nhân, bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài, người không quốc tịch. Pháp nhân tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật và thỏa mãn các tiêu chí để xác định là pháp nhân[87].

---

[84] Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[85] Khoản 1 Điều 23 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[86] Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[87] Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Pháp nhân bao gồm pháp nhân thương mại[88] và pháp nhân phi thương mại[89]. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở địa phương khi tham gia quan hệ dân sự thì bình đẳng với các chủ thể khác và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật[90].

2.3.1.3. Nội dung quan hệ pháp luật

Nội dung quan hệ pháp luật là các quyền, nghĩa vụ pháp lý do pháp luật quy định hoặc do các bên tạo lập nên nhưng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Quyền chủ thể là khả năng hành động mà pháp luật bảo đảm cho cá nhân, tổ chức được tiến hành nhằm thỏa mãn quyền lợi của họ. Chủ thể thực hiện quyền của mình thông qua: i) Hành vi pháp lý trong khuôn khổ pháp luật quy định để thỏa mãn nhu cầu của mình; ii) Yêu cầu chủ thể khác thực hiện hoặc kiềm chế không thực hiện những hành vi nhất định như yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện những hành động nhất định bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình; yêu cầu chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của mình chấm dứt hành vi vi phạm…

Nghĩa vụ pháp lý là cách xử sự bắt buộc do pháp luật quy định mà một bên phải thực hiện nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền chủ thể của bên kia. Nghĩa vụ pháp lý thường được thể hiện dưới dạng: phải hành động hoặc kiềm chế không hành động, chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình…

Thông thường trong các quan hệ pháp luật mang tính chất công, quyền, nghĩa vụ pháp lý thường do pháp luật quy định. Trong các quan hệ pháp luật tư, quyền, nghĩa vụ pháp lý thường do các bên thỏa thuận tạo lập

---

[88] Điều 75 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

[89] Điều 75 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

[90] Xem cụ thể tại Điều 99 và Điều 100 Bộ luật Dân sự năm 2015.

nên. Khi nào các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận trái pháp luật và đạo đức xã hội thì áp dụng quy định pháp luật.

2.3.1.4. Khách thể quan hệ pháp luật

Khách thể quan hệ pháp luật là cái mà các bên tham gia quan hệ pháp luật hướng tới, tức là câu trả lời cho câu hỏi về mục đích tham gia quan hệ pháp luật. Khách thể quan hệ pháp luật được hợp thành bởi nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố vật chất, yếu tố phi vật chất, vừa phản ánh quan hệ lợi ích cá nhân, vừa góp phần xây dựng, bảo vệ các giá trị xã hội. Khách thể của quan hệ pháp luật rất đa dạng tùy thuộc vào từng loại quan hệ pháp luật, đó có thể là kết quả của công việc trong hợp đồng khoán việc; là quyền sở hữu tài sản trong quan hệ mua bán, tặng cho; là quyền sử dụng trong quan hệ thuê mượn tài sản; là giá trị sức lao động trong quan hệ lao động… Xác định chính xác khách thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật giúp các bên có thể dễ dàng đạt được mục đích với chi phí và rủi ro thấp nhất.

2.3.1.5. Sự kiện pháp lý

Sự kiện pháp lý là yếu tố làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật. Trong khoa học pháp lý, sự kiện pháp lý là sự kiện, hiện tượng, hành vi, sự biến… diễn ra trong đời sống xã hội có liên quan đến việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật; quyền, nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật. Do đó, một quan hệ pháp luật cụ thể sẽ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý, vì vậy, sự kiện pháp lý được coi là căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật. Sự kiện pháp lý có thể mang tính ý chí, thường là hành vi pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thực hiện bằng hành động hoặc không hành động. Sự kiện pháp lý không mang tính ý chí là các sự biến diễn ra trong đời sống xã hội, nằm ngoài khả năng dự đoán của các bên trong quan hệ pháp luật. Sự kiện pháp lý nếu căn cứ vào dấu hiệu pháp lý phân loại thành *sự biến pháp lý* hoặc *hành vi pháp lý*. Trong đó, *sự biến pháp lý* được hiểu là những hiện tượng tự nhiên xảy ra ngoài ý chí chủ quan của con người, được nhà làm luật dự kiến trong quy phạm pháp luật gắn liền với sự hình thành, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Ví dụ như lũ lụt, động đất, hạn hán…gọi chung là các thiên tai hoặc cái chết tự nhiên của con người. *Hành vi pháp lý* là hành vi của con người khi tham gia vào các quan hệ xã hội và được điều chỉnh bởi pháp luật. Quan hệ pháp luật sẽ phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt khi chủ thể thực hiện những hành vi pháp lý trong nhưng hoàn cảnh, tình huống cụ thể. Hành vi pháp lý được phân thành hành vi hành động (Ký Hợp đồng thuê

phòng trọ làm phát sinh quan hệ pháp luật dân sự) và hành vi không hành động (hành vi thấy người khác trong tình trạng bị nạn mà không cứu giúp….) Các sự kiện pháp lý thường rất đa dạng, một sự kiện pháp lý có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt nhiều quan hệ pháp luật và ngược lại, một quan hệ pháp luật có thể làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt do tác động của một sự kiện pháp lý. Ví dụ: Một cái chết của một công dân là một sự kiện pháp lý làm chấm dứt quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của người này, nhưng lại làm phát sinh quyền thừa kế tài sản của người chết đối với những người được thừa kế…

2.3.2. Thực hiện pháp luật

Xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật là hai hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau, là các yếu tố hợp thành cơ chế điều chỉnh pháp luật. Những hành vi, xử sự được tiến hành phù hợp với các yêu cầu của pháp luật đều được coi là việc chấp hành pháp luật. Đó là những hành vi, xử sự của các cá nhân, tổ chức phù hợp với các quy định của pháp luật, có ích cho xã hội, Nhà nước và cá nhân. Căn cứ vào tính chất hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý đã chia ra các hình thức thực hiện pháp luật sau: tuân thủ pháp luật, chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật, áp dụng pháp luật. Việc phân chia thực hiện pháp luật thành các hình thức nêu trên có tính tương đối vì trong hình thức này lại chứa đựng cả những yếu tố của hình thức khác.

- Tuân thủ pháp luật là việc thực hiện pháp luật mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức kiềm chế không thực hiện các hoạt động mà pháp luật ngăn cấm. Ở hình thức này chỉ đòi hỏi mỗi người tự kiềm chế mình, không thực hiện những hành vi mà pháp luật ngăn cấm. Chủ thể tuân thủ pháp luật là các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân, cán bộ, công chức và mọi công dân.

- Chấp hành pháp luật là việc thực hiện pháp luật, trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình bằng các hành động tích cực. Hình thức chấp hành pháp luật đòi hỏi phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý một cách chủ động, tích cực. Ví dụ, một thanh niên trong hạn tuổi làm nghĩa vụ quân sự đã đăng ký và thực hiện nghĩa vụ quân sự, tức là thanh niên đó đã chấp hành pháp luật.

- Sử dụng pháp luật là việc thực hiện pháp luật, trong đó các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền chủ thể của mình mà pháp luật cho phép. Ví dụ, một công dân gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tức là anh ta đã

sử dụng pháp luật. Nếu như trong hình thức thứ nhất và hình thức thứ hai thể hiện nghĩa vụ phải thực hiện các quy phạm một cách "thụ động" hay "tích cực" thì trong hình thức thứ ba này chỉ thực hiện các quyền mà pháp luật cho phép. Hình thức này khác các hình thức trên ở chỗ chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện các quyền chủ thể của mình được pháp luật quy định theo ý chí của mình, mà không buộc phải thực hiện.

- Áp dụng pháp luật. Nếu như các hình thức tuân thủ, chấp hành và sử dụng pháp luật là những hình thức thực hiện pháp luật mà mọi chủ thể pháp luật đều có thể thực hiện thì áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật chỉ do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền thực hiện. Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật luôn gắn với công quyền. Ví dụ: Tòa án nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp đất đai, tranh chấp di sản thừa kế; Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định thu hồi đất; Cảnh sát giao thông ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ thể có hành vi vượt đèn đỏ hoặc chạy quá tốc độ……

Từ nội dung và bản chất của các hình thức thực hiện pháp luật ở trên cho thấy, giữa cơ chế điều chỉnh pháp luật và thực hiện pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu như cơ chế điều chỉnh pháp luật được quan niệm là quá trình từ ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật thì thực hiện pháp luật nhấn mạnh tới việc triển khai trong thực tế quy định pháp luật của nhà nước thông qua hành vi pháp lý của chủ thể pháp luật. Thông qua hành vi thực hiện pháp luật, chúng ta có thể nhận diện được "tính thực tiễn" của pháp luật, là thước đo đánh giá mức độ phù hợp của việc mô hình hóa hành vi xử sự trong hoạt động ban hành pháp luật của nhà nước với thực tiễn xã hội. Nếu việc mô hình hóa này phù hợp thì các hành vi thực hiện pháp luật phần lớn là hành vi hợp pháp, nếu quy tắc xử sự này không phù hợp thì chủ thể pháp luật hoặc là không chấp hành, tuân thủ pháp luật hoặc là lần tránh pháp luật thậm chí làm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2.4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

2.4.1. Vi phạm pháp luật

2.4.1.1. Khái niệm vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý là những vấn đề cơ bản, quan trọng trong khoa học lý luận nhà nước và pháp luật, được hình thành và phát triển nhằm cung cấp kiến thức pháp lý cơ bản, làm nền tảng để tiếp

cận, nghiên cứu và phát triển các khoa học pháp lý chuyên ngành khác. *Vi phạm pháp luật là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các lợi ích được bảo vệ bằng ngành luật tương ứng hoặc trái với các quy định được quy định trong ngành luật ấy, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý và đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý thực hiện một cách có lỗi*[91]. Một quan niệm khác cho rằng, *vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ*[92]. Quan niệm về vi phạm pháp luật trong các giáo trình, sách tham khảo về lý luận nhà nước và pháp luật tương đối thống nhất khi xác định vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Chúng ta nhận diện vi phạm pháp luật qua các dấu hiệu:

Thứ nhất, vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật.

Một hành vi bị coi là trái pháp luật khi chủ thể thực hiện hành vi này làm trái với các quy định (khuôn mẫu xử sự được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật), xâm phạm trực tiếp hoặc đe dọa xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ. Hành vi trái pháp luật thông thường là các hành vi làm trái với quy định pháp luật, vượt quá giới hạn cho phép của pháp luật hoặc không thực hiện sự bắt buộc của pháp luật hay không đúng với cách thức mà pháp luật buộc chủ thể phải thực hiện. Đây là dấu hiệu để phân biệt hành vi trái pháp luật với hành vi trái đạo đức xã hội, trái với quy định nội bộ của tổ chức cũng như trái với phong tục tập quán. Về hình thức thể hiện, hành vi vi phạm pháp luật có thể thể hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Pháp luật chỉ có thể điều chỉnh hành động, không điều chỉnh những gì là tư tưởng, ý nghĩ, ý niệm khi chúng chưa được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động hoặc không hành động.

Thứ hai, chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật phải có năng lực trách nhiệm pháp lý.

Năng lực trách nhiệm pháp lý của chủ thể vi phạm pháp luật là khả năng phải gánh chịu các biện pháp cưỡng chế, biện pháp chế tài do thực

---

[91] Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr.537.

[92] Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2018, tr.422.

hiện hành vi trái pháp luật. Năng lực trách nhiệm pháp lý được xác định dựa trên độ tuổi theo quy định của từng lĩnh vực pháp luật[93] và phải có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Khả năng nhận thức của chủ thể phản ánh việc nhận thức hành vi của mình là đúng hay sai theo chuẩn mực pháp luật. Khả năng điều khiển hành vi thể hiện việc chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật một cách cố ý hay vô ý, nghĩa là khi thực hiện hành vi trái pháp luật chủ thể đang ở trong trạng thái nào.

Thứ ba, lỗi trong vi phạm pháp luật.

Vi phạm pháp luật luôn chứa đựng yếu tố lỗi của chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Điều này được lý giải ở chỗ, hành vi vi phạm pháp luật luôn là hành vi có ý chí của chủ thể và là yếu tố không thể thiếu trong mặt chủ quan của hành vi. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật phản ánh khả năng nhận thức, đánh giá trạng thái tâm lý của người vi phạm pháp luật cũng như khuynh hướng ý chí của người đó. Lỗi trong vi phạm pháp luật thể hiện trạng thái tâm lý của người vi phạm tại thời điểm thực hiện hành vi cũng như thái độ của người ấy đối với hậu quả của hành vi. Vì vậy, hành vi trái pháp luật bị coi là vi phạm pháp luật khi có sự biểu hiện ý chí của người thực hiện hành vi đó trong những hoàn cảnh, tình huống cụ thể thông qua cách lựa chọn phương án, cách thức thực hiện hành vi. Vì vậy, một người nào đó thực hiện hành vi trái pháp luật trong điều kiện khách quan mà người đó không có khả năng lựa chọn phương án hành vi của mình thì không thể kết luận hành vi trái pháp luật của người đó là vi phạm pháp luật. Để đánh giá đúng đắn về mặt pháp lý hành vi trái pháp luật có phải là vi phạm pháp luật hay không, cần xác định tình trạng tâm lý và khuynh hướng ý chí của người vi phạm, tức là xem xét yếu tố lỗi của người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

---

[93] Chẳng hạn:
- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định tuổi bị xử lý vi phạm hành chính như sau: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính (Điểm a, Khoản 1 Điều 5).
- Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:
i) Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.
ii) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

2.4.1.2. Cấu thành của vi phạm pháp luật

Cấu thành của vi phạm pháp luật là những yếu tố hợp thành vi phạm pháp luật hoặc những dấu hiệu đặc trưng của một vi phạm pháp luật cụ thể. Mỗi vi phạm pháp luật sẽ có cấu thành riêng, song trong cấu thành của mọi vi phạm pháp luật đều có 4 yếu tố là mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể.

(1) Mặt khách quan của hành vi vi phạm pháp luật: là những dấu hiệu biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của hành vi vi phạm pháp luật. Nó bao gồm các yếu tố:

- Hành vi trái pháp luật hay còn gọi là hành vi nguy hiểm cho xã hội: là hành vi trái với các yêu cầu của pháp luật, nó gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại hay những hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

- Hậu quả nguy hiểm cho xã hội: là những thiệt hại về người và của hoặc những thiệt hại phi vật chất khác do hành vi trái pháp luật gây ra.

- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, giữa chúng phải có mối quan hệ nội tại và tất yếu với nhau. Hành vi đã chứa đựng mầm mống gây ra hậu quả hoặc là nguyên nhân trực tiếp của hậu quả nên nó phải xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian; còn hậu quả phải là kết quả tất yếu của chính hành vi đó mà không phải là của một nguyên nhân khác.

Khi xét mặt khách quan của hành vi vi phạm pháp luật còn chú ý đến: Thời gian vi phạm pháp luật là giờ, ngày, tháng, năm xảy ra vi phạm pháp luật; Địa điểm vi phạm pháp luật là nơi xảy ra vi phạm pháp luật; Phương tiện vi phạm pháp luật là công cụ mà chủ thể sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

(2) Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật: là trạng thái tâm lý bên trong của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật, bao gồm các yếu tố: lỗi, động cơ, mục đích vi phạm pháp luật.

- Lỗi là trạng thái tâm lý hay thái độ của chủ thể đối với hành vi và hậu quả do hành vi trái pháp luật gây ra cho xã hội, được thể hiện dưới hai hình thức: cố ý hoặc vô ý. Lỗi cố ý gồm hai loại: cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp.

Cố ý trực tiếp là lỗi của một chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra.

Cố ý gián tiếp là lỗi của một chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, thấy trước được hậu

quả của hành vi đó, tuy không mong muốn song có ý thức để mặc cho hậu quả đó xảy ra.

Lỗi vô ý bao gồm hai loại: vô ý vì cẩu thả và vô ý vì quá tự tin.

Vô ý vì cẩu thả là lỗi của chủ thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng do cẩu thả nên không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả đó, mặc dù có thể thấy trước và phải thấy trước hậu quả này.

Vô ý vì quá tự tin là lỗi của một chủ thể tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội song tin chắc rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được nên mới thực hiện và có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

- Động cơ vi phạm pháp luật: là động lực tâm lý bên trong thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Mục đích vi phạm pháp luật: là cái đích trong tâm lý hay kết quả cuối cùng mà chủ thể mong muốn đạt được khi thực hiện hành vi trái pháp luật.

(3) Chủ thể của vi phạm pháp luật là cá nhân, tổ chức, có năng lực trách nhiệm pháp lý và đã thực hiện hành vi trái pháp luật, có lỗi.

(4) Khách thể của vi phạm pháp luật là quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

2.4.1.3. Phân loại vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là hiện tượng lịch sử, gắn liền với hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, rất đa dạng và phức tạp; do đó, việc phân loại vi phạm pháp luật cũng có nhiều cách. Căn cứ vào khách thể tác động, xâm phạm của vi phạm pháp luật có thể chia vi phạm pháp luật tương ứng với quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ như vi phạm pháp luật môi trường, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, vi phạm pháp luật về lao động, hôn nhân gia đình…

Cách phân loại vi phạm pháp luật phổ biến trong khoa học pháp lý là chia vi phạm pháp luật thành bốn loại là vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự, vi phạm pháp luật kỷ luật dựa trên các yếu tố khách thể, hậu quả, phương pháp, cách thức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật[94].

a) Vi phạm pháp luật hình sự còn được gọi là tội phạm

Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại

[94] Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2018, tr.427.

thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự[95]. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây[96]:

- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù.

- Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù.

- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

b) Vi phạm pháp luật hành chính

Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. So với tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính có tính nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm. Điều này được lý giải ở khía cạnh tầm quan trọng của khách thể bị xâm phạm thấp hơn so với tội phạm và tính chất, mức độ thiệt hại cho xã hội do vi phạm hành chính gây ra cũng thấp hơn so với tội phạm.

c) Vi phạm pháp luật dân sự

Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự thực hiện, xâm hại tới các quan hệ nhân thân gắn với tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản.

---

[95] Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015.
[96] Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

d) Vi phạm kỷ luật

Vi phạm kỷ luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại tới các quan hệ xã hội trong nội bộ cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước cũng như trong phạm vi của các tổ chức không gắn với hoạt động của nhà nước. Đối với vi phạm kỷ luật nhà nước chỉ được áp dụng đối với cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước đó.

2.4.2. Trách nhiệm pháp lý

2.4.2.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý là khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý, được hiểu là bổn phận của một chủ thể nào đó trước mệnh lệnh, quy định hoặc quyền lợi của chủ thể khác như công việc mà chủ thể phải thực hiện theo quy định của pháp luật, theo mệnh lệnh của cơ quan, tổ chức hay cá nhân; nghĩa vụ pháp lý về tài sản mà bắt buộc chủ thể phải thực hiện; là sự bắt buộc phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi do pháp luật quy định và đã được cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền quyết định. Dưới góc nhìn tiêu cực, trách nhiệm pháp lý là sự đánh giá phủ nhận của nhà nước và xã hội đối với những hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu các biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền thực hiện. Ở khía cạnh tích cực, trách nhiệm pháp lý thể hiện sự "có trách nhiệm" của chủ thể pháp luật đối với các nghĩa vụ, bổn phận được giao phó.

Nghiên cứu trách nhiệm pháp lý có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với công tác lập pháp mà còn đối với hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật và hiệu quả của cơ chế điều chỉnh pháp luật. Đối với hoạt động lập pháp, thông qua trách nhiệm pháp lý nhà làm lập pháp có thể xác định tính chất, tầm quan trọng của khách thể cần bảo vệ để quy định trách nhiệm pháp lý phù hợp. Đối với hoạt động tổ chức thực hiện pháp luật và hiệu quả của cơ chế điều chỉnh pháp luật, trách nhiệm pháp lý giúp cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn các quy định pháp luật để tránh phải gánh chịu chế tài do nhà nước áp dụng, từ đó giúp giảm thiểu những hậu quả tiêu cực cho xã hội do các hành vi vi phạm pháp luật thực hiện. Bản chất của trách nhiệm pháp lý được thể hiện trên các khía cạnh:

- Trách nhiệm pháp lý luôn gắn liền với vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của vi phạm pháp luật mà cơ quan nhà nước có thể áp dụng trách nhiệm pháp lý tương ứng. Cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền không thể áp dụng trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm đạo đức, tín điều tôn giáo, phong tục tập quán, quy chế nội bộ của tổ chức.

- Trách nhiệm pháp lý thể hiện thái độ, phản ứng của nhà nước và xã hội với chủ thể, tính chất mức độ, đối tượng tác động của hành vi vi phạm pháp luật. Tính chất, tầm quan trọng của khách thể, đối tượng tác động của hành vi vi phạm pháp luật càng quan trọng thì thái độ, phản ứng của nhà nước và xã hội càng lớn, nên trách nhiệm pháp lý theo đó cũng nặng hơn. Trong bối cảnh thông tin và mạng xã hội, sự phản ứng của xã hội có nhiều khả năng dẫn dắt thái độ, phản ứng và cả cách ứng xử của nhà nước trước các vi phạm pháp luật. Do đó, khi truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật cần đánh giá một cách khách quan dư luận xã hội để tránh việc áp dụng trách nhiệm pháp lý chỉ để làm hài lòng dư luận xã hội mà không dựa vào các cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm pháp luật.

- Hậu quả của trách nhiệm pháp lý luôn mang tính bất lợi đối với chủ thể thực hiện vi phạm pháp luật về quyền, tự do, tài sản, tinh thần, thậm chí là cả tính mạng. Do vậy, trách nhiệm pháp lý là loại nghĩa vụ pháp lý đặc biệt, phát sinh khi có vi phạm pháp luật và chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý buộc phải thực hiện những xử sự nhất định trước một chủ thể khác như nhà nước, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích bị xâm phạm.

- Trách nhiệm pháp lý luôn được nhà nước bảo đảm thực hiện. Sự bảo đảm này vừa để bảo vệ trật tự pháp luật, vừa để bảo vệ trật tự xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong xã hội, đồng thời làm cho hiệu quả và ưu thế của pháp luật so với các quy phạm xã hội khác được phát huy.

2.4.2.2. Phân loại trách nhiệm pháp lý

Cách phân loại trách nhiệm pháp lý thường được xác định và phân loại dựa trên vi phạm pháp luật. Do đó, tương ứng với từng vi phạm pháp luật sẽ có các loại trách nhiệm pháp lý tương ứng.

a) Trách nhiệm pháp lý hình sự

Đây là loại trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc nhất của nhà nước áp dụng đối với chủ thể thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, chủ thể thực hiện hành vi phạm tội bị áp dụng hình phạt - là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó[97] như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình[98]. Ngoài hình phạt chính, người thực hiện hành vi phạm

[97] Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 2015.
[98] Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Hình sự năm 2015.

tội có thể phải gánh chịu các hình phạt bổ sung[99]. Đối với pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội thì có thể áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân thương mại cũng có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn; phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính[100].

Trách nhiệm pháp lý hành chính được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm pháp luật hành chính. Người vi phạm hành chính có thể bị phạt cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); trục xuất. Trong các biện pháp xử phạt hành chính này thì cảnh cáo; phạt tiền chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); trục xuất có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính[101]. Ngoài ra, người vi phạm hành chính có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả[102].

---

[99] Khoản 2 Điều 32 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định các hình phạt bổ sung bao gồm: a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; b) Cấm cư trú; c) Quản chế; d) Tước một số quyền công dân; đ) Tịch thu tài sản; e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính.

[100] Điều 33 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[101] Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

[102] Theo quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện; đ) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; i) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; k) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

b) Trách nhiệm pháp lý dân sự

Trách nhiệm pháp lý dân sự áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật dân sự, nghĩa là xâm phạm đến quyền tài sản và quyền nhân thân của tổ chức, cá nhân trong xã hội. Các biện pháp trách nhiệm pháp lý dân sự áp dụng đối với chủ thể vi phạm có thể là buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự, buộc bồi thường thiệt hại… Trách nhiệm pháp lý dân sự có thể áp dụng kèm theo các loại trách nhiệm pháp lý hình sự, trách nhiệm pháp lý hành chính, trách nhiệm kỷ luật nếu xâm phạm đến quyền dân sự của tổ chức, cá nhân trong xã hội.

c) Trách nhiệm kỷ luật

Trách nhiệm kỷ luật nhà nước áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trật tự kỷ luật nhà nước và có thể bị áp dụng các biện pháp chế hành như cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc… Trách nhiệm pháp lý kỷ luật có thể áp dụng đi kèm với trách nhiệm pháp lý khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp năm 2013.
2. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
3. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
4. Bộ luật Dân sự năm 2015.
5. Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012
6. *Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật*, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2018.
7. Nguyễn Minh Đoan (2009), *Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội*, sách chuyên khảo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
8. Đào Trí Úc (1999), *Những vấn đề cơ bản về pháp luật*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
9. Nguyễn Đình Đặng Lục (2005), *Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách*, sách chuyên khảo, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
10. Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật (1995), *Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật*, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nộ.
11. Đức Vượng (1993), *Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật thể hiện trong bộ "Hồ Chí Minh toàn tập"*, in trong "Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật", Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Hà Nội.

12. Nguyễn Minh Đoan, “Bàn về khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật” trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 15(271), tháng 8/2014.
13. Nguyễn Xuân Tùng, “Luật tự nhiên trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam”, *Tạp chí Luật học* số 3/2010.
14. Phan Nhật Thanh, “Bàn về nguồn gốc của pháp luật”, *Tạp chí Khoa học Pháp lý* số 03(97)/2016.

CHƯƠNG 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT HÌNH SỰ

3.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh

3.1.1. Khái niệm

Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm hệ thống các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội nào là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

Các quy phạm pháp luật hình sự được chia làm hai loại: phần chung quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật hình sự, những vấn đề chung về tội phạm và hình phạt. Phần các tội phạm: quy định những dấu hiệu pháp lý của tội phạm cụ thể, loại hình phạt và mức hình phạt có thể áp dụng đối với các tội phạm.

3.1.2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật của ngành luật đó điều chỉnh. Các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật hình sự tác động tới là đối tượng điều chỉnh của luật hình sự. Luật hình sự chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội khi có tội phạm xảy ra - đó cũng chính là các quan hệ pháp luật hình sự.

Thời điểm bắt đầu xuất hiện quan hệ pháp luật hình sự là thời điểm người phạm tội bắt đầu thực hiện tội phạm và quan hệ pháp luật này chấm dứt khi người phạm tội được xóa án tích. Trong cả quá trình này xuất hiện đồng thời quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, quan hệ pháp luật dân sự. Tuy nhiên, quan hệ pháp luật tố tụng hình sự, đa số trường hợp bắt đầu xuất hiện khi có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can.

Trong quan hệ pháp luật hình sự luôn có hai chủ thể là Nhà nước và người phạm tội với những vị trí pháp lý khác nhau. Trong đó, Nhà nước có quyền truy tố, xét xử người phạm tội, buộc họ phải chịu những biện pháp trách nhiệm hình sự nhất định để bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích của toàn xã hội. Nhà nước thực hiện quyền này bằng cách thể hiện ý chí của mình trong Bộ luật hình sự. Mặt khác, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội. Ngược lại, người phạm tội, có trách nhiệm chấp hành các biện pháp cưỡng chế mà Nhà nước áp

dụng đối với mình; bên cạnh đó, người phạm tội cũng có quyền yêu cầu Nhà nước đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm mà luật hình sự quy định.

3.1.3. Phương pháp điều chỉnh

Xuất phát từ chức năng điều chỉnh và địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hình sự, luật hình sự sử dụng phương pháp quyền uy - phương pháp sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa Nhà nước và người phạm tội. Nhà nước áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người phạm tội không bị cản trở hay phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Người phạm tội phải phục tùng những biện pháp mà Nhà nước đã áp dụng với họ. Trách nhiệm của người phạm tội về tội phạm mà họ đã gây ra là trách nhiệm đối với Nhà nước chứ không phải trách nhiệm đối với người bị hại hay trách nhiệm đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tất nhiên, bên cạnh buộc người phạm tội phải chịu hình phạt, Nhà nước cũng có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.

3.2. Tội phạm

3.2.1. Khái niệm tội phạm

Xuất phát từ những quan điểm khác nhau về nguồn gốc và bản chất giai cấp của tội phạm mà mỗi Nhà nước có cách thức quy định không giống nhau xung quanh vấn đề khái niệm tội phạm. Ở Việt Nam hiện nay, khái niệm tội phạm được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể: *"Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự".*

So với Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã có một số điều chỉnh về mặt nội dung và kỹ thuật lập pháp. Cụ thể:

Khái niệm tội phạm lần đầu tiên đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội;

Thể chế hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân với việc thay cụm từ: *"xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân"* bằng cụm từ: "*xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân"*;

Khẳng định tội phạm và hình phạt chỉ được quy định trong Bộ luật Hình sự, ngoài Bộ luật Hình sự không có một đạo luật nào khác quy định về tội phạm và hình phạt bằng việc bổ sung cụm từ: *"mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự"*.

Từ định nghĩa này, có thể khái quát như sau: *Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật hình sự, có lỗi và phải bị xử lý về hình sự.*

Việc quy định khái niệm tội phạm trong luật hình sự có một vai trò hết sức quan trọng. Một mặt, nó thể hiện tập trung bản chất giai cấp, các đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý của luật hình sự mỗi quốc gia. Mặt khác, nó là cơ sở khoa học thống nhất cho việc xác định các loại tội phạm cụ thể và tạo cơ sở pháp lý cho việc nhận thức và áp dụng đúng đắn những điều luật quy định về từng tội phạm cụ thể trong thực tiễn phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Từ khái niệm tội phạm nói trên, có thể rút ra một số nội dung sau:

- Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội;

- Tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự;

- Tội phạm do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện;

- Tội phạm được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý (lỗi);

- Tội phạm xâm phạm vào những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

3.2.2. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm

Theo luật hình sự Việt Nam hiện hành, dựa trên khái niệm về tội phạm, hành vi bị xem là tội phạm phải có đủ bốn dấu hiệu: tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội; tội phạm là hành vi có lỗi; tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự; tội phạm phải bị xử lý về hình sự. Những dấu hiệu này đồng thời cũng là những thuộc tính của tội phạm để phân biệt tội phạm với hành vi khác không phải là tội phạm.

- Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội

Đây là dấu hiệu cơ bản quan trọng, quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm, bởi nó là thuộc tính và là nội dung của tội phạm. Một hành vi sở dĩ bị quy định là tội phạm vì bản thân nó có "tính nguy hiểm". Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm về khách quan có nghĩa là gây ra hoặc đe dọa gây ra những thiệt hại cho các quan hệ xã hội. Đây là các quan hệ xã hội gắn liền với lợi ích của Nhà nước, của công dân và toàn xã hội và khi bị xâm hại, có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các quan hệ xã hội. Những quan hệ xã hội đó được quy định rất cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành. Theo nghĩa đầy đủ, tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm còn bao hàm cả yếu tố chủ quan tức là lỗi. Tuy nhiên, để nhấn mạnh sự thừa nhận lỗi là một nguyên tắc cơ bản, luật hình sự nước ta từ trước đến nay vẫn luôn xem lỗi là một dấu hiệu độc lập của tội phạm.

Bất kỳ một hành vi vi phạm các chuẩn mực chung của xã hội nào cũng có tính nguy hiểm, có nghĩa là có khả năng gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, so với các hành vi vi phạm khác, tội phạm có tính nguy hiểm "đáng kể" hơn cả. Ví dụ, hành vi chửi mắng ông bà, cha mẹ bị xem là hành vi vi phạm đạo đức. Hành vi này về bản chất cũng có tính nguy hiểm nhất định cho xã hội vì nó đã xâm phạm đến quan hệ tình cảm giữa những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, hành vi này chưa phải là tội phạm vì mức độ nguy hiểm vẫn còn hạn chế, chưa "đáng kể". Trong trường hợp hành vi chửi mắng này diễn ra một cách liên tục, kèm theo những hành vi đối xử tàn ác về vật chất, tinh thần đối với ông bà, cha mẹ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì hành vi đó bị coi là tội phạm. Bởi vì, trong trường hợp đó, tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi đã "đáng kể".

Khoản 4 Điều 8 Bộ luật Hình sự đã quy định: *"Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng có tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác".* Như vậy, hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm phải có tính chất nguy hiểm cho xã hội "đáng kể". Để xác định sự nguy hiểm "đáng kể" phải căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cụ thể là dựa vào các căn cứ sau: Căn cứ vào tầm quan trọng của các quan hệ xã hội bị xâm phạm; căn cứ vào tính chất nguy hiểm của hành vi khách quan; căn cứ vào mức độ thiệt hại cho quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ; căn cứ vào tính chất, mức độ lỗi của người thực hiện hành vi; căn cứ vào động cơ,

mục đích phạm tội; căn cứ vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nơi và lúc xảy ra tội phạm và yêu cầu đấu tranh chống tội phạm; căn cứ vào đặc điểm nhân thân của người phạm tội; căn cứ vào các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

- Tội phạm là hành vi có lỗi

Luật hình sự Việt Nam không chấp nhận hình thức quy tội khách quan, tức là không chấp nhận quy tội đối với một người mà chỉ căn cứ vào hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ chứ không xem xét hành vi đó có lỗi hay không. Hay nói cách khác, tội phạm phải là hành vi tổng hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan. Về mặt khách quan, tội phạm là hành vi gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho các quan hệ xã hội. Về mặt chủ quan, hành vi phạm tội đó phải được kiểm soát bởi ý thức và ý chí của người thực hiện nó. Có nghĩa là, một hành vi bị coi là tội phạm khi về mặt khách quan đã gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và về chủ quan là có lỗi. Lỗi hiểu theo nghĩa thông thường là chỗ sai sót do không thực hiện đúng quy tắc hoặc điều sai sót không nên, không phải trong cách cư xử, trong hành động.

Theo quan điểm thống nhất của lý luận luật hình sự, lỗi là thái độ chủ quan của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và đối với hậu quả của hành vi đó thể hiện dưới dạng cố ý hoặc vô ý.

Trách nhiệm hình sự phải là hệ quả tất yếu của quá trình tương tác đó. Nói cách khác, người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ có thể phải chịu hình phạt khi hành vi đó có tính có lỗi.

Một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là có lỗi khi người đó phải có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Năng lực trách nhiệm hình sự, theo quan điểm của pháp luật hình sự nói chung được hiểu là khả năng và điều kiện của một người phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm mà họ thực hiện.

Trong Bộ luật Hình sự không có điều luật nào quy định thế nào là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự lại có quy định về *"tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự"*. Từ đó có thể cho phép ta hiểu được "người có năng lực trách nhiệm hình sự" là người mà tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội họ không ở trong "tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự".

Cơ sở để quy định tội phạm là hành vi do người có năng lực trách nhiệm thực hiện:

- Cơ sở về mặt xã hội: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà có năng lực trách nhiệm hình sự thì hành vi đó nếu có lỗi, việc áp dụng hình phạt đối với họ sau này mới có hiệu quả; nghĩa là có thể trừng trị và giáo dục họ trở thành công dân có ích cho xã hội. Nếu họ không có năng lực trách nhiệm hình sự thì áp dụng hình phạt đối với họ không có hiệu quả. Chẳng hạn: Người bị bệnh tâm thần, hoặc bị bệnh khác không thể điều khiển hành vi của mình, khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà hành vi đó được quy định trong Bộ luật Hình sự. Nếu ta áp dụng hình phạt đối với họ thì hình phạt sẽ không có tác dụng giáo dục, cải tạo họ. Không phù hợp với mục đích của mình phạt.

- Về mặt y học: Căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, vào sự phát triển về mặt sinh học của con người mà luật hình sự Việt Nam quy định như thế nào là người có năng lực trách nhiệm hình sự. Một người có điều kiện và khả năng nhất định để gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi về hành vi phạm tội của mình thì người đó phải có những đặc điểm về sinh học nhất định, chứ không phải ai cũng có khả năng đó. Việc quy định về người có năng lực trách nhiệm hình sự ở mỗi nước là khác nhau, tuỳ theo tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm của mỗi nước và tuỳ vào sự phát triển về sinh học của con người ở mỗi quốc gia.

- Cơ sở pháp lý: Người có năng lực trách nhiệm hình sự phải hội đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, người đó phải đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): *"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này".*

Thứ hai, người đó phải không thuộc trường hợp không có năng lực trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): *"Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng*

nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự".

- Tội phạm là hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự

Theo luật hình sự Việt Nam, hành vi nguy hiểm cho xã hội chỉ bị coi là tội phạm khi nó được quy định trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự. Bộ luật Hình sự nước ta thể hiện rất rõ điều này khi khẳng định tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự... (Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)), *"Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự"* (Điều 2 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)).

Tội phạm là hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự theo cách hiểu của luật hình sự Việt Nam hiện hành là hành vi phạm tội trái với quy định của Bộ luật Hình sự. Nghĩa là khi Bộ luật Hình sự quy định một hành vi nào đó bị cấm thì người phạm tội thực hiện hành vi đó. Ngược lại, khi Bộ luật Hình sự quy định hành vi đó phải được làm thì người phạm tội không làm hoặc làm không hết trách nhiệm và khả năng của mình. Ví dụ: Điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định trách nhiệm cứu giúp người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy, một người chứng kiến người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà không có hành vi cứu giúp khi có khả năng và điều kiện cứu giúp bị xem là trái Bộ luật Hình sự.

Giữa hai dấu hiệu tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội và tội phạm là hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự có mối quan hệ chặt chẽ nhau. Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là thuộc tính khách quan, biểu hiện nội dung, bản chất chính trị, xã hội của tội phạm. Dấu hiệu này quyết định một hành vi có được quy định trong Bộ luật Hình sự và bị coi là tội phạm hay không.

- Tội phạm phải bị xử lý hình sự

Đây là dấu hiệu mang tính hệ quả, đó chính là hậu quả pháp lý bất lợi hoặc nguy cơ sẽ phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi của người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội vì đã thực hiện những hành vi đi ngược lại với quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân được quy định trong Bộ luật Hình sự và bị coi là tội phạm. Chỉ có hành

vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.

Các biện pháp xử lý hình sự được áp dụng đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:

+ Hình phạt với tư cách là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật Hình sự, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó.

+ Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): *"1. Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm: a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; c) Bắt buộc chữa bệnh. 2. Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm: a) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; b) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; c) Khôi phục lại tình trạng ban đầu; d) Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra".*

+ Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

+ Án tích với nội dung là đặc điểm nhân thân xấu của người bị kết án được ghi và lưu giữ trong lý lịch tư pháp trong một khoảng thời gian nhất định.

Bốn dấu hiệu của tội phạm nêu trên quan hệ chặt chẽ với nhau trong đó tính nguy hiểm cho xã hội, tính có lỗi là những dấu hiệu biểu hiện mặt nội dung, còn tính trái pháp luật hình sự, tính phải chịu hình phạt là những dấu hiệu biểu hiện mặt hình thức của tội phạm.

3.2.3. Phân loại tội phạm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự tội phạm được phân thành 4 loại, đó là: tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự

quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Đồng thời, việc phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể: *"Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại Khoản 1 Điều này và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này".*

Ngoài ra, dưới góc độ Khoa học pháp lý, việc phân loại tội phạm còn dựa trên một số tiêu chí khác như sau:

Căn cứ vào hình thức lỗi (tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý hoặc tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý).

Căn cứ vào số lượng người tham gia (tội phạm được thực hiện dưới hình thức đồng phạm hoặc tội phạm do một người thực hiện).

Căn cứ vào giai đoạn hoàn thành (tội phạm hoàn thành hoặc tội phạm chưa hoàn thành).

Căn cứ và đặc điểm cấu trúc của cấu thành tội phạm (tội phạm có cấu thành hình thức hoặc tội phạm có cấu thành vật chất).

3.2.4. Cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Cấu thành tội phạm là cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự và căn cứ pháp lý để định tội danh. Các yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm:

- Khách thể của tội phạm

+ Khái niệm

Theo quy định của luật hình sự Việt Nam, những quan hệ xã hội được coi là khách thể bảo vệ của luật hình sự là những quan hệ xã hội được xác

định trong Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) bao gồm các quan hệ xã hội như: *"Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa".*

Một hành vi được coi là tội phạm bao giờ cũng xâm phạm vào một hoặc nhiều khách thể bảo vệ của luật hình sự. Sự xâm phạm này được thể hiện ở hành vi gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại trong một chừng mực nhất định cho quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Ngược lại, nếu một hành vi nguy hiểm không xâm phạm vào quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ; hoặc có hành vi xâm phạm vào quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, nhưng mức độ thiệt hại không đáng kể thì không được coi là có tội phạm xảy ra.

Mức độ thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại tuỳ thuộc vào tính chất, tầm quan trọng của quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Có những quan hệ xã hội được bảo vệ nhưng sự xâm hại phải được thể hiện bằng hậu quả nhất định. Nếu chưa gây thiệt hại nhất định cho quan hệ xã hội thì chưa cấu thành tội phạm. Ngược lại, có những quan hệ xã hội có tầm quan trọng cao, cần phải được bảo vệ tuyệt đối an toàn; cho nên chỉ cần có hành vi đe doạ gây thiệt hại cho quan hệ xã hội đó đã có thể bị coi là tội phạm và phải bị xử lý bằng hình phạt nghiêm khắc.

Từ những lập luận nêu trên, khách thể của tội phạm được xác định như sau: *Khách thể của tội phạm là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ bị xâm phạm bằng cách gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại trong một chừng mực nhất định. Không có sự xâm hại đến quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ thì không có tội phạm.*

+ Những dấu hiệu trong khách thể của tội phạm:

* Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

* Những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ bị xâm phạm.

+ Các loại khách thể của tội phạm:

* Khách thể chung của tội phạm

Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp tất cả các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại và được luật hình sự bảo vệ.

* Khách thể loại của tội phạm

Khách thể loại của tội phạm là nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất được một nhóm các quy phạm pháp luật hình sự bảo vệ và bị một nhóm tội phạm xâm hại.

* Khách thể trực tiếp của tội phạm

Khách thể trực tiếp của tội phạm là một hoặc một số quan hệ xã hội cụ thể bị hành vi phạm tội cụ thể xâm hại. Thông qua việc gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại (xâm hại) đối với khách thể trực tiếp mà tội phạm đã gây phương hại đến khách thể chung và khách thể loại của tội phạm.

+ Đối tượng tác động của tội phạm:

Đối tượng tác động của tội phạm là những phần trong khách thể của tội phạm mà khi tác động đến nó, người phạm tội gây nên thiệt hại hoặc đe dọa gây nên thiệt hại cho quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.

* Các dạng đối tượng tác động

Con người

Con người là đối tượng tác động của tội phạm. Con người vừa là thực thể tự nhiên, vừa là thực thể xã hội có thể là chủ thể của nhiều quan hệ xã hội khác nhau. Con người là đối tượng tác động của hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm (quyền nhân thân).

Ngoài ra, con người còn là chủ thể của các quan hệ xã hội khác, cho nên hành vi làm biến đổi trạng thái bình thường của con người cũng nhằm gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội nhất định.

Các đối tượng vật chất

Các đối tượng vật chất với ý nghĩa là khách thể của quan hệ xã hội có thể là đối tượng tác động của tội phạm (loại đối tượng này trước đây gọi là vật thể của tội phạm) như tài sản, phương tiện có chủ sở hữu hợp pháp…

Trong những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ, có những quan hệ xã hội bị tội phạm gây thiệt hại qua việc làm biến đổi tình trạng bình thường của những đối tượng vật chất như quan hệ sở hữu… Tất cả những hành vi làm biến đổi tình trạng bình thường của tài sản một cách trái pháp luật đều là những hành vi gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu.

Sự tác động vào các đối tượng vật chất này thường được thể hiện dưới dạng: Chiếm đoạt: như trong tội trộm cắp tài sản (Điều 173 Bộ luật Hình sự), tội tham ô tài sản (Điều 353 Bộ luật Hình sự); hành vi chiếm giữ, hành vi sử dụng như tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176 Bộ luật Hình sự), tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 177 Bộ luật Hình sự); hành vi làm hư hỏng như trong tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 Bộ luật Hình sự)…

Hoạt động bình thường của các chủ thể

Hoạt động bình thường của chủ thể được coi là đối tượng của tội phạm như: Hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội trên các lĩnh vực an ninh quốc gia, quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội. Sự tác động vào các hoạt động này dẫn đến hoạt động không bình thường, không đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, gây thiệt cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Dạng biến đổi tình trạng của đối tượng tác động loại này là sự cản trở hoạt động bình thường của chủ thể. Thể hiện dưới các hình thức: Chủ thể làm biến đổi xử sự của người khác. Ví dụ: Tội đưa hối lộ (Điều 364 Bộ luật Hình sự) là hành vi nhằm làm biến dạng xử sự của người có chức vụ, quyền hạn.

Cần phân biệt khách thể của tội phạm với đối tượng tác động của tội phạm. Ví vụ: A lấy trộm của B 100 triệu đồng thì khách thể mà hành vi của A xâm hại tới là quan hệ sở hữu còn 100 triệu đồng là đối tượng tác động.

- Mặt khách quan của tội phạm

Nghiên cứu luật hình sự Việt Nam hiện hành, khoa học luật hình sự nêu ra các biểu hiện bên ngoài của tội phạm tạo thành mặt khách quan của tội phạm bao gồm: hành vi nguy hiểm cho xã hội; hậu quả nguy hiểm cho xã hội; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả; các điều kiện bên ngoài khác của tội phạm (công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm phạm tội).

+ Dấu hiệu hành vi khách quan

Lý luận luật hình sự Việt Nam hiện hành xem hành vi khách quan của tội phạm là sự thống nhất giữa các yếu tố khách quan và chủ quan (nghĩa rộng) hay là những biểu hiện của con người ra thế giới khách quan qua những hình thức cụ thể nhằm đạt những mục đích đã định trước (nghĩa hẹp).

Hành vi khách quan của tội phạm là yếu tố quan trọng nhất của mặt khách quan của tội phạm, không có hành vi thì tất cả những yếu tố khác như hậu quả, phương tiện, công cụ phương pháp phạm tội không có ý nghĩa gì cả. Ngoài ra, những biểu hiện của mặt chủ quan như lỗi, mục đích, động cơ phạm tội cũng luôn gắn liền với hành vi khách quan cụ thể. Những biểu hiện của con người ra ngoài thế giới khách quan về thực tế nó được ý thức kiểm

soát và ý chí điều khiển. Chính vì thế, chỉ khi có hành vi nguy hiểm được thực hiện thì vấn đề lỗi mới được đặt ra. Tuy nhiên, một hành vi có thể có lỗi hoặc không có lỗi. Biểu hiện ra bên ngoài của con người sẽ không được xem là hành vi khách quan (với tư cách là một biểu hiện của mặt khách quan) nếu nó không được ý thức kiểm soát hoặc không phải là hoạt động ý chí. Ví dụ, phản xạ không điều kiện, phản ứng trong tình trạng xúc động quá mạnh, những biểu hiện trong tình trạng bộ não mất khả năng nhận thức, điều khiển.

* Hành vi khách quan của tội phạm có 3 đặc điểm sau:

♦ Hành vi khách quan của tội phạm phải có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội. Đây là đặc điểm cơ bản của dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm. Nó giúp phân biệt giữa hành vi phạm tội với các hành vi khác.

♦ Hành vi khách quan của tội phạm là hoạt động có ý thức và ý chí. Hành vi được thực hiện chỉ được coi là hành vi khách quan của tội phạm khi nó được biểu hiện trong sự thống nhất với ý thức vô ý chí. Không có sự kiểm soát của ý thức và ý chí thì hành vi không được coi là hành vi khách quan của tội phạm.

♦ Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi trái pháp luật hình sự. Hành vi khách quan của bất cứ tội phạm nào cũng đều được quy định trong luật hình sự. Do vậy, đã gọi là hành vi phạm tội thì bắt buộc hành vi đó phải trái pháp luật hình sự, nghĩa là hành vi đó được luật hình sự quy định.

* *Các dạng biểu hiện của hành vi khách quan*

Hành vi khách quan có thể được biểu hiện thông qua hành động hoặc không hành động.

♦ Hành động phạm tội là hình thức của hành vi phạm tội làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động gây thiệt hại cho khách thể của nó bằng cách thực hiện một việc mà pháp luật hình sự cấm. Ví dụ, giết người bằng cách bóp cổ, dùng súng bắn, dao đâm...

♦ Không hành động phạm tội là hình thức của hành vi phạm tội làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động, gây thiệt hại cho khách thể của nó bằng việc chủ thể không thực hiện một việc mà pháp luật yêu cầu hoặc làm không đến mức yêu cầu dù có đủ khả năng và điều nện để thực hiện.

* *Các dạng cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan*

Hai hình thức biểu hiện của hành vi: hành động phạm tội và không hành động phạm tội là đặc trưng trong dấu hiệu hành vi của cấu thành tội phạm.

Tuy nhiên, trong thực tế hành vi phạm tội còn được biểu hiện rất đa dạng. Có hành vi khách quan xảy ra trong chốc lát, có hành vi xảy ra trong thời gian dài, có hành vi xảy ra liên tục, có hành vi cùng một lúc xâm phạm vào hai hoặc nhiều quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ…

Chính vì vậy, căn cứ vào đặc điểm cấu trúc đặc biệt của hành vi khách quan, khoa học luật hình sự còn phân định ra các hình thức thể hiện khác nhau của hành vi trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm với những tên gọi như: tội ghép, tội kéo dài, tội liên tục.

♦ Tội ghép được tạo thành bởi nhiều hành vi khách quan, mỗi hành vi xâm hại đến một khách thế nhất định nhưng chúng lại hợp thành một tội phạm. Ví dụ: tội cướp tài sản bao gồm hành vi tấn công vào người quản lý tài sản (quan hệ nhân thân) và hành vi chiếm đoạt tài sản (quan hệ sở hữu). Dù hành vi gây phương hại đến nhiều khách thể trực tiếp nhưng ta chỉ xem xét về một tội phạm.

♦ Tội kéo dài là tội phạm mà hành vi khách quan của tội phạm diễn ra không gián đoạn trong một thời gian dài. Ví dụ, tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép (Điều 304 Bộ luật Hình sự). Tội kéo dài chỉ bị coi là một tội, có xem xét trên tổng số thời gian phạm tội.

♦ Tội liên tục là tội phạm đó hành vi khách quan gồm nhiều hành vi cùng loại xảy ra kế tiếp nhau về mặt thời gian cùng xâm hại đến một khách thể và đều bị chi phối bởi một ý định phạm tội chung. Ví dụ: thủ quỹ lấy tiền của cơ quan 2 triệu mỗi tháng, kéo dài trong ba năm (cấu thành tội tham ô tài sản, Điều 353 Bộ luật Hình sự). Trong một số trường hợp này, tội liên tục cũng có thể bị coi là phạm tội nhiều lần. Trong trường hợp khác, các hành vi phạm pháp mỗi lần chưa cấu thành một tội phạm độc lập, nhưng nhiều lần, dựa trên tổng số thiệt hại thì cấu thành tội phạm. Ví dụ, một tên trộm mỗi lần trộm một con chó trị giá 700 ngàn đồng, nhưng trong ba ngày trộm được 3 con chó (tổng trị giá là 2,1 triệu đồng). Tội phạm liên tục cũng chỉ xem xét xử một tội nhưng có cân nhắc trên tổng số thiệt hại để xác định khung hình phạt và lượng hình.

+ Dấu hiệu hậu quả

Hậu quả nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là những thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra cho các quan hệ xã hội - khách thể của tội phạm.

* Các loại hậu quả của tội phạm

♦ Hậu quả vật chất là những thiệt hại mà con người trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện kỹ thuật có thể xác định được một cách chính xác mức độ của nó.

♦ Hậu quả phi vật chất là những thiệt hại không thể tính toán một cách chính xác bằng các phương tiện đo lường.

+ Dấu hiệu mối quan hệ nhân quả

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc phải có để cấu thành tội phạm (đối với tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất) mặc dù dấu hiệu này không được thể hiện trong cấu thành tội phạm. Về nguyên tắc, một người chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình nếu giữa hành vi đó và hậu quả của tội phạm có mối quan hệ nhân quả. Chính vì vậy, khi xác định tội phạm ngoài việc xác định hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi khách quan, chúng ta còn phải xác định mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Để xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả chúng ta cần dựa vào các cơ sở có tính nguyên tắc sau:

* Hành vi được coi là nguyên nhân phải là hành vi trái pháp luật hình sự và xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian.

* Giữa nguyên nhân và hậu quả phải có mối quan hệ nội tại và tất yếu.

+ Những dấu hiệu khác trong mặt khách quan của tội phạm

* Thứ nhất: Công cụ, phương tiện phạm tội

Công cụ, phương tiện phạm tội là những đối tượng vật chất được chủ thể của tội phạm sử dụng để hỗ trợ cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Công cụ phạm tội là dạng cụ thể của phương tiện phạm tội. Công cụ, phương tiện có thể là dao, súng, thuốc độc… ô tô, xe máy, phương tiện thông tin liên lạc. Trong một số tội phạm, phạm tội có thể là tiền như các tội đánh bạc, tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ… Công cụ, phương tiện càng nguy hiểm thì phản ánh mức độ tội phạm càng nghiêm trọng.

* Thứ hai: Phương pháp, thủ đoạn phạm tội

Là cách thức thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có các cách thức sử dụng công cụ, phương tiện phạm tội.

Phương pháp thủ đoạn phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của tất cả các cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, ở một số tội phạm, nội dung của biểu hiện này có thể được phản ánh là dấu hiệu của cấu thành tội phạm cơ bản hoặc của cấu thành tội phạm tăng nặng.

* Thứ ba: Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh phạm tội

Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh phạm tội là thời gian, không gian khi xảy ra tội phạm. Bất kỳ tội phạm nào cũng phải xảy ra trong một thời gian,

trong một không gian nhất định. Những dấu hiệu này chỉ trở thành dấu hiệu bắt buộc trong mặt khách quan của tội phạm khi được quy định trong luật hình sự.

* Hoàn cảnh phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ (Điều 124 Bộ luật Hình sự). Ngoài ra, dấu hiệu này có thể là tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ví dụ: phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định ở Điều 51 Bộ luật Hình sự; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội được quy định ở Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- **Chủ thể của tội phạm**

Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật hình sự quy định hoặc pháp nhân thương mại thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội một cách cố ý hoặc vô ý.

+ Các dấu hiệu chủ thể của tội phạm

* Dấu hiệu của chủ thể của tội phạm là cá nhân con người

♦ *Một người cụ thể đang sống*

Chủ thể của tội phạm trước tiên phải là một con người cụ thể. Tội phạm là một dạng hoạt động có ý thức và ý chí của con người, do vậy chỉ được thực hiện bởi những con người cụ thể; họ phải là người có danh (họ tên, quê quán,…).

Con người cụ thể là chủ thể của tội phạm phải là người đang sống. Nếu người thực hiện hành vi phạm tội đã chết thì trách nhiệm hình sự đối với người đã chết không được đặt ra vì hình phạt không có ý nghĩa với người đã chết. Chính vì vậy, dấu hiệu con người cụ thể đang sống là dấu hiệu đầu tiên trong chủ thể của tội phạm.

♦ *Người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự*

Chủ thể của tội phạm theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, ngoài dấu hiệu là con người cụ thể đang sống, thì họ phải có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vì: khi đó họ mới có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trong các điều kiện nhất định là trái hay phù hợp với chuẩn mực xã hội. Năng lực trách nhiệm hình sự là điều kiện cần thiết để xác định một người có lỗi khi họ thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

♦ *Người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự*

Theo quy định của luật hình sự Việt Nam thì không phải mọi trường hợp sinh ra đều có năng lực trách nhiệm hình sự, mà chỉ khi họ đạt đến độ tuổi nhất định (tuổi chịu trách nhiệm hình sự), lúc này họ thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì: "1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. 2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, *303 và 304 của Bộ luật này".*

Cách tính tuổi chịu trách nhiệm hình sự hiện nay được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Việc xác định ngày sinh phải dựa vào các giấy tờ có tính chất pháp lý như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình… nếu không có phải trưng cầu giám định để có kết luận chính xác.

♦ *Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội*

Những người chưa có ba dấu hiệu nói trên chưa thể trở thành chủ thể của tội phạm nếu như họ không thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm vào khách thể được luật hình sự bảo vệ. Cho nên, một người là chủ thể của tội phạm thì ngoài các dấu hiệu là người đang sống, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định thì họ phải là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tức là, người đó có hành vi xâm phạm vào những quan hệ xã hội do luật hình sự bảo vệ, hành vi đó đã gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho khách thể bảo vệ của luật hình sự.

* Dấu hiệu của chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại

♦ *Về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự*

Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây: hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại; chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

* *Chủ thể đặc biệt của tội phạm*

Chủ thể của tội phạm thông thường đòi hỏi phải đáp ứng dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đối với những tội phạm cụ thể cần phải có những dấu hiệu đặc trưng khác mà không có nó thì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không thể trở thành là chủ thể của tội phạm đó được. Những chủ thể đòi hỏi dấu hiệu đặc biệt như vậy gọi là chủ thể đặc biệt. Chủ thể đặc biệt = Chủ thể thường + (những) dấu hiệu đặc biệt.

Những dấu hiệu đặc biệt có thể thuộc một trong các dạng sau:

♦ Các dấu hiệu liên quan đến chức vụ, quyền hạn. Ví dụ, tội tham ô tài sản (Điều 353 Bộ luật Hình sự) đòi hỏi dấu hiệu đặc biệt của chủ thể phải là người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp quản lý tài sản.

♦ Các dấu hiệu liên quan đến nghề nghiệp công việc. Ví dụ, tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối (Điều 382 Bộ luật Hình sự) yêu cầu chủ thể phải là người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa.

♦ Các dấu hiệu liên quan đến nghĩa vụ.

♦ Các dấu hiệu liên quan đến tuổi. Ví dụ, tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147 Bộ luật Hình sự) đòi hỏi chủ thể phải là người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên).

♦ Các dấu hiệu liên quan đến quan hệ, họ hàng. Ví dụ, tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình (Điều 185 Bộ luật Hình sự).

♦ Các dấu hiệu khác. Ví dụ, tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ (Điều 124 Bộ luật Hình sự) đòi hỏi chủ thể phải là người mẹ sinh ra đứa trẻ.

Các đặc điểm của chủ thể đặc biệt là bắt buộc và có ý nghĩa quyết định trong việc định tội. Tuy nhiên, đối với các vụ phạm tội do đồng phạm, các dấu hiệu của chủ thể đặc biệt chỉ đòi hỏi đối với người thực hành, những người khác không cần các dấu hiệu đặc biệt của tội phạm đó.

- Mặt chủ quan của tội phạm

+ Khái niệm: Mặt chủ quan của tội phạm là diễn biến bên trong phản ánh trạng thái tâm lý của chủ thể đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả do hành vi đó gây ra.

+ Những dấu hiệu trong mặt chủ quan của tội phạm:

* Dấu hiệu lỗi

Lỗi là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội của mình và hậu quả do hành vi đó gây ra được biểu hiện dưới hình thức cố ý hoặc vô ý.

Trong luật hình sự, lỗi là dấu hiệu bắt buộc đối với tất cả các cấu thành tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự (bắt buộc chung), vì: Không có lỗi không có tội phạm (Điều 8 Bộ luật Hình sự); trên cơ sở lỗi, hình phạt mới phát huy tác dụng... Nội dung của lỗi thể hiện ở hai yếu tố sau: yếu tố lý trí: thể hiện chủ thể nhận thức được yêu cầu và chuẩn mực xã hội, đánh giá được ý nghĩa xã hội của hành vi mà mình thực hiện theo các chuẩn mực xã hội; yếu tố ý chí: chủ thể có năng lực kiểm soát và điều khiển được các xử sự của mình (phù hợp hoặc trái chuẩn mực xã hội).

♦ Các hình thức lỗi

Căn cứ vào đặc điểm thái độ tâm lý của chủ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Luật hình sự chia lỗi thành hai loại: lỗi cố ý và lỗi vô ý.

Lỗi cố ý được biểu hiện dưới hai hình thức: cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp.

Lỗi cố ý trực tiếp *là lỗi của người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhận thực rõ hành vi của mình có tính chất nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn cho hậu quả xảy ra.*

Xét về lý trí: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội. Nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội: Là sự nhận thức được tính chất gây thiệt hại cho xã hội của hành vi đang thực hiện trên cơ sở nhận thức những tình tiết khách quan của nó. Những tình tiết đó có thể là: mặt thực tế của hành vi, là đặc điểm của đối tượng tác động của tội phạm, là những điều kiện khách quan như: thủ đoạn phạm tội, phương tiện thực hiện, thời gian, địa điểm phạm tội. Ngoài ra, người phạm tội còn phải thấy trước hậu quả của hành vi do mình thực hiện, là sự dự kiến của người phạm tội về sự phát triển của hành vi. Người phạm tội có thể dự kiến hành vi tất nhiên sẽ gây ra hậu quả hoặc dự kiến hành vi có thể gây ra hậu quả, chứ không phải hậu quả đã xảy ra họ mới thấy.

Xét về ý chí: Người phạm tội mong muốn cho hậu quả xảy ra

Người phạm tội khi thực hiện hành vi, không chỉ nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó,

mà người phạm tội còn phải mong muốn hậu quả xảy ra, mặc dù hậu quả có thể chưa xảy ra.

Lỗi cố ý gián tiếp *là trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra.*

Về lý trí: Người phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình, thấy trước hành vi đó có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi nguy hiểm cho xã hội, điều này giống với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Tuy nhiên, trong hình thức lỗi cố ý gián tiếp người phạm tội chỉ thấy trước hậu quả có thể xảy ra mà không chắc chắn nhất định xảy ra. Tức là, người phạm tội nhận thức được hai khả năng phát sinh hậu quả: khả năng hậu quả có thể xảy ra và khả năng hậu quả có thể không xảy ra.

Về ý chí: Người phạm tội không mong muốn cho hậu quả xảy ra nhưng có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Không mong muốn cho hậu quả xảy ra trong cố ý gián tiếp là không mong muốn trong ý thức, nhưng lại mong muốn thực hiện hành vi và bỏ mặc cho hậu quả xảy ra như thế nào người phạm tội đều chấp nhận, miễn là thực hiện bằng được hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đây là điểm khác nhau cơ bản so với hình thức lỗi cố ý trực tiếp. Sự bỏ mặc thể hiện ở trạng thái tâm lý bàng quan, thờ ơ của người phạm tội. Người phạm tội chấp nhận hậu quả xảy ra cho dù không muốn. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà người phạm tội có thể thấy trước không phù hợp với mục đích của họ. Người phạm tội thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là nhằm mục đích khác. Chính nhằm mục đích này mà người phạm tội chấp nhận hậu quả nguy hiểm cho xã hội do hành vi của mình có thể gây ra.

Lỗi vô ý vì quá tự tin: *Người phạm tội tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không thể xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.*

Xét về lý trí: Người phạm tội nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình thể hiện ở chỗ họ thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà hành vi của mình có thể gây ra. Cụ thể: Người phạm tội ở trường hợp này thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội có thể xảy ra, nhưng đồng thời lại cho rằng hậu quả đó không xảy ra và đã loại trừ khả năng này. Khả năng hậu quả xảy ra và không xảy ra là khả năng thực tế, nhưng người phạm tội lại tin rằng hậu quả không xảy ra khi quyết định

hành động và chính sự tin tưởng này thể hiện họ đã không nhận thức một cách đầy đủ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi.

Xét về ý chí: Người phạm tội không mong muốn hành vi của mình gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Sự không mong muốn này gắn liền với việc chủ thể đã loại trừ khả năng hậu quả xảy ra, họ đã cân nhắc tính toán và cho rằng hậu quả không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Thái độ nhẹ dạ tin rằng hậu quả không xảy ra là do họ đánh giá quá cao các điều kiện khách quan và chủ quan khi thực hiện hành vi.

Lỗi vô ý vì cẩu thả: *là trường hợp người phạm tội do cẩu thả mà không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.*

Căn cứ vào khái niệm trên, ta thấy lỗi vô ý phạm tội vì cẩu thả có những dấu hiệu sau:

Một là, người thực hiện hành vi không nhận thức được hành vi của mình là hành vi có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Khác với lỗi vô ý vì quá tự tin và các hình thức lỗi cố ý khác, người phạm tội do vô ý vì cẩu thả hoàn toàn không thấy trước hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội; nhưng lý do không thấy trước là do họ cẩu thả, tức là không cẩn thận khi xử sự, nếu cẩn thận thì hậu quả sẽ không xảy ra.

Hai là, (phân biệt với không có lỗi) người phạm tội phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả của hành vi đó (có đủ điều kiện để thấy).

"Thấy trước" nghĩa là với địa vị của mình họ có nghĩa vụ phải thấy, nhận thức và xử sự theo đúng chuẩn mực xã hội. Tiêu chuẩn để xác định một người phải thấy trước hậu quả nguy hại cho xã hội, là căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể lúc xảy ra sự việc, vào độ tuổi, trình độ nhận thức, trình độ văn hoá, tay nghề. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì người khác cũng thấy trước hành vi và hậu quả do hành vi gây ra là nguy hại cho xã hội.

Để xác định việc đáng ra phải thấy trước hoặc có thể phải thấy trước cần thiết dựa vào những quy tắc, nội quy, quy định được pháp luật hóa hoặc đã được thừa nhận và mọi người có trách nhiệm thực hiện. Ví dụ như: quy tắc nghề nghiệp, quy tắc an toàn giao thông, quy tắc phòng cháy chữa cháy, quy tắc sử dụng súng đạn, quy tắc quản lý chất cháy, chất độc…

"Có thể thấy trước" nghĩa là người phạm tội có đủ điều kiện khách quan (hoàn cảnh cụ thể bên ngoài lúc xảy ra sự việc) cũng như điều kiện chủ quan (trình độ nhận thức, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm bản thân)

để có thể thấy sự việc vi phạm các quy tắc sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

+ Động cơ phạm tội

Động cơ phạm tội được hiểu là động lực bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội (có thể hiểu là nguyên nhân tinh thần của tội phạm). Ví dụ, tội phạm trộm cắp tài sản có thể vì nghèo, thù ghét người bị hại hoặc để chia cho người nghèo khác.

+ Mục đích phạm tội

Mục đích phạm tội là điểm cuối cùng mà người phạm tội đặt ra cho hành động phạm tội phải đạt tới. Mọi hành vi của một người bình thường đều nhằm vào mục đích nhất định. Mục đích phạm tội chỉ đặt ra đối với các tội phạm có lỗi cố ý trực tiếp, vì trong trường hợp này, người phạm tội mới có sự mong muốn gây ra hậu quả nhằm đạt tới những mục đích phạm tội nhất định. Đối với các tội phạm trong những trường hợp khác, mục đích là mục đích của hành vi. Khi ấy, người phạm tội không mong muốn thực hiện hành vi phạm tội hoặc không tin rằng hành vi của mình trở thành hành vi phạm tội. Do đó, mục đích mà người phạm tội muốn đạt tới không phải là mục đích thực tế mà người phạm tội đã đạt được sau khi đã thực hiện hành vi.

3.2.5. Các giai đoạn thực hiện tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình phạm tội do cố ý, bao gồm: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành. Các giai đoạn này thể hiện các mức độ thực hiện tội phạm khác nhau và cũng phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau.

- Chuẩn bị phạm tội

+ Khái niệm

Điều 14 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về giai đoạn chuẩn bị phạm tội như sau: *"Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này…".*

Các đặc điểm của giai đoạn chuẩn bị phạm tội như sau:

* Ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, người phạm tội chưa bắt đầu thực hiện tội phạm.

* Người phạm tội chưa gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

+ Trách nhiệm hình sự

Tại Điều 14 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định việc xác định trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi phạm tội ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội như sau: *"...2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự".*

Như vậy, trách nhiệm hình sự của người phạm tội ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội cũng nhẹ hơn so với các giai đoạn sau, nó được quy định cụ thể trong từng điều luật quy định về tội phạm cụ thể.

Lưu ý: Nếu hành vi chuẩn bị phạm tội đã cấu thành một tội độc lập thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội độc lập đó và tội họ định thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội. Ví dụ: A có ý định giết B. A đã mua một khẩu súng với mục đích để giết B, nhưng chưa kịp hành động giết B thì bị phát hiện. Trường hợp này A phải chịu trách nhiệm về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội giết người ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội.

- Phạm tội chưa đạt

+ Khái niệm

Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về trường hợp phạm tội chưa đạt như sau: *"Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội"*.

Phạm tội chưa đạt có đặc điểm sau đây:

** Người phạm tội đã bắt đầu thực hiện tội phạm*

Được coi là bắt đầu thực hiện tội phạm khi người phạm tội bắt đầu thực hiện các hành vi khách quan được mô tả trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Có nghĩa là ở giai đoạn này, hành vi của người phạm tội không còn là hành vi chuẩn bị phạm tội nữa.

** Người phạm tội đã bắt đầu thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện tội phạm được đến cùng*

Không thực hiện tội phạm được đến cùng không có nghĩa là người phạm tội chưa đạt được mục đích hay chưa gây ra hậu quả hay chưa thực

hiện hết hành vi khách quan, mà hiểu theo góc độ pháp lý thì: Không thực hiện tội phạm được đến cùng tức là người phạm tội chưa thực hiện đầy đủ các dấu hiệu được mô tả trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Như: dấu hiệu hành vi khách quan, dấu hiệu hậu quả, mối quan hệ nhân quả và các điều kiện khác.

Và trong thực tế không thực hiện tội phạm được đến cùng được xác định qua các trường hợp cụ thể sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Người phạm tội mới chỉ thực hiện "hành vi đi liền trước" hành vi khách quan của cấu thành tội phạm thì bị dừng lại. Ví dụ, mới rút súng để giết người thì bị bắt, mới vung dao lên định chém thì bị người khác ngăn cản.

Trường hợp thứ hai: Người phạm tội đã thực hiện hành vi khách quan nhưng chưa thực hiện hết hành vi khách quan trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Ví dụ trong "tội trộm cắp tài sản", người phạm tội mới thực hiện hành vi leo tường vào nhà người khác để trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ.

Trường hợp thứ ba: Người phạm tội đã thực hiện hết hành vi khách quan được quy định trong cấu thành tội phạm nhưng chưa gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội hoặc có hậu quả nhưng hậu quả không như mong muốn của người phạm tội (đối với những tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất). Ví dụ, đã ném lựu đạn để giết người nhưng lựu đạn không nổ hoặc nổ nhưng nạn nhân không chết.

** Việc người phạm tội không thực hiện tội phạm được đến cùng là do những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội*

Trong thực tế, việc người phạm tội không thực hiện tội phạm được đến cùng có thể là do nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan của người phạm tội thì thuộc trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Còn ở giai đoạn phạm tội chưa đạt, nguyên nhân làm cho tội phạm không thực hiện được đến cùng là do nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội.

Khi căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, khoa học luật hình sự đã phân chia các trường hợp phạm tội chưa đạt như sau:

Trường hợp thứ nhất: Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành

Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành là trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội chưa thực hiện hết các hành vi khách quan được quy định

trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm do nguyên nhân ngoài ý muốn của họ và hậu quả chưa xảy ra.

Về dấu hiệu hành vi khách quan: Người phạm tội mới thực hiện hành vi đi liền trước hành vi khách quan hoặc bắt đầu thực hiện hành vi khách quan được quy định trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm cụ thể nhưng chưa thực hiện đầy đủ hành vi khách quan.

Về dấu hiệu hậu quả thiệt hại: Chưa gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Trường hợp này là trường hợp chưa đạt về hậu quả và chưa hoàn thành về hành vi.

Trường hợp thứ hai: Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành

Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành là trường hợp người phạm tội đã thực hiện hết các hành vi khách quan được quy định trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm nhưng do nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội mà hậu quả chưa xảy ra hoặc đã xảy ra nhưng không theo ý muốn của người phạm tội hoặc không có mối quan hệ nhân quả với hành vi của người phạm tội.

Về dấu hiệu hành vi khách quan: Người phạm tội đã thực hiện đầy đủ, đã thỏa mãn các dấu hiệu hành vi khách quan được quy định trong mặt khách quan của cấu thành tội phạm cụ thể.

Về dấu hiệu hậu quả: Hậu quả chưa xảy ra hoặc có hậu quả xảy ra nhưng hậu quả đó không như mong muốn của người phạm tội hoặc không có mối quan hệ nhân quả với hành vi của người phạm tội.

Trường hợp này là trường hợp chưa đạt về hậu quả nhưng hoàn thành về hành vi.

+ Trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội chưa đạt

Hành vi của người phạm tội ở giai đoạn phạm tội chưa đạt đã xâm hại trực tiếp đến khách thể được luật hình sự bảo vệ. Đây là những hành vi nguy hiểm, đe dọa gây ra thiệt hại cho các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ. Người phạm tội có động cơ, mục đích phạm tội rõ ràng, luôn mong muốn thực hiện tội phạm đến cùng. Người phạm tội không thực hiện tội phạm được đến cùng hoàn toàn là do những nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn chủ quan của họ. Chính vì vậy, Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định trách nhiệm hình sự trong trường hợp phạm tội chưa đạt như sau: *"Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt"*.

- Tội phạm hoàn thành

Tội phạm hoàn thành là trường hợp phạm tội đã thoả mãn các dấu hiệu được quy định trong cấu thành tội phạm ở mỗi tội phạm cụ thể.

Tội phạm hoàn thành là hoàn thành về mặt pháp lý tức là hành vi phạm tội của người phạm tội đã thỏa mãn các dấu hiệu pháp lý của cấu thành tội phạm đó mà không phụ thuộc vào việc người phạm tội đã đạt được mục đích phạm tội của mình hay chưa (có thể đạt, có thể chưa). Khi tội phạm hoàn thành cũng có thể người phạm tội đã đạt được mục đích của mình, nhưng cũng có thể chưa đạt được mục đích đó.

Đối với tội phạm có cấu thành vật chất thì thời điểm hoàn thành của tội phạm là khi người phạm tội đã gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội và hậu quả xảy ra cũng là mục đích của người phạm tội. Trong trường hợp này người phạm tội đã đạt được mục đích của mình. Có nghĩa thời điểm tội phạm hoàn thành là thời điểm người phạm tội đã đạt được mục đích của mình. Đối với tội phạm có cấu thành hình thức thì tội phạm hoàn thành khi người phạm tội đã bắt đầu thực hiện hành vi khách quan được mô tả trong mặt khách quan của tội phạm mà không cần mục đích của người phạm tội có đạt được hay chưa. Với những tội phạm này thì thời điểm tội phạm hoàn thành không có nghĩa là người phạm tội đã đạt được mục đích của mình.

Trên thực tế thì một tội phạm hoàn thành có thể kết thúc nhưng cũng có thể chưa kết thúc nên trong một số trường hợp thời điểm tội phạm hoàn thành và thời điểm tội phạm kết thúc có thể trùng nhau, nhưng khái niệm thời điểm tội phạm hoàn thành và thời điểm tội phạm kết thúc là khác nhau.

- Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

+ Khái niệm

Trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì chế định "Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội" được quy định tại Điều 16 với nội dung như sau: *"Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng tuy không có gì ngăn cản. Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này".*

Luật hình sự quy định, người có hành vi tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, cho nên để xác định trường

hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội cần phải có những điều kiện cụ thể để tránh những trường hợp nhầm lẫn trong thực tế.

+ Những điều kiện về tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

** Việc chấm dứt thực hiện tội phạm phải xảy ra khi tội phạm đang ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc ở giai đoạn chưa đạt chưa hoàn thành.*

Ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội: Người phạm tội mới tạo ra các điều kiện về vật chất cũng như tinh thần nhằm thực hiện tội phạm mà chưa có bất kỳ hành vi nào thực hiện tội phạm. Có nghĩa là chưa trực tiếp xâm phạm khách thể cũng như chưa gây ra hậu quả thiệt hại. Vì vậy, nếu người phạm tội tự nguyện không thực hiện tội phạm nữa thì được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Ở giai đoạn phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành: Người phạm tội mặc dù đã bắt đầu thực hiện tội phạm nhưng chưa thực hiện hết các hành vi cho là cần thiết để gây nên hậu quả của tội phạm nên hậu quả chưa xảy ra hoặc chỉ xảy ra trong chừng mực nhất định. Vì vậy, nếu người phạm tội tự nguyện dừng lại không thực hiện tội phạm nữa thì cũng được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

** Việc chấm dứt việc thực hiện tội phạm phải tự nguyện và dứt khoát*

Việc chấm dứt việc thực hiện tội phạm phải do tự bản thân người phạm tội không thực hiện tội phạm nữa chứ không phải do người khác ép buộc, ngăn cản hoặc các lý do khách quan khác ngăn cản. Đồng thời việc chấm dứt việc thực hiện tội phạm phải dứt khoát, nghĩa là bản thân người phạm tội quyết tâm không thực hiện đến cùng chứ không phải là tạm thời dừng lại để tìm thời cơ hoặc thủ đoạn khác để tiếp tục thực hiện tội phạm.

Việc chủ thể dừng lại không thực hiện tiếp tục tội phạm phải hoàn toàn do động lực bên trong chứ không phải do trở ngại khách quan chi phối. Chủ thể dừng lại không thực hiện tiếp tục tội phạm phải là từ bỏ hẳn ý định phạm tội chứ không phải là thủ đoạn để tiếp tục thực hiện tội phạm.

Những lý do chủ quan khiến người phạm tội tự nguyện dừng lại việc thực hiện tội phạm có thể là: do sợ bị trả thù, gia đình bị liên luỵ; do thương xót nạn nhân; do người khác thuyết phục tác động… Việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội có thể do những động cơ khác nhau thúc đẩy, chứ không nhất thiết là do sự hối hận của chủ thể.

+ Trách nhiệm hình sự trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Điều 16 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố cấu thành tội phạm của một tội khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này".* Ví dụ, một người mua súng về với mục đích là để giết người nhưng cảm thấy lo sợ, đã suy nghĩ lại và không thực hiện hành vi phạm tội nữa. Trong trường hợp này, người đó sẽ được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị giết người vì thuộc trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Tuy nhiên, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự vì hành vi đã đủ yếu tố cấu thành tội này.

3.2.6. Đồng phạm

3.2.6.1. Khái niệm và những dấu hiệu pháp lý của đồng phạm

Tội phạm được thực hiện bởi con người cụ thể, tội phạm có thể do một người hoặc nhiều người thực hiện. Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, tội phạm do nhiều người thực hiện rất phức tạp, có vụ là đồng phạm có vụ không phải là đồng phạm. Khái niệm đồng phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) như sau: "*Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm*".

Để xem xét một trường hợp có đồng phạm hay không cần căn cứ vào những dấu hiệu pháp lý sau đây:

- Những dấu hiệu khách quan:

+ *Dấu hiệu số lượng người thực hiện tội phạm*: Có từ hai người trở lên và những người này có năng lực trách nhiệm hình sự đồng thời đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định.

+ Những người đồng phạm phải cùng thực hiện một tội phạm

Mỗi người đồng phạm phải có hành vi tham gia thực hiện tội phạm. Hành vi của họ có thể là một trong 4 loại hành vi sau đây:

* Hành vi thực hiện tội phạm: Tức là thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm. Người thực hiện hành vi này gọi là người thực hành.

* Hành vi tổ chức thực hiện tội phạm: Tức là tổ chức thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm. Người thực hiện hành vi này gọi là người tổ chức.

* Hành vi xúi giục người khác thực hiện tội phạm: Tức là xúi giục người khác thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm. Người thực hiện hành vi này gọi là người xúi giục.

* Hành vi giúp sức người khác thực hiện tội phạm: Tức là giúp người khác thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm. Người thực hiện hành vi này gọi là người giúp sức.

+ Hậu quả của tội phạm là kết quả chung do hoạt động chung của những người đồng phạm gây ra.

Hành vi của mỗi người đồng phạm và hậu quả của tội phạm do những người đồng phạm cùng thực hiện có mối quan hệ nhân quả. Hành vi của người thực hành là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh hậu quả còn hành vi của người tổ chức, xúi giục, giúp sức thông qua hành vi của những người thực hành mà gây ra hậu quả. Tuy nhiên, cần chú ý là hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong việc xác định đồng phạm trừ trường hợp luật định.

Hậu quả tác hại có phải là dấu hiệu bắt buộc để xác định đồng phạm hay không, phụ thuộc vào tội phạm được thực hiện. Nếu tội phạm được thực hiện có dấu hiệu hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm thì dấu hiệu hậu quả là bắt buộc trong xác định đồng phạm vì: Có hậu qủa xảy ra thì tội phạm mới được xác lập, do đó, mới có đồng phạm. Nếu dấu hiệu hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm thì cũng không bắt buộc trong xác định đồng phạm vì hậu quả có xảy ra hay không thì cấu thành tội phạm cũng được xác lập, do đó, đồng phạm cũng xảy ra. Ví dụ: Các tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức thì hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, do đó, không phải là dấu hiệu bắt buộc trong xác định đồng phạm.

Các tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất nhìn chung hậu quả tác hại là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm, do đó, cũng là dấu hiệu bắt buộc trong xác định đồng phạm.

Tuy nhiên, khi xác định đồng phạm, dấu hiệu hậu quả mặc dù không phải là dấu hiệu bắt buộc nhưng cũng cần phải xét đến để xác định sự tác hại của việc cùng chung hành động phạm tội của những người đồng phạm, qua đó thấy được mối liên hệ của sự cùng thực hiện tội phạm và mối quan hệ nhân quả của hành vi từng người đồng phạm đối với hậu quả chung.

- Những dấu hiệu chủ quan:

+ Dấu hiệu lỗi

Khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, mỗi người đồng phạm không chỉ cố ý với hành vi của mình mà còn biết và mong muốn sự cố ý tham gia của những người đồng phạm khác. Do đó dấu hiệu lỗi trong đồng phạm là dấu hiệu cùng cố ý của những người đồng phạm. Sự cùng cố ý trong đồng phạm biểu hiện như sau:

* Về lý trí: Sự cùng cố ý phải thỏa mãn ba điều kiện sau đây:

♦ Mỗi người đồng phạm đều nhận thức tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình.

♦ Mỗi người đồng phạm còn nhận thức được hành vi của người khác cùng với mình cũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên cũng cần chú ý là: Người đồng phạm chỉ cần nhận thức được hành vi của một người khác trong số những người cùng thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

♦ Mỗi người đồng phạm thấy trước hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình cũng như hậu quả chung của tội phạm mà họ tham gia thực hiện.

* Về ý chí: Những người đồng phạm cùng mong muốn có hoạt động chung và cùng mong muốn hoặc để mặc cho hậu quả xảy ra.

+ Dấu hiệu động cơ và mục đích trong đồng phạm

Động cơ và mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc trong đồng phạm trừ trường hợp luật định.

Nếu tội phạm được thực hiện trong đồng phạm là tội phạm mà trong cấu thành tội phạm dấu hiệu động cơ, mục đích là dấu hiệu bắt buộc thì những người đồng phạm phải có cùng dấu hiệu động cơ, mục đích đó.

Nếu tội phạm được thực hiện trong đồng phạm là tội phạm mà trong cấu thành tội phạm dấu hiệu động cơ, mục đích không phải là dấu hiệu bắt buộc thì cũng không bắt buộc trong việc xác định đồng phạm.

* Việc xác định dấu hiệu cùng động cơ, mục đích dựa trên quan điểm: Nếu một người biết người khác có động cơ, mục đích phạm tội bị pháp luật hình sự quy định là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành tội phạm (dấu hiệu quy định của một tội danh cụ thể nào đó) mà vẫn tham gia cùng thực hiện tội phạm (tổ chức, xúi giục, giúp sức) với người đó thì bị coi là cùng mục đích với người đó.

* Việc cùng mục đích được thể hiện như sau:

Những người trong đồng phạm đều hướng tới một động cơ, mục đích chung.

Những người đồng phạm tiếp nhận mục đích của nhau. Nghĩa là khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội tuy không có mục đích được quy định trong cấu thành tội phạm, nhưng vì những động cơ và mục đích khác đã chấp nhận mục đích đó và cùng thực hiện tội phạm với người có mục đích được quy định trong cấu thành tội phạm.

3.2.6.2. Các loại người đồng phạm

Những người được gọi là đồng phạm bao gồm: người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.

- Người tổ chức

Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: "*Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm*". Người tổ chức là người đứng ra giữ vai trò lãnh đạo, thành lập, điều khiển mọi hoạt động của người đồng phạm, do vậy người tổ chức giữ vai trò quan trọng trong vụ án đồng phạm. Người tổ chức có ba loại người sau đây:

+ Người chủ mưu

Người chủ mưu là người đưa ra mưu kế để thực hiện tội phạm.

Để xác định là người chủ mưu trong vụ đồng phạm phải xác định được các dấu hiệu pháp lý sau:

* Người chủ mưu là người có sáng kiến thành lập tổ chức phạm tội;

* Đưa ra kế hoạch lôi kéo những người khác cùng tham gia vào tổ chức phạm tội;

* Đưa ra phương hướng, cách thức thực hiện tội phạm;

* Vai trò của chủ mưu chiếm vị trí rất quan trọng quyết định phương hướng, đường lối hoạt động của tổ chức đó.

+ Người cầm đầu

Người cầm đầu là người đứng đầu tổ chức phạm tội, người đứng ra thành lập các băng, ổ, nhóm, hoặc tham gia soạn thảo kế hoạch, đôn đốc điều khiển mọi hoạt động của tổ chức.

Đặc điểm hành vi của người cầm đầu:

* Thành lập băng, nhóm, ổ phạm tội;

* Tham gia soạn thảo kế hoạch hoạt động phạm tội của tổ chức;

* Người cầm đầu có vai trò rất quan trọng: Đứng đầu, có chức vụ cao nhất. Có quyền phân công giao nhiệm vụ cho từng tên tổ chức. Có

quyền đôn đốc, kiểm tra điều khiển mọi hoạt động của tổ chức nên người đó nắm toàn bộ tổ chức;

* Một tổ chức phạm tội có thể có nhiều người cầm đầu;

* Người cầm đầu có khi là kẻ chủ mưu: Vì thực tế cho ta thấy có người vừa sáng kiến ra việc thực hiện tội phạm, lại vừa đứng ra thành lập và điều khiển tổ chức; bày mưu tính kế, vạch hướng cho đồng bọn hành động phạm tội. Trong trường hợp này thì tính nguy hiểm càng cao hơn;

* Người cầm đầu bao giờ cũng đứng trong tổ chức.

+ Người chỉ huy

Người chỉ huy là người trực tiếp điều khiển việc thực hiện tội phạm có tính chất vũ trang quân sự. Như tội hoạt động phỉ, tội bạo loạn…

Vai trò của người chỉ huy giống như người cầm đầu.

- Người thực hành

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Trực tiếp thực hiện tội phạm, theo pháp luật hình sự Việt Nam, là trực tiếp thực hiện những hành vi khách quan được mô tả trong cấu thành tội phạm. Có hai hình thức sau đây được coi là trực tiếp thực hiện tội phạm, đó là: tự mình thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm; không tự mình thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm, nhưng cố ý tác động đến người khác để người này thực hiện hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm mà bản thân những người bị tác động không phải chịu trách nhiệm hình sự.

+ Người thực hành là người tự mình thực hiện tội phạm

Là người tự mình sử dụng hoạt động cơ học của chính cơ thể mình (hoặc có công cụ hỗ trợ) để thực hiện những hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm như dùng tay, chân đấm đá người khác gây thương tích… (hoặc dùng kìm cắt khóa để lấy tài sản của người khác).

+ Người thực hành thực hiện hành vi phạm tội thông qua những người không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc không đủ độ tuổi theo luật định

Người không có năng lực trách nhiệm hình sự là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Người không đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật định là người mà tại thời điểm thực hiện tội phạm không đủ độ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự về tội mà họ đã phạm.

Thực hiện tội phạm thông qua những người không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc không đạt độ tuổi theo luật định là tác động đến người không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc không đạt độ tuổi theo luật định để những người này thực hiện tội phạm, cụ thể:

* Người thực hành là người đã tác động đến người bị tâm thần hoặc bị bệnh hiểm nghèo khác (người không có năng lực trách nhiệm hình sự, hoặc không có khả năng điều khiển hành vi) thực hiện hành vi phạm tội.

* Người thực hành là người tác động đến người chưa đủ 14 tuổi thực hiện tội phạm.

* Người thực hành là người tác động đến người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng không thuộc các tội phạm quy định tại Khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

* Người thực hành là người tác động đến người khác thực hiện tội phạm mà những người này không phải chịu trách nhiệm hình sự như:

♦ Người bị tác động là người không có lỗi hoặc chỉ có lỗi do sai lầm.

♦ Người bị tác động là người được loại trừ trách nhiệm hình sự do bị cưỡng bức thân thể. Ví dụ: Cầm tay người khác điểm chỉ vào đơn tố cáo sai sự thật.

+ Những điểm cần chú ý khi xác định người thực hành

* Người thực hành phải đủ điều kiện chủ thể của tội đang thực hiện.

* Hành vi của người thực hành có ý nghĩa trong việc xác định tội danh, tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm.

- Người xúi giục

Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

+ Kích động: Tác động mạnh vào tinh thần người khác làm cho người này nảy sinh ý định phạm tội và thực hiện tội phạm.

+ Dụ dỗ: Tác động về mặt tình cảm, làm cho người bị tác động nảy sinh ý định phạm tội và thực hiện tội phạm.

+ Thúc đẩy: Tác động đến người đã có ý định phạm tội, hoặc đang chuẩn bị phạm tội hoặc đang thực hiện tội phạm làm cho việc thực hiện tội phạm được nhanh chóng và đến cùng.

Xúi giục từ đầu

Người xúi giục có hành vi tác động mạnh đến tư tưởng, ý chí của người khác làm cho người này từ chưa có ý định phạm tội đến nảy sinh ý định phạm tội và thực hiện tội phạm đó. Thủ đoạn của xúi giục từ đầu thông thường là kích động, dụ dỗ.

Xúi giục nửa chừng

Người xúi giục có hành vi tác động đến tư tưởng, ý chí của người đang chần chừ trong việc thực hiện tội phạm đi đến quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Người bị tác động đã có ý định phạm tội nhưng vì lý do nào đó còn chần chừ (có thể có ý định từ bỏ) thì người xúi giục tác động đến làm họ quyết tâm thực hiện tội phạm.

Đặc điểm hành vi xúi giục

Hành vi xúi giục phải trực tiếp: Phải tác động đến một người hoặc một nhóm người nhất định và hành vi xúi giục là nguyên nhân trực tiếp làm nảy sinh ở người bị xúi giục ý thức phạm tội và thực hiện tội phạm đó. Người xúi giục xác định rõ hành vi xúi giục của mình tác động đến người nào (có thể đã có quan hệ trước, có thể chưa có quan hệ gì, nhưng phải xác định được người bị tác động là ai), có thể đó là một người hoặc một nhóm người.

Hành vi xúi giục phải cụ thể: Nghĩa là người xúi giục đã nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm mà người bị xúi giục sẽ thực hiện. Thấy trước hậu quả của tội phạm đó và mong muốn hoặc bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

Hành vi xúi giục phải có trước hành vi thực hiện tội phạm và là nguyên nhân dẫn đến hành vi thực hiện tội phạm.

Mức độ nghiêm trọng của hành vi xúi giục phụ thuộc vào bản chất của người xúi giục, người bị xúi giục và bản chất của họ. Nếu giữa họ có quan hệ phụ thuộc thì tính nguy hiểm của hành vi xúi giục càng cao.

Cần chú ý: Nếu hành vi xúi giục không nhằm vào đối tượng cụ thể thì không phải là hành vi xúi giục.

- Người giúp sức

Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: "*Người giúp sức là người tạo điều kiện về tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm*".

* Giúp sức về vật chất: là những hành vi cung cấp cho người thực hành những dạng vật chất nhất định hoặc khắc phục những trở ngại để người thực hành thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm, như cung cấp công cụ, phương tiện phạm tội…

Cần chú ý: Giúp sức về vật chất có thể thể hiện dưới hình thức không hành động. Ví dụ: Các nhân viên bảo vệ của công ty được phân công bảo vệ ở công ty đã "làm ngơ" cho người khác vào trộm cắp tài sản của công trường của công ty.

Hành vi giúp sức có thể đủ yếu tố cấu thành tội phạm độc lập. Ví dụ: cung cấp súng cho người khác thực hiện hành vi giết người.

+ Giúp sức về tinh thần: là hành vi tạo những điều kiện thuận lợi cho người thực hành thực hiện tội phạm, những điều kiện thuận lợi đó không phải là vật chất. Như cung cấp những thông tin cần thiết cho việc thực hiện tội phạm như vẽ sơ đồ, nghiên cứu quy luật làm việc, đi lại của người bị hại… Tuy nhiên cần chú ý là: Hành vi "hứa hẹn trước" sẽ che giấu tội phạm, tang vật hoặc tiêu thụ các vật do phạm tội mà có là giúp sức về tinh thần, vì người hứa hẹn trước không tạo ra những điều kiện thuận lợi cụ thể, nhưng sự "hứa hẹn trước" cũng có những tác động tích cực vào quá trình thực hiện tội phạm. Sự tác động này thể hiện ở chỗ đã cũng cố ý định phạm tội, cũng cố quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

+ Hành vi giúp sức trong đồng phạm có những đặc điểm sau đây:

* Hành vi giúp sức thông thường thông qua hành động nhưng cũng có những trường hợp không thông qua hành động. Trong trường hợp không thông qua hành động có thể là những trường hợp của những người có nghĩa vụ pháp lý phải hành động để ngăn chặn tội phạm nhưng đã cố ý không hành động và qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hành thực hiện tội phạm hoặc thực hiện tội phạm đến cùng.

* Hành vi giúp sức có thể xảy ra trước hoặc trong khi tội phạm đang xảy ra.

* Hành vi giúp sức có thể đủ yếu tố cấu thành tội phạm độc lập.

Cũng cần chú ý phân biệt giữa hành vi góp ý bàn bạc của những người giúp sức và người xúi giục. Hành vi giúp sức không làm người thực hành nảy sinh ý định phạm tội và thực hiện tội phạm mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm. Còn hành vi xúi giục làm cho người thực hành nảy sinh ý định phạm tội và thực hiện tội phạm.

3.2.6.3. Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm

- Tất cả những người đồng phạm đều phải bị truy tố, xét xử về cùng tội danh, theo cùng điều luật và trong phạm vi chế tài mà luật đã quy định.

- Mỗi người đồng phạm phải chịu trách nhiệm độc lập về từng hành vi, vai trò của mình trong việc cùng thực hiện đồng phạm. Những người đồng phạm không chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá của đồng phạm khác. Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của cá nhân nào thì chỉ áp dụng với cá nhân đó.

- Trách nhiệm hình sự của mỗi người tham gia đồng phạm phụ thuộc vào mức độ đóng góp vào tính chất của hành vi khi tham gia vào việc thực hiện đồng phạm.

3.2.7. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

Loại trừ trách nhiệm hình sự là trường hợp một người có hành vi gây thiệt hại cho xã hội, nhưng theo quy định của Bộ luật Hình sự thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự do có một trong những căn cứ được loại trừ trách nhiện hình sự - chứa đựng yếu tố loại trừ tính chất phạm tội của hành vi. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định 7 trường hợp.

3.2.7.1. Phòng vệ chính đáng

- Khái niệm

Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên".*

- Điều kiện của phòng vệ chính đáng

+ Có hành vi xâm hại vào lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền và lợi ích hợp pháp khác

Đây là cơ sở làm phát sinh quyền phòng vệ. Không phải trong mọi trường hợp khi có sự tấn công đều được áp dụng phòng vệ chính đáng. Mà chỉ được thực hiện quyền phòng vệ khi sự tấn công là bất hợp pháp, xâm hại lợi ích của Nhà nước của tập thể hoặc lợi ích chính đáng của công dân. Và sự tấn công có thể là tội phạm cũng có thể không phải là tội phạm, nhưng sự tấn công đó phải mang tính hiện thực, tức là nó phải đang xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc. Sự cho phép phòng vệ cả những

trường hợp tấn công chưa xảy ra, nhưng có những biểu hiện đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc là một cần thiết khách quan nhằm tạo điều kiện phòng vệ ngăn chặn sự tấn công được kịp thời và hiệu quả.

Đối với những trường hợp, người tấn công là trẻ em hoặc là người không có năng lực trách nhiệm hình sự thì chỉ được quyền thực hiện phòng vệ chính đáng khi không còn biện pháp khác để ngăn cản sự tấn công. Nội dung dấu hiệu này là:

* Hành vi xâm hại là có thật, nghĩa là hành vi xâm hại đến những lợi ích hợp pháp phải tồn tại khách quan chứ không phải do suy đoán, tưởng tượng. Thực tế có những trường hợp không có sự xâm hại của người khác đối với mình nhưng lại lầm tưởng rằng có sự xâm hại nên đã có hành vi chống trả gây thiệt hại cho người khác. Khoa học luật hình sự gọi trường hợp này là phòng vệ tưởng tượng, và tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người có hành vi phòng vệ tưởng tượng phải chịu trách nhiệm hình sự.

* Hành vi xâm hại phải là hành vi phạm tội hoặc rõ ràng là có tính chất mức độ nguy hiểm đáng kể, trái pháp luật nghiêm trọng. Nghĩa là hành vi xâm hại có thể là tội phạm hoặc không cấu thành tội phạm nhưng phải chứa đựng tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, uy hiếp nghiêm trọng đến các lợi ích cần bảo vệ. Mức độ nguy hiểm đáng kể tuỳ thuộc vào quan hệ xã hội bị xâm hại, tính chất và mức độ thực hiện hành vi xâm hại...

+ Hành vi xâm hại phải đang diễn ra

Không phải trong mọi trường hợp khi có sự tấn công đều được áp dụng phòng vệ chính đáng. Mà chỉ được thực hiện quyền phòng vệ khi sự tấn công là bất hợp pháp, xâm hại lợi ích của Nhà nước của tập thể hoặc lợi ích chính đáng của công dân. Và sự tấn công có thể là tội phạm cũng có thể không phải là tội phạm, nhưng sự tấn công đó phải mang tính hiện thực, tức là nó phải đang xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc. Sự cho phép phòng vệ cả những trường hợp tấn công chưa xảy ra, nhưng có những biểu hiện đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khắc là một cần thiết khách quan nhằm tạo điều kiện phòng vệ ngăn chặn sự tấn công được kịp thời và hiệu quả.

Hành vi xâm hại đang xảy ra là đã bắt đầu và chưa kết thúc, đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ngay tức khắc cho các lợi ích cần bảo vệ. Sở dĩ luật hình sự coi hành vi xâm hại đang xảy ra mới được coi là phòng vệ chính đáng vì chỉ có như vậy mục đích ngăn chặn hành vi tấn công, bảo vệ các lợi ích hợp pháp mới đạt được.

Trường hợp hành vi xâm hại chưa bắt đầu mà đã thực hiện việc chống trả gây thiệt hại thì không coi là phòng vệ chính đáng (phòng vệ sớm).

Trường hợp hành vi xâm hại đã kết thúc mà vẫn còn chống trả và gây thiệt hại thì không phải là phòng vệ chính đáng (phòng vệ muộn).

Người thực hiện hành vi phòng vệ sớm hoặc phòng vệ muộn phải chịu trách nhiệm hình sự về những thiệt hại do hành vi của mình gây ra.

+ Phòng vệ chính đáng phải gây thiệt hại cho chính người đang có hành vi xâm hại

Điều kiện này xuất phát từ mục đích của phòng vệ chính đáng là nhằm gạt bỏ sự xâm hại, đẩy lùi sự tấn công để bảo vệ các lợi ích hợp pháp, cho nên phòng vệ chính đáng phải hướng sự chống trả của mình vào việc gây thiệt hại cho người đang có hành vi xâm hại. Có như vậy hành vi xâm hại mới được ngăn chặn kịp thời, nguồn gốc làm phát sinh ra nó mới bị loại trừ tận gốc.

Khi thực hiện hành vi phòng vệ không chỉ đơn thuần là đẩy lùi được sự tấn công là được, mà phải ngăn chăn chặn chính nguồn xâm hại. Vì vậy, nếu bằng mọi cách mà chỉ cần đạt được mục đích là đẩy lùi sự tấn công xâm hại thì cũng không phải là hành vi phòng vệ chính đáng. Ví dụ, người phòng vệ đã chọn giải pháp gây thiệt hại cho người thân của người xâm hại để người này dừng hành vi tấn công lại.

Khác với hành vi xâm hại có thể gây thiệt hại cho tất cả các lợi ích hợp pháp của Nhà Nước, tổ chức, cá nhân như tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản… hành vi chống trả chỉ được gây thiệt hại về sức khoẻ hay tính mạng cho người có hành vi xâm hại, đủ làm tê liệt nguồn gốc làm phát sinh sự tấn công, bảo vệ được các lợi ích hợp pháp.

+ Hành vi chống trả gây thiệt hại là sự cần thiết để bảo vệ lợi ích đang bị xâm hại

"Cần thiết" trong phòng vệ chính đáng, nghĩa là, trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, người bị tấn công nhận thức phải phòng vệ để bảo vệ các lợi ích chính đáng và sử dụng biện pháp chống trả nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự tấn công, đẩy lùi được hành vi xâm hại, bảo vệ được các lợi ích hợp pháp. Thể hiện tính không thể không chống trả, không thể bỏ qua trước một hành vi xâm hại đến các lợi ích của xã hội.

Về mặt lý luận, để đánh giá hành vi chống trả có "cần thiết" hay không phải dựa vào một loạt các yếu tố khách quan và chủ quan của hành vi phòng vệ cũng như hành vi xâm hại và những điều kiện, hoàn cảnh cụ

thể, các mối tương quan khác khi xảy ra sự việc. Cụ thể phải dựa vào những yếu tố sau đây:

* Tầm quan trọng của các lợi ích cần bảo vệ (quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ). Những lợi ích bị xâm hại càng quan trọng bao nhiêu thì đòi hỏi hành vi chống trả phải mạnh mẽ bấy nhiêu để ngăn chặn có hiệu quả sự tấn công, bảo vệ được các lợi ích hợp pháp.

* Tính chất của hành vi xâm hại.

* Tương quan lực lượng giữa bên tấn công và bên phòng vệ.

* Sự quyết tâm của người xâm hại. Thông thường thể hiện ở thái độ bất chấp sự can ngăn của người khác, bất chấp pháp luật, bất chấp sự răn đe cảnh cáo từ phía người phòng vệ...

* Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh cụ thể khác khi sự việc xảy ra.

* Nhân thân người có hành vi xâm hại.

* Yếu tố tâm lý của người phòng vệ…

Tóm lại, khi đánh giá hành vi chống trả có "cần thiết" hay không phải xem xét một cách toàn diện tất cả các tình tiết của vụ việc, việc đánh giá mức độ cần thiết chỉ là giới hạn tương đối. Do đó, người phòng vệ chỉ bị coi là vượt quá khi vượt quá mức cần thiết.

- Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này".*

Điều kiện bị coi là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và người phòng vệ phải chịu trách nhiệm hình sự là:

+ Đã có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện quyền phòng vệ của mình. Nghĩa là đang có hành vi phạm tội hoặc hành vi nguy hiểm đang xâm phạm trực tiếp đến các lợi ích cần được bảo vệ. Người phòng vệ có quyền thực hiện hành vi chống trả.

+ Hành vi tước đoạt tính mạng hoặc gây thương tích cho đối tượng đang tấn công xâm hại là không cần thiết mà rõ ràng là quá mức cần thiết để ngăn chặn lại sự tấn công.

- Phòng vệ tưởng tượng

Phòng vệ tưởng tượng là trường hợp người do lầm tưởng có sự tấn công của người khác nên đã có hành vi chống trả gây thiệt hại cho họ.

Các dạng lầm tưởng như:

+ Hoàn toàn không có sự tấn công mà cho là có mà thực hiện chống trả, là trường hợp phòng vệ đã gây thiệt hại cho người khác do lầm tưởng người này đang có hành vi xâm hại đến các lợi ích cần bảo vệ.

+ Có sự tấn công thật sự đang xâm hại nhưng nhầm lẫn đối tượng tấn công.

+ Sự tấn công không đáng kể nhưng người phòng vệ đánh giá sai tính chất của sự tấn công.

+ Có sự tấn công, nhưng xác định sai thời điểm tấn công tức là không phải đang diễn ra (phòng vệ quá sớm, là trường hợp phòng vệ đã gây ra thiệt hại trước khi hành vi xâm hại xảy ra hoặc phòng vệ quá muộn, là trường hợp phòng vệ đã gây ra thiệt hại sau khi hành vi xâm hại đã kết thúc).

Mọi trường hợp phòng vệ tưởng tượng đều không có cơ sở pháp lý để được thực hiện quyền phòng vệ do đó không được coi là phòng vệ chính đáng hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Do đó vấn đề trách nhiệm hình sự phải đặt ra nếu hành vi phòng vệ tưởng tượng gây thiệt hại rõ ràng là quá đáng và có đủ yếu tố cấu thành của một tội phạm độc lập.

3.2.7.2. Tình thế cấp thiết

- Khái niệm

Khoản 1 Điều 23 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm".*

- Điều kiện của tình thế cấp thiết

Hành vi gây thiệt hại cho xã hội được coi là tình thế cấp thiết phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

+ Có sự nguy hiểm đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của công dân

* Là những tình huống, sự cố, hiện tượng đang diễn ra gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tài sản của xã hội, tính mạng, sức khoẻ đối với con người. Nguồn của sự nguy hiểm đó có thể do con người gây ra, do

thiên nhiên, do súc vật gây ra. Ví dụ: mưa bão làm đổ cây, sét đánh gây cháy nổ, trâu bò chạy giẫm đạp lên người, những trục trặc, hư hỏng của máy móc...

* Sự nguy hiểm là có thật, sẽ gây thiệt hại ngay hoặc đang gây thiệt hại và chưa kết thúc, đe dọa ngay tức khắc các lợi ích hợp pháp. Ví dụ: Nhà đang cháy, thuyền sắp bị bão... nghĩa là nguồn nguy hiểm là có thật, tồn tại khách quan chứ không phải do suy đoán, tưởng tượng ra.

Nguồn nguy hiểm đang xảy ra và phải đe doạ ngay tức khắc các lợi ích cần bảo vệ nếu không được khắc phục kịp thời. Nếu nguồn nguy hiểm không có thật; hoặc chưa có nguy cơ thực tế đe doạ gây thiệt hại ngay tức khắc; hoặc đã kết thúc thì không được coi là tình thế cấp thiết.

+ Việc gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết là cách duy nhất để bảo vệ lợi ích hợp pháp khác

Biện pháp gây thiệt hại là duy nhất và cuối cùng. Nếu còn biện pháp khác tốt hơn, hợp lý hơn trong hoàn cảnh cụ thể đó mà không sử dụng thì không phải là tình thế cấp thiết.

+ Thiệt hại gây ra phải nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa

Mức độ thiệt hại phải nhỏ hơn thiệt hại cần bảo vệ. Nếu thiệt hại bằng hoặc lớn hơn thì không đạt được mục đích của tình thế cấp thiết.

Thiệt hại do hành vi trong tình thế cấp thiết gây ra là hiện hữu còn thiệt hại cần ngăn ngừa là trừu tượng, khó xác định. Mặt khác, trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đó họ có đủ bình tĩnh, sáng suốt để cân nhắc mức độ thiệt hại hay không. Do vậy, cần phải xem xét một cách toàn diện trong hoàn cảnh sự việc xảy ra để xác định có phải là tình thế cấp thiết hay không.

- Vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Khoản 2 Điều 23 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự".*

Thông thường vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết được hiểu là gây thiệt hại lớn hơn thiệt hại cần bảo vệ. Vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết khi phạm tội được coi là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự).

3.2.7.3. Sự kiện bất ngờ

Điều 20 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong*

trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự".

Một người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội được coi là sự kiện bất ngờ khi thoả mãn một trong hai trường hợp sau đây:

- Không thể thấy trước hậu quả cho xã hội của hành vi

Việc không thấy trước hậu quả là có cơ sở khoa học. Trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đó thì không thể thấy trước. Hai yếu tố làm căn cứ để đánh giá đó là:

+ Về khách quan: trong điều kiện, hoàn cảnh đó bất kỳ ai cũng không thể thấy trước.

+ Về chủ quan: xem xét các đặc điểm về nhân thân như: tuổi, sức khoẻ, trình độ hiểu biết... của người gây hậu quả.

- Không buộc phải thấy trước hậu quả cho xã hội của hành vi

Không buộc phải thấy trước là tuy có khả năng thấy trước được hậu quả nguy hại cho xã hội do hành vi của mình nhưng theo pháp luật không buộc họ phải thấy trước hậu quả của hành vi và nếu hậu quả xảy ra thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nguy hiểm đó.

3.2.7.4. Gây thiệt hại khi bắt giữ người phạm tội

Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được mô tả là "*Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ*". Đây là một chế định có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong thực tiễn, phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân và tính tích cực, chủ động của mỗi cá nhân trong công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Chế định tạo cơ sở pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân khi tham gia, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Để được coi là gây thiệt hại trong bắt giữ người phạm tội là một trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, phải thỏa mãn ba dấu hiệu: một là, hành vi bắt giữ phải thuộc về các chủ thể có thẩm quyền bắt giữ người phạm tội; hai là, hành vi dùng vũ lực gây thiệt hại cho người bắt giữ phải là biện pháp cuối cùng, không còn cách nào khác để bắt giữ người phạm

tội; ba là, hành vi dùng vũ lực gây thiệt hại cho người bị bắt giữ phải là cần thiết.

Đối với trường hợp người gây thiệt hại quá đáng cho người phạm tội tuy phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng pháp luật hình sự vẫn xác định đó là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 51 và trong một số tội liên quan đến việc bắt giữ người có hình phạt nhẹ hơn như *tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội* quy định tại Điều 126 và *tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội* quy định tại Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quy định này thể hiện chính sách hình sự của Nhà nước đối với các trường hợp phạm tội cụ thể, đảm bảo cơ chế pháp lý để mọi người dân có ý thức tôn trọng và bảo vệ pháp luật.

3.2.7.5. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Đây cũng là điều luật hoàn toàn mới trong quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của tính năng động, sáng tạo trong công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế của đất nước. Những đòi hỏi ấy là hệ quả tất yếu dẫn đến chính sách ưu tiên, tập trung phát triển kinh tế nhằm xóa nghèo cho Việt Nam, khuyến khích tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ mới.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật luôn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro gây thiệt hại cho người và tài sản bởi những tính năng hoàn toàn mới mà con người chưa đạt đến tầm nhận thức đó. Tính rủi ro này đặt ra hai vấn đề đối với xã hội, đó là: Nếu như sợ rủi ro, gây thiệt hại cho xã hội mà không có một cơ chế rõ ràng về chính sách hình sự để khuyến khích động viên các hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, thì vô hình chung điều đó sẽ trở thành nhân tố cản trở nền kinh tế phát triển, làm thui chột tài năng, triệt tiêu sự năng động, sáng tạo trong đời sống kinh tế. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam sẽ luôn lạc hậu, chậm tiến hơn so với các quốc gia trên thế giới. Nhưng nếu, cơ chế chính sách và quy định của pháp luật không chặt chẽ, sẽ dẫn đến hiện tượng làm bừa, làm ẩu gây thiệt hại cho xã hội và trốn tránh trách nhiệm.

Dự báo và cân nhắc những ưu điểm và hạn chế của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã đưa ra quy chuẩn định mức để xác định, phân loại đối với từng trường hợp gây thiệt hại cho xã hội:

- Đối với trường hợp người nghiên cứu nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới gây thiệt hại cho xã hội mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm. Người này chỉ được loại trừ trách nhiệm hình sự khi đã thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể phát sinh trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới. Hậu quả thiệt hại này không xuất phát từ ý thức chủ quan của người đó mà từ những đặc điểm, tính chất hoàn toàn mới của những ứng dụng tiến bộ đó mà con người chưa thể nhận biết được.

- Đối với người nghiên cứu nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới gây thiệt hại cho xã hội khi không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

3.2.7.6. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên

Điều luật được xây dựng mới xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, từ đặc điểm, tính chất của lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, Điều 26 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: "*Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự*".

Việc thi hành mệnh lệnh cấp trên gây thiệt hại cho xã hội chỉ không phải chịu trách nhiệm hình sự khi hội tụ đủ 3 điều kiện: (1) Chủ thể thực hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên phải là người làm trong lực lượng vũ trang nhân dân; (2) Thi hành mệnh lệnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; (3) Đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người chỉ huy hoặc cấp trên ra mệnh lệnh nhưng vẫn bị yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó.

Phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm là một phạm trù có nội hàm rất rộng, bao hàm toàn bộ các hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm trong lĩnh vực tư pháp như dùng nhục hình, bức cung... đối với người tham gia tố tụng như người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người làm chứng, người bị hại... để lấy lời khai của họ lại là những hành vi được xác định là tội phạm theo quy định tại Chương XXIV Bộ luật Hình sự năm 2015 (các tội xâm phạm hoạt động tư pháp). Quy định về việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp này không chỉ không phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, gây mâu thuẫn trong quy định giữa phần chung và phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự mà còn không phù hợp với Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác của Liên hợp quốc năm 1984.

Theo những quy định pháp luật hình sự thì không ai có quyền tra tấn người khác dưới bất kỳ hình thức gì, bằng bất cứ lý do nào. Một người có hành vi tra tấn, gây đau đớn về thể xác, tổn hại về sức khỏe, hoảng loạn về tinh thần cho người khác thì không thể biện minh cho lý do vì phục tùng mệnh lệnh cấp trên để phủ nhận tội ác của mình. Trong trường hợp này người có hành vi tra tấn, truy bức người khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Với những lý do trên, Bộ luật Hình sự năm 2015 chỉ khoanh cắt phạm vi của chế định này trong hai lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm đảm bảo giữ gìn thành trì hòa bình của quốc gia dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đồng thời vẫn thể hiện rõ chính sách hình sự của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, nâng cao tính hướng thiện trong xử lý hình sự. Thông qua quy định này, nguyên tắc kỷ luật của lực lượng vũ trang được đảm bảo tôn trọng nhưng không vì thế mà tạo ra kẽ hở để các đối tượng phạm tội lợi dụng tiến hành các hành vi đối xử ngược đãi với người khác, vi phạm trắng trợn quyền con người.

3.2.7.7. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự có thể hiểu là trường hợp người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do đang trong tình trạng mắc

bệnh tâm thần hoặc bệnh khác. Để xác định việc mất khả năng nhận thức hành vi hoặc mất khả năng điều khiển hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có kết luận giám định về hậu quả cũng như tính chất của hành vi nguy hiểm cho xã hội.

3.3. Hình phạt

3.3.1. Khái niệm hình phạt

Trong tất cả các biện pháp đấu tranh phòng và chống tội phạm thì hình phạt là một biện pháp cưỡng chế của Nhà nước có tính chất đặc biệt.

Khái niệm hình phạt được quy định cụ thể tại Điều 30 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017): *"Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy định trong Bộ luật này, do Tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại đó".*

Cùng với việc tước bỏ hoặc hạn chế những quyền và lợi ích thiết thân của người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội, hình phạt tác động trực tiếp đến người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội cũng như các thành viên khác trong xã hội. Luật hình sự đòi hỏi sự tác động của hình phạt trong thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đạt được những mục đích cụ thể.

Điều 31 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm".*

3.3.2. Đặc điểm

- Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước.

Trong hệ thống biện pháp cưỡng chế của nhà nước áp dụng đối với hành vi vi phạm pháp luật thì hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất. Hình phạt là biện pháp cưỡng chế của nhà nước vì hình phạt bắt buộc người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội phải chấp hành. Việc bắt buộc này do cơ quan đại diện của nhà nước là Tòa án quyết định. Hình phạt do nhà nước quy định thông qua cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước là Quốc hội.

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước vì hình phạt có thể tước bỏ hoặc hạn chế những quyền và lợi ích thiết thân nhất của người, pháp nhân thương mại bị kết án, như: quyền tự do, quyền chính trị (tước một số quyền công dân), quyền sở hữu (phạt tiền, tịch thu tài sản), quyền tự do kinh doanh và cả quyền sống của con người.

Hình phạt để lại cho người bị kết án hoặc pháp nhân thương mại bị kết án hậu quả pháp lý là án tích trong một thời gian nhất định. Trong thời gian chưa được xoá án tích nếu người đó tiếp tục phạm tội thì sẽ coi là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình phạt chính, người bị kết án hoặc pháp nhân thương mại bị kết án còn có thể chấp hành hình phạt bổ sung ngay sau khi đã chấp hành xong hình phạt chính như cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, cấm huy động vốn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định...

- Hình phạt áp dụng đối với cá nhân người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội.

Điều 2 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự".*

Theo luật hình sự Việt Nam, trách nhiệm hình sự là trách nhiệm của cá nhân hoặc pháp nhân thương mại, hình phạt áp dụng đối với cá nhân người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội. Hình phạt chỉ áp dụng cho người phạm tội, không được áp dụng cho các thành viên trong gia đình hoặc người thân thiết khác của người phạm tội, kể cả khi người phạm tội lẩn trốn. Vì người phạm tội là người có lỗi và đã gây ra thiệt hại cho xã hội nên cần trừng trị và giáo dục họ chứ không phải trừng trị và giáo dục người khác.

- Hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự và do Toà án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội.

Hiện nay Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là văn bản pháp luật hình sự duy nhất quy định các loại hình phạt; nội dung, điều kiện cho phép áp dụng; quy định khung hình phạt của từng tội phạm cụ thể.

Trong Bộ luật Hình sự, hình phạt được quy định ở cả phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Phần chung quy định những vấn đề lý luận chung nhất liên quan đến hình phạt như mục đích của hình phạt, hệ thống hình phạt, nội dung, điều kiện, phạm vi áp dụng của từng loại hình phạt cụ thể, vấn đề miễn hình phạt, quyết định hình phạt. Phần các tội phạm cụ thể hình phạt được quy định trong phần chế tài của tất cả các tội phạm cụ thể dưới hai dạng chế tài lựa chọn và chế tài tương đối dứt khoát.

Biện pháp cưỡng chế là hình phạt thì chỉ có Tòa án mới có quyền nhân danh Nhà nước quyết định áp dụng loại và mức hình phạt đối với người phạm tội. Người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội chỉ chịu hình phạt khi bản án của Tòa án đối với họ có hiệu lực pháp luật.

Việc áp dụng hình phạt đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội phải công khai. Khi quyết định hình phạt, Tòa án phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

3.3.3. Hệ thống hình phạt

Hệ thống hình phạt là tổng thể các loại hình phạt do Nhà nước quy định trong luật hình sự và được sắp xếp theo một trật tự nhất định tuỳ thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm khắc của mỗi loại hình phạt.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hệ thống hình phạt bao gồm các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung.

Hình phạt chính là hình phạt bắt buộc phải áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội và được Tòa án tuyên độc lập, phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Hình phạt bổ sung không được tuyên độc lập mà được tuyên kèm theo hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.

- Các hình phạt đối với người phạm tội

+ Các loại hình phạt chính

Thứ nhất, cảnh cáo: là sự khiển trách công khai của Nhà nước do Toà án tuyên đối với người bị kết án.

Cảnh cáo là hình phạt nhẹ nhất trong các hình phạt chính, không có khả năng đưa lại những hạn chế pháp lý liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích thiết thân về thể chất và tài sản,... của người bị kết án. Tuy vậy, với tư cách là khiển trách công khai của Nhà nước, đối với người phạm

tội, cảnh cáo gây ra cho họ những tổn hại nhất định về mặt tinh thần. Người bị phạt cảnh cáo đã phải chịu sự lên án của Nhà nước về hành vi phạm tội của mình.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người bị phạt cảnh cáo mang án tích trong thời hạn tối đa là 01 năm.

Phạm vi và điều kiện áp dụng hình phạt cảnh cáo được Điều 34 Bộ luật Hình sự quy định: *"Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt"*.

Thứ hai, phạt tiền: là buộc người bị kết án phải nộp một khoản tiền nhất định sung quỹ Nhà nước.

Với tư cách là một hình phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự thì hình phạt tiền mang tính nghiêm khắc nhất so với phạt tiền được quy định trong các biện pháp cưỡng chế khác của nhà nước.

Tính nghiêm khắc nhất của hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự thể hiện ở chỗ là nó tước đi ở người phạm tội một khoản tiền nhất định, nghĩa là trực tiếp làm hạn chế về mặt lợi ích vật chất của người phạm tội, đồng thời, người bị kết án phạt tiền còn phải gánh chịu hậu quả pháp lý là mang lại án tích trong một thời hạn theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền là buộc người bị kết án phải nộp một khoản tiền nhất định để sung quỹ Nhà nước trong những trường hợp do luật quy định. "Một khoản tiền nhất định" được hiểu là khoản nằm trong giới hạn giữa mức tối thiểu và mức tối đa của từng điều luật cụ thể trong phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự có quy định về hình phạt tiền. Hiện nay, Bộ luật Hình sự chỉ quy định mức phạt tiền tối thiểu là 1.000.000 đồng và không quy định mức tối đa. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả. Khi quyết định hình phạt và mức phạt tiền, Tòa án phải xem xét và cân nhắc đến các quy định của Bộ luật Hình sự; tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện; nhân thân người phạm tội; các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời có xem xét tới tình hình tài sản của người phạm tội và biến động của giá cả thị trường. Trên cơ sở đó, Tòa án có thể quyết định mức phạt tiền hợp lý, tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Có như vậy thì mới đảm bảo được tính khả thi của hình phạt tiền trên thực tế.

Phạt tiền là hình phạt được áp dụng là hình phạt chính hoặc áp dụng là hình phạt bổ sung, khi hình phạt chính là loại hình phạt khác. Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật Hình sự quy định; người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định và được áp dụng là hình phạt bổ sung khi hình phạt tiền không phải là hình phạt chính đối với người phạm tội về tham nhũng, mua túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định. Như vậy, hình phạt tiền chỉ được áp dụng là hình phạt chính hoặc là hình phạt bổ sung khi hình phạt chính không phải là hình phạt tiền đối người phạm tội trong số các tội phạm cụ thể được quy định trong phần các tội phạm Bộ luật Hình sự.

Hình phạt tiền đối với pháp nhân thương mại phạm tội được quy định tại Điều 77 của Bộ luật Hình sự.

Thứ ba, cải tạo không giam giữ: là không buộc người bị kết án phải cách ly khỏi xã hội mà giao cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục.

Trong hệ thống hình phạt mà Bộ luật Hình sự quy định thì hình phạt cải tạo không giam giữ có vị trí quan trọng, đây là hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn. Hình phạt này vừa thể hiện tính nghiêm khắc của Nhà nước, vừa thể hiện chính sách nhân đạo trong xử lý tội phạm...

Khác với hình phạt tù, cải tạo không giam giữ không buộc người bị kết án phải cách ly với xã hội. Do vậy, trong thực tiễn xét xử, cải tạo không giam giữ được áp dụng khi đủ các điều kiện:

Hình phạt cải tạo không giam giữ chỉ áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng.

Người phạm tội phải có nơi làm việc ổn định, hoặc nơi thường trú rõ ràng (việc luật quy định như vậy là vừa tạo điều kiện thuận lợi giúp người bị kết án có thể lao động cải tạo tốt, vừa là điều kiện để việc áp dụng hình phạt có hiệu quả. Bản chất của hình phạt cải tạo không giam giữ là không tước tự do của người bị kết án nhưng mục đích trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội vẫn đạt được khi người bị kết án chịu sự giám sát của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, gia đình nơi người đó làm việc, học tập hoặc cư trú).

Xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội với xã hội: Điều kiện này đòi hỏi Tòa án phải phân tích, đánh giá một cách toàn diện những tình tiết ảnh hưởng đến tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, những đặc điểm về nhân thân của người phạm tội có ảnh hưởng đến khả năng tự cải tạo, giáo dục của họ cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

Khi áp dụng hình phạt này, Tòa án giao người bị kết án cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi người đó làm việc hoặc thường trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong thời gian chấp hành án, người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án. Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ trong 01 ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần. Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

Thứ tư, trục xuất: là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng giống như hình phạt tiền, trục xuất mang tính chất vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung trong hệ thống hình phạt của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa hình phạt trục

xuất với các hình phạt còn lại ở chỗ nếu các hình phạt khác có thể áp dụng chung cho tất cả mọi chủ thể thực hiện hành vi phạm tội thì trục xuất là hình phạt chỉ được áp dụng đối với chủ thể là người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam và theo quyết định của Tòa án nhân dân trong một thời hạn nhất định thì người đó bắt buộc phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Người nước ngoài" được hiểu là "người không có quốc tịch Việt Nam". Từ khái niệm này có thể hiểu người nước ngoài là người mang quốc tịch của một nước khác và người không mang quốc tịch của bất kỳ một nước nào (người không có quốc tịch). Tuy nhiên, ở đây cũng có một trường hợp biệt lệ cần lưu ý là, trục xuất sẽ không được áp dụng đối với người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam. Cụ thể với đối tượng này, Tòa án có thể áp dụng một trong các hình phạt chính khác căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà họ đã thực hiện. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

Thứ năm, tù có thời hạn: là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Hình phạt tù có thời hạn là một loại hình phạt nghiêm khắc, vì người bị kết án bị tước tự do, bị cách ly với xã hội, họ phải lao động cải tạo trong trại giam dưới sự quản lý và giám sát của lực lượng cảnh sát. Chế độ cải tạo cũng như việc chấp hành hình phạt tù có thời hạn theo Luật Thi hành án hình sự và Nghị định của Chính phủ.

Hình phạt tù có thời hạn trong luật hình sự Việt Nam tuy là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc, nhưng không mang tính chất trả thù hay hành hạ người bị kết án mà có ý nghĩa cải tạo giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội. Trong thời gian chấp hành hình phạt, nếu họ tiến bộ thì được xét giảm mức hình phạt. Thực tiễn cho thấy hầu hết những người bị phạt tù có thời hạn đều được giảm và được trả lại tự do trước thời hạn.

Mức tối thiểu và tối đa đối với hình phạt tù có thời hạn được quy định trong các điều luật và trong từng khung hình phạt cụ thể không hoàn

toàn giống với mức tối thiểu và tối đa quy định cho loại hình phạt này, mà tùy thuộc và từng tội phạm, từng trường hợp phạm tội cụ thể mà nhà làm luật quy định mức tối thiểu và tối đa cho phù hợp. Có tội phạm nhà làm luật chỉ quy định mức tối thiểu là ba tháng và mức tối đa là hai năm, nhưng có tội phạm phải quy định mức tối thiểu là mười năm và tối đa là hai mươi năm. Nếu khung hình phạt quy định mức tối thiểu cao hơn ba tháng tù thì khi quyết định hình phạt Tòa án có thể phạt bị cáo dưới mức tối thiểu của khung hình phạt, nhưng không được xuống dưới quá ba tháng tù.

Với khả năng kết hợp tối đa giữa thuyết phục với cưỡng chế, giữa trừng trị với giáo dục cải tạo và phòng ngừa tội phạm, tù có thời hạn là loại hình phạt có tính chất phổ biến và thông dụng nhất trong pháp luật Việt Nam. Tù có thời hạn được quy định đối với hầu hết các tội phạm cụ thể trong Bộ luật Hình sự.

Người bị kết án bị Tòa án áp dụng hình phạt tù có thời hạn, nếu trước đó họ đã bị tạm giữ hoặc tạm giam, thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù.

Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.

Thứ sáu, tù chung thân: là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Tù chung thân giống tù có thời hạn ở chỗ hình phạt này đều tước tự do của người bị kết án, cách ly họ khỏi xã hội để cải tạo, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Nhưng khác với tù có thời hạn, tù chung thân không có thời hạn, nghĩa là nó có khả năng tước tự do của người bị kết án đến hết đời.

Với tính chất là một hình phạt nặng hơn tù có thời hạn và nhẹ hơn hình phạt tử hình, tù chung thân giúp cho việc thực hiện đường lối xử lý tội phạm được sát hợp với thực tế phức tạp và đa dạng của tình hình tội phạm. Thông thường trong thực tiễn, hình phạt tù chung thân được áp dụng đối với những trường hợp mà nếu áp dụng tù có thời hạn vẫn còn nhẹ nhưng nếu phạt tử hình thì chưa thật cần thiết.

Về mặt luật định, giữa hình phạt tù chung thân và tử hình không có ranh giới rõ ràng về điều kiện áp dụng. Điều 39 Bộ luật Hình sự quy định điều kiện áp dụng tù chung thân dưới một dạng tổng quát là: *"...được áp*

dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình". Đối với đa số các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Bộ luật Hình sự thường quy định cả tù chung thân và tử hình trong cùng chế tài để Tòa án lựa chọn áp dụng vào những trường hợp phạm tội cụ thể.

Vì vậy, việc áp dụng đúng đắn hình phạt tù chung thân đòi hỏi Tòa án phải phân tích vụ án một cách cụ thể, vận dụng đường lối xử lý phù hợp với chính sách hình sự của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa riêng và phòng ngừa chung. Do tính chất nghiêm khắc của hình phạt tù chung thân, Bộ luật Hình sự Việt Nam không cho phép áp dụng hình phạt này đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Thứ bảy, tử hình: là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật Hình sự quy định.

Hình phạt tử hình là một hiện tượng xã hội mang tính khách quan. Nó là phương tiện để bảo vệ mình của xã hội chống lại sự vi phạm các điều kiện tồn tại của nó. Tội phạm đe dọa sự tồn tại của xã hội nên xã hội phải phản ứng một cách tự nhiên là trừng trị người phạm tội. Là một loại hình phạt, nên hình phạt tử hình cũng như các hình phạt khác trong hệ thống hình phạt, có những đặc điểm chung, như: là một biện pháp cưỡng chế của Nhà nước; được quy định trong pháp luật hình sự; được Tòa án áp dụng theo một trình tự tố tụng chặt chẽ, công bằng đối với người bị kết án.

Với tư cách là một hình phạt đặc biệt, hình phạt tử hình có những đặc điểm riêng, đó là: Thứ nhất, tử hình là một loại hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt, nó tước đi quyền sống của người bị kết án, vì thế nó chỉ được quy định áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; Thứ hai, hình phạt tử hình có mục đích phòng ngừa tái phạm tội một cách triệt để từ phía người bị kết án. Hình phạt này không có mục đích cải tạo, giáo dục người bị kết án, như vậy nó tước bỏ cơ hội tái hòa nhập và phục thiện của họ; Thứ ba, hình phạt tử hình có khả năng đem lại hiệu quả cao trong phòng ngừa chung; Thứ tư, hình phạt tử hình có tính chất không thay đổi, nó tước đi khả năng khắc phục sai lầm trong hoạt động tư pháp.

Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; Người bị kết án

tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Trong các trường hợp nêu trên hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.

+ Các loại hình phạt bổ sung

Thứ nhất, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó, thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Đây là hình phạt bổ sung, được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án tiếp tục đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định nào đó sau khi chấp hành hình phạt tù hoặc sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, nếu là hình phạt chính khác thì họ có thể lại có điều kiện phạm tội mới.

Áp dụng hình phạt bổ sung này nhằm tăng cường hiệu quả của hình phạt chính đã áp dụng đối vối ngươi bị kết án củng cố hiệu quả của hình phạt chính đó bằng cách tước bỏ người bị kết án môi trường (cương vị công tác, lĩnh vực hành nghề…) có thể tạo điều kiện cho họ dễ dàng phạm tội lại.

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm. Thời điểm tính thời hạn là: Nếu hình phạt chính là tù có thời hạn thì thời hạn cấm tính từ ngày chấp hành xong hình phạt; nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo thì thời hạn tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, cấm cư trú

Cấm cư trú là hình phạt bổ sung áp dụng đối với người bị kết án phạt tù, buộc người đó không được tạm trú và thường trú từ một năm đến năm năm ở một số địa phương nhất định, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tự do cư trú là quyền của mọi công dân được pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực thực hiện. Tuy nhiên, đối với người phạm tội bị phạt tù, khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, nhân thân người phạm tội và yêu cầu phòng ngừa, tòa án có thể tuyên cấm cư trú ở

một số địa phương nhất định để tước đi khả năng sử dụng những điều kiện vốn có của địa phương để hoạt động phạm tội. Địa phương có thể bị cấm cư trú là: Thành phố lớn và khu công nghiệp tập trung; khu vực biên giới, bờ biển, hải đảo; khu vực có những cơ sở quốc phòng quan trọng; khu vực có các đầu mối giao thông quan trọng… Đây là những địa phương cần thiết phải bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mức độ cao.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thi hành hình phạt cấm cư trú có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, giám sát, giáo dục, tạo điều kiện giúp đỡ người bị kết án làm ăn, sinh sống, ngăn chặn không để họ tiếp tục vi phạm pháp luật và thi hành nghiêm chỉnh bản án của Tòa án.

Người bị cấm cư trú có nghĩa vụ: Không được cư trú ở những nơi đã bị cấm theo quyết định của tòa án, phải cư trú ở nơi khác; trình diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi được đến cư trú, xuất hành giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù, bản nhận xét về kết quả chấp hành án phạt tù của trại giam, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Người bị cấm cư trú có quyền: Khi có lý do chính đáng, có thể được phép đến địa phương đã bị cấm cư trú nơi có nhân thân, gia đình đang sinh sống hoặc quê quán nếu được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đến quyết định nhưng mỗi lần không được quá 5 ngày; được tự do cư trú ngoài những nơi bị cấm; không bị hạn chế việc đi lại, hành nghề hoặc làm công việc nếu không có bản án hoặc quyết định khác của tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc đó và không thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; được đề nghị Ủy ban nhân dân xã nơi mình cư trú làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại khi đủ điều kiện. Các điều kiện đó là: Đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời hạn cấm cư trú; tích cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi đang cư trú đề nghị.

Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Thứ ba, quản chế

Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người

bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật Hình sự và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do Bộ luật Hình sự quy định.

Thời hạn quản chế là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Thứ tư, tước một số quyền công dân

Tước một số quyền công dân là hình phạt bổ sung được áp dụng với công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp Bộ luật Hình sự quy định. Công dân trong trường hợp pháp luật quy định có thể bị tước một hoặc một số quyền sau:

Tước quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước: Theo đó, trong thời gian bị tước quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước, người chấp hành án không được tham gia ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực nhà nước.

Tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước: Trong thời gian bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước, người chấp hành án không được phép dự tuyển hoặc tiếp tục làm việc trong cơ quan nhà nước. Trường hợp người chấp hành án đang là cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước mà bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước thì cơ quan nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc thôi việc hoặc đình chỉ công tác trong thời hạn bị tước quyền làm việc trong cơ quan nhà nước đối với người đó.

Tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân: Trong thời gian bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, người chấp hành án không được đăng ký nghĩa vụ quân sự; dự tuyển hoặc tiếp tục làm công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân; dự tuyển hoặc tiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân. Trường hợp người chấp hành án đang là quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng trong Quân đội nhân dân hoặc đang phục vụ trong cơ quan, đơn vị Công an nhân dân mà bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân thì cơ quan, đơn vị nơi người đó làm việc phải ra quyết định hoặc đề

nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc người đó ra khỏi lực lượng vũ trang nhân dân.

Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

Thứ năm, tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án sung quỹ Nhà nước.

Tịch thu tài sản là hình phạt bổ sung và nó chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp phạm tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng đều bị tịch thu tài sản, mà chỉ áp dụng đối với trường hợp do phạm tội mà có một khối tài sản bất chính (thu nhập bất chính), hoặc nếu không tịch thu tài sản của họ thì có thể họ dùng tài sản đó để thực hiện tội phạm mới như đối với người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, tuy họ không có thu nhập bất chính nhưng nếu không tịch thu tài sản của họ thì sẽ có nguy cơ họ lại tiếp tục phạm tội. Trong các trường hợp không phải người bị kết án phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia thì hình phạt tịch thu tài sản chủ yếu áp dụng đối với người bị kết án phạm các tội có liên quan đến tài sản.

Khác với hình phạt cấm cư trú và hình phạt quản chế chỉ áp dụng đối với người bị kết án phạt tù, hình phạt tịch thu tài sản áp dụng đối với cả người bị kết án bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất hoặc được hưởng án treo.

Về nguyên tắc, khi áp dụng hình phạt tịch thu tài sản thì không có nghĩa là Tòa án không được áp dụng hình phạt phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với người bị kết án nữa. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử, các Tòa án thường chỉ áp dụng một trong hai loại hình phạt, hoặc là tịch thu tài sản hoặc là phạt tiền. Nếu áp dụng hình phạt tiền mà mức tiền phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự chưa có tác dụng tước đoạt những khoản thu nhập bất chính của người bị kết án thì Tòa án áp dụng hình phạt tịch thu tài sản, nếu điều luật quy định cả hai loại hình phạt này.

Việc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của người bị kết án là căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm do người bị kết

án gây ra, căn cứ vào tình hình tài sản của người bị kết án, những khoản thu nhập bất chính có liên quan đến tội phạm. Trong trường hợp tịch thu một phần tài sản, Tòa án phải tuyên rõ tịch thu những tài sản gì, phần tài sản nào, không nên tuyên tịch thu một phần ba hoặc một phần hai tài sản của người bị kết án sẽ gây khó khăn trong việc thi hành án. Trong trường hợp tuyên tịch thu toàn bộ tài sản, thì Tòa án vẫn phải để lại cho người bị kết án và gia đình họ một số tài sản để họ có điều kiện sinh sống, trong bản án phải ghi rõ để lại những tài sản nào. Các tài sản như: đồ nữ trang, quần áo, các vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của gia đình người bị kết án không được tịch thu.

Chỉ tịch thu tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án, đối với tài sản thuộc sở hữu chung theo phần hoặc sở hữu chung hợp nhất, trước khi tuyên bố tịch thu phần của người bị kết án, phải xác định phần quyền sở hữu của người bị kết án là bao nhiêu, là những thứ gì, nếu tài sản không thể chi được thì tuyên tịch thu phần giá trị của tài sản đó và quyết định kê biên tài sản đó để đảm bảo thi hành án.

Thứ sáu, phạt tiền khi không áp dụng là hình phạt chính

Phạt tiền là hình phạt bổ sung được áp dụng đối với người bị kết án về các tội tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định, nhằm buộc người bị kết án phải nộp một khoản tiền nhất định sung quỹ nhà nước.

Đối tượng áp dụng: Người bị kết án về các tội tham nhũng, ma tuý hoặc nhũng tội phạm khác do Bộ luật Hình sự quy định khi không áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền.

Nội dung hình phạt: Buộc người phạm tội phải nộp một khoản tiền nhất định sung quỹ Nhà nước, nhưng không thấp hơn một triệu đồng; Khi áp dụng hình phạt tiền có xem xét đến tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người bị kết án, sự biến động giá cả.

Thứ bảy, trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính

Trục xuất là hình phạt bổ sung được áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: Người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung hình phạt: Buộc người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các biện pháp tư pháp

Nhằm đa dạng các biện pháp cưỡng chế hình sự, ngoài việc quy định hệ thống hình phạt, Bộ luật Hình sự còn quy định các biện pháp tư pháp.

Các biện pháp tư pháp là những biện pháp cưỡng chế của nhà nước được các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội hoặc người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhằm ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội hoặc gây nguy hiểm cho xã hội, giáo dục họ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Trước hết, các biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế của Nhà nước nhưng không phải là hình phạt có tác dụng hỗ trợ hoặc thay thế hình phạt khi có những điều kiện nhất định, giúp cho việc xử lý tội phạm được triệt để.

Chủ thể áp dụng không chỉ có Tòa án mà còn các cơ quan tiến hành tố tụng khác. Thời điểm áp dụng các biện pháp tư pháp là tất cả các giai đoạn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án.

Đối tượng áp dụng: người phạm tội; pháp nhân thương mại phạm tội; người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Việc áp dụng các biện pháp tư pháp có tác dụng đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của những người tham gia quá trình giải quyết vụ án hình sự như người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan, đồng thời có thể ngăn ngừa người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội tiếp tục phạm tội mới, giáo dục người phạm tội hoặc người có hành vi nguy hiểm cho xã hội ý thức tôn trọng pháp luật, trở thành công dân có ích cho xã hội thể hiện sâu sắc tính nhân đạo trong chính sách hình sự của nhà nước đối với người phạm tội.

Các biện pháp tư pháp cụ thể:

Các biện pháp tư pháp được quy định tại chương VII Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Chương này bao gồm 04 điều luật, trong đó có 01 điều luật quy định về hệ thống các biện pháp tư pháp được áp dụng đối với cả người phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội và 03 điều luật quy định về các biện pháp tư pháp cụ thể được áp dụng đối với người phạm tội. Các biện pháp đó bao gồm:

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi.

Điều 49. Bắt buộc chữa bệnh.

Cùng với hình phạt, các biện pháp tư pháp được xác định là hệ thống các biện pháp xử lý hình sự thứ hai mang tính cưỡng chế nghiêm khắc của Nhà nước áp dụng đối với người phạm tội. Biện pháp này được áp dụng trong những trường hợp đặc biệt nhất định nhằm thay thế hình phạt hoặc nhằm bổ trợ làm tăng hiệu quả của hình phạt.

Bên cạnh các biện pháp tư pháp được áp dụng đối với người phạm tội quy định tại Khoản 1 Điều 46, Bộ luật Hình sự cũng liệt kê các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội tại Khoản 2 Điều này. Các biện pháp đó gồm: 1) Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; 2) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; 3) Khôi phục lại tình trạng ban đầu; 4) Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

Như vậy, biện pháp tư pháp được áp dụng đối với người phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội có sự tương đồng, đồng thời cũng có sự khác biệt căn cứ vào tính chất, đặc điểm của chủ thể thực hiện tội phạm cũng như khả năng áp dụng những biện pháp đó trên thực tế.

- Căn cứ quyết định hình phạt

Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: *"1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, Tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội".*

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Hình sự, những căn cứ có tính nguyên tắc, đòi hỏi bắt buộc Tòa án phải tuân thủ khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội là:

- Các quy định của Bộ luật Hình sự.

- Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

- Nhân thân người phạm tội.

- Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Giữa các căn cứ quyết định hình phạt trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau và luôn thể hiện trong một thể thống nhất. Khi quyết định hình phạt, Tòa án phải nắm vững nội dung, ý nghĩa pháp lý của từng căn cứ có tính nguyên tắc đó cũng như mối liên hệ giữa chúng.

Ngoài ra, tại Điều 83 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội, theo đó: *"Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp luật của pháp nhân thương mại và các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại".*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Hiến pháp năm2013*, Nxb Chính trị Quốc gia.
2. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
3. Nghị quyết 41/2017/QH14 về hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2017.
4. Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.
5. Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), *Giáo trình Luật Hình sự*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
6. Trường Đại học Luật Hà Nội (2004), *Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
7. Trường Đại học Luật TP HCM (2013), *Giáo trình Luật Hình sự - phần các tội phạm*, Nxb Hồng Đức.
8. Trường Đại học Luật TP HCM (2015), *Giáo trình Pháp luật đại cương*, Nxb Sư phạm.
9. Trường Đại học Kinh tế TP HCM (2016), *Giáo trình Pháp luật đại cương*, Nxb Đại học Kinh tế TP HCM.
10. Đinh Văn Quế (2018), *Bình luận Bộ luật Hình sự 2015 - Phần thứ nhất những quy định chung*, Nxb Thông tin và Truyền thông.
11. Nguyễn Minh Toàn (2012), *Giáo trình Pháp luật đại cương*, Nxb Chính trị Quốc gia.
12. Đoàn Công Thức (2015), *Pháp luật đại cương*, Nxb Đại học Quốc gia TP HCM.

CHƯƠNG 4
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT DÂN SỰ

4.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể của luật dân sự

4.1.1. Khái niệm

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, ngành luật dân sự đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là ngành luật chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh nhiều quan hệ xã hội cơ bản cốt lõi, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của cuộc sống bao gồm quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của các chủ thể trong giao lưu dân sự. Luật dân sự được xem là luật chung trong lĩnh vực luật tư, bao gồm các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của chủ thể và về nguyên tắc có thể thay đổi bằng những thỏa thuận của các bên[103]. Cụ thể, luật dân sự được xem là luật chung của các luật thương mại, luật lao động, luật hôn nhân và gia đình,… trong trường hợp các quan hệ xã hội được các luật này điều chỉnh này không có quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp thì áp dụng các quy phạm của bộ luật dân sự để điều chỉnh.

Dưới góc độ của một ngành luật thì luật dân sự được hiểu *là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa, tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ đó.*

Khái niệm trên đã nêu rõ các đặc điểm của ngành luật dân sự. Là một ngành luật nên luật dân sự là một tổng thể các quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh về một nhóm các quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực nhất định trong đời sống xã hội. Nhóm quan hệ xã hội mà luật dân sự điều chỉnh là nhóm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản như đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ, hợp đồng, bồi thường thiệt hại, thừa kế,… và các quan hệ xã hội này được tác động bằng cách ghi nhận sự bình đẳng, độc lập và tôn trọng thỏa thuận của các chủ thể khi tham gia.

4.1.2. Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự

Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự bao gồm quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Tuy nhiên quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản là những

[103] Trường Đại học Luật Hà Nội, *Giáo trình Luật dân sự 1*, Nxb Công an nhân dân, 2020, tr.19.

quan hệ phổ biến, chủ yếu và có nhiều nội dung phức tạp được nhiều ngành luật khác nhau điều chỉnh ở các góc độ khác nhau. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân mà luật dân sự điều chỉnh gồm có các đặc điểm riêng khác biệt.

* *Quan hệ tài sản*

Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản. Quan hệ tài sản bao giờ cũng gắn với một tài sản nhất định được thể hiện dưới dạng này hay dạng khác. Quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự rất đa dạng và phức tạp

Sự đa dạng và phức tạp thể hiện ở điểm quan hệ tài sản gồm nhiều chủ thể, khách thể và nội dung khác nhau.

Chủ thể của quan hệ tài sản có thể là Nhà nước, cá nhân, pháp nhân, công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch. Với mỗi loại quan hệ tài sản cụ thể, Luật sẽ điều chỉnh và xác định điều kiện cho từng loại chủ thể khác nhau chẳng hạn như chủ thể nào có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản, chủ thể nào có quyền để và nhận thừa kế, chủ thể nào có quyền tự mình xác lập, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến một tài sản nhất định,…

Khách thể của quan hệ tài sản trong luật dân sự cũng rất rộng gồm nhiều quan hệ xã hội khác nhau từ quan hệ sở hữu tài sản; quan hệ nghĩa vụ dân sự; quan hệ hợp đồng dân sự; quan hệ bồi thường thiệt hại; quan hệ chuyển quyền sử dụng đất; quan hệ thừa kế;… mỗi nhóm quan hệ này lại có nhiều đối tượng tác động khác nhau liên quan đến vật, tiền, giấy tờ có giá, tài sản hữu hình, vô hình, tài sản hiện tại, tài sản hình thành trong tương lai.

Nội dung của quan hệ tài sản được luật dân sự điều chỉnh gồm những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể gắn với vật cụ thể (quan hệ vật quyền) như các quy định về cách thức xác lập quyền sở hữu đối với vật và những quyền, nghĩa vụ giữa người với người thông qua một tài sản nhất định (quan hệ trái quyền) như các giao dịch mua, bán tặng cho, thuê, gia công,…

Ngoài ra, quan hệ quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự còn mang tính chất hàng hóa, tiền tệ và tính chất đền bù tương đương. Các quan hệ tài sản thường được hình thành theo quy luật giá trị, chủ yếu thông qua hình thức tiền hàng; có thể tính toán đo lường được trị giá của nó; và có sự đền bù ngang giá.

* *Quan hệ nhân thân*

Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân nhất định. Luật dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân bằng cách quy định những giá trị nhân thân nào được coi là quyền nhân thân, trình tự thực hiện, giới hạn các quyền nhân thân đó, đồng thời quy định các biện pháp để bảo vệ quyền nhân thân.

Các quan hệ nhân thân được chia thành hai nhóm: quan hệ nhân thân gắn với tài sản và quan hệ nhân thân không gắn với tài sản.

- Quan hệ nhân thân gắn với tài sản: là những giá trị nhân thân khi được xác lập làm phát sinh quyền tài sản. Ví dụ như: quyền tác giả trong các tác phẩm văn học nghệ thuật; quyền tác giả của sáng chế, giải pháp hữu ích;…

- Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản: Ví dụ như danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân, quyền đối với họ tên, bí mật đời tư,…

Khi quyền nhân thân đó bị xâm phạm thì chủ thể có quyền tự mình cải chính, yêu cầu người có hành vi xâm phạm hoặc yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc yêu cầu Tòa án buộc người vi phạm phải bồi thường một khoản tiền để bồi thường thiệt hại về tinh thần.

4.1.3. Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự

Phương pháp điều chỉnh của luật dân sự là những biện pháp mà Nhà nước tác động lên các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản làm cho các quan hệ này phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo ý chí của Nhà nước phù hợp với lợi ích Nhà nước, lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân.

Phương pháp chủ yếu và đặc trưng của pháp luật dân sự là bình đẳng thỏa thuận:

Một là, các bên bình đẳng với nhau về địa vị pháp lý. Khi tham gia vào quan hệ dân sự, các bên có sự độc lập về tổ chức và tài sản, độc lập về ý chí, độc lập về tư cách chủ thể. Không có sự phân chia cao thấp, trên dưới, không bên nào có quyền áp đặt ý chí buộc bên kia phải thực hiện theo. Các bên có cùng quyền và nghĩa vụ như nhau khi ở cùng một vai trò trong cùng những điều kiện, hoàn cảnh mà luật dân sự dự liệu điều chỉnh.

Hai là, các bên có quyền tự định đoạt. Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn thể hiện tự do ý chí của mình trong việc tự lựa chọn chủ thể tham gia quan hệ, tự lựa chọn biện pháp, cách thức giải quyết khi phát sinh hành vi vi phạm của một bên hoặc khi có tranh chấp khác. Mặc dù vậy, sự

tự định đoạt này cũng có những giới hạn nhất định là phải tuân thủ nguyên tắc "Việc xác lập thực hiện chấm dứt nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác".

Ba là, đặc trưng của phương pháp giải quyết tranh chấp trong dân sự là hòa giải. Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp có sự tham gia của bên thứ ba để hỗ trợ, thuyết phục các bên tìm kiếm giải pháp để loại trừ mâu thuẫn phát sinh. Hòa giải có thể tiến hành ngoài tố tụng và trong tố tụng. Phương pháp này sẽ tạo điều kiện cho các bên cân bằng được lợi ích của mình và lợi ích của bên kia tránh những xung đột căng thẳng không cần thiết.

4.1.4. Chủ thể của luật dân sự

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự được Bộ luật Dân sự 2015 quy định gồm: cá nhân và tổ chức.

4.1.4.1. Cá nhân

Để tham gia vào các quan hệ dân sự, cá nhân phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi:

- Năng lực pháp luật của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

Quyền dân sự của cá nhân được ghi nhận cụ thể trong tất cả các phần của Bộ luật Dân sự như: các quyền về nhân thân "quyền xác định dân tộc; quyền về hình ảnh; quyền bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe…; quyền về tài sản: quyền sở hữu, quyền hưởng thừa kế...". Năng lực pháp luật của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và mất khi người đó chết. Trong một số trường hợp đặc biệt, tư cách chủ thể của cá nhân có thể bị tạm dừng hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan. Cụ thể, trong những điều kiện nhất định một cá nhân có thể bị tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố chết.

+ Điều 68, Bộ luật Dân sự 2015 quy định điều kiện để tuyên bố một người mất tích như sau:

Khi một người biệt tích 02 năm liền trở đi, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về người đó đã chết hay còn sống thì theo yêu cầu của người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo

tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

+ Điều 81, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về điều kiện tuyên bố là đã chết như sau:

- Sau 3 năm kể từ ngày tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có tin tức là người đó còn sống.
- Biệt tích 05 năm liền trở lên mà không có tin tức còn sống hay đã chết.
- Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống.
- Bị tai nạn hoặc thảm họa thiên tai mà sau 02 năm kể từ ngày chấm dứt các sự kiện đó mà không có tin tức là còn sống.

- Năng lực hành vi dân sự là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập và thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi thì năng lực hành vi dân sự của cá nhân được chia thành các mức độ:

+ Năng lực hành vi đầy đủ:

Người thành niên (người từ đủ mười tám tuổi trở lên) được xem là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Những người này được quyền tự mình thực hiện các giao dịch dân sự và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự.

+ Năng lực hành vi một phần: Người có năng lực hành vi một phần hay không đầy đủ là người chỉ có thể xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trong một giới hạn nhất định.

- Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
- Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

+ Không có năng lực hành vi: Người không có năng lực hành vi là người chưa đủ sáu tuổi. Các giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

+ Mất năng lực hành vi dân sự: Khi một người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức hoặc làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở của tổ chức giám định. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

+ Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của người này, người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

+ Hạn chế năng lực hành vi dân sự: Người nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền và lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác.

4.1.4.2. Pháp nhân

Ngoài chủ thể là cá nhân khi tham gia vào các quan hệ dân sự thì còn có các tổ chức. Để các tổ chức này tham gia vào quan hệ pháp luật cần đáp ứng các điều kiện cần thiết cho mỗi loại quan hệ. Pháp luật dân sự đưa ra khái niệm pháp nhân để phản ánh địa vị pháp lý của một tổ chức nhằm phân biệt với một thể nhân.

- Các điều kiện của pháp nhân:

Theo Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, một tổ chức được xem là pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Được thành lập một cách hợp pháp theo quy định của Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan: Một tổ chức được xem là thành lập hợp pháp khi sự ra đời và hoạt động của tổ chức đó được Nhà nước công nhận dưới các hình thức như được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, được đăng ký thành lập hoặc được công nhận theo quy trình, thủ tục, điều kiện thành lập nhất định:

+ Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: Pháp nhân phải có cơ quan điều hành. Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.

+ Có tài sản độc lập và chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản đó: Để có thể tham gia vào các quan hệ tài sản một cách độc lập thì chủ thể đó phải có tài sản riêng của mình. Tài sản này độc lập với thành viên của pháp nhân, độc lập với chủ sở hữu của pháp luật. Pháp nhân có quyền tự mình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó theo quy chế của mình và pháp luật của Nhà nước.

+ Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập: Là một chủ thể riêng biệt, pháp nhân sẽ tham gia xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quan hệ pháp luật với các chủ thể khác bằng chính tên của mình, bằng chính địa vị pháp lý của mình. Pháp nhân tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật.

- Các loại pháp nhân:

Căn cứ vào nhiệm vụ, mục đích và hình thức sở hữu, có thể chia pháp nhân thành các loại như:

+ Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.

+ Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận, nếu có lợi nhuận cũng không được phân chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

- Địa vị pháp lý và hoạt động của pháp nhân:

Giống với các chủ thể khác khi tham gia vào các quan hệ pháp luật, pháp nhân cũng cần phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực

pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

Mọi hoạt động của pháp nhân được thực hiện thông qua hành vi của cá nhân – người đại diện của pháp nhân.

+ Đại diện theo pháp luật: Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Đại diện theo ủy quyền: Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác thay mình nhân danh pháp nhân thực hiện các giao dịch.

4.1.4.3. Các chủ thể khác

Ngoài cá nhân và pháp nhân thì khi tham gia các quan hệ dân sự còn có các chủ thể sau:

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương khi tham gia quan hệ dân sự thì bình đẳng với các chủ thể khác và chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự của mình bằng tài sản mà mình là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, trừ trường hợp tài sản đã được chuyển giao cho pháp nhân.

- Trường hợp chủ thể trong quan hệ dân sự có sự tham gia của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Bộ luật Dân sự 2015 không đưa ra định nghĩa về hộ gia đình và tổ hợp tác nhưng có ghi nhận sự tham gia của hai chủ thể này trong quan hệ dân sự. Theo đó trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biết.

Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện.

4.2. Quyền nhân thân

4.2.1. Khái niệm, đặc điểm quyền nhân thân

Quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với giá trị tinh thần của mỗi chủ thể, không định giá được bằng tiền và không thể chuyển giao cho chủ thể khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 25, Bộ luật Dân sự 2015).

Quyền nhân thân có những đặc điểm sau:

- Quyền nhân thân là một quyền dân sự nên mang đầy đủ các đặc điểm của quyền dân sự như: phát sinh trong lĩnh vực dân sự đặc trưng bởi tính bình đẳng, tự do, tự nguyện của các chủ thể trong việc xác lập, thay đổi, đình chỉ các quan hệ giữa các chủ thể (cá nhân, pháp nhân) với nhau. Quyền này do pháp luật dân sự quy định hoặc do các bên tự thỏa thuận tự xác lập bằng hành vi pháp lý đơn phương, việc thực hiện các quyền này chủ yếu do các bên tự nguyện mà không cần đến sự cưỡng chế của Nhà nước.

- Quyền nhân thân có tính chất phi tài sản: Khác với quyền tài sản, đối tượng của quyền nhân thân là một giá trị tinh thần, do đó, quyền nhân thân không biểu hiện bằng vật chất, không quy đổi được thành tiền. Giá trị tinh thần và tiền tệ không phải là những đại lượng tương đương và không thể trao đổi ngang giá. Trong trường hợp bồi thường cho cá nhân một khoản tiền do việc xâm phạm đến quyền nhân thân như xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân thì khoản tiền này không phải là trị giá của nhân thân mà là nhằm bù đắp những mất mát, tổn thương đã gây ra cho người bị thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm,…

- Quyền nhân thân luôn gắn liền với cá nhân, không thể chuyển giao cho chủ thể khác. Mỗi một chủ thể mang một giá trị nhân thân đặc trưng, do đó, quyền nhân thân luôn gắn liền với một chủ thể nhất định. Quyền nhân thân không thể bị định đoạt hay mang ra chuyển nhượng cho người khác (không thể là đối tượng trong các giao dịch mua bán, trao đổi, tặng, cho,…) việc sử dụng quyền nhân thân chỉ do chính cá nhân đó hoặc trong một số trường hợp do chủ thể khác được pháp luật quy định thực hiện. Chẳng hạn như Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 ghi nhận quyền quyền nhân thân của tác giả là công bố tác phẩm nhưng quyền này có thể được chuyển giao sang chủ thể khác.

4.2.2. Các quyền nhân thân trong luật dân sự

Bộ luật Dân sự 2015 ghi nhận quyền nhân thân của cá nhân bao gồm các quyền cụ thể sau: Quyền có họ, tên (Điều 26); Quyền thay đổi họ (Điều

27); Quyền thay đổi tên (Điều 28); Quyền xác định, xác định lại dân tộc (Điều 29); Quyền được khai sinh, khai tử (Điều 30); Quyền đối với quốc tịch (Điều 31); Quyền của cá nhân đối với hình ảnh (Điều 32); Quyền sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể (Điều 33); Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín (Điều 34); Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (Điều 35); Quyền xác định lại giới tính (Điều 36); Chuyển đổi giới tính (Điều 37); Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình (Điều 38) và Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình (Điều 39).

- Quyền về họ, tên của cá nhân:

Họ và tên là những yếu tố nhân thân nhằm cá biệt hóa cá nhân, định danh cá nhân. Thông qua họ và tên có thể phần nào xác định được nguồn gốc, dân tộc, giới tính của người đó.

Họ là một phần trong tên gọi đầy đủ của một người để chỉ ra rằng người đó thuộc về dòng họ nào; tên được dùng để nhận dạng, xác định một con người nhất định.

Theo Điều 26, Bộ luật Dân sự quy định thì cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Việc xác định họ, tên của cá nhân được quy định như sau: (i) Trường hợp xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của cá nhân: Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ, tùy theo sự thỏa thuận của cha mẹ; nếu cha mẹ không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán; (ii) Trường hợp chưa xác định được cha đẻ của cá nhân thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ; (iii) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì: Họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi; Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc mẹ nuôi đó; (iv) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi: Họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng. Bộ luật Dân sự 2015 cũng chỉ rõ cha đẻ, mẹ đẻ của cá nhân được xác định họ và tên là: (i) người trực tiếp sinh ra đứa trẻ hoặc (ii) người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ.

Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác

định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng. Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

- Quyền thay đổi họ (Điều 27, Bộ luật Dân sự 2015)

Họ là yếu tố quan trọng để xác định nguồn gốc gia đình của một cá nhân. Họ của cá nhân mang tính bền vững ít thay đổi. Trong một số trường hợp sau thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ. (i) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại; (ii) thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi; (iii) khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ; (iv) thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con; (v) thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình; (vi) thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi; (vii) thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ; (viii) trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

- Quyền thay đổi tên (Điều 28, Bộ luật Dân sự 2015)

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây: (i) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.Trong thực tế có những tên gọi mang những ý nghĩa tiêu cực khiến cá nhân mặc cảm hoặc có những tên gọi bị phạm húy làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình thì người có tên có quyền yêu cầu thay đổi. (ii) Theo yêu cầu của cha

nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt. (iii) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con. Trong trường hợp cá nhân được xác định cha, mẹ cho con theo pháp luật hôn nhân và gia đình, cá nhân đó có quyền thay đổi họ, tên, phù hợp với họ, tên của cha đẻ, mẹ đẻ. (iv) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình. Trường hợp cá nhân tìm ra được nguồn gốc huyết thống của mình và biết được chính xác họ của mình thì cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi họ và yêu cầu thay đổi tên hiện tại của mình cho phù hợp. (v) thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi. (vi) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.

- Quyền xác định, xác định lại dân tộc

Xác định lại dân tộc là quyền cơ bản của con người. Điều 42, Hiến pháp 2013 có ghi nhận "Công dân có quyền xác định dân tộc của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp". Điều 29 Bộ luật Dân sự quy định chi tiết hơn về quyền xác định lại dân tộc theo các trường hợp sau:

+ Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ; trường hợp không có thỏa thuận thì dân tộc của con được xác định theo tập quán; trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn.

+ Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ em được xác định theo dân tộc của người đó.

+ Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

- Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

- Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

Việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi phải được sự đồng ý của người đó. Nghiêm cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam

- Quyền khai sinh khai tử:

Đăng ký khai sinh là thủ tục hộ tịch đầu tiên của cá nhân. Thủ tục này đóng vai trò quan trọng và ý nghĩa khi đánh dấu mốc xác lập các quyền và nghĩa vụ của cá nhân được Luật quy định.

Tại khoản 3 Điều 30 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như sau: "Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu". Có thể thấy, việc đăng ký khai sinh là hoạt động bắt buộc, dù trong trường hợp trẻ sinh ra và sau quá 24 giờ mà chết đi thì vẫn phải thực hiện thủ tục khai sinh. Còn nếu chưa được 24 giờ từ khi sinh ra mà trẻ chết đi thì cha, mẹ có quyền xem xét thực hiện hoạt động đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền.

Ngược lại với sự kiện khai sinh thì khai tử cũng là sự kiện pháp lý làm chấm dứt sự tồn tại của một cá nhân được pháp luật ghi nhận. Việc đăng ký khai tử này cũng được thực hiện kể cả trong trường hợp trẻ em sinh ra quá 24 giờ mà chết đi. Việc khai tử không chỉ có ý nghĩa trong tạo lập cơ sở để chấm dứt quyền và nghĩa vụ của người chết mà còn là cơ sở quan trọng để xác lập, giải quyết các quan hệ khác khi người chết phát sinh như quan hệ thừa kế, quan hệ giữa vợ và chồng.

- Quyền đối với quốc tịch:

Quốc tịch là trạng thái pháp lý xác lập mối quan hệ giữa công dân và một quốc gia. Theo đó công dân sẽ được hưởng các quyền và lợi ích cũng như thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm mà quốc gia đó quy định cho công dân nước mình. V*iệc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật Quốc tịch Việt Nam quy định.*

- Quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, thân thể

Quyền sống, quyền an toàn về tính mạng sức khỏe là những những quyền thiêng liêng của mỗi con người không ai có quyền xâm phạm tới. Những quyền này đã được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và được Bộ luật Dân sự 2015 cụ thể hóa thành các quy định sau:

Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

+ Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện có trách nhiệm hoặc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có điều kiện cần thiết đưa ngay đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi gần nhất; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

+ Việc gây mê, mổ, cắt bỏ, cấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; thực hiện kỹ thuật, phương pháp khám, chữa bệnh mới trên cơ thể người; thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải được sự đồng ý của người đó và phải được tổ chức có thẩm quyền thực hiện.

Trường hợp người được thử nghiệm là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc là bệnh nhân bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con thành niên hoặc người giám hộ của người đó đồng ý; trường hợp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân mà không chờ được ý kiến của những người nêu trên thì phải có quyết định của người có thẩm quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyền của cá nhân đối với hình ảnh:

Hình ảnh của cá nhân là sự tái hiện, sao chụp lại một phần hoặc toàn bộ đặc điểm hình dáng của một người dưới các hình thức như ảnh chụp, ảnh vẽ, quay phim, ghi hình,…

Quyền đối với hình ảnh của cá nhân là quyền nhân thân gắn liền với mỗi cá nhân được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Theo đó, cá nhân có toàn quyền quyết định đối với việc tạo dựng, sử dụng, cho phép sử dụng hoặc định đoạt về hình ảnh của cá nhân mình. Việc sử dụng hình ảnh của một người phải được người đó đồng ý. Mặc dù quyền nhân thân về hình ảnh là quyền tuyệt đối của cá nhân nhưng trong một số trường hợp nhất định, chủ

thể của hình ảnh bị giới hạn trong việc cho phép hoặc không phép người khác sử dụng như sau:

+ Trường hợp hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng:

Lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng là một khái niệm rộng được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong bối cảnh của Điều luật này thì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng được xem là lợi ích chung; các lợi ích này gắn với vị thế, mục tiêu của quốc gia, dân tộc, cộng đồng. Về nguyên tắc lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng là trên hết nên cá nhân không được hạn chế quyền sử dụng hình ảnh của chính mình. Các trường hợp sử dụng hình ảnh cá nhân vì mục đích đảm bảo an toàn trật tự xã hội thì không cần phải xin phép cá nhân có hình ảnh đó. Chẳng hạn việc sử dụng hình ảnh của danh nhân, lãnh tụ cho việc quảng bá đất nước trong các sự kiện, việc cơ quan Nhà nước sử dụng hình ảnh cá nhân để điều tra hay bắt giữ mặc nhiên là được phép.

+ Trường hợp hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân có hình ảnh. Hoạt động công cộng là hoạt động sự kiện có sự tham gia của nhiều người trong cùng một thời gian, một địa điểm. Hình ảnh trong các sự kiện thường mang tính chất về thông tin chung, khó xác định danh tính của toàn bộ các chủ thể có hình ảnh. Vì vậy việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp này không cần phải xin phép. Tuy nhiên nếu hình ảnh tại các hoạt động công cộng trên lại ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân thì không được phép sử dụng.

+ Trường hợp việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh.

Sử dụng hình ảnh vì mục đích thương mại có thể được hiểu là việc tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh của người khác vào các hoạt động như mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác nhằm mục đích sinh lợi khác, cụ thể như sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; hay việc sử dụng hình ảnh của một cá nhân gắn với các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp;… Khi sử dụng hình ảnh cá nhân nhằm mục đích thương mại như trên thì người sử dụng hình ảnh có nghĩa vụ trả thù lao cho cá nhân có hình ảnh. Mức thù lao phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bên sử dụng và cá nhân có hình ảnh.

+ Khi phát hiện việc sử dụng hình ảnh trái phép thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật".

- Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín:

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của mỗi cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Khi danh dự, nhân phẩm, uy tín của một cá nhân cụ thể nào đó bị xâm phạm thì cá nhân đó có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố bác các thông tin đã gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân. Cá nhân không chỉ được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín khi còn sống mà ngay cả khi cá nhân đã chết thì vợ, chồng hoặc con đã thành niên của người bị xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín; hoặc cha, mẹ của cá nhân này trong trường hợp cá nhân không có vợ, chồng, con đã thành niên có quyền yêu cầu tòa án bảo vệ. Đối với những thông tin gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó, nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được huỷ bỏ. Trong trường hợp không xác định được người đưa tin, chẳng hạn như có những người đã lập facebook ảo… thì cá nhân bị đưa tin sẽ căn cứ vào phương thức yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng, trái với sự thật để bảo vệ quyền nhân thân của mình. Cá nhân bị thông tin xấu làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm có quyền yêu cầu người vi phạm cải chính, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại (nếu có). Bên cạnh các chế tài dân sự (bồi thường thiệt hại, buộc xin lỗi) thì trong trường hợp mà hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân có tính chất nguy hiểm cho xã hội, người có hành vi xâm phạm còn có thể phải gánh chịu những chế tài của pháp luật hình sự.

- Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (Điều 35, Bộ luật Dân sự 2015):

Theo từ điển Tiếng Việt, hiến có nghĩa là cho tặng, dâng thứ quý giá của mình một cách tự nguyện. Việc hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác là hành động cao cả mang giá trị nhân văn sâu sắc. Điều 35 Bộ luật Dân sự 2015 đã ghi nhận quyền này của cá nhân "Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. Cá nhân có

quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác".

Theo Luật Hiến, lấy ghép, mô bộ phận cơ thể người thì điều kiện để chủ thể có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác là người đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nguyên tắc của việc của hiến tặng phải là tự nguyện, không nhằm mục đích thương mại. Mô, bộ phận cơ thể hay xác của một người là những thành phần cơ thể mang giá trị nhân thân gắn liền với mỗi cá nhân không phải là hàng hóa có thể trao đổi, mua bán hay định giá được bằng tiền. Vì vậy Điều 35 Bộ luật Dân sự ghi nhận "Cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống hoặc hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác. Cá nhân có quyền nhận mô, bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, pháp nhân có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học có quyền nhận bộ phận cơ thể người, lấy xác để chữa bệnh, thử nghiệm y học, dược học và các nghiên cứu khoa học khác".

4.3. Tài sản và quyền sở hữu

4.3.1. Tài sản

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản bao gồm "vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản".

- Vật, là bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại khách quan mà con người có thể cảm nhận bằng giác quan của mình. Dưới góc độ pháp lý để xem xét một đối tượng là vật trong dân sự thì đối tượng đó phải được con người chiếm hữu được, mang lại lợi ích cho chủ thể, có thể đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai chẳng hạn như ô tô, điện thoại, chung cư cao tầng sẽ được hoàn thiện vào một thời gian nhất định…

Có nhiều tiêu chí để phân loại vật như:

+ Căn cứ vào công dụng trong mối tương quan giữa các thành phần của vật thì vật được chia thành vật chính và vật phụ. Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng. Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính nhưng có thể tách rời vật chính. Ví dụ như ti vi là vật chính còn điều khiển ti vi là vật phụ.

+ Căn cứ vào cấu tạo, tính chất phân chia thì vật chia thành vật chia được và vật không chia được. Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng ban đầu ví dụ như gạo, muối, xăng, dầu.… Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu ví dụ như giường tủ, bàn ghế,… Khi cần phân chia vật không phân chia được thì phải trị giá thành tiền để chia.

+ Căn cứ vào tính tiêu hao vật chia thành vật tiêu hao và vật không tiêu hao. Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu ví dụ như thực phẩm, mỹ phẩm,… Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu như xe cộ, nhà cửa,…

+ Căn cứ vào tính chất độc bản của vật có thể chia thành vật cùng loại và vật đặc định. Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định bằng những đơn vị đo lường. Vật cùng loại có cùng chất lượng có thể thay thế cho nhau. Khi một vật cùng loại bị tiêu hủy, mất đi, ta có thể thay thế bằng những vật cùng loại khác. Ví dụ: các sản phẩm sản xuất công nghiệp hàng loạt như thiết bị điện tử, vật dụng gia đình,… Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí, ví dụ tranh độc bản, hàng thủ công chỉ làm với số lượng 1 cái,… Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đặc định thì ta cần phải giao đúng vật đó. Khi vật đặc định bị tiêu hủy, mất đi, ta không thể thay thế bằng bất cứ vật nào khác, mà chỉ có thể chấm dứt các mối quan hệ pháp luật liên quan đến vật đó.

- Tiền là một loại hàng hóa đặc biệt, là công cụ thanh toán đa năng, là công cụ tích luỹ tài sản và là thước đo giá trị. Tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành và chỉ có loại tiền có giá trị đang được lưu hành trên thực tế, tức là được pháp luật thừa nhận, mới được coi là tài sản. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì các loại tiền ảo (tiền kỹ thuật số) không phải là tiền, không phải là tài sản của chủ sở hữu. Việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam[104].

[104] Trần Văn Biên, Nguyễn Minh Oanh, Tiền ảo và một số vấn đề pháp lý đặt ra ở Việt Nam hiện nay, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật* số 4/2020, tr.30.

- Giấy tờ có giá, được hiểu là giấy tờ trị giá được bằng tiền và chuyển giao được trong giao lưu dân sự. Giấy tờ có giá hiện nay tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như séc, cổ phiếu, tín phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, công trái,… Xét về mặt hình thức, thì giấy tờ có giá là một chứng chỉ được lập theo hình thức, trình tự luật định. Nội dung thể hiện trên giấy tờ có giá là thể hiện quyền tài sản, giá của giấy tờ có giá là giá trị quyền tài sản và quyền này được pháp luật bảo vệ. Giấy tờ có giá có tính thanh khoản và là công cụ có thể chuyển nhượng với điều kiện chuyển nhượng toàn bộ một lần, việc chuyển nhượng một phần giấy tờ có giá là vô hiệu. Ngoài ra còn có các loại giấy tờ xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giấy đăng ký xe máy, xe ô tô,… không phải là giấy tờ có giá. Những loại giấy tờ này chỉ được coi là một vật thuộc sở hữu của người đứng tên trên giấy tờ đó.

- Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Chủ thể của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có thể hưởng các quyền tài sản như nhận nhuận bút thù lao, chi phí cấp phép hoặc chuyển nhượng các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Quyền sử dụng đất là là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,… từ chủ thể có quyền.

Quyền tài sản khác là quyền trị giá được bằng tiền như quyền đòi nợ, quyền đòi bồi thường thiệt hại,…

4.3.2. Quyền sở hữu tài sản

4.3.2.1. Nội dung quyền sở hữu

Theo quy định tại Điều 158 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: "Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật".

- Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.

- Sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Khai thác công dụng của tài sản chính là việc đưa ra sử dụng trực tiếp các tính năng, công dụng, lợi ích vật chất của tài sản nhằm phục vụ nhu cầu của chủ sở hữu còn hưởng hoa lợi lợi tức là nhận và khai thác những lợi ích thu được từ những sản vật tự nhiên như hoa màu, trái cây từ việc trồng trọt hoặc khoản lợi có được từ khai thác tài sản như lãi suất ngân hàng, tiền cho thuê nhà.

Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Đối với quyền sử dụng của chủ sở hữu, chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; Đồng thời, người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

- Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu huỷ tài sản. Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu huỷ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản. Điều kiện để thực hiện quyền định đoạt là chủ thể phải có có năng lực hành vi dân sự thực hiện theo quy định trình tự, thủ tục đối với loại tài sản đó. Đối với các cá nhân không đủ năng lực hành vi dân sự để tự mình định đoạt tài sản thì có thể xác lập, thực hiện các giao dịch thông qua người đại diện hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật về đại diện. "Người đại diện hợp pháp chỉ được xác lập giao dịch phù hợp với các phạm vi đại diện, hoàn toàn vì lợi ích tuyệt đối của người được đại diện và theo đúng yêu cầu và điều kiện của Pháp luật. Đối với người không phải chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của luật".

4.3.2.2. Xác lập quyền sở hữu

Việc xác lập quyền sở hữu tài sản dựa vào các căn cứ phát sinh sau đây:

- Do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, do hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

Lao động là hoạt động cơ bản của con người trong đó con người tác động vào tự nhiên làm biến đổi tự nhiên tạo ra các sản phẩm cần thiết phục vụ con người. Các sản phẩm do lao động thuộc quyền sở hữu của người lao động.

Hoạt động sản xuất kinh doanh là quá trình tiến hành các công đoạn từ việc khai thác sử dụng các nguồn lực sẵn có trong nền kinh tế để sản xuất ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ nhằm cung cấp cho nhu cầu thị trường. Các chủ thể đã đầu tư để tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ này được thừa nhận là chủ sở hữu.

Sản phẩm của các hoạt động sáng tạo cũng là sản phẩm của quá trình lao động bằng trí óc nên chủ thể đương nhiên có quyền xác lập chủ sở hữu với các đối tượng do mình tạo ra.

- Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Thỏa thuận là cơ sở quan trọng để xác lập quyền sở hữu cho người khác không phải là chủ sở hữu ban đầu của tài sản. Thông qua các thỏa thuận như hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay quyền sở hữu của chủ thể cũ bị chấm dứt, hình thành quyền sở hữu của chủ sở hữu mới.

Trong giao lưu dân sự có thể xảy ra các tranh chấp về việc xác định chủ sở hữu của tài sản hoặc các tình huống đặc biệt phát sinh trong cuộc sống thì việc xác lập quyền sở hữu còn dựa vào bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Thu hoa lợi, lợi tức

Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Về nguyên tắc chủ sở hữu tài sản có quyền hưởng hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản của mình nhưng cũng có trường hợp chủ thể khác được hưởng do thỏa thuận hoặc do quy định của pháp luật.

- Tạo thành tài sản mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến

Trường hợp tài sản của nhiều chủ sở hữu khác nhau được sáp nhập với nhau tạo thành vật không chia được và không thể xác định tài sản đem sáp nhập là vật chính hoặc vật phụ thì vật mới được tạo thành là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó; nếu tài sản đem sáp nhập là vật chính và vật phụ thì vật mới được tạo thành thuộc chủ sở hữu vật chính,

kể từ thời điểm vật mới được tạo thành, chủ sở hữu tài sản mới phải thanh toán cho chủ sở hữu vật phụ phần giá trị của vật phụ đó, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Chế biến là quá trình biến đổi vật chất thành vật mới, sản phẩm mới. Việc chủ sở hữu của nguyên vật liệu được đem chế biến tạo thành vật mới là chủ sở hữu của vật mới được tạo thành.

Trộn lẫn là việc các chất hoặc vật thể được trộn vào nhau tạo thành tạo thành vật mới không chia được. Trong trường hợp vật mới được tạo thành từ trộn lẫn sẽ được xác định là tài sản thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu đó, kể từ thời điểm trộn lẫn.

- Được thừa kế

Thừa kế là việc chuyển quyền sở hữu tài sản từ người chết sang tổ chức, cá nhân khác theo di chúc hoặc theo pháp luật. Như vậy thông qua thừa kế thì chủ sở hữu tài sản mới được xác lập từ thời điểm người để lại di sản chết.

- Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật quy định đối với tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên.

+ Vật vô chủ là vật mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó. Người đã phát hiện vật vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó theo quy định của pháp luật; nếu vật được phát hiện là bất động sản thì thuộc Nhà nước.

+ Tài sản không xác định được chủ sở hữu là trường hợp không biết ai là người có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hợp pháp đối với tài sản và không có căn cứ để xác định việc chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu

Người phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về người phát hiện tài sản. Sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

+ Tài sản bị đánh rơi, bỏ quên là những tài sản có chủ sở hữu nhưng do những lý do khách quan hoặc chủ quan từ chính chủ sở hữu hoặc người đang quản lý mà tài sản không còn nằm trong sự chi phối, chiếm hữu của các chủ thể đó.

Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai về tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận thì quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định: (i) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bỏ quên có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người nhặt được được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của Bộ luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp tài sản có giá trị lớn hơn mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước; (ii) Trường hợp tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì tài sản đó thuộc về Nhà nước; người nhặt được tài sản được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

+ Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm là tình trạng tài sản không hiển thị một cách rõ ràng về sự tồn tại do các yếu tố chủ quan như có người cố tình chôn, vùi lấp xuống lòng đất hoặc do các yếu tố tự nhiên như động đất, sóng cuốn,… Tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy mà không có hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu đối với tài sản này được xác định: (i) Tài sản được tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa thì thuộc về Nhà nước; người tìm thấy tài sản đó được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật; (ii) Tài sản được tìm thấy không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn mười lần

mức lương cơ sở do Nhà nước quy định thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định và 50% giá trị của phần vượt quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

+ Đối với gia súc bị thất lạc thì người bắt được gia súc bị thất lạc phải nuôi giữ và báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 06 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hoặc sau 01 năm đối với gia súc thả rông theo tập quán thì quyền sở hữu đối với gia súc và số gia súc được sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia súc. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc. Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.

+ Đối với gia cầm bị thất lạc thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu đối với gia cầm và hoa lợi do gia cầm sinh ra trong thời gian nuôi giữ thuộc về người bắt được gia cầm. Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chi phí khác cho người bắt được gia cầm. Trong thời gian nuôi giữ gia cầm bị thất lạc, người bắt được gia cầm được hưởng hoa lợi do gia cầm sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia cầm.

+ Đối với vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ của người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu vật nuôi dưới nước đó thuộc về người có ruộng, ao, hồ.

- Chiếm hữu, được lợi về tài sản theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó.

4.3.2.3. Chấm dứt quyền sở hữu

Quyền sở hữu chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác.
- Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình.
- Tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy.
- Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu.
- Tài sản bị trưng mua.
- Tài sản bị tịch thu.
- Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định của Bộ luật này.
- Trường hợp khác do luật quy định.

4.3.3. Chiếm hữu tài sản

Một trong những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 là đã ghi nhận chiếm hữu tài sản không chỉ là một trong các quyền của chủ sở hữu mà là một nội dung độc lập với mục đích chỉ một thực trạng chiếm hữu trên thực tế của chủ thể khác.

Luật dân sự phân chiếm hữu tài sản thành hai loại là: chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Chiếm hữu có căn cứ pháp luật được hiểu là các trường hợp người chiếm hữu thực sự có quyền chiếm hữu đối với tài sản của mình dựa trên những căn cứ do pháp luật quy định. Việc chiếm hữu này là chiếm hữu hợp pháp.

Việc chiếm hữu có căn cứ pháp luật được ghi nhận tại Điều 165 bao gồm các căn cứ sau:

- Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;

Chủ sở hữu là chủ thể đương nhiên được quyền nắm giữ, chi phối tài sản của chính mình theo ý chí của mình. Chủ sở hữu có toàn quyền chiếm hữu đối với tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

- Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản;

Ủy quyền là việc một người giao cho người khác thay mình thực hiện quyền và nghĩa vụ nhất định. Việc một người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản là cơ sở pháp lý để được chiếm hữu tài sản. Tuy nhiên việc chiếm hữu này phải nằm trong phạm vi, theo cách thức, thời

hạn do chủ sở hữu xác định. Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu đối với tài sản được giao.

- Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

Có nhiều giao dịch dân sự làm phát sinh việc việc chuyển giao quyền chiếm hữu tài sản giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền với bên thứ ba như thực hiện hợp đồng gửi giữ tài sản, hợp đồng thuê tài sản,… Trong những trường hợp này, người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch, chỉ được sử dụng hoặc chuyển giao quyền chiếm hữu cho người khác nếu chủ sở hữu đồng ý.

- Chiếm hữu của người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm;

Bộ luật Dân sự 2015 cũng đưa ra khái niệm chiếm hữu ngay tình, không ngay tình và hậu quả pháp lý của nó. Theo đó, chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu, còn chiếm hữu không ngay tình là trường hợp đòi hỏi người chiếm hữu phải nhận thức được mình không có quyền đối với tài sản, và việc chiếm hữu này không có căn cứ pháp luật.

Ví dụ 1: A mua 1 chiếc laptop cũ từ B là bạn học cùng lớp của mình. A không hề biết chiếc laptop đó là do B lấy trộm của C. Việc chiếm hữu của A là không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình.

Ví dụ 2: X mua xe máy Lead cũ từ Y với giá 10 triệu, mặc dù Y không có giấy đăng ký xe nhưng X ham rẻ nên vẫn mua mà không hỏi gì. Thực chất chiếc xe này do Y lấy trộm của hàng xóm. Trong trường hợp này việc chiếm hữu của X là không có căn cứ pháp luật và không ngay tình.

Về hậu quả pháp lý:

+ Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Đối với hoa lợi, lợi tức thì người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật và không ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật. Người chiếm hữu,

người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình thì phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm người đó biết hoặc phải biết việc chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.

4.4. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

4.4.1. Nghĩa vụ dân sự

4.4.1.1. Khái niệm

Theo nghĩa thông thường, nghĩa vụ là xử sự bắt buộc mà một chủ thể phải thực hiện đối với chủ thể khác theo quy định của pháp luật hoặc theo các quy tắc đạo đức hoặc tôn giáo nhất định.

Bộ luật Dân sự 2015 đưa ra định nghĩa về nghĩa vụ dân sự tại Điều 274 như sau:

"Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thế khác (sau đây gọi chung là bên có quyền)". Theo định nghĩa này thì nghĩa vụ dân sự có những đặc điểm:

- Thứ nhất, chủ thể của nghĩa vụ dân sự thường bao gồm hai bên có mối liên hệ pháp lý mật thiết nhau giữa một bên là bên có nghĩa vụ (là bên phải thực hiện hoặc không thực hiện một hành vi, một công việc nhất định) còn một bên là bên có quyền (là bên được phép yêu cầu bên kia phải thực hiện hoặc không thực hiện một công việc nhất định).

- Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của các bên trong nghĩa vụ dân sự luôn đối lập nhau một cách tương ứng. Chủ thể có quyền chỉ có thể đạt được lợi ích khi bên có nghĩa vụ thực hiện và hoàn thành nghĩa vụ của mình. Ví dụ trong hợp đồng mua bán hàng hóa bên mua chỉ có thể nhận được hàng khi bên bán hoàn thành việc giao hàng.

- Thứ ba, nội dung của nghĩa vụ dân sự là các xử sự nhất định mà bên có nghĩa vụ phải thực hiện nhằm đáp ứng các lợi ích mà bên có quyền được hưởng, các xử sự đó có thể là chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền, giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không thực hiện công việc nhất định

4.4.1.2. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ dân sự là những cơ sở pháp lý xác định khi nào thì xuất hiện nghĩa vụ dân sự.

Theo Điều 275 Bộ luật Dân sự năm 2015 nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ sau đây:

- Hợp đồng: là khi các bên thỏa thuận về việc xác lập, chấm dứt, thay đổi quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy, từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực pháp luật sẽ phát sinh nghĩa vụ dân sự.

Ví dụ trong hợp đồng cho thuê tài sản các bên thỏa thuận các nội dung liên quan đến việc thuê tài sản. Trong hợp đồng này thì bên thuê phải có nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đối với bên cho thuê.

- Hành vi pháp lý đơn phương: là việc một bên chủ thể tuyên bố ý chí của mình nhằm làm phát sinh, chấm dứt, thay đổi quyền và nghĩa vụ. Ví dụ, Điều 570 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hứa thưởng "Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho công việc của người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng".

- Thực hiện công việc không có ủy quyền: là khi một người tự nguyện thực hiện công việc mặc dù không có nghĩa vụ phải thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

Về nghĩa vụ thanh toán khi thực hiện công việc như sau: khi người thực hiện công việc không có ủy quyền hoàn thành công việc thì người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc và thanh toán các khoản chi phí hợp lý, kể cả trường hợp công việc không được theo kết quả mong muốn của mình.

Ví dụ: Chị A là hàng xóm của chị B thấy trời sắp mưa lớn có thể làm ảnh hưởng đến số lúa đang phơi ngoài sân của chị B nên dù không có ủy quyền của chị B, chị A vẫn chủ động nhờ thêm một vài người nữa để gom lúa đưa vào nhà.

- Chiếm hữu, sử dụng tài sản hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật:

Chiếm hữu, sử dụng, được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật có thể hiểu là trường hợp một chủ thể chiếm hữu, sử dụng, được lợi một tài sản nhất định mà không thuộc các trường hợp chiếm hữu có căn cứ pháp luật. Pháp luật chỉ thừa nhận và bảo vệ cho việc chiếm hữu, sử dụng, được lợi từ tài sản theo những trường hợp điều kiện cụ thể mà Luật quy định. Vì vậy, đối với trường hợp chiếm hữu, sử dụng, được lợi từ tài sản mà không có căn pháp luật sẽ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của họ đối với

chủ sở hữu tài sản hợp pháp, bao gồm: nghĩa vụ hoàn trả lại tài sản, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

Ví dụ: Khách hàng chuyển nhầm tiền vào tài khoản của ông X thì ông X phải có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm.

- Trường hợp gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật: nghĩa vụ phát sinh là bồi thường thiệt hại khi có hành vi trái pháp luật.

Gây thiệt hại do hành vi trái pháp luật là việc một người bằng hành vi của mình xâm phạm đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ gây ra các thiệt hại thực tế như tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản cho người khác. Đây là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại đối với người vi phạm.

Theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015 căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là: Người nào có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp, tài sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trường hợp thiệt hại phát sinh do hoàn toàn lỗi của bên bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Chủ sở hữu tài sản, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu tài sản gây thiệt hại.

- Căn cứ khác do pháp luật quy định.

4.4.1.3. Thực hiện nghĩa vụ dân sự

Thực hiện nghĩa vụ dân sự là việc chủ thể có nghĩa vụ phải tiến hành chuyển giao tài sản, thực hiện hoặc không thực hiện công việc vì lợi ích của người có quyền.

Việc thực hiện nghĩa vụ dân sự phải theo nguyên tắc chung được quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể:

- Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản.

Đây là nguyên tắc cơ bản của luật dân sự đảm bảo vị trí bình đẳng với nhau giữa các chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự, đảm bảo các cá nhân, pháp nhân đều được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau trong cùng điều kiện, hoàn cảnh mà luật dân sự dự liệu, không có bất kỳ sự thiên vị, phân biệt đối xử vì bất kỳ lý do gì kể cả tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, điều kiện kinh tế, trình độ văn hóa,…

- Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng.

- Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực.

- Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

- Cá nhân, pháp nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự.

Thực hiện nghĩa vụ dân sự phải đảm bảo các nội dung như: đúng địa điểm, đúng thời hạn, đúng đối tượng, đúng phương thức.

4.4.1.4. Các biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự

Biện pháp bảo đảm là những phương thức do pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận nhằm đảm bảo cho một nghĩa vụ chính thực hiện; đồng thời, xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong biện pháp đó. Các biện pháp bảo đảm có mục đích nâng cao trách nhiệm của các bên, đề phòng rủi ro, trong việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Điều 292, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định có 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, cụ thể như sau:

- Cầm cố tài sản

Cầm cố có thể hiểu là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản cho bên có quyền giữ để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ sau này. Tài sản cầm cố phải là tài sản thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ. Khi chuyển giao tài sản cầm cố, bên có nghĩa vụ phải chuyển giao tài sản kèm với giấy tờ quyền sở hữu tài sản (nếu có).

Ví dụ: A đến vay B 50 triệu và có sử dụng chiếc xe máy làm tài sản cầm cố thì A phải chuyển giao cả xe máy và giấy chứng nhận đăng ký xe máy cho B.

- Thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Khác với cầm

cố, trong thế chấp tài sản thế chấp không cần chuyển giao cho bên nhận thế chấp, mà vẫn do bên thế chấp giữ.

Ví dụ: X vay một khoản tiền tại ngân hàng có sử dụng quyền sử dụng đất để thế chấp thì trong trường hợp này X chỉ chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng còn tài sản vẫn do X nắm giữ.

- Đặt cọc

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Đặt cọc chỉ áp dụng với đối tượng là động sản là tiền hoặc vật có giá trị. Theo đó, bên có quyền sẽ nắm giữ tài sản đặt cọc. Các bên xác lập biện pháp đặt cọc nhằm đảm bảo cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Ví dụ: T đang muốn mua nhà của H với giá 1 tỷ. T đặt cọc cho B 100 triệu nhằm đảm bảo cho việc ký kết hợp đồng mua bán nhà sẽ diễn ra vào thời điểm 1 tháng sau.

- Ký cược

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. Như vậy, ký cược hình thành từ hợp đồng cho thuê tài sản có đối tượng là động sản. Theo đó, ký cược là hình thức đảm bảo bên thuê sẽ trả lại tài sản sau khi hết thời hạn thuê. Khi hết thời hạn, thuê bên ký cược có thể nhận lại tài sản ký cược khi đã trả tài sản thuê và thanh toán tiền thuê đầy đủ. Ví dụ: M thuê các thiết bị xây dựng của N để phục vụ cho việc thi công công trình xây dựng, hai bên thỏa thuận ký cược 100 triệu đồng. Sau khi hết thời hạn cho thuê, M phải trả các thiết bị cho N đồng thời thanh toán tiền thuê, khi đó N sẽ trả lại cho M khoản tiền đã ký cược.

- Ký quỹ

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, tùy thuộc vào từng loại hợp đồng mà hai bên trong quan hệ phải mở một tài khoản tại ngân hàng, nhưng không được sử dụng tài khoản đó khi hợp đồng chưa chấm dứt. Nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ, mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực

hiện không đúng nghĩa vụ, thì ngân hàng nơi ký quỹ sẽ sử dụng tài sản đó để thanh toán cho bên có quyền.

Ví dụ: A và B ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. A và B có thỏa thuận A là bên mua sẽ gửi 500 triệu vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng K để bảo đảm A sẽ thực hiện nghĩa vụ trả tiền khi B đã giao hàng đúng và đủ theo thỏa thuận. Nếu đến thời hạn mà A không thanh toán thì ngân hàng nơi ký quỹ sẽ sử dụng khoản tiền ký quỹ để thanh toán cho B.

- Bảo lưu quyền sở hữu

Bảo lưu quyền sở hữu là một biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo đó trong hợp đồng mua bán các bên có thể thỏa thuận việc bên bán có quyền bảo lưu quyền sở hữu tài sản của mình cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.Việc bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

Ví dụ: A và B thỏa thuận giao kết hợp đồng mua bán xe ô tô trong đó có điều khoản về việc bảo lưu quyền sở hữu của A cho đến khi B thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán. Mặc dù A đã chuyển giao xe cho B vào thời điểm ký hợp đồng nhưng đã hết hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà B chưa hoàn thành A nên A không hỗ trợ B hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sở hữu và có quyền đòi lại tài sản.

- Bảo lãnh

Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Ví dụ: A cam kết dùng quyền sử dụng đất của mảnh đất tại vị trí X để bảo lãnh cho khoản vay của B tại ngân hàng C. Theo đó, nếu B không trả tiền khi đến hạn thì A sẽ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền đó cho ngân hàng.

- Tín chấp

Tín chấp là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự trong đó các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở như Hội phụ nữ, Hội nông dân dùng uy tín của tổ chức mình bảo đảm cho các cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

- Cầm giữ tài sản

Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Ví dụ: Trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa giữa A và B có thỏa thuận về việc cầm giữ tài sản của bên vận chuyển. Theo đó, nếu bên khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên vận chuyển có quyền cầm giữ một số lượng hàng hóa và chứng từ liên quan đến hàng hóa đó.

4.4.2. Hợp đồng dân sự

4.4.2.1. Khái niệm và phân loại

Hợp đồng là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ. Hợp đồng được định nghĩa tại Điều 385, Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

Như vậy, bản chất của Hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên thông qua việc thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ liên quan đến đối tượng Hợp đồng.

Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau thì Hợp đồng được chia thành nhiều loại, theo Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì có 06 loại hợp đồng như sau:

- Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa
- Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. Ví dụ như hợp đồng tặng cho tài sản
- Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
- Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

Ví dụ: A mua của B 10 cái máy lạnh và thuê B lắp đặt thiết bị cho A. Như vậy hợp đồng mua bán máy lạnh là hợp đồng chính còn hợp đồng lắp đặt thiết bị là hợp đồng phụ.

- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi

ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó. Ví dụ: A và B ký hợp đồng trồng và chăm sóc cây cảnh tại nhà C. Việc giao kết giữa A và B là vì lợi ích của C.

- Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

Ví dụ: A và B có thỏa thuận rằng A sẽ tặng cho B một chiếc ô tô nếu B thực hiện việc chăm sóc bố mẹ A trong thời gian 6 tháng khi A đi công tác nước ngoài.

4.4.2.2. Hình thức và nội dung hợp đồng

Hình thức của hợp đồng là cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài dưới hình thức nhất định của các chủ thể hợp đồng, là phương tiện để các bên ghi nhận những nội dung đã thỏa thuận.

Điều 119 Bộ luật Dân sư năm 2015 thì hình thức của hợp đồng (cũng là hình thức của giao dịch dân sự) bao gồm: (i) Hình thức miệng (bằng lời nói); (ii) Hình thức viết (bằng văn bản); (iii) Hình thức có công chứng, chứng thực, đăng ký.

Nội dung của Hợp đồng là tổng hợp những điều khoản mà các bên đã thỏa thuận. Thông thường trong Hợp đồng, các điều khoản được chia thành 3 nhóm gồm: (1) nhóm điều khoản cơ bản là nhóm xác định các nội dung chủ yếu không thể thiếu trong hợp đồng, liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của các chủ thể như nghĩa vụ giao hàng, nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa… (2) nhóm điều khoản thông thường là nhóm bao gồm các điều khoản đã được Luật quy định nếu các bên không thỏa thuận trước thì sẽ áp dụng quy định của Luật như điều khoản về chuyển quyền sở hữu, điều khoản về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng… (3) nhóm điều khoản tùy nghi là nhóm gồm các điều khoản do các bên tùy ý lựa chọn để đảm bảo mục đích của mình như điều khoản về ngôn ngữ Hợp đồng, điều khoản chọn luật, cơ quan giải quyết tranh chấp…

Điều 398 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định "Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng". Hợp đồng có thể có các nội dung sau:

- Đối tượng của hợp đồng;
- Số lượng, chất lượng;
- Giá, phương thức thanh toán;
- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
- Quyền, nghĩa vụ của các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Phương thức giải quyết tranh chấp.

4.4.2.3. Điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng và hợp đồng vô hiệu

Điều 117 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (trong đó có hợp đồng) có hiệu lực khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Thứ nhất, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với hợp đồng được xác lập.

Chủ thể trong hợp đồng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về độ tuổi và khả năng nhận thức cho mỗi loại giao dịch dân sự cũng như loại hợp đồng tương ứng, còn pháp nhân tham gia vào giao dịch dân sự thông qua đại diện của pháp nhân.

Thứ hai, chủ thể tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện.

Sự tự nguyện của chủ thể trong hợp đồng biểu hiện bằng sự tự do ý chí và bày tỏ ý chí. Một hợp đồng được giao kết do có yếu tố lừa dối, cưỡng ép sẽ không làm phát sinh hậu quả pháp lý vì thiếu tính tự nguyện.

Thứ ba, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng không thuộc hàng hóa cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Bên cạnh đó, nội dung của hợp đồng cần phải cụ thể, bởi vì việc xác lập nghĩa vụ trong hợp đồng phải cụ thể và có tính khả thi. Những nghĩa vụ trong hợp đồng mà không thể thực hiện được thì hợp đồng cũng không được coi là có hiệu lực pháp lý làm phát sinh quyền và nghĩa vụ.

Thứ tư, hợp đồng phải đảm bảo quy định về hình thức theo quy định pháp luật

Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt thì pháp luật mới có yêu cầu về hình thức buộc các chủ thể phải tuân thủ theo (yêu cầu phải lập thành văn bản, phải có chứng nhận, chứng thực, đăng ký, xin phép). Trong trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản, phải được công chứng nhà nước chứng nhận, được chứng thực, đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không thỏa mãn các điều kiện về hiệu lực của hợp đồng thì sẽ bị vô hiệu, cụ thể Hợp đồng có thể vô hiệu theo các trường hợp như (i) không đáp ứng điều kiện về năng lực chủ thể gồm: Hợp đồng vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; vô

hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện; (ii) không thỏa mãn điều kiện về tự nguyện: do giả tạo, do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa; (iii) do vi phạm điều kiện về nội dung hợp đồng: vô hiệu do giả tạo.

Hợp đồng có thể bị vô hiệu từng phần hoặc toàn phần. Theo điều 137 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì hợp đồng dân sự vô hiệu sẽ phát sinh những hậu quả pháp lý sau:

Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

4.5. Thừa kế

4.5.1. Khái quát về thừa kế

- *Khái niệm*

Theo từ điển tiếng Việt "thừa kế là việc hưởng tài sản của người chết để lại cho"[105]. Như vậy dưới góc độ ngôn ngữ thì thừa kết là hoạt động phổ biến trong xã hội gắn liền với việc chuyển giao tài sản khi có người qua đời.

Dưới góc độ là một chế định luật trong luật dân sự thì thừa kế bao gồm nhiều quy phạm pháp luật điều chỉnh sự chuyển dịch tài sản từ người chết sang tổ chức, cá nhân khác theo di chúc hoặc theo trình tự thủ tục do Luật định đồng thời quy định các quyền và nghĩa vụ của những người nhận thừa kế và những người liên quan.

Dưới góc độ của chủ thể liên quan đến việc để lại và nhận di sản thì quyền thừa kế là một quyền dân sự được Bộ luật Dân sự 2015 xác định gồm có cá nhân và người thừa kế không phải là cá nhân. Cụ thể "cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc".

thời hiệu khởi kiện về thừa kế:
ntk yêu cầu chia, xác nhận/bác bỏ quyền thừa kế
để yêu cầu ntk thực hiện nghĩa vụ về tài sản nc để lại là 3 năm

bất động sản là 30 năm
động sản là 10 năm

(nợ của ng chết: sau 3 năm chủ nợ k đến đòi thì sẽ ko có khoản nợ đó)

[105] Viện Ngôn ngữ học, *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb Đà Nẵng, 2003, tr.971.

- *Thời điểm mở thừa kế*

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại tài sản chết, trường hợp Tòa án tuyên bố một người chết thì thời điểm chết là thời điểm được Tòa án xác định tại bản án hoặc quyết định tuyên bố chết.

Việc xác định thời điểm mở thừa kế rất quan trọng, thời điểm này ảnh hưởng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ liên quan đến di sản của người chết, xác định người được nhận thừa kế cũng là thời hiệu khởi kiện về thừa kế.

Địa điểm mở thừa kế: tại nơi cư trú trước khi chết hoặc nơi có tổng tài sản lớn nhất nếu k có nơi cư trú.

- *Di sản thừa kế*

Di sản thừa kế là toàn bộ tài sản hợp pháp của người chết. Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: "Di sản của người chết để lại bao gồm: tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác".

Tài sản riêng của người chết là tài sản chỉ do người chết làm chủ sở hữu, người chết có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt khối tài sản này. Theo Luật Hôn nhân và gia đình thì tài sản của vợ và chồng có thể từ các nguồn là tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ và chồng; tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ và chồng;...

Tài sản trong khối tài sản chung với người khác có thể là phần tài sản trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng chẳng hạn như tài sản do thu nhập, sản xuất kinh doanh phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được tặng cho chung, thừa kế chung,... cũng có thể là khối tài sản chung theo phần với người khác như tài sản do góp vốn để mua sắm hay sản xuất, kinh doanh với người khác.

Việc xác định đúng di sản thừa kế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân chia di sản cũng như vấn đề giải quyết tranh chấp về thừa kế.

- *Người thừa kế*

Người thừa kế có thể là cá nhân hoặc là tổ chức. Người thừa kế phải bảo đảm theo các điều kiện pháp luật đã quy định. Đối với thừa kế theo pháp luật thì người thừa kế chỉ có thể là cá nhân. Người thừa kế cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo điều 621, Bộ luật Dân sự 2015 thì những người không được hưởng thừa kế bao gồm:

+ Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó.

+ Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

+ Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng.

+ Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Các trường hợp trên vẫn được thừa kế, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

4.5.2. Thừa kế theo di chúc

- *Khái niệm*

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của chủ tài sản về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Di chúc chỉ có hiệu lực khi người để lại di chúc chết. Theo đó, thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển di sản thừa kế của người chết sang cho tổ chức, cá nhân khác theo sự định đoạt của người có di sản khi còn sống.

- *Chủ thể lập di chúc*

Theo điều 625, Bộ luật Dân sự 2015 thì chủ thể có quyền lập di chúc phải là người thành niên, trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Như vậy chủ thể của việc lập di chúc phải là người thành niên. Người thành niên là người đủ 18 tuổi trở lên. Đây là độ tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, chủ thể có thể tự mình thực hiện các giao dịch, tự mình thực hiện những hoạt động mang ý chí của chính bản thân mình trong đó có việc để lại thừa kế. Đối với người đủ 15 đến 18 tuổi là người có năng lực hành vi dân sự một phần, những người này được quyền lập di chúc nếu được sự đồng ý cha, mẹ hoặc người giám hộ. Việc đồng ý của cha mẹ là cơ sở để người 15 - 18 tuổi thực hiện việc lập di chúc chứ không có quyền can thiệp hay quyết định về nội dung di chúc.

- *Điều kiện có hiệu lực của di chúc*

Điều 630, Bộ luật Dân sự đã quy định các điều kiện để di chúc có hiệu lực bao gồm:

+ Người lập di chúc phải tự nguyện, không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép

Bản chất của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc quyết định tài sản của mình nên điều kiện thiết yếu đối với người lập di chúc phải là tự nguyện, phải có sự thống nhất giữa mong muốn và biểu hiện ra bên ngoài. Một di chúc được lập do bị lừa dối (tiếp nhận thông tin sai sự thật), bị đe dọa (khống chế về mặt tinh thần, thể xác) hay bị cưỡng ép (bắt buộc thực hiện công việc trái ý muốn của chủ thể) thì di chúc đó không mang tính ý chí của người lập di chúc nên không thể có hiệu lực.

+ Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Theo quy định này thì người lập di chúc không được đưa vào di chúc những nội dung thuộc các trường hợp cấm mà các văn bản pháp luật cụ thể đã quy định. Chẳng hạn không đưa nội dung là để lại di sản thừa kế để kinh doanh pháo nổ vì đây là trường hợp cấm theo Luật Đầu tư 2020. Đồng thời nội dung di chúc cũng không được trái đạo đức xã hội nghĩa là phải đảm bảo những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

+ Hình thức di chúc không trái quy định của luật. Hình thức di chúc bao gồm các loại sau:

- Di chúc được công chứng, chứng thực

Việc lập di chúc có thể tiến hành tại tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp này thì yêu cầu công chứng viên, người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; là người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật hoặc người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

- Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

- Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di

chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

- Di chúc miệng

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

- Trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Khi phân chia di sản, ý chí của người để lại di chúc là nền tảng quan trọng nhất. Tuy nhiên trong một số trường hợp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của những người có quan hệ nuôi dưỡng, hôn nhân với người chết thì pháp luật có quy định về trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Theo quy định tại Điều 644, Bộ luật Dân sự 2015 thì các trường hợp gồm "con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên mà không có khả năng lao động" vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

Ví dụ: Ông A có vợ và 3 người con là E, B, C. Trong đó E, B đã lập gia đình, có công việc ổn định còn C là con gái (12 tuổi) đang sống chung với vợ chồng ông. Trước khi ông A qua đời có để lại di chúc cho người con trai E hưởng toàn bộ tài sản. Như vậy, theo quy định trên thì mặc dù di chúc của ông A chỉ cho E hưởng tài sản nhưng vợ ông A và đứa con gái (12 tuổi chưa thành niên) vẫn được hưởng một phần di sản vì thuộc trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc và hai người này hưởng ít nhất là 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật. Giả sử tài sản của ông

A được chia thừa kế theo pháp luật thì 1 suất là 300 triệu thì vợ ông A và C mỗi người ít nhất phải nhận được 200 triệu.

4.5.3. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự do pháp luật. Người thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ nuôi dưỡng.

- *Các trường hợp hưởng thừa kế theo pháp luật*:

Theo điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong các trường hợp sau

+ Không có di chúc;

+ Di chúc không hợp pháp;

+ Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

+ Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

+ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

+ Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

+ Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

- *Diện và hàng thừa kế:*

Diện thừa kế được hiểu là phạm vi những người có quyền hưởng di sản của người chết theo quy định của pháp luật. Diện thừa kế được xác định dựa vào quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng với người để lại di sản. Hàng thừa kế là nhóm những đối tượng được thừa kế xếp cùng một hàng. Theo quy định tại Điều 651, Bộ luật Dân sự 2015 thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo 3 hàng sau đây

+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

+ Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

+ Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Thừa kế được phân chia theo nguyên tắc (i) Di sản thừa kế chỉ được chia cho một hàng thừa kế theo thứ tự 1, 2, 3. (ii) Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. (iii) Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước.

- *Một số trường hợp đặc biệt khi chia thừa kế theo pháp luật*

+ Thừa kế thế vị (Điều 652, Bộ luật Dân sự 2015)

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Ví dụ: A và B là hai vợ chồng có hai con là C và D. C có vợ là H, có con là K. K có vợ là M, có con là N. Giả sử C, K bị tai nạn giao thông và qua đời cùng lúc vào năm 2015. Đến năm 2017, A bị bệnh qua đời thì N được hưởng thừa kế thế vị. Vậy di sản của A được chia cho B, D và N.

+ Thừa kế của con riêng và bố dượng, mẹ kế

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau. Trong trường hợp này con riêng hoặc cha dượng và mẹ kế được tính là một diện trong hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại Điều 651 và vẫn được hưởng thừa kế thế vị theo Điều 652.

4.5.4. Thanh toán và phân chia di sản

- *Thanh toán các nghĩa vụ tài sản của người chết để lại:*

Người hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng với tài sản mà mình đã nhận. Trong trường hợp giá trị di sản để lại ít hơn các nghĩa vụ tài sản thì thứ tự thanh toán được quy định như sau:

+ Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng;

+ Tiền cấp dưỡng còn thiếu;

+ Chi phí cho việc bảo quản di sản;

+ Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ;

+ Tiền công lao động;

+ Tiền bồi thường thiệt hại;

+ Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước;

+ Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân;

+ Tiền phạt;

+ Các chi phí khác.

Sau khi thanh toán các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế như trên thì số tài sản còn lại được phân chia cho người thừa kế.

- *Phân chia di sản thừa kế:*

+ Phân chia di sản theo di chúc

Điều 659, Bộ luật Dân sự 2015 quy định "việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản".

+ Phân chia di sản theo pháp luật

- Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

- Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể

thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

- Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia. Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

- Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Dân sự năm 1995.
2. Bộ luật Dân sự năm 2005.
3. Bộ luật Dân sự năm 2015.
4. Ngô Huy Cương (2013), *Giáo trình Luật Hợp đồng – Phần chung*, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Trường Đại học Luật Hà Nội (2020), *Giáo trình Luật dân sự 1*, Nxb Công an nhân dân.
6. Trường Đại học Luật TP. HCM (2014), *Giáo trình Những quy định chung về luật dân sự*, Nxb Hồng Đức.
7. Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), *Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*, Nxb Công an nhân dân.

8. Đỗ Văn Đại (2019), *Luật Hợp đồng Việt Nam- bản án và bình luận bản án*, Nxb Hồng Đức.
9. Đỗ Văn Đại (2016), *Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015*, Nxb Hồng Đức**.**
10. Nguyễn Ngọc Điện (2000), *Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt Nam*, Nxb Trẻ, TP HCM.
11. Nguyễn Văn Huy (2019), *Quyền nhân thân trong pháp luật dân sự Việt Nam*, Nxb Tư pháp.
12. Trương Hồng Quang (2018), *Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật Dân sự hiện hành (năm 2015) và những tình huống thực tế*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật.
13. Lê Quang Thành (2018), *Pháp luật về thừa kế được áp dụng theo Bộ luật Dân sự năm 2015*, Nxb Lao động.
14. Trần Văn Biên, Nguyễn Minh Oanh, Tiền ảo và một số vấn đề pháp lý đặt ra ở Việt Nam hiện nay, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 4/2020**.**

CHƯƠNG 5
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT LAO ĐỘNG

5.1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT LAO ĐỘNG

5.1.1. Khái niệm luật lao động

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động luôn được xem là vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng quan trọng đến sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Nguồn lao động là tổng số những người trong độ tuổi lao động quy định đang tham gia lao động hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm. Quan hệ lao động là sự thể hiện trên thực tế quan hệ cung – cầu lao động, là sự tương tác giữa người lao động và người sử dụng lao động đối với các bên liên quan. Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động thuộc nhóm những vấn đề phức tạp và hóc búa nhất đối với mỗi nhà nước nói chung, với các nhà hoạch định chính sách, pháp luật nói riêng do tính nhạy cảm của quan hệ lao động liên quan đến sức lao động của con người – đối tượng luôn được ưu tiên bảo vệ của các nhà nước.

Quan hệ lao động là một trong những vấn đề lý luận quan trọng của khoa học luật lao động. Để duy trì, phát triển bền vững, hài hòa và tốt đẹp giữa người sử dụng lao động và người lao động luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ của của các bên tham gia quan hệ lao động mà còn của tổ chức đại diện người lao động cũng như nhà nước. Quan hệ lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 "*là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể*"[106].

Người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi[107]. Từ quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động bao gồm:

[106] Khoản 5 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019.
[107] Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019.

- Người lao động là người thành niên, là người từ đủ mười tám tuổi trở lên. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người lao động là người chưa thành niên được toàn quyền tham gia vào quan hệ sử dụng lao động một cách độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trừ trường hợp bị hạn chế[108] hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự[109] theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Người lao động là người chưa thành niên nghĩa là người chưa đủ mười tám tuổi. Để tham gia vào quan hệ sử dụng lao động, lao động là người chưa thành niên phải tuân thủ quy định về lao động là người chưa thành niên.

Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ[110].

Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh[111].

---

[108] Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án có thể ra quyết định tuyên bố người này là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tòa án quyết định người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và phạm vi đại diện. Việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày hoặc luật liên quan có quy định khác. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

[109] Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

[110] Khoản 2 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019.

[111] Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động là một quyền của doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp[112]. Khi tham gia vào quan hệ sử dụng lao động, tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà chủ thể xác lập, tổ chức thực hiện việc sử dụng lao động là khác nhau.

Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã[113]. Hợp tác xã có quyền tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên, quyền quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cũng như thuê và sử dụng lao động[114].

Cơ quan, tổ chức, trừ tổ chức kinh tế là các pháp nhân phi thương mại, nghĩa là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên. Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác[115]. Khi tham gia vào quan hệ sử dụng lao động, pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký[116].

---

[112] Khoản 6 Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
[113] Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2012.
[114] Khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Hợp tác xã năm 2012.
[115] Điều 76 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[116] Điều 86 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Hộ gia đình, bao gồm hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ và hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp cũng có quyền tham gia vào quan hệ pháp luật sử dụng lao động[117]. Chủ hộ là người đại diện hộ gia đình xác lập quan hệ sử dụng lao động. Tuy nhiên, cần có những quy định cụ thể hơn, nhất là việc sử dụng lao động là người trong gia đình[118].

5.1.2. Đối tượng điều chỉnh

Về lý luận, đối tượng điều chỉnh của ngành luật là các quan hệ xã hội thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật. Theo quy định hiện hành, phạm vi áp dụng của Bộ luật Lao động hiện hành bao gồm các quy định về[119]:

- Tiêu chuẩn lao động.

- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

- Các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 đã mở rộng thêm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động cùng một số tiêu chuẩn riêng. Có thể khẳng định, việc điều chỉnh cả các việc làm không có quan hệ lao động đã mở rộng và đảm bảo người sử dụng lao động phải nghiêm túc hơn trong quá trình sử dụng lao động. Những trường hợp dù không ký kết hợp đồng nhưng hai bên thỏa thuận, có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động.

Bộ luật Lao động được áp dụng đối với các đối tượng sau đây[120]:

---

[117] Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 4/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

[118] Giang, V. T., & Huong, V. T. M. (2022). Business households in the context of Vietnam's culture and law. *Linguistics and Culture Review*, *6*(1), 127-142. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n1.2069

[119] Điều 1 Bộ luật Lao động năm 2019.

[120] Điều 2 Bộ luật Lao động năm 2019.

- Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.

- Người sử dụng lao động.

- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động do nhiều chủ thể tương tác với nhau, gồm: người lao động và tổ chức đại diện của người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước. Các chủ thể quan hệ lao động tương tác thông qua cơ chế tham vấn, đối thoại, thương lượng tạo thành cơ chế vận hành của quan hệ lao động. Trong đó có cơ chế hai bên (người lao động, đại diện của người lao động với người sử dụng lao động; đại diện của người lao động với đại diện người sử dụng lao động) và cơ chế ba bên (Nhà nước – đại diện người sử dụng lao động – đại diện của người lao động)[121].

- Cơ chế ba bên được hình thành trên cơ sở tương tác giữa Chính phủ với tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, trong đó Chính phủ có vai trò chính trong việc tham vấn ý kiến của các bên về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng, ban hành các chính sách pháp luật về quan hệ lao động; đối thoại để giải quyết những vướng mắc cũng như hỗ trợ các bên trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Cơ chế ba bên được hình thành ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ chế hai bên được hình thành trên cơ sở tương tác giữa người lao động, tổ chức đại diện của người lao động với người sử dụng lao động động trong phạm vi doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức đại diện của người lao động với tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong phạm vi ngành thông qua cơ chế đối thoại, thương lượng, thỏa thuận để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cả hai bên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ.

---

[121] Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, *Báo cáo quan hệ lao động 2017*, Hà Nội, 2018, tr.3.

5.1.3. Phương pháp điều chỉnh

a) Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận

Đây là phương pháp điều chỉnh quan trọng của luật lao động trong nền kinh tế thị trường phương pháp này được sử dụng trong việc thiết lập quan hệ lao động (giao kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, phương pháp này được sử dụng khi ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động,…). Theo quy định hiện hành, "Quan hệ lao động được xác lập qua đối thoại, thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện người lao động xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định với sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền"[122].

b) Phương pháp mệnh lệnh

Phương pháp này một mặt được sử dụng để xác định nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động[123], mặt khác cũng là biện pháp để Nhà nước quy định chính sách áp dụng đối với quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động. Chính sách của Nhà nước về lao động bao gồm[124]:

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

- Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng một số quy định của Bộ luật này đối với người làm việc không có quan hệ lao động.

- Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; nâng cao năng suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; hỗ trợ duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người

[122] Khoản 1, khoản 2 Điều 7 Bộ luật Lao động năm 2019.
[123] Xem cụ thể tại Điều 5, Điều 6 Bộ luật Lao động năm 2019.
[124] Điều 4 Bộ luật Lao động năm 2019.

lao động; ưu đãi đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung, cầu lao động.

- Thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

- Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên.

c) Phương pháp tác động xã hội thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn tác động vào các quan hệ phát sinh trong quá trình lao động

Đây là phương pháp điều chỉnh đặc thù của luật lao động, theo phương pháp này để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình lao động có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn, tuy nhiên mức độ phạm vi tham gia do pháp luật quy định nhằm đảm bảo tính tự chủ của người sử dụng lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, công đoàn tham gia cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động[125]. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động khác được thành lập theo quy định của pháp luật có vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định[126].

5.2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

5.2.1. Khái niệm, phân loại hợp đồng lao động

5.2.1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng lao động

Về lý luận, hợp đồng được tạo ra bởi sự thỏa thuận/sự ưng thuận của hai hoặc nhiều bên[127] (gọi là các bên). Sự thỏa thuận là sự thống nhất ý chí

[125] Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Lao động năm 2019.
[126] Khoản 4 Điều 7 Bộ luật Lao động năm 2019.
[127] Đỗ Văn Đại, *Luật Hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án (tập 1)*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.556.

của các bên, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, là tiền đề hình thành hợp đồng giữa các bên trong hợp đồng. Đối với lĩnh vực lao động, chế định hợp đồng lao động là chế định chủ yếu, chiếm vị trí quan trọng và giữ vai trò trung tâm điều chỉnh quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường. Hợp đồng lao động là xương sống, là hình thức pháp lý ghi nhận quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, là căn cứ pháp lý chủ yếu làm phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật lao động. Hợp đồng lao động có vai trò quan trọng trong tạo lập, duy trì quan hệ lao động bền vững, ổn định, cùng có lợi. So với Bộ luật Lao động 2012, những quy định về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều thay đổi chủ yếu theo hướng mở rộng hơn quyền tự do thỏa thuận của các bên, bình đẳng và tôn trọng hơn quyền của lao động đặc thù, bắt nhịp với sự vận động của quan hệ lao động trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ thông tin, bảo đảm tính khả thi hơn. Cùng với việc sửa đổi, khắc phục những hạn chế trong quy định Bộ luật Lao động 2012, quy định về hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019 tiếp cận gần hơn với những tiêu chuẩn lao động quốc tế, hoàn thiện một bước trong điều chỉnh pháp luật về hợp đồng lao động. Cụ thể:

- Hợp đồng lao động được nguyên tắc tự do khế ước của nền kinh tế thị trường và yêu cầu phát triển thị trường lao động. Các quan hệ hợp đồng mang tính tự nguyện và bình đẳng. Trong đó, các bên có quyền tự nguyện thỏa thuận với nhau về các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình. Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý linh hoạt, phù hợp với sự năng động của cơ chế thị trường. Sự linh hoạt của hợp đồng lao động thể hiện qua các loại hợp đồng có thời hạn dài, ngắn khác nhau, được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc lời nói, cùng với các trường hợp có thể thay đổi, hủy bỏ hợp đồng…

- Nội dung của hợp đồng lao động liên quan đến hầu hết các chế định của Bộ luật Lao động và là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Thông thường, trong một bản hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu như: công việc phải làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội,… Do đó, nội dung của hợp đồng lao động trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hầu hết các chế định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động là công cụ pháp lý hữu hiệu để Nhà nước quản lý lao động. Việc ký kết một hợp đồng lao động cụ thể là công việc của từng người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, lao động là

vấn đề xã hội, Nhà nước không chỉ tạo điều kiện để các bên dễ dàng, thuận tiện trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động mà còn phải đảm bảo để việc giao kết, thực hiện hợp đồng đúng pháp luật.

Hợp đồng lao động theo quy định hiện hành là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động[128]. So với Bộ luật Lao động năm 2012, điểm khác biệt ở đây là định nghĩa này đã thay cụm từ "việc làm có trả công, tiền lương" thay vì cụm từ "việc làm có trả lương" trong quy định Bộ luật Lao động 2012. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ luật Lao động năm 2019 mở rộng phạm vi nội dung của hợp đồng lao động, chỉ cần nội dung là việc làm có trả công cũng là một dấu hiệu thỏa mãn tiêu chí nội dung hợp đồng lao động thay vì chỉ là trả lương như trước kia. Điều này cũng là hoàn toàn phù hợp với một quy định rất mới mẻ, có tính đột phá về nhận diện hợp đồng lao động được đề cập ngay tại Điều 15 Bộ luật Lao động 2019: "Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động".

Quy định về nhận diện hợp đồng lao động này là một điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019 bằng việc chú trọng tới bản chất, nội dung của hợp đồng lao động chứ không chỉ dựa vào hình thức của hợp đồng lao động. Như vậy, chỉ cần có đủ dấu hiệu: (i) Có sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, (ii) Việc làm có trả công, tiền lương và (iii) Có sự quản lý điều hành, giám sát của một bên thì là hợp đồng lao động mà không cần quan tâm đến tên gọi của nó. Đây là những dấu hiệu nhận diện vốn được ILO đề cập trong Công ước, khuyến nghị của mình khi nhận diện hợp đồng lao động so với các quan hệ dân sự khác. Mặt khác, quy định này cũng sẽ khắc phục được hạn chế trong thực tiễn trước đây khi người sử dụng lao động thường sử dụng các tên gọi như Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng chuyên gia, Hợp đồng cộng tác viên,... để tránh phải thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng theo quy định luật lao động cũng

[128] Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019.

như nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Vô hình trung, người thiệt lại chính là những người lao động khi quyền lợi không được bảo vệ trong khi nội dung hợp đồng xác định các nghĩa vụ giống hệt như hợp đồng lao động. Quy định mới này sẽ khắc phục được hạn chế diễn ra trong thời gian dài trước đây.

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm của hợp đồng lao động như sau:

Thứ nhất, có sự phụ thuộc pháp lý của người lao động với người sử dụng lao động. Vì vậy, yếu tố bình đẳng trong hợp đồng dường như mờ nhạt, khi người sử dụng lao động có quyền ra lệnh cho người lao động và người lao động có nghĩa vụ phải thực hiện.

Thứ hai, đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm có trả công. Hợp đồng lao động là một loại quan hệ mua bán đặc biệt khi hàng hóa mang ra trao đổi là sức lao động, luôn tồn tại gắn liền với cơ thể người lao động. Tiền công trong hợp đồng lao động được trả cho sức lao động hiện tại – lao động sống.

Thứ ba, hợp đồng lao động do đích danh người lao động thực hiện. Người lao động phải trực tiếp thực hiện hợp đồng lao động, người lao động muốn nhờ người khác làm thay phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hợp đồng lao động với hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế. Vì trong hợp đồng dân sự hay trong hợp đồng kinh tế, người ký hợp đồng có thể uỷ quyền hoặc thuê người khác thực hiện, đảm bảo đúng nghĩa vụ hai bên đã thỏa thuận.

Thứ tư, nội dung của hợp đồng lao động luôn bị chi phối bởi những giới hạn pháp lý nhất định. Cũng như các loại hợp đồng khác, nội dung của hợp đồng lao động do các bên thỏa thuận. Tuy nhiên, quyền tự do của các bên thường bị chi phối bởi các quy định của pháp luật lao động. Đặc trưng này của hợp đồng lao động, xuất phát từ nhu cầu bảo vệ, duy trì và phát triển sức lao động trong nền kinh tế thị trường trên cơ sở nguyên tắc thỏa thuận: quyền lợi của người lao động là tối đa, nghĩa vụ là tối thiểu.

Thứ năm, hợp đồng lao động được thực hiện liên tục trong một khoảng thời gian nhất định hay vô hạn định. Sự ngắt quãng, tạm ngưng trong việc thực hiện hợp đồng chỉ được thực hiện trong các trường hợp được pháp luật quy định.

5.2.1.2. Các loại hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định 3 loại Bộ luật Lao động gồm không xác định thời hạn; xác định thời hạn từ 12 tới 36 tháng và Hợp đồng

lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chỉ gồm 2 loại, đó là:

(5) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

(ii) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn mà khi hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động.

Từ quy định trên cho thấy, Bộ luật Lao động 2019 đã gộp 2 loại hợp đồng lao động xác định thời hạn và theo mùa vụ, công việc lại thành một loại sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho việc quy định và thực hiện pháp luật về thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động vì xét về bản chất 2 loại này đều là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Về mặt hình thức nó cũng rất phù hợp với tên gọi, đỡ gây khó khăn trong giải thích pháp luật so với quy định trước đây. Về thực tiễn thì rất khó xác định hợp đồng lao động nào là trên hay dưới 12 tháng mà điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của các bên, do vậy cần đảm bảo sự tự do trong giao kết về thời hạn hợp đồng lao động, hạn chế sự can thiệp không cần thiết vào việc tự do xác định thời hạn của hợp đồng lao động.

Bộ luật Lao động năm 2019 không giới hạn số lần giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động cao tuổi và lao động nước ngoài. Về nguyên tắc, chỉ được ký tối đa 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn (Điều 20 Bộ luật Lao động 2019) vốn được quy định từ năm 2012, song, điểm mới là tại Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 cho phép người sử dụng lao động "thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn với người cao tuổi" và Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 cho phép người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài tại Việt Nam "có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn". Đây là quy định nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế khi người sử dụng lao động không thể ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động cao tuổi bởi đặc điểm riêng về tuổi của lao động này dẫn đến những khó khăn khi chấm dứt hợp đồng lao động theo luật. Thực tế thì họ thường ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và vì vậy việc quy định được phép ký nhiều lần là rất phù hợp. Còn với lao động nước ngoài thì bảo đảm quyền lao động của họ phù hợp với quy định về cấp phép lao động vốn đang quy định là với thời hạn tối đa là 2 năm nên nếu chỉ khống chế ký 2 lần loại hợp đồng lao động xác định thời hạn sẽ dẫn đến những khó khăn, cản trở trong việc huy động và sử dụng lao động này bởi chỉ được tối đa 4 năm (trong bối cảnh quy định mới không được sửa đổi về thời hạn của hợp đồng lao động theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 hiện nay).

5.2.2. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

Về nguyên tắc người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó; c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó; d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

5.2.3. Hình thức và nội dung của hợp đồng lao động

Hình thức hợp đồng trong Bộ luật Dân sự hiện hành được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Trong đó, giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản[129]. Lời nói là những gì con người nói trong một hoàn cảnh giao tiếp cụ thể, là sản phẩm cụ thể của hoạt động ngôn ngữ[130]. Thông qua hệ thống các cơ quan của con người làm cho ngôn ngữ được phát ra nên pháp luật dùng thuật ngữ "bằng lời nói" để chỉ hình thức hợp đồng. Thông qua lời nói, các thông tin về các nội dung cơ bản của hợp đồng được các bên giao kết hợp đồng thể hiện và thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng (*đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết*). Khi các bên thỏa thuận được các nội dung của hợp đồng thì đồng nghĩa với hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực.

Văn bản là bản viết hoặc in, mang nội dung là những gì cần được ghi để lưu lại làm bằng. Nó là một chuỗi ký hiệu ngôn ngữ, hay nói chung là những ký hiệu thuộc về một hệ thống nào đó, làm thành một chỉnh thể mang một nội dung ý nghĩa trọn vẹn[131]. Hệ thống các câu, các đoạn văn sẽ ghi nhận đầy đủ những nội dung cơ bản của hợp đồng và các bên cùng ký tên xác nhận, làm cho hợp đồng có tính xác thực về nội dung đã cam kết, có tính tin cậy cao. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm

---

[129] Xem: Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[130] Viện Ngôn ngữ học, *Từ điển Tiếng Việt,* Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, tr.756.
[131] Viện Ngôn ngữ học, *Từ điển Tiếng Việt,* Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội tr.1406.

điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác cũng đã được ghi nhận và giải thích trong pháp luật Việt Nam.

Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự[132]. Trên cơ sở phương tiện điện tử, các thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ[133]. Biểu hiện của thông điệp dữ liệu là các hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác[134].

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với với chuyển đổi công nghệ, tự động hoá, số hoá trong nền kinh tế truyền thống, một bộ phận người lao động có thể chuyển sang các ngành mới nổi (như kinh tế nền tảng), một bộ phận người lao động sẽ phải đào tạo lại để chuyển đổi việc làm, trong khi tỉ trọng lao động kỹ năng bậc cao sẽ tăng lên. Trong khi đó, áp lực của thị trường và công nghệ ngày càng cao, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, giữa các nền kinh tế, và giữa các chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp sẽ là đối tác dẫn dắt sự phát triển quan hệ lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng trong nền kinh tế phối hợp, công đoàn và nhà nước đóng vai trò điều chỉnh, hỗ trợ quan trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là với người lao động[135].

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định hợp đồng lao động được giao kết dưới hình thức (i) bằng văn bản, (ii) bằng lời nói và (iii) thông điệp dữ liệu điện tử (Điều 14). Hợp đồng lao động giao kết bằng lời nói chỉ được áp dụng đối với hợp đồng lao động dưới 1 tháng thay vì 3 tháng như trước đây (trừ 3 trường hợp: lao động giúp việc gia đình, người lao động dưới 15 tuổi và người lao động được ủy quyền đại diện nhóm). Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử cũng được xác định là chứng cứ trong hoạt động tố tụng dân sự, vì vậy, cần bảo vệ quyền lợi cho

---

[132] Khoản 10 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
[133] Khoản 12 Điều 4 Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
[134] Điều 10 Luật Giao dịch điện tử năm 2005.
[135] Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Sam sung Việt Nam, *Nhận diện Quan hệ lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và vấn đề đặt ra cho việc nâng cao vị thế và bảo vệ người lao động tại Việt Nam,* nghiên cứu trong khuôn khổ của Diễn đàn đa phương – MSF 2021, Hà Nội, tháng 10, 2021.

người lao động bằng việc ghi nhận hình thức giao kết hợp đồng lao động này. Quy định này còn phù hợp với sự phát triển trong ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự tại doanh nghiệp hiện nay.

Để bảo đảm cho việc xác lập hợp đồng, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin của các bên trong hợp đồng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu[136]. Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu[137].

Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động.

- Công việc và địa điểm làm việc.

- Thời hạn của hợp đồng lao động.

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Chế độ nâng bậc, nâng lương.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

---

[136] Khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019.
[137] Khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2019.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

Trong thực tiễn giao kết hợp đồng lao động người lao động do là bên yếu thế nên thường gặp khó khăn trong tiếp cận nội dung dự thảo hợp đồng lao động. Do đó, để tạo lập hợp đồng lao động ít rủi ro và vận dụng các quy định pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động để giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình lao động thì người lao động phải có được các kỹ năng cần thiết để giao kết, thực hiện hợp đồng lao động. Thực tế là, hầu hết người lao động còn thiếu các kỹ năng cần thiết để giao kết, thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận riêng với người sử dụng lao động. Điều này được thể hiện ở chỗ người lao động chưa chú ý đến các điều khoản của hợp đồng, nhất là các điều khoản ẩn chứa nguy cơ gây bất lợi cho người lao động. Trong giai đoạn triển khai các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì việc trang bị, phát triển các kỹ năng giao kết, thực hiện hợp đồng lao động cần thiết để người lao động có thể dự liệu hoặc định hướng những nội dung cốt lõi của hợp đồng lao động để giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình lao động là công việc cần phải được thực hiện càng nhanh càng tố để người lao động có thể chủ động hội nhập với tiêu chuẩn lao động mới[138].

5.2.4. Thử việc

Thử việc là một trong những quyền của các bên trong quan hệ hợp đồng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc[139]. Tuy nhiên, thử việc

[138] Vien The Giang, Developing Skills In Signing and Implementing Labor Contracts For Employees To Meet The Requirements of New-Generation Free Trade Agreements, *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, Vol. 5 No. 3 (2021), p.1329-1338.
[139] Khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019.

không áp dụng đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng[140]. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó[141]. Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây[142]:

- Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

- Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Thỏa thuận thử việc phải lập hợp đồng với các nội dung chủ yếu sau đây[143]:

- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động.

- Công việc và địa điểm làm việc.

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao

[140] Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019.
[141] Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2019.
[142] Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019.
[143] Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019.

kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường[144].

5.2.5. Thực hiện Hợp đồng lao động

Về cơ bản, Bộ luật Lao động 2019 không có sửa đổi nhiều về quy định trong thực hiện hợp đồng lao động so với Bộ luật Lao động 2012. Những thay đổi chủ yếu tập trung ở quy định về tạm hoãn hoặc điều chuyển người lao động sang làm công việc khác. Cụ thể là:

Thứ nhất, bổ sung thêm một số các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động. Bên cạnh 5 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 thì tại Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định bổ sung thêm 3 trường hợp thành 8 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, 3 trường hợp bổ sung là:

(i) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

(ii) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

(iii) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Việc mở rộng hơn các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động đã bảo đảm hơn sự linh hoạt cho cả người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động. Cũng cần lưu ý, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Thứ hai, lý do chuyển người lao động sang làm công việc khác do nhu cầu sản xuất kinh doanh phải được quy định cụ thể trong nội quy lao động. Cũng như Bộ luật Lao động 2012 (Điều 31), Bộ luật Lao động 2019

[144] Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019.

quy định các trường hợp điều chuyển lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Điều 29 bao gồm gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng các biện pháp ngừa,... và do nhu cầu sản xuất, kinh doanh với các điều kiện về thời gian (không quá 60 ngày cộng dồn trong năm), tiền lương (theo công việc mới, nếu thấp hơn công việc cũ thì được giữ nguyên trong thời hạn 30 ngày...).

Tuy nhiên, điểm khác là Bộ luật Lao động 2019 đã quy định cụ thể trường hợp điều chuyển vì lý do "do nhu cầu sản xuất kinh doanh" phải được quy định cụ thể các trường hợp trong nội quy lao động, nếu không việc điều chuyển được coi là không bảo đảm căn cứ pháp lý (khoản 1 Điều 29). Quy định này nhằm bảo vệ người lao động tránh việc điều chuyển theo "cảm tính", thiếu cơ sở vốn diễn ra khá phổ biến trước đây khi không có quy định này.

Về thủ tục, khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động. Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, người lao động được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Các trường hợp người lao động được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

- Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;.

- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật Lao động.

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác[145].Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

5.2.6. Chấm dứt hợp đồng lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động tức là sự kiện pháp lý quan trọng ảnh hưởng lớn tới các bên trong quan hệ lao động, đặc biệt là trường hợp chấm dứt ngoài ý muốn chủ quan được thống nhất bởi các chủ thể. Theo quy định pháp luật, việc chấm dứt hợp đồng lao động có thể diễn ra do ý chí một bên, hai bên hoặc bên thứ ba. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm:

[145] Điều 31 Bộ luật Lao động năm 2019.

- Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động.

- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

- Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 của Bộ luật Lao động[146].

---

[146] Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động được quy định trong hai trường hợp:

Một là, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.
- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Hai là, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động.

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động[147].

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật Lao động.
- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động.
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Lao động.
- Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật Lao động làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

[147] Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
- Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc.
- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động.
- Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.
- Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật Lao động khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Để bảo đảm quyền lợi người lao động, Bộ luật Lao động không cho phép người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trong các trường hợp:
- Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động.
- Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

- Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật Lao động.

- Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật Lao động.

- Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc.

Bộ luật Lao động năm 2019 đã có nhiều thay đổi về việc chấm dứt hợp đồng lao động so với Bộ luật Lao động năm 2012, cụ thể:

Một là, bổ sung các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Bên cạnh 10 trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt được quy định trước đó tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012 thì tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định tới 13 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm 3 trường hợp mới được bổ sung như sau:

(i) Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân bị cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật;

(iii) Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Với ba trường hợp mới bổ sung này chủ yếu liên quan đến yếu tố nước ngoài là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thực tế cho thấy chúng ta đã từng rất khó khăn, thiếu cơ sở pháp lý để xử lý và giải quyết quyền lợi cho người lao động trong trường hợp một tình huống khá phổ biến gần đây, đó là tình trạng chủ sử dụng lao động nước ngoài bị trục xuất, bỏ trốn. Hậu quả để lại là những khó khăn trong giải quyết quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bởi thiếu người xác nhận, hoàn thiện hồ sơ

- Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

hưởng trợ cấp, chốt sổ Bảo hiểm xã hội. Quy định này đã lấp chỗ hổng của pháp luật, bảo đảm căn cứ để xác định chấm dứt hợp đồng lao động, giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Hai là, bỏ quy định về bảo đảm căn cứ khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Trước đây, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải bảo đảm điều kiện về nội dung (có căn cứ) và thủ tục (nghĩa vụ báo trước) trừ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì không cần viện dẫn lý do mà chỉ cần bảo đảm điều kiện báo trước. Đến Bộ luật Lao động 2019 đã có một thay đổi lớn bằng việc mở rộng quyền chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động thông qua quy định về điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động là không cần có lý do đối với mọi loại hợp đồng lao động mà chỉ cần bảo đảm điều kiện báo trước theo quy định pháp luật. Mục đích báo trước cho người sử dụng lao động nhằm giúp cho người sử dụng lao động có kế hoạch tìm người thay thế, tránh tình trạng bị động dẫn đến sự gián đoạn trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

"1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ".

Đồng thời, Bộ luật Lao động 2019 cũng mở rộng quyền của người lao động với một số trường hợp đặc biệt, họ còn được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước, như: (i) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động; (ii) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp bất khả kháng; (iii) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; (iv) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; (v) Lao động nữ

mang thai phải nghỉ việc; (vi) Đủ tuổi nghỉ hưu hoặc theo thỏa thuận của các bên; (vii) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Có thể nói đây là một quy định mới có tính đột phá và cũng có nhiều quan điểm xung quanh quy định này. Về tổng quan, mục đích của thay đổi quy định này nhằm mở rộng quyền tự do cho người lao động, đồng thời cũng xuất phát từ một thực tế khá phổ biến trước đây đó là tình trạng người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không có lý do là khá phổ biến, khi cần chấm dứt họ sẵn sàng thực hiện việc chấm dứt mà ít khi viện dẫn những lý do hợp pháp. Điều này không chỉ xuất phát từ nhu cầu chủ thể mà còn từ thực tiễn quy định các căn cứ chấm dứt khá cứng nhắc, khó có thể đáp ứng được yêu cầu căn cứ chứng minh (chẳng hạn như bị quấy rối tình dục, ngược đãi,...) hoặc người lao động nghĩ rằng có chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp thì cũng khó được bảo đảm quyền lợi và nếu có chấm dứt bất hợp pháp thì mức bồi thường cũng thấp và người sử dụng lao động cũng khó có thể lấy khoản tiền bồi thường này và vì vậy họ thường bỏ qua điều kiện căn cứ này.

Ba là, bổ sung thêm căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Bộ luật Lao động năm 2019 đã mở rộng hơn quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động đối với người lao động bằng việc bổ sung thêm các căn cứ hợp pháp. Bên cạnh 5 căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động đã quy định trong Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động 2019 còn bổ sung thêm ba trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động sau:

(i) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quy định này bảo đảm tương thích với quy định về nghỉ hưu, trường hợp đủ tuổi nhưng không đủ năm hưởng bảo hiểm hưu trí theo quy định trước đây thì người sử dụng lao động không được phép chấm dứt bởi quy định là chấm dứt để hưởng chế độ hưu trí, nay quy định chỉ cần đủ tuổi nghỉ hưu là người sử dụng lao động có quyền chấm dứt là phù hợp hơn, bảo đảm quyền cho người sử dụng lao động. Người lao động có đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hay chưa vì lý do số năm đóng bảo hiểm xã hội có thể tiếp tục thỏa thuận ký hợp đồng lao động với người cao tuổi hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng hưu hàng tháng.

(ii) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên. Trước đây trường hợp này người sử dụng

lao động được áp dụng kỷ luật sa thải, song nhận thấy hậu quả pháp lý đều dẫn đến việc chấm dứt quan hệ lao động, đồng thời mức độ lỗi cũng như hành vi cho thấy người sử dụng lao động có thể áp dụng căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp hơn, linh hoạt hơn, đồng thời hạn chế bớt những thủ tục xử lý kỷ luật tỏ ra không cần thiết cho người sử dụng lao động. Trên thực tế trước đây, nhiều trường hợp có hành vi vi phạm kỷ luật này người sử dụng lao động cũng đã linh hoạt áp dụng thủ tục và giải quyết theo chế độ chấm dứt hợp đồng lao động nhận được sự đồng tình của hai bên cũng như chấp thuận của cơ quan tư pháp khi có tranh chấp với ý nghĩa bảo vệ hơn quyền lợi của NLĐ so với thực hiện kỷ luật sa thải.

(iii) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. Quy định này tương ứng với trách nhiệm của chủ thể khi giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 15, 16 Bộ luật Lao động 2019. Trong tương quan quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, quy định này là bảo đảm bình đẳng, tương thích.

Bốn là, quy định cụ thể về các trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế làm cơ sở thực hiện cho người lao động nghỉ việc. Điều 44 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định giải quyết cho nhiều NLĐ thôi việc nhưng không quy định cụ thể mà cần có sự hướng dẫn trong Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Khắc phục hạn chế trong áp dụng pháp luật, hiện nay quy định này đã được hướng dẫn cụ thể hơn trong Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019, theo đó những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ gồm:

(i) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

(ii) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;

(iii) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Các lý do kinh tế gồm: (i) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; (ii) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Năm là, không quy định thời hạn thông báo cho người lao động trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Theo Bộ luật Lao động 2012, tại Điều 47 quy định người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động ít nhất 15 ngày, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy việc quy định cụ thể giới hạn thời gian này tỏ ra cứng

nhắc, thậm chí khó khăn cho người sử dụng lao động, thực tế có nhiều trường hợp người sử dụng lao động không muốn thông báo bởi sợ người lao động cản trở, ảnh hưởng tới công việc chung trong bối cảnh chia tay. Vì vậy, nếu báo trước một khoảng thời gian dài ít nhất là 15 ngày, người sử dụng lao động thường rơi vào tâm lý lo lắng về trách nhiệm của người lao động trong công việc và thường họ chấp nhận vi phạm điều luật này bằng việc sát ngày mới thông báo. Mặt khác, người lao động cũng biết rõ về thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động của mình rồi nên việc khống chế thời hạn tỏ ra không phù hợp.

Khắc phục hạn chế này, Bộ luật Lao động năm 2019 dành riêng một điều luật quy định về việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 45). Theo đó, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật này (trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của Bộ luật). Như vậy việc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng không quy định thời hạn yêu cầu thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động được quyền chủ động trong việc thông báo này.

Sáu là, mở rộng thời hạn giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ chấm dứt hợp đồng lao động. Khoản 2 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Bộ luật Lao động 2019 đã nâng lên gấp đôi thời hạn này là 14 ngày, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp được coi là đặc biệt để kéo dài thời hạn thanh toán tới 30 ngày bao gồm:

(i) Trường hợp người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

(ii) Trường hợp người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

(iii) Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

(iv) Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

5.3. Tiền lương, thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi

5.3.1. Tiền lương

Tiền lương là một phạm trù kinh tế, là một kết quả quan trọng của sự phân phối của cải trong xã hội. Kinh tế học vi mô coi sản xuất là sự kết hợp giữa hai yếu tố là lao động và vốn. Vốn thuộc quyền sở hữu của một bộ phận dân cư trong xã hội, còn một bộ phận dân cư khác do không có vốn chỉ có sức lao động, phải đi làm thuê cho những người có vốn và đổi lại họ nhận được một khoản tiền gọi là tiền lương. Theo tổ chức lao động Quốc tế (ILO), tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm. Bản chất của tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động, là số tiền mà người lao động được người sử dụng lao động của họ thanh toán lại, tương ứng với số lượng và chất lương lao động mà họ đã tiêu hao trong quá trình tạo ra của cải, vật chất, phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu lao động trên thị trường lao động, nhưng không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu đủ sống do luật pháp quy định và được xác định thông qua cơ chế thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động. Do đó, được hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động là một trong những quyền của người lao động[148].

Tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau[149]. Nội dung chế độ pháp lý tiền lương hiện nay bao gồm:

Thứ nhất, các quy định về tiền lương tối thiểu

[148] Điểm b Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019.
[149] Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong khu vực thị trường, tiền lương thường được điều chỉnh thông qua đàm phán tự nguyện, theo hình thức cá nhân hoặc tập thể, giữa người sử dụng lao động và người lao động. Do cần thiết phải bảo vệ người lao động ở dưới đáy của thị trường lao động, là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi mức lương cực thấp và sự bóc lột lao động, các công cụ chính sách quy định tiền lương tối thiểu bắt buộc được thiết lập và áp dụng ở hầu khắp các quốc gia. Đồng thời, đàm phán tự nguyện (thương lượng tập thể) giữa người sử dụng lao động và các tổ chức công đoàn, công đoàn doanh nghiệp hay công đoàn ngành, đã trở thành một định chế chính để cùng điều chỉnh mức lương và điều kiện làm việc trong nền kinh tế thị trường nhằm hỗ trợ giải quyết sự mất cân đối về quyền thương lượng giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động.

Tiền lương tối thiểu được hiểu là mức lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được, không thể cắt giảm hơn nữa và được bảo vệ bằng pháp luật. Theo công ước về tiền lương tối thiểu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ban hành, các yếu tố được xem xét để xác định mức lương tối thiểu gồm: nhu cầu của người lao động và gia đình họ, mức lương chung của nền kinh tế, chi phí cho cuộc sống và thay đổi nếu có, lợi ích về an sinh xã hội, mức sống tương quan của các nhóm xã hội và các nhân tố kinh tế, bao gồm yêu cầu phát triển kinh tế, mức tăng năng suất và lao động. Việc thiết kế lương tối thiểu cần chú trọng đến mức chi trả và khả năng chi trả của người chủ lao động và của nền kinh tế. Mức lương tối thiểu không phù hợp sẽ tạo ra các tác động vĩ mô bất lợi cho nền kinh tế. Sau khi xác định được mức lương tối thiểu, việc điều chỉnh vẫn được tiến hành định kỳ nhằm đảm bảo cho người lao động có được mức sống tương đối ổn định và tái tạo sức lao động. Như vậy, "sứ mệnh" chính yếu của tiền lương tối thiểu là bảo đảm "mức sống tối thiểu" cho người lao động. Chính vì vậy, khi xây dựng khung tiền lương tối thiểu cần căn cứ vào điều kiện, mức sống, chi phí sinh hoạt theo từng vùng lãnh thổ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi được thiết kế chặt chẽ, tiền lương tối thiểu đem lại sự bảo vệ hiệu quả cho người lao động khỏi việc bị trả lương quá thấp mà không tạo ra tác động tiêu cực đối với việc làm. Các minh chứng quốc tế cũng cho thấy thương lượng tập thể góp phần vào sự ổn định xã hội bằng cách giải quyết các mâu thuẫn giữa người sử dụng lao động và người lao động bằng một quy trình thống nhất để cùng điều chỉnh mức lương và điều kiện làm việc, phù hợp với cá nhân từng doanh nghiệp và/hoặc các ngành kinh tế cụ thể, trong khi cho phép người lao động được chia sẻ thành quả tăng trưởng kinh

tế và năng suất công việc một cách công bằng. Kết hợp lại hai yếu tố, tiền lương tối thiểu và thương lượng tập thể đóng góp cho công bằng xã hội và kinh tế, giúp cho xã hội tiến đến tăng trưởng toàn diện đóng góp vào việc ổn định chính trị và xã hội của quốc gia[150].

Theo quy định hiện hành, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Thứ hai, xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động để làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Thứ ba, nội dung quy định về trả lương cho người lao động bao gồm:

Một là, nguyên tắc trả lương

Việc trả lương cho người lao động được thực hiện trên hai nguyên tắc: "1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người

[150] Decent Work và ILO, Cải cách tiền lương trong khu vực ngoài nhà nước, Tóm tắt chính sách tháng 5/2018, truy cập tại địa chỉ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_628975.pdf.

lao động ủy quyền hợp pháp và 2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định"[151]. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Hai là, hình thức trả lương

Sau khi người lao động được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động, xếp lương theo công việc, chức vụ của hệ thống chế độ tiền lương quy định, căn cứ vào cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phân công lao động, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể lựa chọn, áp dụng các hình thức trả lương để gắn với kết quả công việc, chức vụ của người lao động. Các hình thức trả lương phổ biến được áp dụng là:

- Hình thức trả lương theo sản phẩm, trong đó có: trả lương sản phẩm trực tiếp cá nhân; trả lương sản phẩm gián tiếp; trả lương sản phẩm tập thể; lương sản phẩm theo đơn giá bình thường, đơn giá có thưởng, đơn giá lũy tiến, lũy thoái; trả lương khoán (thường áp dụng trong khu vực sản xuất, kinh doanh).

- Hình thức trả lương theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng, năm) có thưởng hoặc không có thưởng (thường áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và bộ phận gián tiếp trong khu vực sản xuất, kinh doanh).

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và

[151] Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019.

chuyển tiền lương[152]. Trường hợp nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật[153].

Ba là, kỳ hạn trả lương[154]

Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Bốn là, tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm[155]

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau: a) Vào

[152] Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019.
[153] Điều 100 Bộ luật Lao động năm 2019.
[154] Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019.
[155] Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019.

ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Năm là, tiền lương khi ngừng việc. Bộ luật Lao động hiện hành quy định việc trả lương khi ngừng việc trong ba trường hợp là[156]:

- Ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

- Ngừng việc do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

- Ngừng việc do sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau: i) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; ii) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Sáu là, chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động[157]. Người lao động cũng có thể được thưởng một số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho

[156] Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019.
[157] Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019.

người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở[158].

Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ[159].

Người sử dụng lao động không được khấu trừ tiền lương của người lao động trừ trường hợp để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật Lao động và phải cho người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân[160].

5.3.2. Thời gian làm việc

Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

---

[158] Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019.
[159] Điều 101 Bộ luật Lao động năm 2019.
[160] Điều 102 Bộ luật Lao động năm 2019.

Về chế độ làm thêm giờ được chia thành hai trường hợp là: làm thêm giờ trong *trường hợp bình thường* theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động và làm thêm giờ trong *trường hợp đặc biệt*. Nội dung quy định về làm thêm giờ bao gồm:

Thứ nhất, điều kiện để người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ. Theo quy định tại khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

- Phải được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm. Người sử dụng lao động được quyền sử dụng lao động làm vượt số giờ quy định, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong các trường hợp:

i) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.

ii) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

iii) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

iv) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

Thứ hai, làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật Lao động và người lao động không được từ chối trong trường hợp sau đây:

- Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ ba, trong thực tiễn thi hành về làm thêm giờ cho thấy, pháp luật hiện hành đã mở rộng quyền quyết định của các bên quan hệ lao động đối với việc làm thêm giờ, không khống chế các trường hợp được phép làm thêm giờ như quy định trước đây, đồng thời cũng đã tính đến việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người lao động nói riêng và lực lượng lao động. Trong điều kiện hiện tại, trình độ lao động xã hội, năng suất lao động, thu nhập và mức sống của người lao động ở Việt Nam còn thấp thì nhu cầu làm thêm giờ của người lao động và người sử dụng lao động sẽ càng nhiều hơn thì chính giới hạn số giờ làm thêm sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có nhiều công việc có tính chất mùa vụ, gia công theo đơn đặt hàng (dệt may, da giầy, chế biến thủy sản, sản xuất hàng xuất khẩu,…) khi công việc dồn vào một số thời điểm trong năm, nhu cầu làm thêm giờ rất lớn, nếu không sử dụng lao động làm thêm giờ quá quy định thì không thể giải quyết hết công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động, khách hàng, người tiêu dùng và xã hội. Điều này lý giải cho hiện tượng vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc nói chung, làm thêm giờ nói riêng diễn ra khá phổ biến trong các doanh nghiệp – vi phạm mới giải quyết được nhu cầu cần thiết của các bên trong quan hệ lao động. Thực tế, nhiều đơn vị sử dụng lao động đã sử dụng người lao động làm thêm giờ vượt quá giới hạn do pháp luật quy định hoặc vận dụng nhiều cách khác nhau để né tránh quy định của pháp luật (giao việc cho người lao động làm tại nhà và không thanh toán theo chế độ làm thêm giờ; thực tế vẫn sử dụng lao động làm thêm giờ nhưng hạch toán chi phí – mà thực chất là tiền lương làm thêm giờ - vào các khoản khác không phải là tiền lương làm thêm giờ, như "xử lý" hóa đơn chứng từ cho hợp lệ; ép định mức lao động để người lao động phải tự kéo dài thời gian làm việc thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không được tính và thanh toán chế độ làm thêm giờ…).

5.3.3. Thời giờ nghỉ ngơi

Thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bao gồm:

Một là, nghỉ trong giờ làm việc[161]. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác[162].

Hai là, nghỉ hằng tuần. Người lao động mỗi tuần được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Ba là, nghỉ lễ, tết[163]

Người lao động là công dân Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

- Tết Âm lịch: 05 ngày.

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch).

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm

[161] Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019.
[162] Điều 110 Bộ luật Lao động năm 2019.
[163] Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019.

2019 còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019.

Bốn là, nghỉ hằng năm[164]

Chế độ nghỉ hằng năm được áp dụng đối với người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

- 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Năm là, chế độ nghỉ theo thâm niên, nghỉ việc riêng và nghỉ không lương[165]

Trường hợp người lao động đã làm việc đủ 5 năm thì cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật Lao động năm 2019 được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

---

[164] Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019.
[165] Điều 114, Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019.

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây: i) Kết hôn: nghỉ 03 ngày; ii) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày; iii) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. Ngoài ra, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

5.4. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

5.4.1. Kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là hệ quả tất yếu của quyền điều hành lao động nhằm để quản lý lao động, xử lý các hành vi tiêu cực của người lao động trong quá trình lao động. Trong số các hình thức kỷ luật lao động, sa thải người lao động là hình thức kỷ luật hà khắc nhất dẫn đến hậu quả chấm dứt quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do hậu quả của quá trình kỷ luật sa thải lao động có thể dẫn đến việc người lao động bị người sử dụng lao động xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp, nên pháp luật lao động đã có những quy định về hình thức, nguyên tắc, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật,… nhằm hạn chế sự lạm quyền của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, những quy định mang tính kiểm soát, hạn chế quyền xử lý kỷ luật lao động trong một số trường hợp gây cản trở nhất định cho người sử dụng lao động khi thực hiện quyền điều hành quản lý doanh nghiệp. Dưới góc độ lý luận, kỷ luật lao động là một nội dung quan trọng trong quyền quản lý của người sử dụng lao động. Việc thiết lập và duy trì kỷ luật lao động là nhu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình tổ chức lao động xã hội.

Theo nghĩa thông thường và đơn giản nhất, kỷ luật lao động là những quy tắc quy định hành vi cá nhân của người lao động mà đơn vị sử dụng lao động xây dựng dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành, chuẩn mực đạo đức xã hội và yêu cầu đặc thù của hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra một khuôn khổ, trật tự làm việc nhất định buộc mọi người phải tuân theo trên tinh thần hợp tác và nếu có sự vi phạm thì sẽ phải gánh chịu hình thức kỷ luật tương ứng. Kỷ luật lao động là những tiêu chuẩn quy định hành vi cá nhân của người lao động dựa trên ý chí của người sử dụng lao động và pháp luật hiện hành, người lao động có nghĩa vụ phải tuân thủ, nếu có vi phạm xảy ra người lao động phải chịu trách nhiệm trước người sử dụng lao động về hành vi vi phạm của mình. Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật

Lao động năm 2019, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định. Nội dung quy định về kỷ luật bao gồm:

Một là, nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động[166]

Khi xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động cũng như phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên. Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất cũng như không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Bộ luật Lao động cũng quy định rõ không áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật lao động trong các trường hợp:

- Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

- Đang bị tạm giữ, tạm giam.

- Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động năm 2019.

- Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Khi xử lý kỷ luật lao động, nghiêm cấm người sử dụng lao động: 1. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; 2. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; 3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định[167].

---

[166] Điều 122 Bộ luật Lao động năm 2019.
[167] Điều 127 Bộ luật Lao động năm 2019.

Hai là, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng. Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động năm 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn do pháp luật quy định.

Ba là, hình thức xử lý kỷ luật

Bộ luật Lao động hiện hành quy định bốn hình thức xử lý kỷ luật lao động là:

- Khiển trách. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật[168].

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn[169].

- Cách chức.

- Sa thải.

Trong các hình thức xử lý luật trên, hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

- Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động.

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp

[168] Khoản 1 Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2019.
[169] Khoản 2 Điều 126 Bộ luật Lao động năm 2019.

người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật Lao động năm 2019.

- Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Trong quá trình xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên.

Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

5.4.2. Trách nhiệm vật chất

Trách nhiệm vật chất được áp dụng trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp

đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động. Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Lao động năm 2019.
2. Luật Doanh nghiệp năm 2020.
3. Luật Hợp tác xã năm 2012.
4. Bộ luật Dân sự năm 2015.
5. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015.
6. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
7. Luật Việc làm năm 2013.
8. Các nghị định liên quan.
9. Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), *Giáo trình Luật Lao động*.
10. Decent Work và ILO, *Cải cách tiền lương trong khu vực ngoài nhà nước, Tóm tắt chính sách tháng 5/2018*, truy cập tại địa chỉ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_628975.pdf.
11. Vien The Giang (2021), Developing Skills In Signing and Implementing Labor Contracts For Employees To Meet The Requirements of New-Generation Free Trade Agreements, *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, Vol. 5 No. 3.
12. Giang, V. T., & Huong, V. T. M. (2022). Business households in the context of Vietnam's culture and law. *Linguistics and Culture Review*, *6*(1), 127-142. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n1.2069

CHƯƠNG 6
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

6.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình

6.1.1. Khái niệm

Hôn nhân và gia đình là biểu hiện mối quan hệ xã hội giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ, con cái và các thành viên trong gia đình. Đây là những mối quan hệ gần gũi thân thiết và bền vững nhất của con người được liên kết bởi yếu tố kết hôn, huyết thống hay nuôi dưỡng. Luật Hôn nhân và gia đình tạo một phương tiện pháp lý hữu hiệu để xây dựng, hình thành và bảo vệ những mối quan hệ đó.

Có nhiều định nghĩa về Luật Hôn nhân và gia đình dựa vào các cách thức tiếp cận khác nhau như dưới góc độ là một môn học, một văn bản luật hay một ngành Luật.

Dưới góc độ là một ngành luật thì Luật Hôn nhân và gia đình được định nghĩa: là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thể chế hóa nhằm điều chỉnh các quan hệ về nhân thân và tài sản trong hôn nhân và gia đình.

6.1.2. Đối tượng điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình là những quan hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình gồm hai nhóm là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

Nhóm quan hệ nhân thân là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các thành viên trong gia đình gắn liền với một giá trị nhân thân như tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm chăm sóc giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái; giữa ông bà và con cháu;…

Nhóm quan hệ về tài sản: là quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn với tài sản như quan hệ sở hữu tài sản chung, tài sản riêng của vợ và chồng, quan hệ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con cái,…

Trong hai nhóm quan hệ trên thì quan hệ nhân thân đóng vai trò chủ đạo và quyết định. Hầu hết các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình gắn liền với yếu tố nhân thân giữa vợ - chồng và giữa các thành viên trong gia đình kể cả các quan hệ tài sản cũng bị chi phối bởi các quan hệ này.

Các quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân gia đình tồn tại bền vững, lâu dài không mang tính chất đền bù, không thể chuyển giao cho người khác.

6.1.3. Phương pháp điều chỉnh

Phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình là những cách thức, biện pháp mà các quy phạm pháp luật hôn nhân gia đình tác động lên các cơ quan xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình chủ yếu là tự nguyện, bình đẳng. Phương pháp này thể hiện trong các quy định về kết hôn, ly hôn, quan hệ tài sản,… Trong một số trường hợp, Luật Hôn nhân và gia đình có sử dụng biện pháp cưỡng chế như hủy hôn nhân trái pháp luật, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên,…

6.1.4. Các nguyên tắc của Luật Hôn nhân và gia đình

- *Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng*

Hôn nhân tự nguyện là hôn nhân đảm bảo quyền tự chủ, tự do thể hiện ý chí, tình cảm của mình trong quan hệ hôn nhân kể cả khi kết hôn cũng như ly hôn. Các bên được tự do tìm hiểu, kết hôn dựa trên tình yêu chân chính không bị cản trở, ngăn cấm bởi bất kỳ ai. Các bên cũng có quyền yêu cầu chấm dứt hôn nhân khi mục đích hôn nhân không đạt được.

Hôn nhân tiến bộ thể hiện rõ trong các quy định mới về kết hôn và ly hôn đã xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, cướp dâu, bắt vợ; đã thay đổi quan niệm về việc phải cam chịu số phận trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Hôn nhân một vợ, một chồng là hình thái hôn nhân tiến bộ nhất trong lịch sử, phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên, phù hợp với tâm lý, đạo đức của con người. Yêu cầu của nguyên tắc này là mỗi chủ thể chỉ được phép duy trì quan hệ hôn nhân với một người khác. Nghiêm cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, đồng thời cũng xử lý đối với những người chưa có vợ, có chồng lại kết hôn hoặc chung sống như người chồng với người đang có vợ, có chồng.

Trong hôn nhân phải có sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Vợ chồng có vai trò, vị trí ngang nhau trong đời sống gia đình; không có sự phân biệt đối xử trong việc xác lập, thực thi các quyền và nghĩa. Vợ, chồng bình đẳng với nhau về trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản, bình đẳng với nhau về việc chăm sóc con cái, bình đẳng về việc quyết định, thực hiện các vấn đề chung trong gia đình đảm bảo mỗi người đều được

tạo điều kiện và cơ hội như nhau để phát huy năng lực, hưởng thụ ngang nhau các thành quả của sự phát triển.

- *Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ*

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc (với 54 dân tộc anh em), đa tín ngưỡng đa tôn giáo (với hơn 2,5 triệu tín độ của 16 tôn giáo khác nhau)[170]. Đặc điểm này hình thành nên những quy tắc, quan niệm, lối ứng xử khác nhau về hôn nhân và gia đình. Mặc dù vậy bản chất của tình yêu của hôn nhân, của các mối quan hệ gần gũi, ruột thịt là không khác biệt, không có ranh giới. Nguyên tắc này nhằm xác lập sự bình đẳng không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân và gia đình.

Trong quan hệ hôn nhân gia đình các bên cần tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau, không được lấy lý do tôn giáo, dân tộc, quốc tịch để cản trở việc kết hôn, ly hôn hoặc ép buộc kết hôn, ly hôn. Mọi chủ thể cho dù khác biệt về dân tộc, tôn giáo hay quốc tịch đều hưởng các quyền và nghĩa vụ như nhau trong quan hệ hôn nhân và gia đình, đều chịu sự điều chỉnh giống nhau của Luật.

- *Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con*

Gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc là mục tiêu cơ bản của mọi thành viên trong gia đình nói riêng và là mục tiêu của cả xã hội nói chung. Mỗi một gia đình ấm no, hạnh phúc mới tạo thành một tế bào lành mạnh cho xã hội phát triển. Để thực hiện mục tiêu này mỗi một thành viên trong gia đình phải có ý thức xây dựng và cùng nhau hành động, phải tôn trọng, quan tâm, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Cụ thể, vợ chồng phải có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình; cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức; con cái phải yêu quý, kính

[170] Tổng cục Thống kê, *Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019*, truy cập tại https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/ lúc 20h ngày 10/2/2021

trọng biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ; ông bà có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho cháu còn các cháu phải kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà; anh chị em trong gia đình phải thương yêu giúp đỡ nhau;…

Trong quan hệ với các con, cha mẹ phải dành tình thương yêu, quan tâm, chăm sóc các con, không phân biệt đó là con gái hay con trai, con trong giá thú hay con ngoài giá thú.

- *Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình; giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ; thực hiện kế hoạch hóa gia đình*

Trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình thì trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật được xem là nhóm yếu thế, chính vì vậy Nhà nước, xã hội và gia đình cần có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ. Trong một số quan hệ pháp luật như yêu cầu xác định cha mẹ cho con, yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ do cha mẹ bị kết án về tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em,… Luật Hôn nhân và gia đình có quy định về sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em. Đối với người già, người khuyết tật, Luật quy định "Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, đặc biệt khi cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, ốm đau, già yếu, khuyết tật". Phụ nữ trong gia đình cũng là một chủ thể đặc biệt với vai trò làm mẹ, người phụ nữ gặp nhiều thiệt thòi khó khăn hơn so với người đàn ông trong gia đình. Vì vậy Luật có những quy định để bảo vệ người mẹ như hạn chế quyền ly hôn của người chồng khi vợ đang mang thai và nuôi con dưới 12 tháng tuổi, quy định về việc nuôi con dưới 3 tháng tuổi khi vợ chồng không thỏa thuận được việc nuôi con,… Ngoài ra, nguyên tắc thực hiện kế hoạch hóa gia đình cũng là một nội dung cần thực hiện để đảm bảo thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số đồng thời đảm bảo các điều kiện cho việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

- *Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình*

Trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam thì gia đình đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là cái nôi nuôi dưỡng và lưu truyền những

giá trị tốt đẹp của con người. Trong gia đình luôn có sự yêu thương, sẻ chia, đùm bọc giữa các thành viên; sự chung thủy, hòa thuận tình nghĩa giữa vợ và chồng, sự hiếu kính của con cháu đối với ông bà. Những truyền thống này đã được Luật Hôn nhân và gia đình thể chế hóa thành các quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái, giữa vợ và chồng, giữa ông bà và con cháu.

Bên cạnh đó, những phong tục tập quán tốt đẹp về hôn nhân và gia đình không được Luật hóa thành các quy phạm pháp luật cụ thể nhưng phù hợp với nguyên tắc này thì được khuyến khích áp dụng trong đời sống hôn nhân và gia đình.

6.2. Kết hôn

6.2.1. Khái niệm kết hôn

Theo *Từ điển Tiếng Việt*, "kết hôn là việc nam, nữ chính thức lấy nhau thành vợ, chồng"[171]. Kết hôn chính là một sự kiện làm thay đổi cuộc sống của một người khi họ có sự kết nối với một người khác tạo thành một mối quan hệ đặc biệt gọi là vợ chồng. Theo truyền thống, phong tục của người Việt thì việc kết hôn hay "lấy nhau" thường được đánh dấu bằng các nghi thức truyền thống hay nghi thức tôn giáo nhất định. Chẳng hạn, các bên lấy nhau phải trải qua nghi thức cưới với các lễ dạm, lễ hỏi, lễ đón dâu hay nghi thức tổ chức cưới tại nhà thờ của những người theo đạo Thiên Chúa. Các nghi thức này phản ánh sự chứng kiến, sự cho phép của gia đình hay của cộng đồng đối với việc thiết lập hôn nhân của hai người. Như vậy, dưới góc độ xã hội kết hôn là hình thức xác lập quan hệ hôn nhân.

Dưới góc độ pháp lý, kết hôn là một sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng. Sự kiện này do Nhà nước quy định nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người tham gia hay nói cách khác khi các bên mong muốn xác lập quan hệ vợ chồng phải có sự chấp thuận của Nhà nước thông qua việc cấp Giấy chứng nhận kết hôn. Đây là một sự kiện có tính chất bắt buộc. Bởi lẽ, không có sự thừa nhận của Nhà nước thì quan hệ hôn nhân không được thừa nhận trước pháp luật dù các bên đã trải qua các nghi thức cưới hỏi truyền thống hay nghi thức tôn giáo.

Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 và năm 1986 không đưa ra khái niệm về kết hôn, chỉ có phần giải thích từ ngữ có đề cập đến "Kết hôn là việc nam nữ lấy nhau thành vợ thành chồng theo quy định của pháp luật".

[171] Hoàng Phê (2019), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb Hồng Đức, tr.504.

Khái niệm kết hôn được Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 ghi nhận tại khoản 2, Điều 8 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 giữ nguyên khái niệm này. Đó là "Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn".

6.2.2. Điều kiện kết hôn

Điều kiện kết hôn là một trong những nội dung quan trọng thuộc phạm vi điều chỉnh của chế định kết hôn. Căn cứ vào tình hình kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia, Nhà nước sẽ ban hành các điều kiện cụ thể mà các bên tham gia cần đáp ứng để có thể xác lập quan hệ vợ chồng nhằm đảm bảo lợi ích cho chính mình, cho gia đình và xã hội.

Trong lịch sử pháp luật về hôn nhân và gia đình của Việt Nam có nhiều quy định khác nhau về điều kiện kết hôn gắn với những giai đoạn thời kỳ nhất định.

Hiện tại, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, điều kiện về độ tuổi kết hôn:

Quy định về độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn là nội dung vô cùng cần thiết. Bởi vì độ tuổi tối thiểu được phép kết hôn thể hiện rõ giới hạn cần thiết đảm bảo cho sự an toàn của mỗi cuộc hôn nhân xét từ phương diện sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của người kết hôn, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của mỗi nam, nữ.

Tại khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định độ tuổi kết hôn của nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ phải từ đủ 18 tuổi trở lên.

Trước đây Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 và Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đều quy định độ tuổi kết hôn là "Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên" nghĩa là nam bắt đầu bước sang tuổi 20, nữ bắt đầu bước sang tuổi 18 đã đủ điều kiện kết hôn. Với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bổ sung thêm từ "đủ" vào độ tuổi, có nghĩa nam phải tròn 20 tuổi không thiếu 01 ngày, nữ phải tròn 18 tuổi không thiếu 01 ngày mới đủ tuổi kết hôn.

Thứ hai, điều kiện về ý chí

Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép cản trở.

Tự nguyện là việc tự do thể hiện ý chí của mình không lệ thuộc vào ý chí người khác, tự nguyện trong kết hôn là việc tự do tìm hiểu, tự do lựa chọn và tự do quyết định về đối tác kết hôn của mình. Sự tự nguyện phải thể hiện bằng ý chí và hành động, việc người kết hôn tự mình ký vào đơn đăng ký kết hôn nhưng không xuất phát từ ý chí chủ quan, không xuất phát từ mong muốn, tình cảm của mình mà do người khác đe dọa hoặc ép buộc, lừa dối thì không phải là tự nguyện.

Để đảm bảo về sự tự nguyện của các bên, Luật yêu cầu các bên trong hôn nhân không được ép buộc hay lừa dối nhau. Ép buộc là việc bắt người khác thực hiện theo ý chí của mình có thể là đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần, vật chất để buộc bên kia kết hôn còn lừa dối là việc đưa ra thông tin không trung thực làm cho người kia lầm tưởng mà kết hôn chẳng hạn như một người bị nhiễm HIV hoặc không có khả năng sinh con nhưng lại cố tình che dấu sự thật với bên kia hoặc một người đang có vợ, có chồng nhưng lại nói với bên kia mình là người chưa có vợ hoặc có chồng.

Ngoài ra, bất kỳ ai cũng không được cưỡng ép hay cản trở kết hôn. Cho dù người đó là cha mẹ, ông bà hay người có công ơn, có ảnh hưởng lớn đến người kết hôn thì dù bất cứ lý do gì cũng không được buộc bên kết hôn phải kết hôn với người họ không mong muốn hoặc cản trở họ kết hôn với người họ có nguyện vọng.

Thứ ba, điều kiện về khả năng nhận thức

Người kết hôn không bị mất năng lực hành vi dân sự. Người bị mất năng lực hành vi dân sự là người bị mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác không làm chủ được hành vi của mình.

Việc yêu cầu người kết hôn phải có năng lực hành vi dân sự xuất phát từ việc đảm bảo quyền tự do kết hôn của mỗi cá nhân, người kết hôn phải được tự mình lựa chọn và quyết định. Người mất năng lực hành vi dân sự sẽ không thể bày tỏ ý được ý chí của mình nên không có sự tự nguyện trong hôn nhân. Mặt khác, nếu người mất năng lực hành vi dân sự được kết hôn sẽ không đảm bảo chất lượng cuộc sống, khó thực hiện chức năng của một gia đình, có thể là gánh nặng đối với người bạn đời, ảnh hưởng lớn đến con cái.

Thứ tư, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm sau:

- Cấm kết hôn giả tạo

Kết hôn giả tạo là việc các bên thỏa thuận việc xác lập quan hệ hôn nhân nhưng không hướng đến việc xây dựng gia đình mà có thể lợi dụng

kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác. Bản chất và mục đích của việc kết hôn phải nhằm xác lập quan hệ vợ chồng, xác lập một gia đình tạo nền tảng cho sự phát triển của chính bản thân và xã hội. Nếu vì những mục đích khác thì việc kết hôn này mang tính chất ngụy tạo, lừa dối người khác, lừa dối xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến các quan hệ xã hội, phá vỡ trật tự, bản chất của hôn nhân.

- Cấm tảo hôn

Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định Luật.

Với cách quy định của Luật về việc tạo hôn có thể hiểu tảo hôn không chỉ là việc nam, nữ kết hôn trước tuổi luật định mà còn bao gồm cả trường hợp nam, nữ chung sống như vợ chồng trước tuổi luật định. Việc lấy vợ lấy chồng khi chưa đủ tuổi để lại nhiều hệ lụy cho chính người kết hôn và toàn xã hội. Người chưa đủ tuổi kết hôn mà lấy vợ, lấy sớm sẽ ảnh hưởng đến thể chất, tâm sinh lý, sức khỏe; con cái không được chăm sóc nuôi dạy đầy đủ để phát triển một cách toàn diện về thể chất và trí lực. Đồng thời, việc kết hôn sớm sẽ làm tăng nhanh dân số, giảm chất lượng cuộc sống, gây nguy cơ đói nghèo, lạc hậu trở thành gánh nặng của xã hội.

- Cấm cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn

Cưỡng ép kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.

Cản trở kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này.

- Cấm yêu sách của cải trong kết hôn

Yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ.

Tại nhiều vùng miền của Việt Nam vẫn còn tồn tại phong tục "thách cưới" như đòi bạc trắng, tiền mặt, của hồi môn, trâu, bò, chiêng ché,... để dẫn cưới. Đây là những phong tục hôn nhân lạc hậu đã làm cản trở đến ý chí tự nguyện của các bên, ảnh hưởng đến nguyên tắc tiến bộ của hôn nhân gia đình.

- Cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

Theo thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP có giải thích người đang có vợ có chồng là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: (i) Người đã kết hôn với người khác theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nhưng chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết; (ii) Người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 03-01-1987 mà chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết; (iii) Người đã kết hôn với người khác vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình nhưng đã được Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân bằng bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và chưa ly hôn hoặc không có sự kiện vợ (chồng) của họ chết hoặc vợ (chồng) của họ không bị tuyên bố là đã chết.

- Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

+ Những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha, mẹ với con; giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là giữa những người cùng một gốc sinh ra: Cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Việc cấm kết hôn các đối tượng này dựa trên cơ sở y học và đạo đức xã hội. Dưới góc độ y học, việc xác lập quan hệ hôn nhân giữa những người có quan hệ huyết thống gần gũi có nguy cơ đột biến gen, gây các bệnh về máu cho thế hệ đời sau. Mặt khác, dưới góc độ xã hội, quan hệ giữa tình cảm của các đối tượng trên thuộc quan hệ huyết thống gia đình là những mối quan hệ thiêng liêng không thể chuyển hóa thành quan hệ vợ chồng được.

+ Cấm kết hôn giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng

Đây là trường hợp cấm kết hôn xuất phát từ truyền thống văn hóa, tập quán của người Việt Nam. Các đối tượng trên không có mối liên hệ huyết thống với nhau sẽ không gây ra những hậu quả tiêu cực về sức khỏe cho các thế hệ sau nhưng ảnh hưởng lớn đến những giá trị văn hóa, đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trong văn hóa của người Việt Nam, giữa các thành viên trong gia đình luôn có thứ bậc, trật tự trên dưới, mỗi mối quan hệ sẽ mang những đặc điểm tính chất khác nhau. Việc thừa nhận hôn nhân của những đối tượng trên sẽ bị xem là "loạn luân" trái với luân thường đạo lý, trái với những giá trị nhân văn của hôn nhân và gia đình.

Ngoài các trường hợp cấm trên thì Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về việc không thừa nhận hôn nhân của những người cùng giới tính. Đây là bước tiến mới về thái độ của nhà làm luật đối với những người thuộc giới tính thứ ba. Nếu như Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính nghĩa là việc họ chung sống với nhau bị xem là vi phạm pháp luật thì với quy định của Luật Hôn và nhân gia đình 2014 đã cho phép các cặp đồng tính có thể chung sống với nhau có thể tổ chức đám cưới trên thực tế nhưng họ không được làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không được công nhận là vợ chồng.

6.2.3. Đăng ký kết hôn

Theo quy định của Luật thì việc xác lập quan hệ vợ chồng phải được đăng ký tại cơ nhà nước có thẩm quyền. Đây là thủ tục bắt buộc để công nhận cuộc hôn nhân của các bên là hợp pháp.

Dưới góc độ quản lý Nhà nước thì thông qua thủ tục này Nhà nước sẽ kiểm soát được việc tuân thủ các điều kiện kết hôn và xác nhận tình trạng pháp lý về hôn nhân của các bên nhằm xác lập những cuộc hôn nhân lành mạnh, tiến bộ, hạnh phúc.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam với công dân Việt Nam; giữa công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam

với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài và trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc đăng ký kết hôn cho các đối tượng công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài.

6.2.4. Kết hôn trái pháp luật

6.2.4.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật

Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định (khoản 3 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014)

Như vậy, kết hôn trái pháp luật là việc kết hôn tuy đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng sau đó mới phát hiện một hoặc cả hai bên kết hôn vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định.

6.2.4.2. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

- Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn;
- Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;
- Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
- Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
- Hội Liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

6.2.4.3. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

Việc xử lý kết hôn trái pháp luật do Tòa án nhân dân thực hiện. Theo Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP thì khi xem xét, giải quyết yêu cầu có liên quan đến việc hủy kết hôn trái pháp luật, Tòa án có thể đưa ra các hướng xử lý sau:

- Trường hợp nam, nữ có đăng ký kết hôn nhưng việc kết hôn đăng ký tại không đúng cơ quan có thẩm quyền (không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) mà có yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì Tòa án áp dụng Điều 9 của Luật Hôn nhân và gia đình tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ đồng thời hủy Giấy chứng nhận kết hôn và thông báo cho cơ quan hộ tịch đã đăng ký kết hôn để xử lý.

- Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn (không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) và có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý, giải quyết và tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ.

- Trường hợp tại thời điểm kết hôn, hai bên kết hôn không có đủ điều kiện kết hôn nhưng sau đó có đủ điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình thì Tòa án xử lý một trong các cách là: (i) Nếu hai bên kết hôn cùng yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án quyết định công nhận quan hệ hôn nhân đó kể từ thời điểm các bên kết hôn có đủ điều kiện kết hôn. (ii) Nếu một hoặc hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc có một bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia không có yêu cầu thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. (iii) Trường hợp hai bên cùng yêu cầu Tòa án cho ly hôn hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

- Trường hợp hai bên đã đăng ký kết hôn nhưng tại thời điểm Tòa án giải quyết hai bên kết hôn vẫn không có đủ các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình thì thực hiện theo hai hướng: Nếu có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thì Tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật; Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Một lưu ý là khi xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, Tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực tại thời điểm xác lập quan hệ hôn nhân để xác định việc kết hôn có trái pháp luật hay không. Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu xử lý việc kết hôn trái pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật tố tụng dân sự có hiệu lực tại thời điểm giải quyết. Đối với yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật thuộc trường hợp cán bộ và bộ

đội miền Nam tập kết ra miền Bắc từ năm 1954, đã có vợ, có chồng ở miền Nam mà lấy vợ, lấy chồng ở miền Bắc thì vẫn xử lý theo Thông tư số 60/TATC ngày 22-02-1978 của Tòa án nhân dân tối cao "Hướng dẫn giải quyết các trường hợp cán bộ, bộ đội trong Nam tập kết ra Bắc mà lấy vợ, lấy chồng khác" cụ thể là không xử huỷ việc kết hôn trái pháp luật mà vẫn công nhận họ là vợ chồng hợp pháp.

6.2.4.4. Hậu quả của việc hủy kết hôn trái pháp luật

Điều 12 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật theo đó khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.

Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết như quy định đối với trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn theo đó quan hệ tài sản nghĩa vụ và Hợp đồng được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.3. Quan hệ giữa vợ chồng theo luật hôn nhân và gia đình

6.3.1. Quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng

Việc xác lập quan hệ vợ chồng trên cơ sở đăng ký kết hôn không chỉ tạo ra sự gắn kết tình cảm giữa các bên mà còn thiết lập các quyền và nghĩa vụ do Luật quy định.

Liên quan đến quyền và nghĩa vụ về nhân thân của vợ chồng, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã dành các Điều 17, 18,19, 20, 21, 22, 23 để điều chỉnh cụ thể như sau:

- Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, pháp luật.
- Quyền và nghĩa vụ về nhân thân của vợ và chồng được tôn trọng và bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

- Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.

- Vợ chồng có quyền lựa chọn nơi cư trú không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

- Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau.

- Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

- Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

6.3.2. Đại diện giữa vợ và chồng

Đại diện giữa vợ và chồng là việc một bên vợ hoặc chồng nhân danh cả hai người để tham gia các quan hệ theo quy định của pháp luật hoặc pháp luật quy định cần phải có sự thỏa thuận của vợ chồng nhưng người còn lại không trực tiếp tham gia các giao dịch đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng và bên thứ ba liên quan. Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có các trường hợp đại diện sau:

- Đại diện theo ủy quyền: Việc đại diện cho nhau giữa hai vợ chồng thực hiện bằng hình thức đại diện theo ủy quyền, được xác lập trên cơ sở sự ủy quyền giữa người đại diện là vợ (chồng) và người được đại diện là chồng (vợ). Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản, trong đó, nêu rõ phạm vi đại diện, những giao dịch được xác lập, thực hiện. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện ghi trong văn bản.

- Đại diện theo pháp luật: Vợ chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định người đại diện theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về

giám hộ trong Bộ luật Dân sự, Tòa án chỉ định người khác đại diện cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Trong trường hợp vợ, chồng kinh doanh chung thì vợ, chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó, trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tài sản chung nhưng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì việc vợ hoặc chồng tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

6.3.3. Quan hệ tài sản của vợ và chồng

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Điều 28) quy định có hai cách thức xác lập chế độ tài sản vợ chồng: chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Theo đó, pháp luật cho phép các bên thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng trường hợp vợ chồng không có thỏa thuận thì chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định. Vợ chồng có thể thỏa thuận trên cơ sở lựa chọn theo một chế độ tài sản riêng biệt, hoàn toàn độc lập với chế độ tài sản theo quy định của pháp luật.

6.3.3.1. Chế độ tài sản theo thỏa thuận

- Thời điểm xác lập: Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng phải được lập trước khi kết hôn. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

- Về hình thức: Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực.

- Nội dung: Văn bản thỏa thuận gồm có các nội dung sau

+ Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;

+ Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;

+ Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung toàn bộ hoặc một phần nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản. Việc sửa đổi, bổ sung này phải lập thành văn bản và phải có công chứng, chứng thực.

- Khi lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì vợ chồng phải cung cấp thông tin về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong giao dịch với người thứ ba biết về những thông tin liên quan; nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật

- Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong các trường hợp sau:

+ Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan;

+ Vi phạm nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng được quy định tại (Điều 29); Vi phạm nguyên tắc quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình (Điều 30); vi phạm quy định về giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng (Điều 31) và vi phạm về quy định về Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Điều 32).

+ Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

6.3.3.2. Chế độ tài sản theo luật định

Tài sản được xác định theo chế độ tài sản theo luật định gồm tài sản chung và tài sản riêng.

- **Căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng**

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tài sản chung bao gồm:

+ Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân như: khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp (trừ khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng), tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối

với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước

+ Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

- Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

+ Ngoài các căn cứ trên để xác định tài sản chung thì Luật còn đưa ra nguyên tắc mang tính suy đoán là trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Điều này có nghĩa khi một trong hai bên vợ, chồng khẳng định tài sản tranh chấp là tài sản riêng thì phải có nghĩa vụ chứng minh nếu không chứng minh được thì tài sản được xem là tài sản chung của vợ chồng.

- **Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung**

+ Quyền đăng ký tài sản chung của vợ và chồng:

Đối với tài sản chung là quyền sử dụng đất và các tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký mà đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu để ghi tên của cả vợ và chồng. Trong trường hợp tài sản chung được chia trong thời kỳ hôn nhân mà trong giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên cả vợ và chồng thì bên được chia phần tài sản bằng hiện vật có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký tài sản cấp lại giấy chứng nhận trên cơ sở văn bản thỏa thuận của vợ chồng hoặc quyết định của Tòa án.

+ Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ, chồng:

Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất có nghĩa là quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung là như nhau không phân biệt mức đóng góp vào tài sản chung, không xác định phần quyền và nghĩa vụ riêng biệt đối với tài sản chung. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ, chồng thỏa thuận quyết định. Cụ thể, khi vợ chồng muốn quyết định về việc quản lý, khai thác công dụng của tài sản hoặc bán, tặng cho, chuyển nhượng đối tài sản chung nào thì phải có sự bàn bạc thống nhất với nhau về việc định đoạt tài sản đó. Đối với các tài sản là bất động sản, động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu (ví dụ: ô tô, xe máy,…) hoặc tài sản đang là nguồn tạo ra thu

nhập chủ yếu của gia đình thì việc thỏa thuận phải thực hiện bằng văn bản. Trong trường hợp vợ hoặc chồng tự ý định đoạt các tài sản chung thuộc các trường hợp trên mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản với người còn lại thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu.

+ Các nghĩa vụ chung của vợ chồng đối với tài sản:

Vợ và chồng phải có nghĩa vụ chung đối với các giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; các giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.

- **Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân**

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân quyết định chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung. Các bên không được thỏa thuận chia tài sản trong các trường hợp: (i) Việc chia tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; (ii) Việc chia tài sản nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; bồi thường thiệt hại; Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức hoặc Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

Về hình thức thì thỏa thuận về việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản.

Về hậu quả pháp lý của việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Đối với các quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập giữa

vợ, chồng với người thứ ba xảy ra trước thời điểm lập văn bản thỏa thuận chia tài sản chung thì không bị ảnh hưởng hoặc thay đổi gì.

- **Căn cứ xác lập tài sản riêng**

Theo Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: "Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng". Cụ thể, tài sản riêng của vợ, chồng gồm:

+ Tài sản có trước thời kỳ hôn nhân: Đây là khối tài sản mà vợ, chồng tự tạo lập hoặc được cho tặng, thừa kế trước khi kết hôn. Những tài sản này là tài sản riêng của vợ chồng và sau khi kết hôn vợ chồng có quyền sáp nhập hoặc không sáp nhập khối tài sản này và khối tài sản chung của vợ chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ khối tài sản này là tài sản chung của vợ chồng.

+ Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân: Đây là khối tài sản mà vợ, chồng nhận được trong thời kỳ hôn nhân mà người tặng cho, người để lại thừa kế chỉ định rõ ràng khối tài sản tặng cho, thừa kế chỉ dành cho vợ hoặc chồng.

+ Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng: Đây là tài sản của vợ, chồng được chia ra từ một phần hoặc toàn bộ khối tài sản chung mà vợ chồng thỏa thuận chia trong thời kỳ hôn nhân. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ khối tài sản riêng này là tài sản riêng của vợ, chồng.

+ Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng: Đây là tài sản nhằm phục vụ những nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

+ Tài sản khác: Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Khi xác lập tài sản riêng thì một bên vợ, chồng có tài sản riêng có quyền sở hữu độc lập và toàn quyền trong chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

tài sản đó mà không phụ thuộc vào ý chí của bên kia. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó. Riêng trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

6.4. Quan hệ giữa cha mẹ và con

6.4.1. Căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa cha mẹ đẻ và con đẻ

Việc xác định quan hệ giữa cha mẹ và con cái là nội dung rất quan trọng. Việc xác định mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa các thành viên nói trên. Luật Hôn nhân và gia đình quy định các trường hợp sau:

- Xác định cha mẹ con khi cha mẹ có hôn nhân hợp pháp

Một là, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Quy định này đưa ra nguyên tắc suy đoán trong việc xác lập tình trạng pháp lý giữa cha mẹ và con dựa vào sự kiện sinh đẻ trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt. Trong khoảng thời gian này nếu người vợ có thai kỳ và sinh con thì người con sinh ra được xem là con chung của hai người.

Hai là, con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Thời điểm chấm dứt hôn nhân là thời điểm do vợ hoặc chồng chết hoặc khi có quyết định của tòa án tuyên bố vợ chồng chết hoặc thời điểm có hiệu lực của quyết định hoặc bản án ly hôn. Luật đưa ra thời hạn 300 ngày sau thời điểm chấm dứt hôn nhân bởi khoảng thời gian này được xác định là khoảng thời gian người vợ mang thai kể từ thời điểm thụ thai vẫn đang trong quá trình tồn tại quan hệ hôn nhân. Chính vì vậy con sinh ra trong khoảng thời gian này vẫn là con chung của hai người.

Ba là, con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Trong trường hợp này việc xác định con chung không phụ thuộc vào thời kỳ hôn nhân vì người mẹ đã sinh ra con trước đó mà căn cứ để xác định là sự thừa nhận của cả cha mẹ. Tuy hôn nhân của hai bên nam nữ

được xác lập sau ngày con sinh ra; nhưng được vợ chồng thừa nhận thì đứa trẻ đương nhiên là con chung của vợ chồng.

Như vậy mối quan hệ giữa cha mẹ - con đương nhiên được thiết lập nếu rơi vào một trong ba trường hợp trên. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

- *Xác định cha mẹ con khi cha mẹ không có đăng ký kết hôn*

Việc nhận cha mẹ của con hay nhận con của cha mẹ là quyền con người được Luật Hôn nhân và gia đình ghi nhận tại Điều 90, 91 của Luật hôn nhân và gia đình. Trong trường hợp cha mẹ không có đăng ký kết hôn thì cũng không làm thay đổi mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Luật Hôn nhân và gia đình đã quy định về cách thức và thẩm quyền xác nhận cha mẹ con như sau:

+ Trường hợp nếu không có tranh chấp gì thì cha, mẹ, con đã thành niên không bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch xác định con, cha, mẹ cho mình.

+ Trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha mẹ, con đã chết thì khi có yêu cầu, Tòa án có thẩm quyền sẽ giải quyết việc xác định cha mẹ con.

- *Xác định cha mẹ con khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản*

Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được áp dụng đối với cặp vợ chồng vô sinh và phụ nữ độc thân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Trong trường hợp vợ chồng vô sinh mà người vợ sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì việc xác định cha mẹ trong trường hợp này căn cứ vào thời kỳ hôn nhân của cặp vợ chồng. Người vợ trong cặp vợ chồng vô sinh được xác là mẹ đứa trẻ trong mọi trường hợp kể cả người mẹ là người nhận tinh trùng, nhận noãn hay nhận phôi của người khác và người chồng hợp pháp của người mẹ đó cũng chính là cha đứa trẻ, ngay cả trường hợp người chồng không phải là người cho tinh trùng.

Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, hoặc cho phôi với đứa con được sinh ra.

Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra.

Trong trường hợp sinh con nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì con sinh ra là con chung của vợ chồng nhờ mang thai hộ kể từ thời điểm con được sinh ra.

6.4.2. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi

Ngoài việc xác định cha mẹ con bằng sự kiện sinh đẻ thì quan hệ giữa cha mẹ con còn được xác lập bằng sự kiện nhận nuôi con nuôi.

Nuôi con nuôi là việc một người đã trưởng thành (hoặc một cặp vợ chồng có quan hệ hôn nhân hợp pháp) nhận một hay nhiều trẻ em không do mình trực tiếp sinh ra làm con. Việc nhận nuôi con nuôi làm phát sinh quan hệ cha, mẹ - con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi, tức là kể từ thời điểm nhận con nuôi, người nhận con nuôi có tư cách là cha, mẹ của trẻ em được nhận làm con nuôi.

Cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi có quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ, con được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình kể từ thời điểm quan hệ nuôi con nuôi được xác lập theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án thì quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

6.4.3. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, con

6.4.3.1. Quan hệ nhân thân

- Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ

Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội; Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật.

- Nghĩa vụ và quyền của con

Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và

giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức; Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình; Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc; Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

6.4.3.2. Quan hệ tài sản

Giữa cha mẹ và con cái có sự độc lập về tài sản cho dù con đang ở chung với bố mẹ.

- Con có quyền có tài sản riêng; Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác; Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

- Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

- Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình.

- Đối với con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý; Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

- Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự; người

tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Về việc định đoạt tài sản riêng của con thì cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con; nếu con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

6.5. Ly hôn

6.5.1. Khái niệm

Nếu như kết hôn là sự kiện xác lập quan hệ vợ chồng thì ly hôn là sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ vợ chồng. Ly hôn là mặt trái của hôn nhân nhưng lại là điều cần thiết và có ý nghĩa khi cuộc hôn nhân đã không đạt được mục đích. Pháp luật bảo vệ quyền tự do ly hôn của mỗi cá nhân nghĩa là việc ly hôn phải xuất phát từ ý chí tự nguyện của các bên trong quan hệ hôn nhân không ai kể cả Nhà nước có quyền ép buộc hoặc cản trở ly hôn. Tuy nhiên quan hệ hôn nhân không chỉ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của hai bên mà còn liên quan đến quyền và nghĩa vụ của con cái, của các thành viên khác trong gia đình; liên quan đến các quan hệ xã hội khác mà Nhà nước bảo vệ. Vì vậy, bằng pháp luật Nhà nước đặt ra các căn cứ nhất định để đánh giá, xem xét cuộc hôn nhân đó có thể duy trì được nữa không và cơ quan có thẩm quyền xem xét là Tòa án.

Theo khoản 3, Điều 14, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định "Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án".

Như vậy, Tòa án là cơ quan duy nhất có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc ly hôn của các bên. Kết luận của Tòa án thể hiện dưới hình thức: bản án, quyết định. Nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn, giải quyết với nhau được tất cả các nội dung sau khi ly hôn thì Tòa án công nhận ly hôn và ra quyết định dưới hình thức quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Nếu vợ chồng mâu thuẫn, tranh chấp thì Tòa án xét xử và ra phán quyết ly hôn dưới dạng bản án.

6.5.2. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn

Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình có quy định vợ hoặc chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn;

Yêu cầu giải quyết ly hôn là quyền của các bên trong quan hệ hôn nhân, quyền này gắn liền với nhân thân của mỗi người không thể chuyển giao cho người khác. Quyền yêu cầu này có thể xuất phát từ chính thỏa thuận của cả hai người cùng nhau yêu cầu hoặc một trong hai bên đều có quyền bình đẳng và tự do thể hiện ý chí của mình trong việc yêu cầu ly hôn. Điểm mới trong quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 là đã bổ sung trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. Quy định này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của một bên trong quan hệ hôn nhân khi sức khỏe, tính mạng và tinh thần của vợ hoặc chồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình mà bản thân họ không nhận thức, không làm chủ hành vi nên không thể tự mình thực hiện quyền yêu cầu giải quyết ly hôn được.

Để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định về trường hợp hạn chế ly hôn cụ thể là "Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi". Mang thai và nuôi con nhỏ thường gắn với đặc điểm sinh lý của người phụ nữ nhưng trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng thai nhi và con cái là trách nhiệm chung của cả vợ và chồng. Đây là giai đoạn đặc biệt ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, tinh thần, sức khỏe của bà mẹ và trẻ nhỏ vì thế cần có sự hạn chế việc yêu cầu đơn phương từ người chồng. Trong trường hợp người vợ có yêu cầu ly hôn hoặc hai bên thỏa thuận ly hôn thì Tòa án sẽ giải quyết theo thủ tục chung.

6.5.3. Các trường hợp ly hôn

6.5.3.1. Thuận tình ly hôn

Thuận tình ly hôn là trường hợp cả vợ hoặc chồng cùng yêu cầu chấm dứt hôn nhân được thể hiện bằng đơn thuận tình ly hôn của vợ chồng.

Theo Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự

nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn".

Như vậy điều kiện để Tòa án công nhận thuận tình ly hôn là:

Thứ nhất, hai bên thật sự tự nguyện ly hôn là cả hai vợ chồng đều được tự do bày tỏ ý chí của mình, không bị tác động bởi bởi kia hoặc bởi bất kỳ bên nào khác khiến họ phải ly hôn trái với ý chí nguyện vọng của mình. Việc ly hôn không bị cưỡng ép (không bị đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải), không bị lừa dối trong việc thuận tình ly hôn.

Thứ hai, hai vợ chồng còn phải có sự thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con.

Đối với trường hợp cả hai bên thỏa thuận được việc ly hôn nhưng không thỏa thuận được việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con hoặc có thỏa thuận nhưng việc thỏa thuận không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự.

6.5.3.2. Ly hôn theo yêu cầu của một bên

Ly hôn theo yêu cầu của một bên là trường hợp chỉ có một trong hai vợ chồng, hoặc cha, mẹ, người thân thích của một trong hai bên yêu cầu được chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Theo Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về ly hôn theo yêu cầu của một bên thì có 3 trường hợp mà Tòa án cần xem xét các căn cứ khác nhau để giải quyết ly hôn.

- Trường hợp thứ nhất, khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được". Cụ thể:

Khi có yêu cầu ly hôn và Tòa án đã thụ lý đơn ly hôn thì Tòa án sẽ tiến hành hòa giải. Thẩm phán giải quyết vụ án có thể điều tra về hoàn

cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn, nguyện vọng của vợ, chồng con có liên quan đến vụ án, phân tích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con cái để đưa ra hướng hòa giải phù hợp để vợ chồng đoàn tụ nhưng hai bên vẫn không đồng ý, khi đó thẩm phán sẽ lập biên bản ghi nhận hòa giải không thành và sẽ xem xét tiếp có các căn cứ về bạo lực gia đình hay có vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của vợ chồng không.

+ Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình172. Bạo lực gia đình có thể là bạo lực về thể chất như hành vi ngược đãi, đánh đập thành viên gia đình, làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của họ; bạo lực về tinh thần như sử dụng lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lý của thành viên gia đình; bạo lực về kinh tế như buộc thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ hoặc kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính; bạo lực về tình dục như cưỡng ép quan hệ tình dục kể cả cưỡng ép sinh con;…

+ Có căn cứ về hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ vợ chồng. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình và các luật khác thường gắn liền với quan hệ nhân thân và tài sản. Một số hành vi bị xem là vi phạm nghiêm trọng như vợ hoặc chồng ngoại tình không chung thủy, chung sống như vợ như chồng với người khác, bỏ mặc không quan tâm chăm sóc lẫn nhau; vợ chồng có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm; vợ hoặc chồng vi phạm quy định về bình đẳng quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung, phân biệt giữa lao động có thu nhập với lao động trong gia đình, không đóng góp tài sản, thu nhập để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình, không thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình…

Hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng như trên còn phải dẫn đến hậu quả là hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

---

[172] Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12

Xét về bản chất thì mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình bền vững hạnh phúc không xét đến các mục đích cá nhân của mỗi bên. Khi quan hệ hôn nhân của hai người đã dẫn đến tình trạng hai vợ chồng không còn tình nghĩa, không tôn trọng giúp đỡ nhau, có ý thức bỏ mặc nhau không thể tiếp tục cuộc sống chung cùng nhau thì lúc đó cuộc hôn nhân có thể bị xem là trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt được.

- Trường hợp thứ hai, khi vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Theo quy định tại Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015 thì Tòa án có thể tuyên bố một người mất tích khi "một người biệt tích 02 năm liền trở đi, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về người đó đã chết hay còn sống".

Trong quan hệ hôn nhân và gia đình, việc chồng hoặc vợ bị mất tích đã ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ vợ chồng và các thành viên trong gia đình. Cần phải giải phóng chồng thoát khỏi "hoàn cảnh đặc biệt" này, khi họ có yêu cầu được ly hôn với người chồng (vợ) đã bị tòa án tuyên bố mất tích.

- Trường hợp thứ ba, khi có yêu cầu ly hôn của cha, mẹ hoặc người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ), Tòa án giải quyết ly hôn trong trường hợp này khi có căn cứ:

+ Bên vợ, chồng bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ hành vi của mình.

+ Bên vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.

6.5.4. Hậu quả pháp lý của việc ly hôn

- *Quan hệ nhân thân*

Khi bản án hoặc quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực thì quan hệ giữa vợ và chồng chấm dứt. Các quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng sẽ chấm dứt hoàn toàn. Vợ và chồng đã ly hôn có quyền kết hôn với người khác. Nếu muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng phải đăng ký kết hôn lại.

- *Về việc nuôi con*

Việc nuôi con sau ly hôn trước hết sẽ dựa vào sự thỏa thuận của vợ chồng, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào các yếu tố sau:

Một là căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Tòa án sẽ xem xét các điều kiện về thu nhập, chỗ ở, thời gian, năng lực chăm sóc con của mỗi bên để đảm bảo đằng người đó sẽ mang đến cho con sự phát triển toàn diện cả thể chất, trí lực, tình cảm tốt hơn người kia.

Hai là nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Theo luật dân sự thì 7 tuổi trở lên là cá nhân đã có một phần năng lực hành vi dân sự có thể tự mình thực hiện một số giao dịch phù hợp với lứa tuổi, độ tuổi này đã phần nào nhận biết được thái độ, tình cảm, sự chăm sóc của người khác dành cho mình hay cho các thành viên khác trong gia đình, trẻ có thể bày tỏ được nguyện vọng mong muốn về người mà mình muốn chung sống trực tiếp sau khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên ý kiến này cũng chỉ mang tính tham khảo, là một trong các cơ sở để Tòa án ra quyết định cuối cùng.

Ba là, trường hợp con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đồng thời có quyền thăm nom con mà không ai được cản trở tuy nhiên không được lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con của người trực tiếp nuôi con.

- *Quan hệ tài sản*

Khi ly hôn việc chia tài sản của vợ và chồng (bao gồm cả chế độ tài sản theo thỏa thuận hay chế độ tài sản theo luật định) đều dựa trên cơ sở tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Nếu bên không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa án sẽ áp dụng các nguyên tắc được quy định tại Điều 59 sau đây:

Một là, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố:

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng là tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả năng lao động tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. Bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

+ Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập là việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo đảm cho vợ, chồng đang hoạt động nghề nghiệp được tiếp tục hành nghề; cho vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch. Việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

Ví dụ: Vợ chồng có tài sản chung là một chiếc ô tô mà người chồng đang chạy xe taxi trị giá 400 triệu đồng và một cửa hàng tạp hóa mà người vợ đang kinh doanh trị giá 200 triệu đồng. Khi giải quyết ly hôn và chia tài sản chung, Tòa án phải xem xét giao cửa hàng tạp hóa cho người vợ, giao xe ô tô cho người chồng để họ tiếp tục kinh doanh, tạo thu nhập. Người chồng nhận được phần giá trị tài sản lớn hơn phải thanh toán cho người vợ phần giá trị là 100 triệu đồng.

+ Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng là lỗi của vợ hoặc chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn đến ly hôn.

Ví dụ: Trường hợp người chồng có hành vi bạo lực gia đình, không chung thủy hoặc phá tán tài sản thì khi giải quyết ly hôn Tòa án phải xem xét yếu tố lỗi của người chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của vợ và con chưa thành niên.

Hai là, tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Ba là, tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Bốn là, Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Ví dụ: Khi chia nhà ở là tài sản chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định cho người vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con chưa thành niên, con bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự nhận hiện vật và thanh toán giá trị tương ứng với phần tài sản được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người vợ hoặc chồng có yêu cầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Hôn nhân và gia đình 1959.
2. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986.
3. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
4. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
5. Luật Hộ tịch năm 2014.
6. Luật Tố tụng dân sự năm 2015.
7. Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.
8. Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
9. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.
10. Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình.
11. Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình.
12. Thông tư số 60/TATC ngày 22-02-1978 của Tòa án nhân dân tối cao "Hướng dẫn giải quyết các trường hợp cán bộ, bộ đội trong Nam tập kết ra Bắc mà lấy vợ, lấy chồng khác".
13. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), *Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình*, Nxb Công an nhân dân.
14. Nguyễn Thị Chi (2018), *Bình luận khoa học Luật Hôn nhân và gia đình*, Nxb Lao động.
15. Bùi Thị Mừng, "Quyền kết hôn và ly hôn của phụ nữ Thái Lan và Việt Nam nhìn từ góc độ so sánh luật", *Tạp chí Luật học* số 2/2011.

CHƯƠNG 7
PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

7.1. KHÁI QUÁT VỀ THAM NHŨNG

7.1.1. Định nghĩa, đặc điểm của tham nhũng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội phức tạp với nhiều biểu hiện khác nhau. Do đó khi nghiên cứu về tham nhũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Dưới góc độ ngôn ngữ, thuật ngữ "tham nhũng" (corruption) có gốc là một động từ tiếng La-tinh "corruptus", nghĩa là lạm dụng, phá hoại hay vi phạm. Như vậy, từ gốc rễ của nó, "tham nhũng" hàm ý những hành vi trái phép hoặc bất hợp pháp.

Một trong những định nghĩa được nhiều học giả sử dụng rộng rãi nhất là định nghĩa của Ngân hàng thế giới (World Bank)[173] "*tham nhũng là* sự *lạm dụng quyền lực công cộng nhằm lợi ích cá nhân*". Định nghĩa này tập trung vào khu vực tham nhũng công và đã loại trừ tham nhũng trong khu vực tư nhân. Tổ chức minh bạch quốc tế đưa ra định nghĩa "tham nhũng là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân"[174]. Trong định nghĩa này đã đề cập đến chủ thể, cách thức và mục đích hành vi tham nhũng. Theo Vito Tanzi (1995) "Tham nhũng là cố tình không tuân theo nguyên tắc chính trực nhằm đưa đến những lợi ích cho chính mình hoặc có liên quan cá nhân từ hành vi này"[175].

Theo *Từ điển Tiếng Việt* "tham nhũng là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu dân lấy của"[176].

Rất khó để đưa ra một định nghĩa chính thức, đầy đủ và toàn diện về tham nhũng. Bussell (2015) cũng đã chỉ ra rằng có nhiều cách để định nghĩa tham nhũng một cách chi tiết. Nhưng không có định nghĩa nào có

---

[173] Liu, X. (2016), A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption. *Open Journal of Social Sciences*, 4, 171-177. doi: 10.4236/jss.2016.46019

[174] Tổ chức minh bạch quốc tế, định nghĩa về tham nhũng, tại: https://www.transparency.org/en/what-is-corruption truy cập lúc 20h ngày 10/12/2021

[175] Tanzi, V. (1995), *Corruption, Arm's Length Relationships and Market, The Economic Organized Crime*, Cambridge: Cambridge University Press.

[176] Hoàng Phê (2019), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb Hồng Đức, tr.910.

thể áp dụng cho tất cả các mục đích nghiên cứu. Do đó, trước hết cần nhận ra sự đa dạng về nội dung của tham nhũng. Tùy mục đích nghiên cứu mà khái niệm tham nhũng và phương pháp đo lường phù hợp được lựa chọn[177].

Dưới góc độ pháp lý Việt Nam, định nghĩa tham nhũng được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật và cũng có sự khác biệt nhất định theo thời gian. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, tham nhũng được định nghĩa là "*là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi*".

Từ định nghĩa trên có thể thấy tham nhũng có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.

Chủ thể của hành vi tham nhũng phải là người có chức vụ, quyền hạn. Người có chức vụ quyền hạn là người đang nắm giữ một vị trí công việc và có quyền hạn nhất định khi thực hiện công việc đó. Vị trí này có thể có được do được bầu cử, do được bổ nhiệm, do hợp đồng,… Tại khoản 2, Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng đã giải thích rõ người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Thứ hai, chủ thể tham nhũng đã lợi dụng chức vụ được giao. Trong hành vi tham nhũng thì chủ thể phải sử dụng chức vụ, quyền hạn là một phương tiện, công cụ để thực hiện hành vi. Nếu không có chức vụ, quyền hạn đó họ sẽ không thể thực hiện được hoặc khó có thể đạt được kết quả. Ví dụ: Ông A là người được giao nhiệm vụ đi mua tài sản cho đơn vị sau đó ông đã kê khống giá trị tài sản để hưởng chênh lệch. Trong tình huống này, nếu ông A không được giao nhiệm vụ thì ông khó thực hiện hành vi tham ô. Như vậy, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật cũng là dấu hiệu đặc trưng của hành vi tham nhũng. Một người có chức vụ, quyền hạn có thực hiện hành vi trái pháp luật lại không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình thì hành vi vi phạm đó không phải là tham nhũng. Ví

[177] Bussell, J. (2015), *Greed, Corruption, and the Modern State Essays in Political Economy*. Edward Elgar, London, 22-32.

dụ ông X là chủ tịch UBND xã T đã bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản tại nơi cư trú. Hành vi này được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn nhưng không phải là hành vi tham nhũng bởi lẽ chủ thể không sử dụng chức vụ, quyền hạn là công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi.

Thứ ba, động cơ của người có hành vi tham nhũng là *vì vụ lợi*.

Vụ lợi là những lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà chủ thể có thể có được do sử dụng không đúng hoặc vượt quá phạm vi, thẩm quyền chức trách, công việc được giao. Những lợi ích vật chất hoặc tinh thần này là yếu tố thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi chứ không phải do nhu cầu công việc hay trách nhiệm được giao. Nếu một hành vi có lợi dụng chức vụ quyền hạn nhưng không có yếu tố vụ lợi thì cũng không bị coi là tham nhũng.

7.1.2. Phân loại hành vi tham nhũng

Có nhiều cách phân loại hành vi tham nhũng dựa vào những tiêu chí khác nhau.

Căn cứ vào mức độ, hậu quả của hành vi tham nhũng, Công ước phòng chống tham nhũng của Liên hợp quốc đã chia tham nhũng thành hai loại là tham nhũng lớn (Grand corruption) và tham nhũng nhỏ (petty corruption). Tham nhũng lớn là loại tham nhũng xâm nhập đến tận những cấp bậc cao nhất của Chính phủ quốc gia, làm xói mòn lòng tin vào sự quản lý đúng đắn, nguyên tắc nhà nước pháp quyền và sự ổn định của nền kinh tế. Tham nhũng nhỏ là tham nhũng liên quan đến việc đổi chác một số tiền nhỏ, việc làm ơn không đáng kể bởi những người tìm kiếm sự ưu đãi, hoặc việc sử dụng bạn bè hay họ hàng nắm giữ chức vụ nhỏ[178].

Căn cứ vào lĩnh vực, tham nhũng được phân loại thành tham nhũng chính trị, tham nhũng hành chính và tham nhũng kinh tế:

- *Tham nhũng chính trị*: là dạng tham nhũng được hình thành do sự câu kết giữa những người có ảnh hưởng trong hệ thống chính trị, chủ yếu là những quan chức cấp cao trong bộ máy cầm quyền, nhằm tạo ra những quyết định, hay tìm cách tác động thiên lệch vào những quyết sách của Nhà nước có lợi cho một cá nhân, doanh nghiệp hoặc những nhóm lợi ích nào đó. Như vậy, có thể hiểu tham nhũng chính trị là sự lạm dụng quyền lực chính trị được giao để thu lợi riêng, với mục đích tăng quyền hoặc tăng

[178] UN, *UN guild for anti – Corruption Policy*, truy cập tại https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf lúc 5h00 ngày 12/1/2021

tài sản. Biểu hiện của dạng tham nhũng này là: dùng vị trí chính trị, ảnh hưởng chính trị của mình để can thiệp vào việc có hoặc không đưa ra một quyết định mang tính chính trị (chính sách, đạo luật, thỏa thuận,…) một cách thiên vị nhằm mục đích vụ lợi; mua bán, trao đổi các chức vụ chính trị, vị trí có quyền lực, chạy chức, chạy quyền, sau đó dùng vị trí của mình để trục lợi cá nhân…

- *Tham nhũng hành chính*: là dạng tham nhũng xảy ra phổ biến trong các hoạt động quản lý hành chính của đội ngũ công chức hành chính. Ở đó những người được giao quyền đã sử dụng quyền lực hành chính, trình tự thủ tục hành chính để gây khó khăn cho công dân hoặc tổ chức nhằm trục lợi cho bản thân. Biểu hiện của tham nhũng hành chính là: hạch sách, nhũng nhiễu trong việc thực hiện một thủ tục, một quyết định cụ thể nào đó mà công dân, tổ chức có quyền được hưởng từ cơ quan hành chính nhà nước; thiên vị trong thực hiện pháp luật;…

Tham nhũng kinh tế: là dạng tham nhũng xảy ra trong hoạt động quản lý kinh tế như, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, mua sắm tài sản công, quản lý tài sản,… được thực hiện bởi những người có thẩm quyền trong quản lý nhà nước về kinh tế, những người có thẩm quyền trong doanh nghiệp nhà nước. Biểu hiện của tham nhũng kinh tế là: chiếm đoạt trái phép các tài sản của Nhà nước, công dân nhằm trục lợi cá nhân; ra các quyết định kinh tế trái pháp luật hoặc thiên vị nhằm trục lợi cá nhân; lợi dụng sơ hở của pháp luật hoặc vi phạm pháp luật để tiến hành sản xuất, kinh doanh, trục lợi, gây thiệt hại cho xã hội,…

7.1.3. Các hành vi tham nhũng và tội phạm tham nhũng

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có sự phân biệt về chủ thể tham nhũng gồm nhóm chủ thể trong khu vực nhà nước và nhóm chủ thể thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Một là, những hành vi do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện, bao gồm 12 hành vi sau đây:

- Tham ô tài sản: là lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

- Nhận hối lộ: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người hối lộ

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của người có chức vụ; quyền hạn đã vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn của mình chiếm đoạt tài sản của người khác.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi: là việc cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi: là việc cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào, gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.

- Giả mạo trong công tác: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi như sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả; Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; biểu hiện của hành vi này thường là các cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương đã tìm cách hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn phụ trách việc phê duyệt chương trình, dự án, cấp kinh phí, ngân sách để được lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình và thông qua đó để đạt được các lợi ích cá nhân.

- Những nhiễu vì vụ lợi là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn gây khó khăn, yêu sách, đòi hỏi về tiền bạc, của cải đối với người khác trong quan hệ công tác của mình nhằm hưởng lợi bất chính.

- Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành

vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi mà không thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao, biểu hiện thực tế của hành vi này như một số viên chức Nhà nước có thẩm quyền cố ý không cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hồ sơ đã đủ điều kiện.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội vì vụ lợi đã che giấu, bỏ qua hành vi vi phạm pháp luật của người khác ví dụ như cán bộ, viên chức có thẩm quyền xử phạt hành chính đã bao che không ra quyết định xử phạt đối với người thực hiện hành vi xây nhà trái phép hay lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán…

- Cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi; là hành vi của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội vì vụ lợi mà ngăn cản, gây khó khăn, làm trì hoãn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp.

Hai là, những hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện, bao gồm 03 hành vi sau: tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định 7 tội phạm tham nhũng gồm:

- Tội tham ô tài sản (Điều 253);

"Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

(i) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

(ii) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm".

Dấu hiệu pháp lý: Chủ thể phạm tội tham ô tài sản là phải là người có chức vụ quyền hạn và là người có trách nhiệm quản lý tài sản. Người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tức là người phạm tội sử dụng quyền hạn được giao để thực hiện không đúng trách nhiệm của mình hoặc làm

trái các quy định về chế độ quản lý tài sản mà mình phụ trách hoặc sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn cho phép nhưng có liên quan đến cương vị công tác để chiếm đoạt tài sản như: Kế toán tự lập chứng từ thanh toán khống không thông qua chủ tài khoản để chiếm đoạt…

Giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên. Nếu tài sản bị chiếm đoạt dưới 2.000.000 đồng thì người phạm tội là chủ thể đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm tham nhũng chưa xóa án tích mà còn vi phạm.

- Tội nhận hối lộ (Điều 354);

"Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

(i) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

(ii) Lợi ích phi vật chất".

Dấu hiệu pháp lý của tội này là chủ thể là người có chức vụ quyền hạn, giữa người phạm tội và bên đưa hối lộ phải có mối liên hệ liên quan đến công vụ mà người phạm tội được giao hoặc phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Giữa người nhận và người đưa hối lộ có sự thỏa thuận về việc làm hay không làm một việc nào đó nhất định có thể là việc hợp pháp hoặc không hợp pháp. Việc người nhận hối lộ đã hoàn thành việc thỏa thuận hay chưa không phải là dấu hiệu bắt buộc chỉ cần người phạm tội đã đồng ý nhận tiền hoặc lợi ích vật chất để thực hiện công việc như đề nghị, thì tội phạm được xem là đã hoàn thành. Về đối tượng hối lộ có thể là tiền, tài sản lợi ích vật chất có trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc các lợi ích phi vật chất như được đề bạt, bổ nhiệm chức vụ, đáp ứng các nhu cầu về tình dục,…

- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355);

"Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm: (a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi

phạm; (b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm".

Dấu hiệu pháp lý của tội này là chủ thể đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn biểu hiện thông qua việc người phạm tội đã thực hiện những hành động vượt quá quyền hạn của mình hoặc không thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm để tạo điều kiện thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Sự lạm dụng chức vụ, quyền hạn được xem là phương thức thực hiện tội phạm này và phải xảy ra trước hành vi chiếm đoạt. Thủ đoạn mà người phạm tội sử dụng chiếm đoạt tài sản rất đa dạng, có thể là thủ đoạn uy hiếp về tinh thần người quản lý tài sản, có thể là thủ đoạn gian dối hoặc lợi dụng sự tin tưởng để chiếm đoạt. Hậu quả thiệt hại về tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên. Đối với thiệt hại về tài sản dưới 2.000.000 đồng thì chủ thể phải thuộc một trong các trường hợp: Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356);

"Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm".

Người phạm tội sử dụng quyền hạn được giao như là một phương tiện để thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, tội phạm này không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi làm trái công vụ như không làm hoặc làm không đúng không đầy đủ nhiệm vụ được giao. Hậu quả của tội phạm là dấu hiệu bắt buộc, cụ thể là hành vi phạm tội phải gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 357);

Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi) quy định: "Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới

100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt…".

Khác với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356) người phạm tội trong tội lạm quyền đã thực hiện những việc làm vượt quá giới hạn, quyền năng của mình trong khi thi hành công vụ. Cụ thể hơn, về mặt pháp lý chủ thể có thẩm quyền thực hiện công vụ và thực tế, có điều kiện pháp lý làm phát sinh công vụ phải thực hiện, nhưng chủ thể đã lợi dụng để thực hiện hoạt động ngoài phạm vi pháp luật cho phép, gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 358);

"Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt: a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; Lợi ích phi vật chất".

Dấu hiệu pháp lý của tội này là chủ thể đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng đến người có chức vụ quyền hạn khác làm hoặc không làm một việc nào đó để đạt được lợi ích vật chất hoặc phi vật chất. Như vậy trong tội phạm này, chủ thể phạm tội không trực tiếp thực hiện công việc với người có yêu cầu mà giải quyết thông qua một người có chức vụ quyền hạn khác. Chủ thể tội phạm có thể nhận trước hoặc nhận sau khi thực hiện yêu cầu của bên đưa.

- Tội giả mạo trong công tác (Điều 359).

"Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; b) Làm, cấp giấy tờ giả; c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

Chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn cụ thể hơn là người có công vụ liên quan đến việc làm, ban hành các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức hoặc họ là người có trách nhiệm tham gia

thực hiện các chỉ đạo, quyết định bằng văn bản của cấp trên… sau đó, người phạm tội lợi dụng quá trình tham gia thực thi công vụ đã sửa chữa, làm sai lệch hoặc làm giả hoặc giả chữ ký của người có thẩm quyền để đưa các loại bằng cấp, giấy tờ, tài liệu vào thực tế, từ đó tác động và gây ra thiệt hại cho các quan hệ xã hội mà pháp luật bảo vệ.

7.1.4. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

7.1.4.1. Nguyên nhân tham nhũng

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực có tính lịch sử, xuất hiện gắn liền với sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự xuất hiện các thiết chế quyền lực xã hội. Trong các dạng quyền lực xã hội thì quyền lực Nhà nước là một dạng quyền lực rất dễ bị lợi dụng để tham nhũng. Vì vậy, có thể khẳng định rằng tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ xã hội với những biểu hiện và mức độ khác nhau, tùy thuộc bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ trong từng giai đoạn phát triển.

Hiện nay, tham nhũng là vấn đề mang tính toàn cầu nhưng đồng thời nó cũng chứa đựng những yếu tố đặc thù gắn với từng quốc gia. Về cơ bản mỗi quốc gia có những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng riêng. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở xem xét nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng của các nước trên thế giới, thấy rằng tuy có điểm riêng nhưng cũng có một số nguyên nhân, điều kiện mang tính chất chung, tương đồng như xuất phát từ các điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá[179]. Dưới góc độ kinh tế, các nhà kinh tế học cho rằng, sự can thiệp, điều tiết của nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường là tất yếu, nhưng nếu trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, những người hoặc những nhóm người có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước lồng vào những ý đồ vụ lợi cá nhân thì sẽ cản trở sự cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và phá vỡ quy luật thị trường, từ đó dẫn đến tham nhũng. Dưới góc độ chính trị, các nhà khoa học chính trị cho rằng tham nhũng thường nảy sinh trong một hệ thống chính trị mà cơ chế kiểm soát quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn thiếu hoặc yếu, vì vậy không thể đảm bảo rằng quyền lực được thực hiện một cách công khai, minh bạch và đúng đắn. Các nhà xã hội học lại cho rằng, sự bất bình đẳng luôn có lợi cho những người giàu và người có vị thế xã hội, và đó là một nguyên nhân gây ra tham nhũng. Với những lợi

[179] Đỗ Thu Huyền, Vũ Công Giao, Khái quát một số lý thuyết, cách tiếp cận về phòng, chống tham nhũng, *VNU Journal of Science: Legal Studies*, Vol. 35, No. 1 (2019) 66-74.

thế sẵn có, nhóm người giàu và thế lực cao có thể dùng tiền để hối lộ hoặc xây dựng các mối quan hệ gây tác động lên quá trình xây dựng và thực thi chính sách có lợi cho họ. Tiếp cận tham nhũng dưới góc độ văn hoá, các nhà nghiên cứu cho rằng văn hóa cũng là một trong những nguyên nhân khiến tham nhũng nảy sinh và phát triển. Ở nhiều quốc gia, những tập tục, truyền thống văn hóa có thể được sử dụng để nguỵ trang cho hành vi tham nhũng, khiến cho tham nhũng tràn lan, rất khó kiểm soát. Và khi tham nhũng ăn sâu bén rễ vào đời sống văn hoá, nó sẽ tồn tại lâu dài khiến cho người dân dần trở nên thờ ơ, thỏa hiệp, không có ý chí kiên quyết đấu tranh chống lại nó.

Tại Việt Nam, có thể kể đến các nguyên nhân sau đây:

Thứ nhất, do hệ thống chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế

Pháp luật là công cụ quản lý chủ yếu của mọi Nhà nước, nếu pháp luật chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và chặt chẽ sẽ tạo điều kiện cho người thi hành pháp luật lợi dụng "kẽ hở" để thực hiện các hành vi trục lợi.

Trong hệ thống pháp luật nước ta, vẫn còn nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội chưa được pháp luật điều chỉnh hoặc điều chỉnh nhưng còn nhiều bất cập, thiếu các quy định yêu cầu sự công khai minh bạch như các quy định trong quản lý tài sản công, quản lý tài chính, đất đai, nhà cửa, xây dựng, đấu thầu, cạnh tranh, cấp phát vốn đầu tư,… Đây là kẽ hở để một số người (trong các cơ quan áp dụng pháp luật) tìm cách sách nhiễu, gây khó khăn khi thực thi công vụ, nhiệm vụ để đòi hối lộ. Thêm vào đó, nhiều văn bản luật đã ban hành từ lâu nhưng thiếu các văn bản hướng dẫn khiến cho việc áp dụng trên thực tế không thống nhất, tạo ra sự tùy tiện. Điều đó dễ làm phát sinh các hành vi tiêu cực, lợi dụng các kẽ hở trong các quy định của pháp luật để làm lợi cho một số ít người trong xã hội.

Thứ hai, hệ thống quản lý hành chính còn hạn chế, chưa điều chỉnh theo hướng tinh gọn; nhiều thủ tục hành chính thiếu sự minh bạch, công khai.

Bộ máy hành chính của nước ta vẫn còn nặng nề, quyền hạn, trách nhiệm giữa các chủ thể còn chồng chéo như "có sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; mô hình tổ chức tổng cục, cục, vụ không thống nhất; Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chưa được hoàn thiện theo hướng phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và phù hợp với đặc thù của địa phương; Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa và đổi mới, sắp xếp lại khu vực các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, hiệu quả thấp.

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được đẩy mạnh. Về thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn nhiều và rườm rà, phức tạp; vẫn còn có tình trạng một số luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật không thống nhất, có nhiều nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính chưa được phát huy mạnh mẽ nên vẫn phải phối hợp, họp nhiều, quy trình xử lý công việc chậm; quy định về thủ tục hành chính chưa đầy đủ các bộ phận cấu thành, chưa chặt chẽ, gây khó khăn cho cả cơ quan chức năng và người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, vẫn còn có hiện tượng yêu cầu thêm nhiều giấy tờ không được quy định trong bộ hồ sơ khi giải quyết các thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị",...[180].

Các hạn chế trong quản lý hành chính được xem là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tham nhũng ở nước ta.

Thứ ba, do sự suy thoái về phẩm chất đạo đức của người giữ chức vụ quyền hạn.

Tham nhũng luôn xuất phát từ lòng tham của con người mà lòng tham tồn tại như một thuộc tính cố hữu của con người - vấn đề là điều tiết và khống chế lòng tham đó như thế nào. Nếu người giữ chức vụ quyền hạn không có một cái tâm trong sáng, không có tinh thần kỷ luật, tính liêm chính thì tính tham sẽ phát triển mạnh mẽ và việc thực hiện các hành vi tham nhũng là tất yếu.

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá: "Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn nhiều yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm". Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 cũng nhận định, một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tham nhũng hiện nay ở nước ta là do "một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tính chuyên nghiệp, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn

[180] Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021.

thấp". Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống thể hiện trước hết ở tư tưởng hưởng thụ, quá coi trọng đồng tiền, tư tưởng vụ lợi, làm giàu bất chính,…

Thứ tư, do các yếu tố văn hóa, tâm lý của người Việt

Một trong những đặc điểm văn hóa của người Việt là xuất phát từ nền văn minh lúa nước với nền sản xuất nhỏ, manh mún bị giới hạn bởi bờ ruộng bởi lũy tre làng nên nảy sinh tâm lý tiểu nông, chỉ muốn thu lợi vun vén cho cá nhân mình. Người Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp như "uống nước nhớ nguồn"; "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" nhưng những truyền thống này lại bị áp dụng một cách lệch lạc, biến tướng thành việc người dân phải "mang ơn" đối với người có chức vụ quyền hạn khi thực hiện một công việc cho người dân. Xã hội cũng dần hình thành những thói quen tâm lý tiêu cực khác như "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" và việc "bỏ phong bì" cho các cơ quan công quyền khi giải quyết công việc lại trở thành hiện tượng bình thường. Bên cạnh đó là tâm lý "dĩ hòa vi quý", "im lặng là vàng" nên ngại va chạm, ngại tố giác và dần dần người dân chấp nhận hoạt động tham nhũng như một lẽ đương nhiên trong khi bản chất của hành vi này đáng lẽ phải bị xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng, là hành vi đáng lên án và đáng bị xử lý.

Thứ năm, do các quy định về phòng chống tham nhũng chưa hiệu quả, chưa triệt để.

Các cơ chế về việc phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn còn chưa hiệu quả như chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những người phát hiện và dám tố cáo tham nhũng; Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với các cơ quan nhà nước để phát hiện tham nhũng chưa được tiến hành thường xuyên và toàn diện dẫn đến hiệu quả của việc phát hiện tham nhũng còn hạn chế; Công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ phát hiện các vụ án tham nhũng chưa cao, vẫn còn hiện tượng bỏ lọt tội phạm, chuyển từ xử lý hình sự sang xử lý hành chính hay xử lý kỷ luật. Việc xử lý các vụ án tham nhũng còn có những biểu hiện thiếu quyết tâm, ngại xử lý. Quá trình giải quyết vụ án còn chậm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng nhưng hoạt động điều tra, truy tố và xét xử kéo dài, hiệu quả xử lý thấp; còn bỏ lọt các hành vi tham nhũng.

7.1.4.2. Tác hại của tham nhũng

Thứ nhất là tác hại về chính trị,

Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp

xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội[181]. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có đề cập đến hậu quả nghiêm trọng của tham ô "Tham ô là hành động xấu xa nhất, tội lỗi nhất trong xã hội, nó làm hại đến sự nghiệp xây dựng nước nhà, hại đến công việc cải thiện đời sống của nhân dân, hại đến đạo đức cách mạng của cán bộ và công nhân" [...] "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, bộ đội và Chính phủ. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng và nằm trong các tổ chức của ta để làm hỏng công việc của ta, làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó của cán bộ ta;… nó làm chậm trễ công cuộc kháng chiến và kiến quốc của ta, nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức Cách mạng cần kiệm liêm chính"[182].

Niềm tin chính trị của dân luôn là cội nguồn sức mạnh của tổ chức. Một công việc dù nhỏ đến đâu nếu dân không tin, không làm theo cũng không hoàn thành được, một công việc khó nếu dân đồng lòng sẽ dễ dàng vượt qua. Trong thời kỳ mới, nạn tham nhũng đã làm suy giảm lòng tin của dân với Đảng, với Nhà nước, dẫn đến hậu quả là người dân bất bình, không hợp tác với người lãnh đạo, với con đường mà người lãnh đạo đang vạch ra, nguy cơ về sự tồn vong của chế độ là có thể thấy được.

Thứ hai, tác hại về kinh tế:

Tham nhũng gây tổn hại to lớn về mặt kinh tế, làm thất thoát, thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Các nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia như đất đai, rừng, hầm mỏ,… không được phân phối và khai thác hợp lý hiệu quả; những dự án trong xây dựng cơ bản bị "rút ruột" ảnh hưởng đến chất lượng công trình; các hoạt động mua sắm và đầu tư công làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, chi phí cho các giao dịch, các thủ tục hành chính của các doanh nghiệp gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cản trở sự tăng trưởng kinh tế.

Thứ ba, tác hại về xã hội

Tham nhũng làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo trong xã hội. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống thể hiện trước hết ở tư tưởng hưởng thụ, quá coi trọng đồng

[181] Thanh tra Chính phủ, *Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng*, Nxb Sự thật, 2011, tr.22.
[182] Hồ Chí Minh, *Toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 6, tr.489.

tiền, tư tưởng vụ lợi, làm giàu bất chính của người có chức vụ quyền hạn ảnh hưởng đến lối sống của giới trẻ. Khi hành vi tham nhũng trở nên phổ biến nhất là tham nhũng lại xảy ra trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa,… thì hành vi tham nhũng còn xâm hại nghiêm trọng đến các giá trị đạo đức, xã hội truyền thống, gây ra những hậu quả xấu, tác động không nhỏ đến hệ tư tưởng trong xã hội.

7.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

7.2.1. Cơ sở pháp lý của việc phòng, chống tham nhũng

7.2.1.1. Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng

Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng là một điều ước quốc tế đa phương do các quốc gia và các tổ chức quốc tế thỏa thuận xây dựng nên qua quá trình đàm phán. Mục tiêu của Công ước là hình thành một khuôn khổ pháp lý toàn cầu cho sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tình trạng tham nhũng.

Công ước được thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2003, theo Nghị quyết 58/4, và có hiệu lực ngày 14 tháng 12 năm 2005. Cho đến thời điểm tháng 11/2021 Công ước có 189 quốc gia thành viên[183].

Công ước gồm 8 chương 71 điều chỉnh năm lĩnh vực chính gồm: các biện pháp phòng ngừa, hình sự hóa và thực thi pháp luật, hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản và hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin. Công ước bao gồm nhiều hình thức tham nhũng khác nhau, như hối lộ, giao dịch ảnh hưởng, lạm dụng các chức năng và các hành động tham nhũng khác nhau trong khu vực tư nhân.

Về các biện pháp phòng ngừa được quy định từ Điều 5 đến Điều 14, quy định chính sách và hành động chống tham nhũng của quốc gia; cơ quan phòng, chống tham nhũng; khu vực công; quy tắc ứng xử cho công chức; báo cáo công khai; khu vực tư; mua sắm tài sản công; quản lý tài chính công; sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp liên quan đến truy tố và xét xử hành vi tham nhũng.

- Về hình sự hóa và thực thi pháp luật

Công ước yêu cầu các quốc gia xác lập tội phạm hình sự và các tội danh khác bao gồm một loạt các hành vi tham nhũng, nếu đây chưa phải

[183] https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/convention-highlights.html truy cập lúc 16h ngày 22/1/2022.

là tội phạm theo luật trong nước đồng thời quy định các biện pháp hỗ trợ, tăng cường hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi đó.

- Về hợp tác quốc tế: quy định hợp tác quốc tế về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án, tương trợ pháp lý, chuyển giao vụ án hình sự, hợp tác thực thi pháp luật, liên kết điều tra và kỹ thuật điều tra đặc biệt đối với hành vi tham nhũng.

- Về thu hồi tài sản: quy định việc phòng ngừa và phát hiện việc chuyển tài sản tham nhũng; các biện pháp và cơ chế hợp tác quốc tế vì mục đích thu hồi, hoàn trả và định đoạt tài sản tham nhũng.

- Về hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin, Công ước quy định về đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật; thu thập, trao đổi và phân tích thông tin về tham nhũng; các biện pháp khác thi hành Công ước thông qua phát triển kinh tế và hỗ trợ kỹ thuật.

7.2.1.2. Luật Phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Ngay từ khi mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc xử lý hành vi tham ô trong cán bộ. Vào ngày 27 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 223 quy định trừng trị các tội đưa, nhận hối lộ, phu lam và biển thủ công quỹ. Đây được xem là văn kiện chống tham nhũng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 26 tháng 2 năm 1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Phòng chống tham nhũng với 5 chương, 38 điều quy định khá chi tiết, cụ thể đối với các hình thức, biện pháp và mức xử lý đối với hành vi tham nhũng. Đến năm 2000, Pháp lệnh được sửa đổi bổ sung theo hướng quy định rõ hơn về hành vi tham nhũng, về những việc người có chức vụ quyền hạn không được làm và các hành vi tham nhũng bị xử lý hình sự. Các quy định của Pháp lệnh đã đặt cơ sở pháp lý quan trọng cho việc phòng chống tham nhũng nhưng quá trình thực hiện bộc lộ nhiều hạn chế. Đến ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng. Sau hơn 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực tuy nhiên một số quy định của Luật vẫn còn bất cập như các quy định về công khai minh bạch, các quy định về trách nhiệm giải trình, thiếu vắng những quy định về kiểm soát xung đột lợi ích, về việc bảo vệ người tố cáo,… Để khắc phục những hạn chế trên, tiếp tục thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, đảm bảo tính đồng bộ với các quy định pháp luật khác trong nước và các Điều ước Quốc tế mà VIệt Nam tham gia, Luật Phòng,

chống tham nhũng 2018 ra đời với 10 chương 96 điều. Đây là văn bản pháp lý hiện hành điều chỉnh về phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 chương với 96 điều, trong đó:

Chương I: Những quy định chung, gồm 8 điều, từ Điều 1 đến Điều 8. Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh; các hành vi tham nhũng; giải thích từ ngữ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; quyền và nghĩa vụ của công dân trong PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN; giám sát công tác PCTN của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; các hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II: Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, gồm 46 điều, từ Điều 9 đến Điều 54. Chương này gồm 6 mục: Mục 1 quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (từ Điều 9 đến Điều 17); Mục 2 quy định về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (từ Điều 18 đến Điều 19); Mục 3 quy định về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (từ Điều 20 đến Điều 23); Mục 4 quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức (từ Điều 24 đến Điều 26); Mục 5 quy định về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt (từ Điều 27 đến Điều 29); Mục 6 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, gồm 25 điều, từ Điều 30 đến Điều 54. Mục này gồm các tiểu mục: Tiểu mục 1 quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập (từ Điều 30 đến Điều 32); Tiểu mục 2 quy định về kê khai tài sản, thu nhập (từ Điều 33 đến Điều 40); Tiểu mục 3 quy định về xác minh tài sản, thu nhập (từ Điều 41 đến Điều 51); Tiểu mục 4 quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập (từ Điều 52 đến Điều 54).

Chương III: Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, gồm 15 điều, từ Điều 55 đến Điều 69; Chương này gồm mục: Mục 1 quy định về công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị (từ Điều 55 đến Điều 58); Mục 2 quy định về phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán (từ Điều 59 đến Điều 64); Mục 3 quy định về phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng (từ Điều 65 đến Điều 69).

Chương IV: Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, gồm 4 điều, từ Điều 70 đến Điều 73; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng.

Chương V: Trách nhiệm của xã hội trong Phòng chống tham nhũng, gồm 4 điều, từ Điều 74 đến Điều 77; quy định về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo; trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Chương VI: Phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, gồm 5 điều, từ Điều 78 đến Điều 82. Chương này gồm mục: Mục 1 quy định về xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng (từ Điều 78 đến Điều 79); Mục 2 quy định về áp dụng Luật Phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (từ Điều 80 đến Điều 82).

Chương VII: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong Phòng chống tham nhũng, gồm 6 điều, từ Điều 83 đến Điều 88, quy định về đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng; trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; trách nhiệm phối hợp của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Chương VIII: Hợp tác quốc tế về Phòng chống tham nhũng, gồm 03 điều, từ Điều 89 đến Điều 91, quy định nguyên tắc chung về hợp tác quốc tế; trách nhiệm thực hiện hợp tác quốc tế; hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng.

Chương IX: Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng, gồm 04 điều, từ Điều 92 đến Điều 95. Chương này có 2 mục: Mục 1 quy định về xử lý tham nhũng (Điều 92, Điều 93); Mục 2 quy định về xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng (Điều 94, Điều 95).

Chương X: Điều khoản thi hành (Điều 96) quy định về hiệu lực thi hành.

7.2.2. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng

7.2.2.1. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ nhất, công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công khai minh bạch được xem là yếu tố kiên quyết để phòng ngừa tham nhũng. Việc công khai minh bạch trong quá trình quản lý của Nhà nước của các cơ quan, tổ chức đơn vị đảm bảo rằng những hoạt động sử dụng quyền lực công đều được thông tin rõ ràng, trung thực với những người có liên quan, đảm bảo các hoạt động đều được chứng kiến, giám sát theo dõi bởi các cơ quan nhà nước và chính người dân. Kiểm soát tham nhũng chỉ có thể thực hiện khi Chính phủ, công dân và khu vực tư nhân hợp tác để đảm bảo tính minh bạch.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 không quy định công khai, minh bạch trong từng lĩnh vực cụ thể mà chỉ quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm thực hiện công khai, minh bạch nói chung trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo quy định tại Điều 9 của Luật có hai nguyên tắc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn là phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật và việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Về nội dung công khai, minh bạch bao gồm: việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch. Riêng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.

Về hình thức công khai có thể thực hiện bằng niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; Phát hành ấn phẩm; Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; Tổ chức họp báo; Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Về trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

Thứ hai, về xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn là biện pháp phòng ngừa tham nhũng tránh tình trạng lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc lạm quyền để thu lợi riêng

Về thẩm quyền ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước, các luật chuyên ngành khác và được giao cho nhiều cấp khác nhau phụ thuộc vào từng loại định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Theo quy định tại Điều 18 của Luật Phòng, chống tham nhũng thì Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ; công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ;thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, đơn vị khác có sử dụng tài chính công, căn cứ vào quy định này, hướng dẫn áp dụng hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành, công khai định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình, thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đó. Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ trái pháp luật.

Việc chấp hành quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải được kiểm tra, thanh tra xử lý kịp thời nếu phát hiện có hành vi vi phạm.

Nếu người cho phép sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mà mình cho phép sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại; người sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ có trách nhiệm liên đới bồi thường với người cho phép sử

dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; người tự ý sử dụng trái quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải hoàn trả phần giá trị mình sử dụng trái quy định và bồi thường thiệt hại.

Thứ ba, thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Quy tắc ứng xử được xem là công cụ quan trọng nhằm điều chỉnh các hành vi cá nhân khi thực hiện các hoạt động phục vụ cho mục tiêu của tổ chức và đơn vị.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 yêu cầu người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Cụ thể, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc như sau:

- Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc; không thực hiện các công việc dẫn đến xung đột lợi ích như thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác; tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị; những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành,

nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

Thứ tư, về tặng quà và nhận quà tặng

Nhận quà và tặng quà là một thói quen trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào mỗi dịp lễ Tết hay bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên đối với người có chức vụ quyền hạn và các cơ quan đơn vị thì hoạt động này cần tuân theo các quy định nhằm tránh việc lợi dụng để trục lợi.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã quy định về việc tặng quà khá cụ thể.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong một số trường hợp cần thiết khác. Đối với việc nhận quà tặng có liên quan đến công việc đang giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của người có chức vụ, quyền hạn cần phải cấm tuyệt đối để phòng ngừa tham nhũng, vì vậy, khoản 2 Điều 22 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Đồng thời Luật giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung về tặng quà và nhận quà tặng.

Thứ năm về kiểm soát xung đột lợi ích

Xung đột lợi ích là tình huống mà trong đó lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích của họ tác động hoặc sẽ tác động

không đúng đắn đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ[184]. Yêu cầu tối thượng của hoạt động công vụ là tính công bằng, bình đẳng trước mọi chủ thể, khi tình huống xung đột xảy ra có thể nó phá vỡ sự liêm chính, công bằng, vô tư của người thực thi công vụ. Đây chính là tiền đề làm nảy sinh tham nhũng[185]. Vì vậy kiểm soát xung đột lợi ích được xem là một công cụ hiệu quả để phòng chống tham nhũng.

Điều 23 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về kiểm soát xung đột lợi ích cụ thể như sau:

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu người được giao nhiệm vụ biết hoặc buộc phải biết nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý.

- Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp sau đây: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác.

Thứ sáu về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mục đích của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm tránh tình trạng một người giữ chức vụ, quyền hạn tại một vị trí quá lâu có thể lợi dụng các công việc được giao, lợi dụng các mối quan hệ và sự ảnh hưởng của mình để thực hiện các hành vi tiêu cực. Ngoài ra việc chuyển đổi vị trí công tác cũng góp phần tăng tính hiệu quả của việc thực thi nhiệm vụ khi loại bỏ được tâm lý trì trệ, tính cục bộ, góp phần giảm thiểu nguy cơ tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đặt ra nguyên tắc việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên

[184] Khoản 8, Điều 3, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.
[185] Phạm Thị Huệ, *Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng ngừa tham nhũng ở Việt Nam hiện nay*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020, tr.39.

môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. Về vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi là một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được chuyển đổi vị trí công tác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Thứ bảy, về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý là các biện pháp rất quan trọng để phòng ngừa tham nhũng. Theo quy định tại Điều 27 của Luật Phòng, chống tham nhũng thì trong cải cách hành chính, cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện nhiệm vụ khác về cải cách hành chính. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tăng cường đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, đẩy mạnh sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; các Bộ, ngành có trách nhiệm đẩy mạnh xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

- Về thanh toán không dùng tiền mặt: Thanh toán không dùng tiền mặt tạo ra sự minh bạch trong các giao dịch thanh toán trong nền kinh tế, hạn chế các "giao dịch ngầm" trong xã hội là giải pháp quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có quy định các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi như các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng

điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên.

Thứ tám, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động do cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ tài sản thu nhập, biến động về tài sản thu nhập, nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng[186].

- Về nội dung kiểm soát tài sản thu nhập, Luật Phòng chống tham nhũng quy định 4 vấn đề chính: (1) Quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; (2) Quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập; (3) Quy định về xác minh tài sản, thu nhập; (4) Quy định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 đã quy định theo hướng giao cho Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người thuộc diện kê khai công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương; các cơ quan khác (cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước) và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.

- Về đối tượng và phạm vi kê khai tài sản, thu nhập

Có bốn nhóm đối tượng phải kê khai là: (i) Cán bộ, công chức; (ii) Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; (iii) Người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; (iv) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Phạm vi

[186] Khoản 1 Điều 3 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

tài sản, thu nhập phải kê khai gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

- Về phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập

Có bốn phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập được quy định, gồm: (1) Kê khai lần đầu: Áp dụng đối với người đang là cán bộ, công chức; sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp tại thời điểm Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực; (2) Kê khai hàng năm: Áp dụng đối với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên; người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ; (3) Kê khai bổ sung: Áp dụng đối với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, có nghĩa là các đối tượng không thuộc diện phải kê khai hàng năm thì chỉ kê khai khi có biến động lớn với tài sản, thu nhập; (4) Kê khai phục vụ công tác cán bộ: Được thực hiện đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; người dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.

- Về xác minh tài sản, thu nhập

Xác minh tài sản, thu nhập là việc xem xét, đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Như vậy, xác minh tài sản, thu nhập là một "mắt xích" quan trọng trong biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập. Tại Điều 41 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 đã quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thể lựa chọn bản kê khai của đối tượng thuộc diện kê khai khi có một trong các căn cứ sau: (i) Có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; (ii) Có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ 300.000.000 đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc; (iii) Có tố cáo về việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đủ điều kiện thụ lý theo quy định của Luật Tố cáo; (iv) Thuộc trường hợp xác minh theo kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên; (v) Có yêu cầu hoặc kiến nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị,

cá nhân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 42 của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

- Về cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Luật Phòng chống tham nhũng 2018 đã quy định Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm thông tin về bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập được xây dựng và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ điều phối các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập khác có trách nhiệm xây dựng, quản lý Cơ sở Dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

7.2.2.2. Các giải pháp phát hiện tham nhũng

Một là, phát hiện tham nhũng từ Công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra là hoạt động thường xuyên và liên tục trong quản lý hành chính nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong đó có hành vi tham nhũng.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng; Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Luật cũng quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tự kiểm tra nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ quyền hạn do mình quản lý mà thường xuyên, trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng. Bên cạnh các chủ thể quản lý hành chính, Luật còn quy định trách nhiệm của người đứng đầu Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phải tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người có chức vụ, quyền hạn khác; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong hoạt động chống tham nhũng.

Hình thức kiểm tra của các chủ thể trên có thể thực hiện theo kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch và tập trung vào lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng hoặc kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng.

Hai là, phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm toán

Đây là những hoạt động chủ yếu trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm toán, xét xử và giám sát có chức năng bảo vệ pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, trong đó có tham nhũng. Đây là lực lượng chính trong cuộc đấu tranh chống vi phạm pháp luật[187].

Theo khoản 1, Điều 2, Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì "giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Như vậy thông qua hoạt động giám sát các chủ thể có thể phát hiện các hành vi tham nhũng của các cá nhân chịu sự giám sát của mình. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định rõ trách nhiệm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hoạt động giám sát nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì đề nghị Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh hoạt động giám sát thì hoạt động thanh tra, kiểm toán cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát hiện tham nhũng.

Thông qua việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật nhiệm vụ được giao cũng như đánh giá tính trung thực của của các thông tin tài chính công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến quản lý, các chủ thể thực hiện việc thanh tra, kiểm toán có thể phát hiện ra các hành vi tham

[187] Viện Khoa học thanh tra, *Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng*, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011, tr.85.

những. Theo quy định tại Điều 62 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trong quá trình thanh tra, kiểm toán nếu phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thì người ra quyết định thanh tra, người ra quyết định kiểm toán phải chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc tham nhũng. Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc và kiến nghị Cơ quan điều tra xem xét, khởi tố vụ án hình sự, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cung cấp. Trong trường hợp này, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm toán về các nội dung khác theo kế hoạch tiến hành thanh tra, kế hoạch kiểm toán đã phê duyệt và ban hành Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán nhà nước; Nếu vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi vi phạm. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý cho Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị.

Ba là, phát hiện tham nhũng thông qua phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

Phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó[188].

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân[189].

Báo cáo là việc trình bày thông tin, sự việc đến một chủ thế nhất định.

Trong Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã quy định về chủ thể của phản ánh, tố cáo là mọi công dân còn chủ thể báo cáo là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình công tác. Như vậy chủ thể của việc phản ánh, tố cáo và báo cáo hành vi

[188] Khoản 2, Điều 2, Luật Tiếp công dân năm 2013.
[189] Khoản 1 Điều 2, Luật Tố cáo năm 2018.

tham nhũng rất rộng gồm nhiều đối tượng, nhiều thành phần. Việc phát huy kênh thông tin này sẽ là giải pháp hữu hiệu trong việc phòng chống tham nhũng.

Một điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về biện pháp phát hiện tham nhũng là đã có những quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của người tiếp nhận phản ánh, tố cáo và báo cáo là phải xem xét, xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh, tố cáo. Đồng thời Luật cũng quy định về việc khen thưởng cũng như việc chịu trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng

7.2.2.3. Xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng

Theo quy định tại Điều 92 của Luật thì việc xử lý người có hành vi tham nhũng, được thực hiện như sau:

- Người có hành vi tham nhũng giữ bất kỳ chức vụ, vị trí công tác nào đều phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác.

- Người có hành vi tham nhũng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật.

- Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

*Về xử lý tài sản tham nhũng, theo quy định tại điều 93 thì t*ài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. Các thiệt hại do hành vi

tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

7.3. Trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng là hoạt động đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Sự nghiệp này cần có sự tham gia đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức đơn vị khác. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã quy định trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng thông qua quy định trách nhiệm của các thiết chế xã hội, bao gồm: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo; Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Điều 74, 75, 76,77 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức như sau:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm sau đây:

+ Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng;

+ Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

+ Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng;

+ Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo:

+ Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

+ Cơ quan báo chí, nhà báo có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền cung cấp thông tin liên quan đến hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề

+ Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

+ Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng.

- Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng:

+ Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng.

+ Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, *Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 21 tháng 8 năm 2006 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí*.
2. Ban Nội chính Trung ương (2005), *Một số văn bản của Đảng về phòng chống tham nhũng*, Nxb Chính trị Quốc gia.
3. Bộ Chính trị, *Nghị quyết số 14/NQ-TW ngày 15 tháng 5 năm 1996 của về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng*;

4. Chính phủ, *Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009.*
5. Chính phủ, *Báo cáo tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021*.
6. Chính phủ, *Nghị định 130/2020/NĐ - CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.*
7. Công ước Liên hợp quốc phòng chống tham nhũng được thông qua ngày 31 tháng 10 năm 2003;
8. Đỗ Thu Huyền, Vũ Công Giao, "Khái quát một số lý thuyết, cách tiếp cận về phòng, chống tham nhũng", *VNU Journal of Science: Legal Studies*, Vol. 35, No. 1 (2019) 66-74.
9. *Hồ Chí Minh toàn tập*, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000, tập 6.
10. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
11. Luật Tố cáo năm 2018.
12. Luật Tiếp công dân năm 2013.
13. Liu, X., A Literature Review on the Definition of Corruption and Factors Affecting the Risk of Corruption. *Open Journal of Social Sciences*, 4/2016, 171-177. doi: 10.4236/jss.2016.46019
14. Hoàng Phê (2019), *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb Hồng Đức.
15. Tanzi, V. (1995), *Corruption, Arm's Length Relationships and Market, The Economic Organized Crime*, Cambridge: Cambridge University Press.

Giáo trình Pháp luật đại cương

Chủ biên: Nguyễn Thị Tuyết Mai,
Nguyễn Minh Thu, Võ Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Tuyết Nga
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trụ sở:
Phòng 501, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM.
ĐT: 028 62726361
E-mail: vnuhp@vnuhcm.edu.vn
Website: www.vnuhcmpress.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản và nội dung
TS ĐỖ VĂN BIÊN
Biên tập
TRẦN THỊ ĐỨC LINH
Sửa bản in
ÁI NHẬT
Trình bày bìa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đối tác liên kết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xuất bản lần thứ 1. Số lượng in: 250 cuốn, khổ 16 x 24cm. Số XNĐKXB: 1254-2023/CXBIPH/9-19/ĐHQGTPHCM. QĐXB số: 61/QĐ-NXB cấp ngày 24/4/2023. In tại: Công ty TNHH In & Bao bì Hưng Phú. Địa chỉ: 162A/1, KP1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nộp lưu chiểu: Năm 2023. ISBN: **978-604-73-9848-5.**

Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ bởi Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phát tán nội dung khi chưa có sự đồng ý của tác giả và Nhà xuất bản.

ĐỂ CÓ SÁCH HAY, CẦN CHUNG TAY BẢO VỆ TÁC QUYỀN!





CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Không ngừng nâng cao chất lượng dạy, học, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng nhằm mang đến cho người học những điều kiện tốt nhất để phát triển toàn diện các năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

ISBN: 978-604-73-9848-5
NXB ĐHQG-HCM
9 786047 398485